

DIGESTO

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Refundición de los apuntes de Cristián Boetsch Gillet, el Tratado de ENRIQUE BARROS BOURIE y la cátedra de CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO, organizada en 25 ejes temáticos, con jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Versión Julio 2026

Índice

- A. Concepto, regulación y funciones de la responsabilidad civil extracontractual
- B. Responsabilidad civil y responsabilidad penal
- C. Delimitación de estatutos: contractual, cuasicontractual y derecho común
- D. Sistemas o modelos de atribución de responsabilidad
- E. La capacidad delictual
- F. El hecho voluntario. Caso fortuito y personas jurídicas
- G. La antijuridicidad y las causales de justificación
- H. La culpabilidad: dolo y culpa
- I. Prueba de la culpa y presunciones de culpabilidad por el hecho propio
- J. El daño: concepto y requisitos de resarcibilidad
- K. Clases de daño (I): el daño patrimonial
- L. Clases de daño (II): el daño moral
- M. La causalidad
- N. Régimen general y casos particulares de responsabilidad por el hecho ajeno
- O. Responsabilidad del empresario
- P. Responsabilidad por el hecho de las cosas
- Q. Regímenes legales de responsabilidad objetiva
- R. Responsabilidad del Estado
- S. La acción por daño contingente
- T. Objeto y extensión de la reparación
- U. Legitimación activa y pasiva
- V. Tribunal, procedimiento y extinción de la acción
- W. Dualidad o unidad de regímenes; diferencias entre estatutos
- X. Cúmulo o concurso de responsabilidades
- Y. Responsabilidad precontractual, por nulidad y postcontractual

A. CONCEPTO, REGULACIÓN Y FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El estudio de la responsabilidad extracontractual comienza con una operación deliberadamente conceptual: antes de examinar los elementos del ilícito civil, es preciso fijar qué se entiende por responsabilidad, dónde la regula el Código y para qué sirve. La secuencia no es caprichosa. La responsabilidad extracontractual carece de concepto legal: el Código Civil no define la responsabilidad, sino que define el delito y el cuasidelito (**artículo 2284**) e impone la obligación de indemnizar a quien los comete (**artículo 2314**), dejando a la doctrina la tarea de construir la noción general y de explicitar la finalidad del estatuto. El punto de partida es, pues, doctrinario. El problema de fondo que subyace a esa definición es el siguiente: la vida en común genera daños de manera constante, y el ordenamiento debe decidir cuándo el costo patrimonial de ese daño permanece en el patrimonio de quien lo sufrió y cuándo se traslada al patrimonio de un tercero. La responsabilidad civil es, precisamente, el conjunto de criterios conforme a los cuales opera ese desplazamiento.

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Cabe distinguir dos niveles. En términos muy generales, la responsabilidad consiste en la necesidad, efectiva o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio. En particular, la responsabilidad civil consiste en la necesidad en que se halla un individuo de reparar un daño causado por su obrar doloso o culposo, necesidad que se satisface por medio de la indemnización de perjuicios. De esta definición se sigue de inmediato la nota característica de la institución: la responsabilidad civil se encuentra esencialmente vinculada al daño que sufre una o más personas y al deber de repararlo o compensarlo con medios equivalentes. No es un juicio sobre la persona, sino sobre las consecuencias patrimoniales de su conducta. La definición no es una construcción original de la doctrina nacional, y conviene conocer su procedencia porque permite advertir que se trata de la noción canónica del derecho civil. Proviene de Henri y **LÉON MAZEAUD** y de **ANDRÉ TUNC**, quienes sostienen que el conflicto entre quien sufre el daño y quien lo causa constituye todo el problema de la responsabilidad, y subrayan el sentido etimológico del término, según el cual responsable es quien responde. Esa noción fue recibida sin alteraciones sustanciales entre nosotros: **ALESSANDRI** define la responsabilidad como la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra, y **DUCCI**, en términos más amplios, como el estar sujeto a responder de alguna cosa o por alguna persona. La jurisprudencia ha suscrito el mismo concepto. La Corte Suprema, en fallo de 6 de noviembre de 1972, declaró que por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado. Doctrina y jurisprudencia coinciden, entonces, en el plano conceptual: en Chile no hay controversia sobre qué es la responsabilidad civil. Las discusiones comienzan después, al determinar sus condiciones y su alcance.

CORTE SUPREMA, 6 DE NOVIEMBRE DE 1972
CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

"Por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado." Es la definición jurisprudencial de referencia en la materia, y suele citarse como punto de partida obligado de cualquier respuesta de examen sobre el concepto de responsabilidad civil.

2. EL DAÑO COMO ELEMENTO ESENCIAL. CONTRASTE CON LA RESPONSABILIDAD PENAL

La esencialidad del daño constituye una notable diferencia con la responsabilidad penal, pues esta última contempla figuras delictivas de mero peligro y sanciona conductas tentativas y frustradas, esto es, sin daño. En sede civil, en cambio, si la acción culpable no genera daño no existe responsabilidad: el derecho penal sanciona el disvalor de la acción, y no sólo el del resultado; el derecho civil sólo reacciona frente al resultado dañoso. Así lo ha declarado la Corte de Apelaciones de Chillán, en fallo de 5 de octubre de 1970, al sostener que el daño es un elemento indispensable de la responsabilidad extracontractual. De esta diferencia estructural deriva una segunda, decisiva para todo el curso: en materia penal rige la tipicidad, que exige que la conducta sancionada se adecue exactamente a la descripción legal del delito. En materia civil, el concepto de ilicitud importa la infracción a un deber de cuidado que sólo excepcionalmente ha sido establecido en forma previa por la ley (hipótesis de culpa infraccional), de manera que en la generalidad de los casos el tipo específico es determinado por el juez con posterioridad a la conducta que se juzga. Esta afirmación anticipa el tratamiento de la culpa y explica por qué el sistema chileno de responsabilidad descansa sobre cláusulas generales y no sobre un catálogo de ilícitos civiles. De esa asimetría de exigencias deriva, por último, una consecuencia procesal: estando sujeta la responsabilidad penal a requisitos más estrictos, la sentencia dictada en sede penal puede producir efectos en materia civil, pero no a la inversa. Así, el **artículo 178** del Código de Procedimiento Civil dispone que en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en proceso criminal siempre que condenen al reo; y, por regla general, las sentencias absolutorias no producen cosa juzgada en materia civil, porque de la inexistencia de responsabilidad penal no se sigue la inexistencia de responsabilidad civil, salvo que se funden en alguna de las circunstancias que taxativamente enumera el **artículo 179** inciso primero del mismo Código. El punto se desarrolla en el Eje 2.

3. REGULACIÓN: EL HECHO ILÍCITO COMO FUENTE DE OBLIGACIONES

La responsabilidad extracontractual está regulada en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, denominado "De los delitos y cuasidelitos", que comprende los **artículos 2314 a 2334**. El Código otorga a los delitos y cuasidelitos civiles la categoría de fuente de las obligaciones en los **artículos 1437 y 2284**. El **artículo 1437** señala que las obligaciones nacen, entre otras causas, a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos. El **artículo 2284** precisa la distinción entre ambas figuras: si el hecho es ilícito y cometi-

do con intención de dañar, constituye un delito; si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. De la conjunción de los **artículos 1437, 2284 y 2314** se extraen las definiciones que deben manejarse con exactitud: el delito civil es el hecho ilícito cometido con intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona; el cuasidelito civil es el hecho culposo, pero cometido sin intención de dañar, que ha inferido injuria o daño a otra persona. Ambos comparten dos notas: son hechos ilícitos y causan daño. La regla capital es el **artículo 2314**: el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. La norma consagra, así, la independencia de la responsabilidad civil respecto de la penal, y la posibilidad de que ambas concurren sobre un mismo hecho. El hecho ilícito es fuente de obligaciones porque da origen a una obligación que antes de él no existía: la de indemnizar los perjuicios causados. Y esa obligación nace al margen de la voluntad tanto del acreedor como del deudor. Aunque se haya actuado con dolo (esto es, en el delito civil), el autor ha querido el daño, pero no ha querido convertirse en deudor de la reparación; y si sólo hubo culpa (cuasidelito civil), no hubo siquiera intención de perjudicar, y menos aún de asumir una obligación. La obligación indemnizatoria es, pues, de fuente legal y de estructura originaria. El instrumento analítico que permite formular con rigor esa idea de obligación originaria es la contraposición de ambos estatutos en términos de grados de obligación, que propone **BARROS**. En materia contractual, la obligación de indemnizar es una obligación de segundo grado: presupone una obligación primaria de origen convencional (cumplir lo pactado) y sólo surge una vez que el deudor la ha incumplido, operando como uno de los remedios que la ley confiere al acreedor. En materia extracontractual, en cambio, no existe vínculo obligatorio previo alguno; el antecedente de la responsabilidad son los deberes de cuidado generales y recíprocos que las personas deben observar en sus encuentros espontáneos, de modo que el vínculo obligatorio tiene carácter originario: nace precisamente del hecho de haber ocasionado un daño infringiendo uno de esos deberes. **DUCCI** sostiene lo mismo.

Esta distinción permite explicar de un solo trazo por qué la obligación indemnizatoria extracontractual es constitutiva y no sustitutiva de otra anterior. La respalda, además, la jurisprudencia: la Corte Suprema, en fallo de 3 de julio de 1951, declaró que la culpa contractual y la extracontractual se rigen por leyes diversas, de alcance y extensión distintos, y que la segunda se genera entre personas extrañas entre sí, sin nexo previo que las vincule.

4. LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Hay un fin primordial, que no se discute, y funciones adicionales que la doctrina reconoce con distinto grado de consenso. Conviene respetar esa jerarquía en la exposición, porque ella misma constituye una toma de posición.

4.1. Función primordial: la reparación del daño

La responsabilidad extracontractual, o derecho de daños, apunta a un fin fundamental: reparar el daño causado, dejar indemne a la víctima. El alcance de esta afirmación debe precisarse, y la precisión es importante: no se pretende que el daño desaparezca, puesto que ya se ha producido; la reparación que se obtiene mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad sólo consigue que otra persona asuma el costo que significa compensar, hasta donde sea posible, la pérdida sufrida

por el perjudicado. La reparación es, entonces, un desplazamiento del costo, no una restitución del estado anterior de las cosas. Esta función no se debate, y sólo adicionalmente la doctrina estima que la responsabilidad cumple otras. Se trata del principio operativo del sistema, y de él se derivan consecuencias concretas que se estudiarán al tratar la extensión de la reparación (principio de reparación integral, reajustabilidad, intereses). La jurisprudencia lo confirma: se ha fallado que nuestro derecho consagra el principio de la reparación integral o completa del daño en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual (Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de septiembre de 2003), y que la reparación del daño es el principal efecto que el legislador asigna a la responsabilidad delictual o cuasidelictual (Corte de Apelaciones de Santiago, 10 de julio de 2002).

4.2. Función de garantía de la libertad de actuar

La libertad de los particulares encuentra, entre otros límites, la prohibición de causar un daño injustificado a otro. Nadie tiene derecho a actuar si con ello perjudica a alguien que no debe soportar ese daño: *alterum non laedere*. La perspectiva debe entonces invertirse, y esta inversión es la clave de la función: las reglas de responsabilidad no sólo restringen la libertad, sino que la definen y la garantizan. Sirven a los particulares para conocer la esfera de libertad que el ordenamiento les reconoce; permiten saber a priori qué eventos podrán serle imputados a quien actúa, y en esa medida consienten a la persona una libre elección de sus propios comportamientos. La responsabilidad opera, así, como un elemento de garantía y de certeza: quien conoce el límite sabe también que dentro de él puede actuar sin temor. La formulación más rigurosa de esta idea es la que ofrece **BARROS** al enunciar el principio que se infiere del ordenamiento civil: cada cual corre con los riesgos que impone la vida en común, de modo que, a falta de una razón jurídica para atribuirla a un tercero, la pérdida derivada de un accidente debe quedar donde cae. La fórmula proviene de **OLIVER WENDELL HOLMES**, y **ALESSANDRI** sostiene lo mismo cuando, siguiendo a **DEMONGUE**, explica la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva: como los hombres pueden actuar libre e independientemente, cada uno debe recoger los beneficios que le proporcionen la suerte o su actividad y soportar los daños causados por la naturaleza o por el hecho ajeno; no basta que un individuo sufra un daño en su persona o bienes para que su autor deba repararlo, sino que es menester que provenga de un hecho doloso o culpable. La consecuencia sistemática es que la no-responsabilidad es el estado por defecto del ordenamiento: el daño, por sí solo, no genera obligación alguna; permanece donde cayó, sobre la víctima, salvo que concurra una razón jurídica que autorice desplazarlo. La responsabilidad es la excepción, y es ella, y no su ausencia, la que exige justificación. De ahí se siguen tres corolarios que se proyectan sobre todo el curso: que la carga de acreditar los elementos de la responsabilidad recae sobre la víctima que pretende el desplazamiento; que las presunciones de culpabilidad son de derecho estricto, porque alteran esa distribución natural de la carga; y que los regímenes de responsabilidad objetiva sólo pueden operar en los ámbitos que el legislador haya definido previamente.

4.3. Función preventiva

El derecho de daños cumple también una función disuasiva, que opera en dos planos. En el plano particular, respecto de quien ya ha sufrido una condena civil: parece lógico que, desde el punto de vista psicológico, la persona que ha obrado dañosamente y que en virtud de esa acción se ve conminada a soportar en su patrimonio el costo del daño causado procurará evitar en el futuro la con-

ducta descuidada o dolosa que le produjo esa pérdida. Y en el plano general, respecto del resto de los integrantes de la sociedad, que quedan advertidos de no producir ciertos daños o de ser más cuidadosos, para no incurrir en los desembolsos que han debido soportar quienes fueron condenados. El argumento admite una formulación más técnica en dos puntos. Primero, la prevención que las reglas de responsabilidad realizan es una prevención general: las reglas están dirigidas a la generalidad de los actores y atribuyen ex ante los riesgos y los costos de las actividades, de modo que la disuasión no depende sólo del efecto psicológico de una condena concreta, sino de la existencia misma de la regla. Segundo, la responsabilidad civil opera como un mecanismo descentralizado de control, toda vez que es la propia víctima quien debe velar por su derecho a ser indemnizada, limitándose la tarea del Estado a establecer las reglas y a proporcionar los medios procesales necesarios para hacerlas valer. Este sistema suele complementarse con normas de prevención especial de carácter administrativo (exigencia de estudios de impacto ambiental, límites de velocidad, certificación sanitaria de medicamentos), cuya manifestación extrema es la prohibición legal de ciertas actividades. Y debe advertirse, con realismo, que la eficacia de esas prohibiciones depende más de las sanciones penales y administrativas que de las obligaciones indemnizatorias que imponga el sistema de responsabilidad civil. La prevención, siendo una función real, no puede erigirse en el fundamento único del sistema.

4.4. Función punitiva

Existen sistemas de derecho de daños en los que la responsabilidad cumple declaradamente una función punitiva o represiva. Es el caso del sistema jurídico angloamericano (Tort Law), en el que se reconoce que el derecho de torts cumple tres funciones: compensation (reparación), deterrence (disuasión) y punishment (sanción). La forma de realizar esta última son los punitive damages: una suma de dinero que el juez puede ordenar pagar a la víctima más allá de la indemnización reparatoria, y que sólo procede en casos de ilícitos de especial malignidad o gravedad. En el sistema inglés se distinguen tres categorías de daños punitivos: los casos de acción represiva, arbitraria e inconstitucional de funcionarios del gobierno; aquellos en que el demandado calculó su conducta dañina de manera de obtener un provecho superior a la indemnización meramente reparatoria que correspondería al demandante; y aquellos en que tales daños están expresamente autorizados por un statute. En los sistemas de derecho civil continental, en cambio, la figura de los daños punitivos es desconocida, y la razón dogmática del rechazo es clara: acordar al demandante una cantidad de dinero no como reparación, sino como pena privada, atentaría contra los principios constitucionales que rigen el debido proceso y la aplicación de las penas. El argumento es de rango constitucional, y por eso es fuerte: la pena requiere ley previa, tipicidad y proceso; una condena civil no reúne esas garantías. A ese fundamento constitucional debe añadirse otro, puramente civil y que resulta decisivo: si la responsabilidad civil cumpliera una función retributiva, el monto de la indemnización debería variar según la intensidad de la culpa del demandado; pero en virtud del principio de reparación integral, la víctima debe quedar indemne de todo daño, con independencia de la gravedad del ilícito. La medida de la indemnización es el daño, no el reproche. Con todo, en ocasiones la propia ley civil mezcla la finalidad reparatoria con la sancionatoria. El ejemplo es el **artículo 1768** del Código Civil, conforme al cual el cónyuge que dolosamente hubiere ocultado o destruido alguna cosa de la sociedad conyugal pierde su porción en la misma y queda obligado a restituirla doblada. Aquí la consecuencia patrimonial excede manifiestamente la reparación del daño y opera como sanción del dolo. Y debe constatar, además, algo que ocurre en la práctica y

no en los textos: la jurisprudencia chilena tiende a incorporar un elemento punitivo encubierto en la valoración del daño no patrimonial. Como éste carece de parámetros económicos de determinación, los jueces suelen incorporar, explícita o implícitamente, consideraciones que no atienden a la intensidad del perjuicio sufrido por la víctima, sino a la gravedad del ilícito cometido o a la capacidad económica del demandado.

DATO DE GRADO

Reparación integral y tentación punitiva

De lo anterior se sigue una tensión que conviene explicitar, porque da unidad al eje. El sistema chileno declara que la reparación es su fin primordial, y de allí deriva el principio de reparación integral: la indemnización se mide por el daño sufrido y no por la gravedad de la conducta. De ese mismo principio se sigue el rechazo de la pena privada, que se funda además en las garantías constitucionales del debido proceso. Ambos fundamentos (el civil, que hace del daño la medida de la reparación, y el constitucional, que reserva la pena al proceso penal) convergen en la misma conclusión: en Chile no hay daños punitivos. Sin embargo, el propio sistema admite excepciones legales en que la finalidad reparatoria se mezcla con la sancionatoria (el **artículo 1768** del Código Civil es el ejemplo), y la práctica judicial reintroduce de hecho la consideración punitiva allí donde el control es más débil, esto es, en la evaluación prudencial del daño moral. La conclusión debe formularse, entonces, de modo matizado: la función punitiva está excluida como fin declarado del sistema, pero opera de manera intersticial, sea porque la ley la consagra en hipótesis puntuales, sea porque el juez la introduce encubiertamente al cuantificar aquello que no admite cuantificación objetiva. El punto reaparecerá con toda su fuerza en el Eje 12.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir señalando que el Código Civil no define la responsabilidad, sino que define el delito y el cuasidelito (**artículo 2284**) e impone la obligación de indemnizar (**artículo 2314**), de modo que el concepto es de construcción doctrinaria. Enseguida, la definición: necesidad en que se encuentra una persona de reparar el daño causado por su obrar doloso o culposo, que se satisface mediante la indemnización de perjuicios; noción compartida por **ALESSANDRI** y **DUCCI**, recibida de **MAZEAUD** y **TUNC**, y refrendada por la Corte Suprema en fallo de 6 de noviembre de 1972. En segundo lugar, la nota esencial: no hay responsabilidad civil sin daño, a diferencia de lo que ocurre en sede penal, donde se sancionan la tentativa, el delito frustrado y las figuras de mero peligro. De esta asimetría se derivan dos consecuencias: la ausencia de tipicidad en materia civil, y el hecho de que la sentencia penal produzca efectos en sede civil pero no a la inversa (**artículos 178 y 179** del Código de Procedimiento Civil). En tercer lugar, la ubicación normativa: Título XXXV del Libro IV del Código Civil, **artículos 2314 a 2334**; el hecho ilícito como fuente de obligaciones conforme a los **artículos 1437 y 2284**; las definiciones de delito y cuasidelito civil; y el carácter originario de la obligación indemnizatoria, que nace al margen de la voluntad del acreedor y del deudor (lo que se formula técnicamente como obligación de primer grado, por oposición a la obligación de segundo grado que caracteriza a la responsabilidad contractual). En cuarto lugar, las fun-

ciones: la reparación como fin primordial no discutido, del cual deriva el principio de reparación integral; la garantía de la libertad de actuar, expresada en el *alterum non laedere* y en el principio de que cada cual corre con los riesgos de la vida en común, de modo que, a falta de razón jurídica para atribuirle a un tercero, la pérdida debe quedar donde cae (de lo que se sigue que la responsabilidad es la excepción que requiere justificación); la prevención, que opera como disuasión general y se complementa con la prevención especial de origen administrativo; y la punición, ajena al derecho civil continental por razones constitucionales y por incompatibilidad con la reparación integral, aunque presente en hipótesis legales excepcionales, como el **artículo 1768** del Código Civil. Cerrar con la tensión: el sistema proscribía la pena privada, pero la reintroduce por dos vías (la excepción legal expresa y la evaluación discrecional del daño moral), lo que anticipa el problema que se examinará al tratar el daño moral y su cuantificación.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 1. Concepto, regulación y funciones de la responsabilidad civil extracontractual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

B. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL

Un mismo hecho (un atropello, un incendio, una estafa) puede ser simultáneamente ilícito penal e ilícito civil. De allí surgen tres preguntas que este eje debe responder de manera sucesiva, y que conviene no confundir. La primera es conceptual: ¿en qué se distinguen la responsabilidad civil y la penal, si ambas reaccionan frente a un hecho ilícito? La segunda es de relación entre estatutos: ¿son independientes entre sí, de modo que pueda existir una sin la otra? Y la tercera, que es la de mayor rendimiento práctico y donde se concentra la dificultad técnica, es procesal: si ambos juicios se siguen por separado, ¿qué efecto produce lo resuelto en sede penal sobre el juicio civil posterior, y viceversa?

1. LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS RESPONSABILIDADES

El criterio ordenador es el siguiente, y conviene abrir por él: las principales diferencias entre la responsabilidad civil y la penal se expresan en las mayores exigencias que el derecho plantea para dar lugar a esta última. Toda la materia se ordena en torno a esa idea, incluidos los efectos procesales que se examinarán después. La responsabilidad penal es más exigente; por eso, quien la acredita ha acreditado a fortiori lo que basta en sede civil, y por eso la sentencia penal condenatoria irradia efectos sobre el juicio civil, mientras que la civil no los irradia sobre el penal.

1.1. Tipicidad y legalidad

En materia penal, el requisito de la tipicidad exige que la conducta sancionada se adecue exactamente a la descripción del delito contenida en la ley. En materia civil, en cambio, el concepto de ilicitud importa la infracción a un deber de cuidado que puede haber sido establecido previamente por la ley (hipótesis de culpa infraccional), pero que en la generalidad de los casos es determinado por el juez con posterioridad a la conducta que se juzga. La tipicidad penal no es una mera exigencia técnica, sino una derivación del principio de legalidad de la pena, reconocido en el **artículo 19** N° 3 de la Constitución Política, que exige que el tipo penal esté expresamente descrito en la ley y que ésta haya sido dictada con anterioridad a la comisión del hecho. Este anclaje es importante porque explica por qué la diferencia es irreductible: no se trata de que el derecho penal sea “más estricto” por opción de política legislativa, sino de que la Constitución le impone esa estrictez. Y explica, correlativamente, por qué el derecho civil puede operar con cláusulas generales (**artículos 2314 y 2329** del Código Civil) sin infringir garantía alguna: porque la indemnización no es pena. La jurisprudencia ha fundado la distinción exactamente en estos términos. La Corte Suprema, en fallo de 16 de septiembre de 1921, declaró que las modalidades de la responsabilidad civil y de la criminal son sustancialmente diversas: el Código Civil no requiere, para la procedencia de la indemnización, sino un hecho del hombre que haya causado daño a otro, aunque se haya producido sin dolo y sólo con culpa leve o levísima del autor; el Código Penal, en cambio, exige para la existencia del delito, además de la concurrencia del dolo, una disposición expresa de la ley que castigue el hecho de que se trata. En el mismo sentido, la Corte Suprema, en fallo de 21 de marzo de 1938, razonó que para que exista responsabilidad penal se exige, además del dolo o la culpa, que la ley castigue el hecho, y que las imprudencias o negligencias constitutivas de cuasidelito pe-

nal no abarcan toda la gradación que puede importar el cuasidelito civil; de modo que el **artículo 2329** del Código Civil obliga a indemnizar todo daño imputable a malicia o negligencia, aunque esa negligencia no reúna los requisitos necesarios para producir responsabilidad criminal. Estos dos fallos son especialmente útiles en el examen porque muestran que la diferencia no es teórica: hay un ámbito de negligencia (la culpa levísima, y en general toda culpa que no alcanza el umbral del cuasidelito penal) que genera responsabilidad civil sin generar responsabilidad penal alguna.

1.2. La culpa

La culpa civil consiste en la infracción a un deber de conducta determinado a partir del estándar del hombre prudente o buen padre de familia; los deberes específicos de conducta expresan las expectativas razonables que recíprocamente tenemos respecto del comportamiento de los demás. Salvo en los casos de dolo, la culpabilidad civil no importa un juicio de disvalor subjetivo referido al autor, sino exclusivamente referido a la conducta: se limita a una comparación en abstracto entre la conducta efectiva y la conducta debida. Más aún, la responsabilidad civil puede prescindir enteramente de la culpa, como ocurre en las hipótesis de responsabilidad estricta. En materia penal, en cambio, la culpabilidad tiene un significado por completo diferente: se diferencia conceptualmente de la ilicitud (que se concibe en abstracto) y permite definir un deber individual de conducta, de modo que se aprecia en concreto, atendiendo a las condiciones particulares del autor. La culpabilidad penal supone descender al individuo concreto y construir el acto como su hecho personal. La consecuencia sistemática es de la mayor importancia: el juicio civil de culpa es objetivo y comparativo; el juicio penal de culpabilidad es subjetivo y personal. De allí que un mismo comportamiento pueda ser civilmente culpable y penalmente inculpable, sin contradicción alguna.

1.3. El daño

El daño es condición necesaria de la responsabilidad civil: si la acción culpable no genera daño, no hay responsabilidad. En materia penal, en cambio, se sanciona el disvalor de la acción y no sólo el del resultado; no es necesario que se produzca un daño efectivo al bien jurídico protegido para atribuir responsabilidad, salvo que se trate de un delito de resultado, y por eso la ley penal contempla sanciones para la mera tentativa y el delito frustrado. La afirmación admite una salvedad que conviene retener, porque conecta con el Eje 19: las únicas acciones civiles que proceden cuando el daño aún no se ha materializado son las acciones preventivas por daño contingente (**artículos 2328** inciso segundo y 2333 del Código Civil), y ellas, precisamente, no son acciones de responsabilidad. La precisión es dogmáticamente exacta: la responsabilidad presupone daño consumado; la acción preventiva opera antes, y por eso no es indemnizatoria. La jurisprudencia ha construido la distinción sobre esta misma base. La Corte de Apelaciones de Iquique, en fallo de 18 de junio de 1953, declaró que la característica esencial del delito civil consiste en que el hecho ilícito infiera injuria o daño a otra persona, circunstancia que marca su diferenciación con el delito penal, el cual, conforme al **artículo 1°** del Código Penal, es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, con prescindencia del factor daño. De ahí que la responsabilidad penal y la civil puedan coexistir respecto de un mismo hecho, cuando el delito o cuasidelito del que derivan es a la vez civil y penal, esto es, cuando ha inferido daño en la persona o bienes de otro y además está penado por la ley.

1.4. Sujetos pasivos de la acción

En materia penal, sólo son sujetos pasivos de responsabilidad las personas naturales personalmente responsables del delito; por la misma razón, la responsabilidad penal es intransmisibile. Las personas jurídicas están excluidas de este tipo de responsabilidad, y conforme al **artículo 39** del Código Penal, por ellas responden quienes hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación a cuyo nombre hubieren obrado. Excepcionalmente, la Ley N° 20.393 estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de determinados delitos (clasificados en Delitos Económicos, Delitos de Corrupción y Soborno, Delitos Patrimoniales, Delitos de Crimen Organizado y Otros), y existen además sanciones que presentan cierta analogía penal, como las multas o incluso la disolución, tratándose de ilícitos contra la libre competencia. En materia civil, en cambio, las personas jurídicas son plenamente responsables, y lo son no sólo por el hecho ajeno, sino también por el hecho propio. La jurisprudencia extrajo de esta asimetría una consecuencia práctica de gran interés: la Corte Suprema, en fallo de 14 de abril de 1953, resolvió que no hay inconveniente legal alguno para sostener que exista responsabilidad delictual o cuasidelictual civil respecto de una persona sin que exista la penal, y que eso es precisamente lo ocurrido en el caso, en que la compañía demandada incurrió en responsabilidad civil sin incurrir en la penal, puesto que una compañía no puede cometer delitos penales. El fallo es la mejor ilustración disponible de la independencia de ambos estatutos.

1.5. Sujetos activos de la acción y disponibilidad

La regla general en materia penal es que la acción sea pública: puede ejercerla el propio afectado, el Estado a nombre de la sociedad o cualquier persona, y es irrenunciable. La acción penal privada, de carácter excepcional, sólo puede ser ejercida por la víctima o por otra persona a su nombre y, por esa razón, es renunciable, quedando incluso sujeta a extinguirse por el ejercicio de la acción civil que emana del mismo delito (**artículo 66** del Código Procesal Penal). En materia civil, en cambio, una vez materializado el daño, la acción indemnizatoria es esencialmente renunciable, conforme al **artículo 12** del Código Civil. Sólo excepcionalmente está prohibida su renuncia antes de producirse el accidente (situación que configura más bien una causal civil de justificación), cuando importa condonación del dolo futuro o renuncia de bienes jurídicos indisponibles, como la vida o la integridad física. Esta última precisión conecta directamente con el consentimiento de la víctima como causal de justificación, materia del Eje 7.

1.6. La prueba

En materia penal rige un estándar probatorio más estricto. Conforme al **artículo 340** del Código Procesal Penal, nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se cometió el hecho punible objeto de la acusación y de que en él correspondió al acusado una participación culpable y penada por la ley. En materia civil, en cambio, el **artículo 428** del Código de Procedimiento Civil establece un principio distinto: entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. Subyacen a cada régimen probatorio conceptos distintos de certeza y de razonabilidad, que en la tradición del common law se expresan en que la responsabilidad penal requiere convicción fuera de toda duda razonable, mientras que la

responsabilidad civil se satisface con una probabilidad razonable. En materia penal rige, además, el sistema de la sana crítica (**artículo 297** del Código Procesal Penal), mientras que en los procesos civiles se aplica la prueba legal tasada, aunque sujeta a correctivos. Esta diferencia de estándar es la clave de bóveda del sistema: si el estándar penal es más exigente, entonces la absolución penal no prueba nada en sede civil (bien puede deberse a que la prueba no alcanzó el umbral penal, aunque sí alcance el civil), mientras que la condena penal, por haber superado el umbral más alto, satisface con creces el más bajo.

1.7. La prescripción

En materia penal, el plazo de prescripción de la acción varía entre seis meses y quince años, según la gravedad de la pena asignada al delito, y se cuenta desde la fecha de comisión del ilícito (**artículos 94** y siguientes del Código Penal). En materia civil, el plazo es de cuatro años contados desde la perpetración del acto (**artículo 2332** del Código Civil), con las calificaciones que se examinarán en el Eje 22 (donde se verá que el cómputo desde la perpetración es precisamente el punto más discutido de la norma).

1.8. La capacidad

Los umbrales de imputabilidad civil y penal no coinciden, siendo la capacidad delictual civil considerablemente más amplia. La materia se desarrolla en el Eje 5, a propósito del **artículo 2319** del Código Civil.

2. LAS RELACIONES ENTRE AMBAS RESPONSABILIDADES: EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

La responsabilidad civil y la penal son independientes entre sí. Puede haber responsabilidad penal sin responsabilidad civil (por ejemplo, si el hecho ilícito penal no ocasiona daño alguno) y, a la inversa, es usual que los casos de responsabilidad civil no conlleven responsabilidad penal, como ocurre genéricamente cuando el hecho que ocasiona el daño no está tipificado como delito. El **artículo 2314** del Código Civil consagra esta coexistencia posible al disponer que quien ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes. La jurisprudencia ha fundado esta independencia atendiendo a la distinta naturaleza de las acciones que emanan de uno y otro ilícito. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 24 de junio de 1965, razonó que el delito, en cuanto ilícito penal, provoca sólo la reacción de la pena, que es personal y se aplica generalmente de oficio; mientras que, en cuanto ilícito civil, es fuente de un derecho subjetivo a la reparación en favor del perjudicado y de la obligación correlativa de producirla, tutelando así intereses patrimoniales que su titular hace efectivos o no según su libre voluntad, mediante una acción civil que incluso puede renunciar o transigir. El fundamento del fallo es especialmente valioso porque no descansa en la estructura del ilícito, sino en el régimen de la acción: pública, oficiosa e irrenunciable en lo penal; privada, disponible, renunciable y transigible en lo civil. Sin embargo, la independencia no es simétrica, y aquí está el núcleo técnico del eje. Estando sujeta la responsabilidad penal a requisitos más estrictos, la sentencia que se pronuncie en esa sede puede producir efectos en materia civil, lo que no

ocurre en sentido contrario. La regla no es arbitraria: se sigue necesariamente de las diferencias antes examinadas, señaladamente de la diferencia de estándar probatorio y de exigencia sustantiva. Quien fue condenado penalmente lo fue tras superar un umbral más alto que el civil; quien fue absuelto penalmente no ha demostrado nada respecto del umbral más bajo. Por la misma razón, la ley atribuye competencia civil al juez penal respecto de las acciones conexas (más precisamente, la acción restitutoria y la acción indemnizatoria), competencia de la que, a la inversa, carece el juez civil. Las influencias recíprocas entre ambos estatutos están determinadas, en definitiva, por los efectos que la ley atribuye a las sentencias dictadas en uno y otro, y específicamente por la institución de la cosa juzgada.

3. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PENALES EN SEDE CIVIL

3.1. Sentencias condenatorias

Conforme al **artículo 178** del Código de Procedimiento Civil, en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo. El fundamento es el ya explicado: la condena penal supone haber acreditado, con un estándar más exigente, aquello que basta y sobra en sede civil. Ámbito de aplicación. La regla se aplica no sólo a las sentencias penales dictadas por jueces ordinarios, sino también a las sanciones impuestas por los jueces de policía local dentro de su competencia. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 3 de octubre de 1958, confirmado por la Corte Suprema, resolvió que la sentencia del juzgado de policía local que impone pena de multa al chofer culpable de un accidente de tránsito por haber infringido los reglamentos es una sentencia condenatoria en juicio criminal, y produce plena prueba en el juicio civil respecto de la infracción reglamentaria a que ella se refiere. La utilidad práctica es evidente: la condena de policía local acredita, en el juicio civil de indemnización, la culpa infraccional del conductor.

Límite subjetivo. Al tercero civilmente responsable sólo le afectará la decisión penal si ha sido parte en el juicio respectivo. La jurisprudencia aplicó este criterio en un caso paradigmático: en el juicio civil seguido contra la empresa de la cual el conductor condenado por delito de lesiones era dependiente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 19 de noviembre de 1934, declaró que no es lícito tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con los hechos que sirvieron de necesario fundamento a la sentencia condenatoria. Límite objetivo, y es el más importante. La condena penal no basta para obtener indemnización. La responsabilidad civil requiere la existencia de daño, y éste debe ser probado; y tratándose de condenas por delitos de mera actividad, será necesario además probar la causalidad, que es propia de los delitos de resultado. La jurisprudencia ofrece una ilustración muy clara: la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 27 de marzo de 1980, sostuvo que, si bien acreditada la existencia del delito de fraude aduanero nace acción civil para que el Fisco obtenga la indemnización de los perjuicios causados por la no percepción de los derechos aduaneros, no resultaba posible acoger la acción deducida, pues el Fisco, correspondiéndole el peso de la prueba, no había rendido la necesaria para acreditar la naturaleza, el monto y las demás particularidades del daño cuyo resarcimiento pedía. La lección de examen es directa: la sentencia condenatoria penal acredita el hecho, la ilicitud y la participación; no acredita el daño ni, en su caso, la causalidad. El actor civil debe probarlos igualmente.

3.2. Sentencias absolutorias

Por regla general, las sentencias absolutorias penales no producen cosa juzgada en materia civil, porque de la circunstancia de que no exista responsabilidad penal no se sigue necesariamente que tampoco exista responsabilidad civil. Así lo establece el **artículo 179** inciso primero del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo sólo producen cosa juzgada en materia civil cuando se funden en ciertas circunstancias que la propia disposición señala. De ello se sigue la consecuencia interpretativa capital: el efecto de cosa juzgada de la sentencia absolutoria es excepcional, procede sólo en los casos expresamente señalados en la ley y, por lo mismo, esas normas deben interpretarse de manera restrictiva. La jurisprudencia lo ha sostenido con firmeza: la Corte Suprema, en fallo de 29 de agosto de 1917, declaró que dichas hipótesis deben interpretarse en sentido estricto, sin extenderlas más allá de su tenor literal ni a situaciones diversas de las contempladas en ellas; y en fallo de 8 de enero de 1938, razonó que si bien en los juicios civiles pueden hacerse valer las sentencias criminales que condenen al reo (lo que es natural y obvio), cuando absuelven u ordenan el sobreseimiento definitivo se les concede la fuerza de cosa juzgada por excepción, en los casos taxativamente enumerados en la ley. En la misma línea, la Corte Suprema, en fallo de 20 de marzo de 1952, fundó la asimetría en la distinta competencia de uno y otro juez: la del juez del crimen está limitada a conocer de los actos dolosos o culpables expresamente sancionados en las leyes penales, en tanto que la del juez civil se extiende a todos aquellos actos en que ha habido cualquier clase de culpa, imprudencia o negligencia; y por eso la sentencia absolutoria criminal no tiene los mismos efectos que la condenatoria. El juez penal sólo está facultado para declarar que alguien carece de responsabilidad en el orden de su propia jurisdicción. Una aplicación muy elocuente de este principio se produjo a propósito de la amnistía. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 14 de enero de 1963, declaró que la amnistía sólo produce efectos en la esfera de la responsabilidad penal, sin alcanzar el campo de la responsabilidad civil: la primera tiene su origen en el hecho punible, que la ley reprime en resguardo del interés de la colectividad; la segunda nace como consecuencia de ese hecho, en cuanto ocasiona al ofendido un daño que le confiere derecho a la reparación. Por consiguiente, la obligación que genera ese derecho no se extingue por la amnistía.

3.3. Las circunstancias del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil

Primera regla: la no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. La propia norma advierte que no quedan comprendidos en este numeral los casos en que la absolución o el sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal. La inexistencia del delito puede obedecer a una razón material (no se cometió el hecho) o a una razón jurídica (los hechos no son constitutivos de delito desde el punto de vista penal). Y aquí opera la interpretación restrictiva: la jurisprudencia ha entendido sistemáticamente que la norma sólo se refiere a la inexistencia del hecho, en consideración a que los elementos del ilícito civil son menos estrictos que los del delito penal. En consecuencia, la absolución fundada en que los hechos no configuran el tipo penal no produce cosa juzgada civil. Dos ejemplos ilustran la doctrina. Se ha fallado que si no se cumplen los requisitos para que haya estafa, pueden sin embargo cumplirse las condiciones de la responsabilidad civil por mala administración (Corte Suprema, 8 de julio de 1971). Y del hecho de que ciertas expresiones no reúnan los requisitos de la injuria, la calumnia o la difamación, no se sigue la exclusión de la responsabilidad civil por inmiscuirse en la vida priva-

da. La conclusión debe retenerse: la inexistencia del delito se refiere sólo a la inexistencia de los hechos que son relevantes a la vez en materia civil y penal (así, la resolución que declara que un incendio se originó por intervención de un tercero produce cosa juzgada civil), y no a la calificación jurídica de esos hechos. Segunda regla: no existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle por actos de terceros o por daños que resulten de accidentes conforme al Título XXXV del Libro IV del Código Civil. La sentencia debe declarar expresamente esa ausencia de relación, y entonces no es admisible volver a discutir la materia en el juicio civil posterior. La salvedad final de la norma es dogmáticamente relevante: aun cuando el acusado no tenga relación alguna con el hecho, puede subsistir su responsabilidad por el hecho ajeno o su responsabilidad estricta, porque en ambos casos la imputación no descansa en su participación personal en el hecho dañoso. Tercera regla: no existir en autos indicio alguno contra el acusado, no pudiendo en tal caso alegarse la cosa juzgada sino respecto de las personas que hayan intervenido en el proceso criminal como partes directas o coadyuvantes. El punto que la práctica suele confundir es el siguiente: no basta la falta de pruebas suficientes, porque el estándar probatorio penal es más estricto que el civil; lo que se exige es que falte todo indicio de participación, y ello debe ser objeto de declaración expresa en la sentencia. Nótese, además, que ésta es la única de las tres reglas cuyo efecto es relativo (limitado a quienes fueron partes), y no absoluto.

3.4. La contraexcepción: las obligaciones restitutorias

El inciso final del **artículo 179** del Código de Procedimiento Civil contiene una limitación adicional: las sentencias absolutorias o de sobreseimiento en materia criminal relativas a tutores, curadores, albaceas, síndicos, depositarios, tesoreros y demás personas que hayan recibido valores u objetos muebles por un título del que nazca obligación de devolverlos, no producirán en ningún caso cosa juzgada en materia civil. El fundamento es límpido: la absolución penal no puede liberar al absuelto de su obligación de restituir, porque la ley diferencia claramente la acción indemnizatoria (que es la acción de responsabilidad civil) de la acción puramente restitutoria. La distinción es la misma que separa la responsabilidad extracontractual del régimen cuasicontractual, y reaparece en el Eje 3.

3.5. El alcance de la cosa juzgada penal: una anomalía del sistema

El efecto de cosa juzgada de la sentencia penal en sede civil se aparta de los principios generales de la institución, y conviene advertirlo. En primer lugar, la jurisprudencia ha resuelto que la cosa juzgada de la sentencia dictada en sede criminal produce efectos erga omnes, sin que se requiera la concurrencia de la triple identidad a que se refiere el **artículo 177** del Código de Procedimiento Civil. Así lo declaró la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de 21 de marzo de 1923, confirmado por la Corte Suprema, razonando que las normas que determinan la influencia de lo penal en lo civil son reglas de excepción respecto de la que consagra la triple identidad, y que por tanto no puede exigirse que entre el juicio criminal y el juicio civil posterior concurren las tres identidades, puesto que jamás pueden existir entre uno y otro juicio (que tienen siempre distintos objetos y distintas causas legales); exigirles equivaldría a negar la influencia de lo criminal en lo civil, influencia que las leyes expresamente reconocen. En la misma línea, la Corte Suprema, en fallo de 5 de noviembre de 1970, en un caso en que se había dictado absolución por estimarse que los hechos se

debieron a caso fortuito, sostuvo que, no mediando dolo ni culpa, no hubo hecho punible que originara obligaciones basadas en esa fuente de responsabilidad; que el fallo absolutorio debía producir cosa juzgada en materia civil, porque no era aceptable una revisión de tal pronunciamiento; y que esa consecuencia afectaba no sólo a quienes fueron partes en la gestión criminal, sino a toda clase de personas, porque sus efectos son de proyección general. Lo insólito del resultado merece subrayarse: se trata de un efecto de cosa juzgada que se aleja de los principios generales aceptados en la materia, ante todo porque el objeto de la acción civil es materialmente diferente del de la acción penal (y, pese a ello, lo resuelto en sede penal produce efectos en la civil); y porque, salvo en el caso de la tercera regla del **artículo 179**, ni siquiera se requiere identidad legal de personas. La sentencia penal opera, así, con una eficacia expansiva que ninguna sentencia civil posee. En cuanto al alcance material de ese efecto, lo precisa el **artículo 180** del Código de Procedimiento Civil: siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en el juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento. De allí que el efecto se limite a dos aspectos: produce cosa juzgada lo resuelto en el juicio criminal, y producen cosa juzgada los hechos que sirven de necesario fundamento a lo resuelto. Nada más. Lo que la sentencia penal haya afirmado a mayor abundamiento, o lo que no constituya fundamento necesario del fallo, no vincula al juez civil.

4. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES CIVILES EN SEDE PENAL

La regla es sencilla y simétricamente inversa: la sentencia dictada en un juicio de responsabilidad civil no produce cosa juzgada en materia penal, sea absolutoria o condenatoria. La jurisprudencia ha fundado la asimetría en la distinta naturaleza de una y otra cosa juzgada: conforme a las reglas generales, la cosa juzgada civil es relativa a las partes, mientras que la penal es absoluta; de manera que, fallada en un sentido una cuestión civil, sólo las partes favorecidas pueden aprovechar la cosa juzgada, sea como acción o como excepción.

DATO DE GRADO**La asimetría y sus tensiones**

La primera tensión es la que existe entre el principio de independencia y el régimen de cosa juzgada. Las responsabilidades son independientes; pero el sistema de los **artículos 178 a 180** del Código de Procedimiento Civil establece una dependencia unilateral y muy intensa de lo civil respecto de lo penal. La independencia, entonces, es sustantiva (cada estatuto tiene sus propios requisitos y puede haber uno sin el otro), pero no es procesal: en el plano de la prueba y de los hechos, el juez civil queda vinculado por lo resuelto en sede penal. Formular esta distinción entre independencia sustantiva y dependencia procesal unilateral es la manera más económica de mostrar dominio de la materia. La segunda tensión se produce entre ese régimen y los principios generales de la cosa juzgada. El **artículo 177** del Código de Procedimiento Civil exige triple identidad; los **artículos 178 y 179** la excluyen. El resultado es que una persona que jamás fue parte en el proceso penal puede verse afectada, en su juicio civil, por lo allí resuelto. La explicación de esta anomalía es que estas normas no responden a la lógica del efecto relativo de las sentencias (proteger a las partes de un nuevo litigio), sino a la necesidad de evitar la contradicción entre los pronunciamientos de dos jurisdicciones sobre unos mismos hechos. De ahí que el **artículo 180** delimite el efecto no por referencia a las partes, sino a los hechos que sirven de necesario fundamento a lo resuelto: lo que queda cubierto por la cosa juzgada no es la relación jurídica, sino la verdad judicialmente establecida sobre los hechos. Y de ahí también que el **artículo 179**, por tratarse de una excepción a los principios generales, se interprete restrictivamente. La tercera tensión enlaza este eje con el anterior. La distinción entre ambas responsabilidades descansa en que la reacción civil no es punitiva: por eso no rige la tipicidad, por eso la culpa se aprecia en abstracto y por eso el estándar probatorio es menor. Pero ya se examinó en el Eje 1 que lo retributivo reaparece en sede civil por dos vías: la excepción legal expresa (el **artículo 1768** del Código Civil) y, sobre todo, la avaluación judicial del daño moral, en la que los jueces suelen atender a la gravedad del ilícito y a la capacidad económica del demandado, y no a la intensidad del perjuicio sufrido por la víctima. Es decir: expulsada la retribución por la puerta de la definición, reingresa por la ventana de la cuantificación. La distinción civil/penal, siendo cierta y estructural, no es tan nítida en su aplicación como su enunciado sugiere. Debe agregarse, por último, una advertencia de método: las reglas de los **artículos 178 a 180** del Código de Procedimiento Civil fueron concebidas bajo el sistema procesal penal antiguo, y su aplicación bajo el Código Procesal Penal vigente exige adaptaciones. Excepcionalmente, la sentencia absolutoria o el sobreseimiento definitivo producen cosa juzgada civil (**artículo 179** del Código de Procedimiento Civil) solo si concurren copulativamente: (i) que se funden en la inexistencia del delito o cuasidelito, sea porque el hecho nunca ocurrió, sea porque, existiendo, carece de relevancia jurídica; y (ii) que la absolución no derive de eximentes de responsabilidad criminal (v. gr. legítima defensa o inimputabilidad). Es clave distinguir la inexistencia del hecho de la insuficiencia probatoria: si se absuelve por duda razonable o falta de acreditación, no hay cosa juzgada civil y la víctima puede demandar con éxito (basta probar la culpa, no el delito más allá de toda duda); en cambio, si se determina que el hecho materialmente nunca existió, la acción civil queda bloqueada.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el criterio ordenador, del que todo lo demás se deduce: las diferencias entre ambas responsabilidades se expresan en las mayores exigencias que el derecho plantea para dar lugar a la penal. Enseguida, el catálogo de diferencias. La tipicidad, exigida en sede penal por el principio de legalidad de la pena del **artículo 19** N° 3 de la Constitución Política, frente a la ilicitud civil, que consiste en la infracción de un deber de cuidado determinado por el juez, salvo culpa infraccional. La culpa, que en sede civil es objetiva y se aprecia en abstracto comparando la conducta efectiva con la debida, y que en sede penal es subjetiva y se aprecia en concreto, atendiendo al autor. El daño, esencial en lo civil (sin daño no hay responsabilidad, salvo las acciones preventivas de los **artículos 2328** inciso segundo y 2333 del Código Civil, que no son acciones de responsabilidad), y prescindible en lo penal, donde se sanciona la tentativa y el delito frustrado. Los sujetos pasivos: personas naturales en lo penal, con responsabilidad intransmisible y con la exclusión de las personas jurídicas salvo los casos de la Ley N° 20.393 (**artículo 39** del Código Penal), frente a la plena responsabilidad civil de las personas jurídicas por hecho propio y ajeno. Los sujetos activos: acción pública e irrenunciable en lo penal, frente a acción civil esencialmente renunciabile conforme al **artículo 12** del Código Civil. La prueba: convicción más allá de toda duda razonable (**artículo 340** del Código Procesal Penal) frente al criterio del **artículo 428** del Código de Procedimiento Civil. Y la prescripción: entre seis meses y quince años según la pena, contados desde la comisión (**artículos 94** y siguientes del Código Penal), frente a los cuatro años desde la perpetración del acto (**artículo 2332** del Código Civil). En tercer lugar, el principio de independencia (puede haber una responsabilidad sin la otra, y el **artículo 2314** del Código Civil consagra su posible coexistencia) y su corrección: la sentencia penal produce efectos en sede civil, pero no a la inversa, porque el estándar penal es más exigente. En cuarto lugar, el régimen de cosa juzgada. Las condenatorias pueden hacerse valer siempre (**artículo 178** del Código de Procedimiento Civil), incluidas las de policía local, pero no eximen de probar el daño ni, en su caso, la causalidad. Las absolutorias sólo producen cosa juzgada en los casos taxativos del **artículo 179** (inexistencia del hecho, ausencia total de relación entre el hecho y el acusado, y ausencia de todo indicio), de interpretación restrictiva; con la contraexcepción del inciso final, que excluye toda cosa juzgada respecto de las obligaciones restitutorias. El alcance material lo fija el **artículo 180**: sólo lo resuelto y los hechos que le sirven de necesario fundamento. Y la sentencia civil no produce jamás cosa juzgada en sede penal. Cerrar señalando la anomalía y su matiz: el efecto erga omnes de la sentencia penal se aparta de la triple identidad del **artículo 177** del Código de Procedimiento Civil, lo que explica precisamente la interpretación restrictiva del **artículo 179**; y la separación entre ambos estatutos, siendo real y estructural, se ve atenuada en la práctica por la reaparición de elementos retributivos en la evaluación judicial del daño moral.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 2. Responsabilidad civil y responsabilidad penal**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

C. DELIMITACIÓN DE ESTATUTOS: CONTRACTUAL, CUASICONTRACTUAL Y DERECHO COMÚN

Este eje resuelve una pregunta que, siendo previa a todo el curso, sólo puede responderse una vez conocida la estructura de la responsabilidad extracontractual: ¿cuándo se aplica este estatuto y cuándo se aplica otro? La pregunta se descompone en tres operaciones sucesivas, de naturaleza distinta. La primera es una delimitación frente al contrato, y es la más sencilla: si existe un vínculo obligatorio previo entre las partes y el daño proviene de su incumplimiento, rige la responsabilidad contractual; si no lo hay, rige la extracontractual. La dificultad no está en el criterio, sino en sus zonas de frontera. La segunda es una delimitación frente al cuasicontrato, y no es una delimitación entre regímenes de responsabilidad, sino entre dos clases de acciones: la indemnizatoria y la restitutoria. Aquí el problema no es cuál estatuto rige, sino qué se puede pedir. La tercera es la más difícil, y es propiamente un problema de laguna legal: el Código regula dos estatutos de responsabilidad, pero no dice cuál de ellos constituye el derecho común, esto es, cuál se aplica supletoriamente a las hipótesis que no encajan limpiamente en ninguno de los dos (señaladamente, el incumplimiento de obligaciones de fuente legal). La cuestión no es académica: de su respuesta depende, en cada caso, quién soporta el peso de la prueba de la culpa, cuál es el plazo de prescripción, si la culpa admite graduación y hasta dónde se extiende la reparación.

1. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

1.1. Los conceptos

La imputación a una persona de la obligación de reparar un perjuicio constituye el contenido esencial del concepto de responsabilidad civil. Ambos estatutos comparten, pues, la misma sustancia; lo que los separa es el antecedente de esa obligación de reparar. La responsabilidad contractual es la obligación del deudor de indemnizar al acreedor los perjuicios que le ha originado el incumplimiento, el cumplimiento imperfecto o el cumplimiento tardío de la obligación. La responsabilidad extracontractual (que suele llamarse también delictual o aquiliana, esta última denominación por la lex Aquilia que reglamentó la materia en la Roma antigua) consiste en la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito, delito o cuasidelito, ha ocasionado a la víctima.

El cuadro de diferencias entre ambos regímenes (capacidad, graduación de la culpa, mora, extensión de la reparación, solidaridad, prescripción y peso de la prueba) es materia del Eje 23, y el cúmulo lo es del Eje 24. Lo que aquí interesa no es enumerar en qué se diferencian, sino establecer cuándo se aplica cada uno.

1.2. El criterio de delimitación

El criterio que permite delimitar ambos estatutos es el que ya se estudió en el Eje 1, y conviene reiterarlo aquí porque es el que resuelve todos los casos de frontera. En materia contractual, la acción de responsabilidad complementa (y en algunos casos sustituye) a la acción que persigue el

cumplimiento forzado en naturaleza de la obligación principal; se traduce, por tanto, en una obligación de segundo grado (indemnizar los perjuicios ocasionados con el incumplimiento) cuyo fundamento es precisamente el incumplimiento de la obligación principal o de primer grado. Así lo sostienen **BARROS** y **DUCCI**. En materia extracontractual, en cambio, la responsabilidad no supone la existencia de un vínculo obligatorio previo, y su antecedente se encuentra en los deberes de cuidado generales y recíprocos que las personas deben observar en sus encuentros espontáneos. El vínculo obligatorio tiene aquí carácter originario: su antecedente es haber ocasionado un daño infringiendo uno de esos deberes. La consecuencia operativa debe retenerse: la pregunta que decide el estatuto aplicable no es “¿hubo culpa?” ni “¿hubo daño?”, sino “¿existía entre las partes una obligación previa cuyo incumplimiento sea el antecedente del daño?”. Si la hay, se está en el segundo grado; si no la hay, en el primero. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia con toda claridad. La Corte Suprema, en fallo de 3 de julio de 1951, declaró que la culpa contractual y la extracontractual están regidas por leyes diversas, de alcance y extensión distintos: la primera se produce por el incumplimiento o el retardo del deudor de una obligación que nace del contrato, del cuasicontrato o de la ley; la segunda no supone nexo alguno entre una parte y otra, pues se genera por hechos de personas extrañas entre sí, que no pueden preverse mediante convenciones preexistentes. Y en el mismo sentido, la Corte Suprema, en fallo de 6 de noviembre de 1972, razonó que las fuentes de las que emana la responsabilidad civil son las mismas que el **artículo 1437** del Código Civil señala como origen de las obligaciones, y que entre ellas aparecen las que surgen a consecuencia de la violación de un vínculo de obligación preexistente y aquellas constituidas por la comisión de un hecho ilícito, ajena a todo vínculo jurídico anterior, mediando dolo o imprudencia. Debe subrayarse un detalle del fallo de 1951 que suele pasar inadvertido y que resultará decisivo en la sección 4: la Corte no dice que la culpa contractual provenga sólo del incumplimiento de obligaciones contractuales, sino del incumplimiento de obligaciones que nacen del contrato, del cuasicontrato o de la ley. La jurisprudencia, entonces, ya venía extendiendo el estatuto llamado “contractual” a toda obligación preexistente, cualquiera fuese su fuente. Ese dato es un argumento de peso (y de origen jurisprudencial, no doctrinario) a favor de la solución que se examinará a propósito del derecho común.

1.3. La sustitución convencional del régimen extracontractual

El riesgo general de ocasionar daños puede ser materia de un acuerdo previo entre los potenciales afectados. Una industria contaminante puede celebrar acuerdos con sus vecinos sobre los daños que provocará su funcionamiento, y en tal caso el contrato regirá materias que, de no mediar acuerdo, se someterían a las reglas de la responsabilidad extracontractual. En principio no existe impedimento para que el contrato sustituya a las reglas de responsabilidad extracontractual, respetando los límites que imponen las normas de orden público: serán ilícitos en razón de su objeto los pactos que importen la condonación anticipada del dolo o la disposición de derechos irrenunciables, como la vida. Esta observación conecta con el consentimiento de la víctima como causal de justificación (Eje 7) y con la renunciabilidad de la acción (Eje 22). Sin embargo, en la práctica la regulación contractual de los riesgos es completamente excepcional. Los riesgos a que diariamente nos vemos enfrentados son de tal modo difusos que la negociación de contratos entre los potenciales causantes de daños y sus víctimas resulta inviable por su extrema onerosidad: las líneas aéreas están en la práctica impedidas de negociar contratos con todos aquellos que podrían verse afectados en tierra por un eventual accidente, y lo mismo ocurre con los fabricantes de bebidas gaseosas

o de medicamentos respecto de los consumidores finales. La sustitución convencional sólo es posible, entonces, en los casos excepcionales en que el riesgo y las potenciales víctimas son perfectamente identificables a priori y, además, se justifica el costo de negociar el acuerdo. De aquí se sigue una conclusión que anticipa la respuesta al problema del derecho común: las reglas de responsabilidad extracontractual conservan el carácter de estatuto general de la responsabilidad civil, y se aplican a todas aquellas situaciones en que no existe una relación obligatoria previa entre la víctima y el autor del daño. La razón no es dogmática, sino estructural: la inmensa mayoría de los encuentros dañosos ocurre entre extraños, y entre extraños no hay contrato posible.

2. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL Y CUASICONTRACTUAL

2.1. El criterio: acción indemnizatoria y acción restitutoria

Mientras en materia extracontractual la acción que se concede a la víctima es esencialmente indemnizatoria y tiene por objeto obtener la reparación íntegra del daño sufrido por ésta (**artículo 2329** del Código Civil), en el ámbito cuasicontractual el derecho concede acciones meramente restitutorias, cuyo objeto es el resarcimiento de los costos directos en que el actor ha incurrido en beneficio de un tercero. La diferencia es de medida, y ahí está la clave. La acción indemnizatoria se mide por el daño sufrido por el demandante; la acción restitutoria se mide por el provecho obtenido por el demandado o por el costo efectivamente incurrido por el actor en beneficio ajeno. Una repara; la otra evita un enriquecimiento injustificado. No son dos intensidades de lo mismo: son dos lógicas distintas.

2.2. La demostración: el artículo 2290 y la agencia oficiosa

El **artículo 2290** del Código Civil, aplicable a la agencia oficiosa, dispone que aquel que sin mediar mandato se ha hecho cargo de la administración de negocios ajenos (el gerente) sólo tiene derecho a que se le restituya lo invertido en expensas útiles o necesarias, pero no puede exigir que se le remunere por sus actos. La consecuencia debe formularse con precisión, porque es la que demuestra la tesis: el gerente no tiene derecho a que se le indemnice el lucro cesante (el costo de oportunidad) que significa haber dedicado tiempo a la protección de los intereses de otro. Si la acción del cuasicontrato fuese indemnizatoria, ese lucro cesante sería resarcible, porque forma parte del daño patrimonial (Eje 11). Al no serlo, queda demostrado que la acción no persigue reparar un daño, sino restituir un gasto. Idéntico principio rige en el cuasicontrato de pago de lo no debido y, en general, en la acción innominada de enriquecimiento sin causa. La distinción se proyecta, además, sobre el propio Título XXXV. El **artículo 2316** inciso segundo del Código Civil (el que obliga a restituir a quien recibe provecho del dolo ajeno, hasta la concurrencia de lo que valga el provecho) consagra precisamente una acción restitutoria de un enriquecimiento sin causa, y no una acción indemnizatoria. De allí que quien recibe provecho del dolo ajeno sin ser cómplice no responde del daño causado a la víctima, sino sólo hasta el monto de su propio provecho. La distinción entre lo indemnizatorio y lo restitutorio no es, pues, una curiosidad del cuasicontrato: explica por qué el **artículo 2316** inciso segundo tiene un límite cuantitativo que el **artículo 2314** no tiene. El punto se retoma en el Eje 21.

3. EL DERECHO COMÚN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

3.1. La laguna

La legislación nacional regula dos grandes estatutos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual), pero no establece explícitamente el régimen común aplicable, por ejemplo, al incumplimiento de obligaciones legales. Se trata de una auténtica laguna: hay hipótesis de responsabilidad civil que no son contractuales (porque no hay contrato) pero que tampoco encajan cómodamente en el modelo extracontractual (porque sí hay una obligación previa, sólo que de fuente legal). El sistema debe decidir cuál de los dos regímenes opera supletoriamente, y el Código no lo dice.

3.2. La tesis contractualista: ALESSANDRI

ALESSANDRI sostiene que el régimen común de responsabilidad es el contractual, y su argumentación se despliega en tres tramos. El primero es de ubicación normativa: el estatuto contractual es el único regulado genéricamente a propósito de los efectos de las obligaciones, en los **artículos 1545** y siguientes del Código Civil. Los hechos ilícitos, en cambio, reciben un tratamiento particular y separado, bastante más adelante.

El segundo es un argumento de epígrafe, y es el más citado: el Título XII del Libro IV, que trata de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, lleva por título “Del efecto de las obligaciones” (expresión que las involucra a todas, sin distinguir su fuente), y los hechos ilícitos se exceptúan de esa regulación general precisamente por el tratamiento separado que el Código les otorga más adelante. La regla, entonces, sería la del Título XII; la excepción, la del Título XXXV. El tercero es un argumento sistemático de considerable fuerza, que conviene manejar con exactitud porque es el que hace difícil descartar la tesis. Se invoca el contenido de los **artículos 391, 427, 2308 y 2288** del Código Civil, todos los cuales emplean nociones de graduación de la culpa (culpa leve, buen padre de familia, culpa levísima), no obstante referirse a obligaciones legales o cuasicontractuales. Ahora bien, la graduación tripartita de la culpa (**artículo 44** del Código Civil) sólo sería admisible en el terreno contractual, pues en sede extracontractual la culpa no admite grados y se responde de toda culpa. Si el legislador gradúa la culpa a propósito de obligaciones legales y cuasicontractuales, ello significaría que las está sometiendo, implícitamente, al régimen de la responsabilidad contractual. La conclusión de ALESSANDRI es categórica: las reglas de la responsabilidad contractual constituyen el derecho común en materia de responsabilidad, y la responsabilidad delictual y cuasidelictual es de excepción.

3.3. La tesis contraria

La réplica se despliega en cuatro movimientos. Primero, se objeta que el Título XII discurre sobre la idea de una estipulación previa de las partes, cuestión que no acontece respecto de las obligaciones extracontractuales. El epígrafe “Del efecto de las obligaciones” prometería más de lo que la regulación efectivamente entrega: sus normas están pensadas para el deudor de una obligación convenida. Segundo, y es el argumento normativo central, se invoca el **artículo 2284** del Código Civil, que agrupa las obligaciones que se contraen sin convención, señalando que nacen o de la ley o

del hecho voluntario de una de las partes, y que, en este último caso, si el hecho es lícito constituye un cuasicontrato y si es ilícito, un delito o un cuasidelito. La norma, al agrupar de ese modo, estaría dando a entender que esas obligaciones tienen una naturaleza similar entre sí y distinta de las que emanan del contrato. Igual cosa hace el **artículo 578** del Código Civil respecto de los derechos personales o créditos. Tercero, se razona por analogía frente a un vacío legal: puesto que la ley no establece cuál es el derecho común, y puesto que ella misma agrupa las obligaciones según tengan o no origen convencional, esa misma distinción debe aplicarse para establecer la regla general en materia de responsabilidad. En otras palabras, hay que agrupar las obligaciones de la misma naturaleza bajo unas mismas reglas supletorias: las convencionales, bajo el estatuto contractual; las no convencionales, bajo el extracontractual. Cuarto, y es el argumento definitivo, se acude a un dato de estructura del tráfico jurídico, y no de exégesis: el contrato supone necesariamente un acuerdo previo, que debe ser observado y cuya inobservancia genera una obligación indemnizatoria de segundo grado; pero la mayoría de los deberes de cuidado a que se está sometido en el tráfico no dan lugar a relaciones obligatorias. Por ello, en la práctica, el régimen común es el de la responsabilidad extracontractual, precisamente porque se refiere a esas relaciones que no están regidas por un vínculo obligatorio preexistente. A ello **BARROS** añade una objeción que ataca la premisa misma de **ALESSANDRI**, y no ya su conclusión. La tesis contractualista descansa en atribuir las normas del Título XII del Libro IV (“Del efecto de las obligaciones”) exclusivamente al ámbito contractual. Pues bien: algunas de las normas de ese título se aplican indistintamente al ámbito contractual y al extracontractual, y por ello la conclusión sobre el carácter de régimen común del primero pierde sustento. El argumento es demoledor en su estructura: si el Título XII no es exclusivamente contractual, entonces del hecho de que regule “el efecto de las obligaciones” en general no se sigue que el estatuto contractual sea el derecho común; se sigue, a lo más, que ciertas reglas son comunes a ambos estatutos, que es cosa muy distinta. Son comunes a ambos regímenes el **artículo 1556**, que fija el contenido de la indemnización (daño emergente y lucro cesante) como regla general de daño patrimonial también aplicada en sede extracontractual, y la parte final del **artículo 1558**, que exige un nexo causal directo entre el hecho y el daño. En cambio, son exclusivas del ámbito contractual los **artículos 1551** y **1557**, sobre la exigencia y los efectos de la mora; el **artículo 1547** inciso 3.º, sobre la carga de la prueba de la culpa; y el **artículo 1558** en lo relativo a la previsibilidad del daño.

3.4. La zona gris: las obligaciones de fuente legal

Aquí está el verdadero punto de dificultad. La cuestión se torna más discutible en los casos en que existe una obligación preexistente que no tiene su origen en el contrato, sino en la ley. Dos ejemplos: la responsabilidad que surge del incumplimiento de la obligación de dar alimentos, y la que tienen los directores de una sociedad anónima respecto de los accionistas (**artículo 41** inciso primero de la Ley N° 18.046). Parte de la doctrina afirma que en tales casos la responsabilidad sigue al incumplimiento de una obligación personal de primer grado y podría regirse, por analogía, por las normas de la responsabilidad contractual. **BARROS** suscribe expresamente esa solución. Conviene advertir, sin embargo, que esa conclusión está en tensión con el argumento del **artículo 2284**, que es el pilar de la tesis extracontractualista. Si esa norma agrupa las obligaciones no convencionales (las legales junto a los delitos y cuasidelitos) y las separa de las contractuales, entonces someter las obligaciones legales al estatuto contractual es precisamente lo contrario de lo que el **artículo 2284** sugiere. La incoherencia sólo se disuelve si se advierte que el criterio decisi-

vo no es la fuente de la obligación, sino su estructura: lo determinante no es de dónde nace la obligación, sino si existe o no una obligación de primer grado entre las partes cuya infracción sea el antecedente del daño. Esa diferencia de criterio (fuente versus estructura) es el origen doctrinario de toda la discusión, y conviene explicitarla en el examen, porque muestra que el problema del derecho común no se juega en la exégesis de los **artículos 1545** o 2284, sino en la pregunta previa sobre qué es lo que define un estatuto de responsabilidad. El argumento jurisprudencial ya anticipado lo confirma: el fallo de la Corte Suprema de 3 de julio de 1951 define la culpa contractual como aquella que se produce por el incumplimiento o retardo del deudor de una obligación que nace del contrato, del cuasicontrato o de la ley. La Corte, entonces, ya adscribía al criterio estructural, no al de la fuente.

4. LAS APLICACIONES DEL CRITERIO

Del criterio anterior se extraen consecuencias prácticas de enorme utilidad, porque son precisamente los casos que suelen preguntarse. Responsabilidad médica. Para determinar la acción que se interpondrá como consecuencia de un daño, deberá precisarse si existe un acuerdo contractual con el médico o con la clínica respectiva: en caso afirmativo, regirá la responsabilidad contractual; en caso contrario, se aplicarán las reglas de la responsabilidad extracontractual. Eventualmente concurrirá además la responsabilidad por el hecho ajeno si el médico trabaja para la clínica o si el daño es causado por miembros de su equipo (Eje 14). Responsabilidad precontractual. Antes de que se celebre el contrato definitivo, y durante la negociación, es frecuente que se suscriba un acuerdo en principio o acuerdo de negociación, en cuyo caso la negociación se rige por las reglas de la responsabilidad contractual. Si no hay tal acuerdo (que será la regla general), la negociación está regida por los deberes de cuidado cuya infracción da lugar a responsabilidad extracontractual. El punto se desarrolla en el Eje 25. Nulidad del contrato. La nulidad no tiene su origen en un incumplimiento contractual, sino en la ineficacia del contrato. Por ello, la indemnización de los perjuicios que se causen con motivo de la nulidad tendrá que regirse por la responsabilidad extracontractual. El razonamiento es riguroso: si el contrato es nulo, no hubo obligación de primer grado que incumplir, de modo que mal puede haber responsabilidad de segundo grado. La responsabilidad por nulidad puede extenderse solidariamente a todos los que hubieren otorgado el pacto nulo; así lo dispone el **artículo 6º** inciso final de la Ley N° 18.046, conforme al cual los otorgantes del pacto declarado nulo responden solidariamente ante los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad. Productos defectuosos. Si hay una cadena de contratos entre el fabricante y quien recibe la mercadería defectuosa, se aplicará la responsabilidad extracontractual (pues entre fabricante y consumidor final no hay vínculo contractual directo), pero es posible recurrir a la presunción de responsabilidad por el hecho propio del **artículo 2329** del Código Civil para establecer una relación entre el fabricante y el consumidor que dé lugar a una inversión del peso de la prueba en favor de la víctima, como ocurre en la responsabilidad contractual. La observación anticipa el Eje 9: la presunción del **artículo 2329** opera aquí como un correctivo que aproxima el resultado extracontractual al contractual, sin necesidad de cambiar de estatuto. Directores de sociedad anónima. Este caso merece atención especial, porque matiza (y a primera vista contradice) lo dicho a propósito de las obligaciones legales. La acción que pertenece a los accionistas contra los directores (**artículo 41** de la Ley N° 18.046) no tiene su antecedente en un contrato, sino en una relación mediata, a través de la sociedad. Por eso, por regla general se aplicará el estatuto de la res-

ponsabilidad extracontractual, la que tendrá su origen en la infracción de un deber de cuidado que la ley establece no sólo respecto de la sociedad, sino también respecto de los accionistas. La aparente contradicción se disuelve atendiendo al criterio estructural, y explicitarlo es una excelente demostración de dominio: para que proceda el estatuto contractual por analogía no basta con que exista una obligación legal; se requiere que exista una obligación personal de primer grado entre las partes del juicio. Entre el director y el accionista no la hay: el vínculo del director es con la sociedad, y sólo mediatamente con los accionistas. De allí que se aplique el régimen extracontractual, aunque (como en la responsabilidad contractual) la responsabilidad surja aquí como reparación por el incumplimiento de una obligación personal de medios establecida por la ley. En principio, cada accionista solo puede demandar individualmente los perjuicios directos y personales que sufra en su patrimonio, quedando excluido el daño meramente reflejo o proporcional al sufrido por la sociedad. Sin embargo, la ley ha abierto la posibilidad de que accionistas que representen el cinco por ciento del total de las acciones emitidas ejerzan la acción social de responsabilidad en beneficio de la sociedad por los perjuicios provocados por los directores (**artículo 133**, inciso tercero, de la Ley N° 18.046, introducido por la Ley N° 19.705). En este caso, el éxito de la acción beneficia directamente al patrimonio social, recibiendo los accionistas demandantes una restitución por los gastos incurridos si la acción es acogida.

DATO DE GRADO**Cuál es el verdadero derecho común**

La tensión de este eje no se libra entre autores, sino entre dos concepciones de lo que define un estatuto de responsabilidad. La tesis de **ALESSANDRI** descansa en un criterio de fuente normativa: el derecho común es el que el Código regula genéricamente, y el Código regula genéricamente el efecto de las obligaciones en el Título XII del Libro IV. Su fuerza es exegetica (el epígrafe, la ubicación, la graduación de la culpa en obligaciones legales y cuasicontractuales) y su debilidad es la que **BARROS** denuncia: si algunas normas de ese título se aplican indistintamente a ambos estatutos, entonces el título no es exclusivamente contractual y el argumento se derrumba en su premisa. La tesis contraria descansa en un criterio estructural: el derecho común es aquel que rige las relaciones que no están regidas por un vínculo obligatorio preexistente, y esas relaciones (los encuentros espontáneos entre extraños) constituyen la inmensa mayoría del tráfico. La fuerza de esta tesis no es exegetica, sino fáctica: no depende de dónde ubicó **BELLO** las normas, sino de cómo se producen efectivamente los daños en la vida social. Y por eso se refuerza con el argumento de los costos de transacción: la contratación previa de los riesgos es inviable salvo en casos excepcionales, luego la regla no puede ser el contrato. La tensión reaparece, sin embargo, en la zona gris de las obligaciones legales, y allí cada tesis se apoya en el argumento de la contraria. Quien construye la regla general sobre el **artículo 2284** (que agrupa las obligaciones no convencionales y las separa de las contractuales) no puede, sin costo, someter luego las obligaciones legales al estatuto contractual por analogía. **BARROS** no incurre en esa incoherencia, porque nunca hizo de la fuente el criterio decisivo: para él lo determinante es la existencia de una obligación personal de primer grado entre las partes, de modo que una obligación legal preexistente (los alimentos) se acerca al estatuto contractual, mientras que una obligación legal mediata (la del director frente al accionista) permanece en el extracontractual. La conclusión que debe extraerse, y que es la más alta que este eje permite alcanzar, es la siguiente: el problema del derecho común no se resuelve preguntando de dónde nace la obligación, sino preguntando si existe o no una obligación previa entre demandante y demandado. El **artículo 2284** clasifica fuentes; la responsabilidad civil distribuye cargas procesales y sustantivas en función de la posición relativa de las partes. Por eso el criterio estructural es superior, y por eso la jurisprudencia lo venía aplicando mucho antes de que la doctrina lo formulara: para la Corte Suprema, la culpa contractual comprende el incumplimiento de obligaciones nacidas del contrato, del cuasicontrato o de la ley, con entera prescindencia de la clasificación del **artículo 2284**. Queda, con todo, una consecuencia práctica que no debe olvidarse: mientras la cuestión no esté zanjada, la calificación del estatuto aplicable a las obligaciones legales sigue siendo materia de discusión, y de ella dependen el plazo de prescripción, la carga de la prueba de la culpa y la graduación de ésta. La elección del estatuto no es, pues, una preferencia teórica: decide litigios.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir distinguiendo las tres operaciones que el eje comprende: la delimitación frente al contrato, la delimitación frente al cuasicontrato y la determinación del derecho común, advirtiendo

que sólo la tercera es un problema propiamente dicho. En cuanto a la delimitación frente al contrato, debe enunciarse el criterio: la responsabilidad contractual es una obligación de segundo grado, que presupone y sanciona el incumplimiento de una obligación previa; la extracontractual es originaria, y su antecedente son los deberes generales de cuidado que rigen los encuentros espontáneos entre personas que no están ligadas por vínculo alguno. La pregunta que decide el estatuto es si existía o no una obligación previa entre las partes cuyo incumplimiento sea el antecedente del daño. Puede citarse el fallo de la Corte Suprema de 3 de julio de 1951. Y puede agregarse que, aunque nada impide que un contrato sustituya las reglas extracontractuales (con el límite del orden público: no cabe condonar el dolo futuro ni disponer de derechos irrenunciables), en la práctica ello es excepcional, porque los costos de negociar con todas las víctimas potenciales lo hacen inviable. En cuanto a la delimitación frente al cuasicontrato, el criterio es que la acción extracontractual es indemnizatoria y se mide por el daño de la víctima (**artículo 2329** del Código Civil), mientras que la cuasicontractual es meramente restitutoria y se mide por el costo incurrido en beneficio ajeno. La demostración es el **artículo 2290** del Código Civil: el agente oficioso sólo obtiene la restitución de las expensas útiles o necesarias, y no puede reclamar remuneración ni, por tanto, el lucro cesante derivado del tiempo dedicado al negocio ajeno. Lo mismo rige en el pago de lo no debido y en la acción de enriquecimiento sin causa; y la misma lógica explica el límite del **artículo 2316** inciso segundo respecto de quien recibe provecho del dolo ajeno. En cuanto al derecho común, debe plantearse primero la laguna. Enseguida, la tesis de **ALESSANDRI**, con sus tres argumentos: es el único régimen regulado genéricamente (**artículos 1545** y siguientes); el Título XII del Libro IV se titula “Del efecto de las obligaciones”, expresión que las involucra a todas; y diversas normas del Código gradúan la culpa a propósito de obligaciones legales y cuasicontractuales (**artículos 391, 427, 2288 y 2308**), siendo la graduación una institución propia del régimen contractual. Luego, la tesis contraria: el Título XII discurre sobre la idea de una estipulación previa; el **artículo 2284** agrupa las obligaciones que se contraen sin convención (legales, cuasicontractuales y delictuales) dando a entender que comparten naturaleza; y, sobre todo, la mayoría de los deberes de cuidado del tráfico no dan lugar a relaciones obligatorias, de modo que en la práctica el régimen común es el extracontractual. Debe añadirse la objeción de **BARROS**, que ataca la premisa de **ALESSANDRI**: si algunas normas del Título XII se aplican indistintamente a ambos estatutos, entonces ese título no es exclusivamente contractual y la conclusión pierde sustento. Finalmente, la zona gris de las obligaciones de fuente legal, alimentos, deberes de los directores de sociedades anónimas (**artículo 41** de la Ley N° 18.046), donde parte de la doctrina, y **BARROS** expresamente, sostienen que, existiendo una obligación personal de primer grado, procede aplicar por analogía el estatuto contractual. Cerrar mostrando que el criterio decisivo no es la fuente de la obligación, sino la estructura de la relación: prueba de ello es que, tratándose de los directores frente a los accionistas, la relación es mediata (el vínculo del director es con la sociedad) y por eso se aplica, no obstante tratarse de una obligación legal, el régimen extracontractual.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 3. Delimitación de estatutos: contractual, cuasicontractual y derecho común**.

Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

D. SISTEMAS O MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La pregunta esencial que plantea la responsabilidad civil dice relación con las razones o fundamentos que el derecho considera para establecer que una determinada persona debe responder por un daño sufrido por otra. Dicho de otro modo, y en la formulación que resulta más productiva para el análisis: qué razones habrá de considerar el ordenamiento para que el costo de un daño sea atribuido a un sujeto distinto de la víctima. Conviene detenerse en esa formulación, porque en ella está contenido todo el problema. El punto de partida del sistema no es la reparación, sino su ausencia: cada cual corre con los riesgos que impone la vida en común, de modo que, a falta de una razón jurídica para atribuirle a un tercero, la pérdida derivada de un accidente debe quedar donde cae. La fórmula es de **OLIVER WENDELL HOLMES**, y **ALESSANDRI** sostiene lo mismo cuando, siguiendo a **DEMOGUE**, explica la teoría clásica: como los hombres pueden actuar libre e independientemente, cada uno debe recoger los beneficios que le proporcionen la suerte o su actividad y soportar los daños causados por la naturaleza o por el hecho ajeno; no basta que un individuo sufra un daño en su persona o bienes para que su autor deba repararlo, sino que es menester que provenga de un hecho doloso o culpable. La responsabilidad es, pues, la excepción, y es ella la que exige justificación. Los modelos de atribución son, precisamente, las distintas respuestas que el derecho ha construido para justificar ese desplazamiento. Y la elección entre ellos no es una cuestión meramente teórica: de ella dependen la carga de la prueba, las defensas admisibles y, en definitiva, cuáles daños se indemnizan y cuáles debe soportar quien los sufrió. Dos son las tendencias que principalmente se han desarrollado para fundamentar la responsabilidad por el hecho ilícito: la responsabilidad subjetiva o por culpa, y la responsabilidad estricta, objetiva o sin culpa. A ellas suele agregarse una tercera técnica (el seguro obligatorio) que, según se verá, no constituye propiamente un modelo de atribución de responsabilidad, aunque cumple una función funcionalmente análoga.

1. LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA O POR CULPA

1.1. El fundamento clásico

La doctrina clásica señala como fundamento de la obligación de indemnizar que la ley impone, la culpabilidad del agente: esto es, la actitud reprochable del autor del delito o cuasidelito, que puede recorrer una cierta graduación desde el dolo hasta la negligencia, pero que le impone en todo caso la necesidad de responder de su conducta. Para esta doctrina, dos son los requisitos fundamentales de la responsabilidad extracontractual: el daño, y que él haya sido originado por la culpa o el dolo de quien lo ha provocado. Se la llama subjetiva o por culpa, precisamente, porque la razón de existir de la obligación indemnizatoria es la actuación ilícita del agente. La razón para atribuir responsabilidad a un tercero radica en que el daño ha sido causado por su acción culpable, esto es, ha sido el resultado de una acción ejecutada con infracción a un deber de cuidado. Ese deber de cuidado puede tener dos orígenes. Puede haber sido establecido por el legislador, mediante la dictación de reglas de conducta orientadas a evitar accidentes, como ocurre en la Ley del Tránsito o en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; o bien puede ser el resultado de una regla no legisla-

da, definida por los jueces recurriendo a la costumbre o a criterios de responsabilidad. Y ocurre que, atendida la enorme plasticidad y variedad de la conducta humana, así como la cantidad de riesgos que impone la vida en sociedad, la mayor parte de estos deberes de cuidado no pueden ser definidos con exhaustividad por la ley, quedando entregada su determinación a los jueces. En esto reside una radical diferencia con la responsabilidad penal, en la cual el requisito de tipicidad excluye la posibilidad de que el ilícito sea definido en instancia judicial sin una ley anterior que describa y sancione la conducta. La observación no es incidental: explica por qué el sistema de responsabilidad por culpa puede operar sobre la base de cláusulas generales (los **artículos 2314 y 2329** del Código Civil) sin infringir garantía alguna, y por qué la culpa civil es, en definitiva, una construcción judicial. Este punto se desarrolla en el Eje 8.

1.2. Las críticas al sistema de la culpa

El sistema de responsabilidad subjetiva no ha estado exento de críticas, y conviene conocerlas porque son el antecedente histórico y dogmático de la aparición de la responsabilidad objetiva. La primera es de orden probatorio: resulta dificultoso para la víctima probar la culpa del autor del daño. La víctima, que ya ha sufrido el perjuicio, debe además acreditar una conducta ajena que por lo general no presenció ni controla, y cuya prueba se encuentra frecuentemente en poder del propio demandado. La segunda es de orden conceptual: se ha sostenido que exigir culpa en la responsabilidad civil importa confundirla con la responsabilidad moral y con la penal, en las cuales justamente se sanciona una actitud reprochable del agente; en la responsabilidad civil, en cambio, lo único que importaría es el daño ocasionado. El reproche va dirigido, pues, a la contaminación moralizante de una institución que debiera ser puramente reparatoria.

La tercera, y la que históricamente tuvo mayor fuerza, es de justicia social. El problema adquirió caracteres dramáticos en los accidentes del trabajo, en los que los obreros quedaban prácticamente desamparados para litigar en pleitos largos y engorrosos contra las empresas. Generalmente la víctima es de menores recursos que el autor del daño, y se sostiene que el legislador debe protegerla. Desde esta perspectiva se critica a la doctrina subjetiva el mirar más hacia la actuación del autor del daño que hacia la situación de la víctima, que es quien merece mayor protección.

1.3. La culpa como régimen común en el derecho chileno

No obstante esas críticas, el sistema de responsabilidad civil por culpa o negligencia constituye el régimen común de responsabilidad en el derecho nacional, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa. Así lo entiende **ALESSANDRI**, quien sostiene que el Código Civil chileno consagra la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva “en toda su amplitud”, y que no admite en caso alguno la teoría del riesgo. Su argumento es de orden histórico y conviene retenerlo porque es el que suele invocarse: no podría ser de otro modo si se considera que el Código fue dictado en una época (1855) en que nadie discutía ni ponía en duda la necesidad de la culpa o el dolo del autor del daño para comprometer su responsabilidad. Las normas que consagran la responsabilidad por culpa como regla general son los **artículos 2284, 2314 y 2329** del Código Civil. El **artículo 2284** define el delito y el cuasidelito por referencia al hecho ilícito cometido con intención de dañar y al hecho culpable cometido sin ella; el **artículo 2314** impone la obligación de indemnizar a quien ha cometido uno u otro; y el **artículo 2329** ordena reparar todo daño

que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona. Los tres, como se advierte, hacen del juicio de reproche sobre la conducta la condición de la responsabilidad. **BARROS** suscribe la misma conclusión, y precisa la razón por la cual el régimen de la culpa merece ser estudiado con prioridad: es el estatuto general y supletorio, en él se establecen las mayores exigencias, y su análisis permite comprender el de responsabilidad estricta, que si bien prescinde del requisito de la culpa, en lo demás está sujeto a reglas semejantes. La observación tiene valor práctico inmediato: el régimen objetivo no es un sistema autónomo y completo, sino el régimen general menos el elemento culpa.

1.4. Los elementos del régimen de responsabilidad por culpa

Establecido que la culpa es el régimen común, corresponde determinar cuáles son sus elementos, y aquí la doctrina nacional se divide. La discusión importa porque de ella depende el orden de la exposición y, sobre todo, la existencia o no de un juicio de antijuridicidad distinto del juicio de culpa. **ALESSANDRI**, encabezando la doctrina y la jurisprudencia tradicional, sostiene que los elementos de la responsabilidad por culpa o negligencia son cuatro: la capacidad, el dolo o la culpa, el daño y la relación de causalidad. **BARROS** coincide en los tres últimos, pero sustituye el primero: los elementos serían la acción u omisión, la culpa o el dolo, el daño y la causalidad. Su razón es que, aunque existen buenas razones para considerar la capacidad como un elemento autónomo, resulta preferible tratarla como uno de los componentes del concepto de acción, en su aspecto subjetivo. La capacidad no sería, pues, un requisito que se agrega a la conducta, sino una condición interna de ella: sin capacidad no hay propiamente acción imputable. **RODRÍGUEZ GREZ** propone una sistematización más analítica, de cinco elementos: el hecho del hombre; la antijuridicidad del mismo; la imputabilidad; el daño; y la causalidad. Para él, la antijuridicidad consiste en la contradicción entre una determinada conducta y el ordenamiento normativo considerado en su integridad, y puede ser formal (si contradice una norma expresa) o material (si consiste en una violación del orden público, las buenas costumbres y análogos). La culpa y el dolo serían, en su esquema, factores de imputabilidad subjetiva, mientras que la imputabilidad objetiva estaría basada en el riesgo creado. **BARROS** rechaza la autonomía del elemento antijuridicidad, y su fundamento es a la vez comparado y dogmático. En algunos ordenamientos la antijuridicidad sí constituye un requisito independiente de la culpa, porque para que haya lugar a la responsabilidad no basta que la negligencia haya provocado un perjuicio a un mero interés, sino que debe haberse afectado un cierto derecho subjetivo: la antijuridicidad expresa, en tales sistemas, precisamente la lesión de un derecho, y así ocurre en el **artículo 823** del Código Civil alemán. Pero en el derecho chileno esa distinción carece de sentido, porque el concepto objetivo de culpa incluye el conjunto de condiciones para dar por establecida la ilicitud: no hay un juicio de antijuridicidad separable, sino que el juicio de culpa es el juicio de ilicitud de la conducta. **CORRAL**, por su parte, sistematiza los elementos en seis, distinguiendo la capacidad delictual como presupuesto general, el hecho voluntario, la antijuridicidad, la culpabilidad, el daño y la causalidad. Es la sistematización que se seguirá en el desarrollo de la Parte II, porque tiene la ventaja de mostrar cada uno de los juicios que el tribunal debe realizar, aun cuando (como advierte **BARROS**) la separación entre antijuridicidad y culpa sea, en el derecho chileno, más analítica que sustantiva. La tensión entre estas sistematizaciones no es meramente ordenatoria, y conviene explicitarla desde ya, porque reaparecerá en el Eje 7. Quien separa antijuridicidad y culpa (**RODRÍGUEZ GREZ**, **CORRAL**) puede sostener que hay conductas objetivamente ilícitas pero no culpables, y que hay conductas culpables amparadas por una

causal de justificación. Quien las funde (**BARROS**) debe resolver esos mismos problemas dentro del juicio de culpa, tratando las causales de justificación como circunstancias que excluyen la infracción al deber de cuidado. El resultado práctico tiende a ser el mismo; lo que cambia es la arquitectura del razonamiento y, con ella, la carga argumentativa de las partes.

2. LA RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OBJETIVA

2.1. El concepto y su antecedente

A diferencia del modelo general de responsabilidad por culpa o negligencia, la responsabilidad estricta u objetiva tiene como antecedente el riesgo generado por una determinada conducta, y no la negligencia, de modo que resulta indiferente el juicio de valor respecto de la conducta del autor del daño.

En este tipo de responsabilidad, la obligación de indemnizar se impone sin necesidad de calificar la acción, bastando que el daño se produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa. En términos generales, se exige únicamente que el hecho se verifique dentro del ámbito de la actividad sujeta al régimen de responsabilidad estricta y que exista relación de causalidad entre el hecho y el daño, prescindiendo del juicio de negligencia propio del régimen de la culpa. La estructura del juicio, entonces, se reduce a dos elementos (ámbito de la actividad y causalidad), allí donde el régimen general exige cuatro. De ahí que la responsabilidad estricta presente, como observa **BARROS**, una analogía con las obligaciones de garantía del derecho contractual (tal como la obligación de saneamiento del vendedor en la compraventa, de los **artículos 1837** y siguientes del Código Civil): se establece un verdadero deber general de garantía que asegura a las potenciales víctimas que todo daño ocasionado en el ámbito de determinada actividad deberá ser reparado por quien la ejerce. La comparación es iluminadora: quien desarrolla la actividad no promete diligencia, sino indemnidad.

2.2. El fundamento: riesgo provecho y riesgo creado

En el plano dogmático, la evolución fue la siguiente. Se comenzó por contraponer a una responsabilidad objetiva indiscriminada (que se fundaba sólo en la causalidad material entre el agente y el daño) diferentes tipos de responsabilidad sin culpa, pero atribuibles a otros factores de imputación diversos del mero nexo causal. La razón de ese desplazamiento es evidente: una responsabilidad fundada en la sola causalidad material carece de todo criterio para discriminar entre las múltiples causas que concurren en cualquier accidente, y termina siendo arbitraria. El más recurrido de esos factores fue el concepto de riesgo, en sus dos versiones. Conforme al riesgo provecho, quien realiza una actividad riesgosa de la cual obtiene beneficios económicos debe responder por los perjuicios que en ella se causen: el fundamento es de correlatividad entre beneficio y carga. Conforme al riesgo creado, quien dirige una actividad que crea riesgos en su propio interés (sea o no pecuniario) debe responder de los daños causados: el fundamento ya no es el provecho, sino el control sobre la fuente del peligro. De allí que muchas veces se empleen como sinónimos los conceptos de responsabilidad objetiva y responsabilidad por riesgo. La distinción entre ambas versiones no es ociosa. El riesgo provecho supone una actividad lucrativa y explica bien la responsabilidad del em-

presario o del explotador de una instalación; el riesgo creado alcanza también a quien crea peligro sin ánimo de lucro, y explica mejor casos como el del tenedor de un animal fiero. Conviene tenerlas presentes porque, al examinar los regímenes legales de responsabilidad objetiva (Eje 17), se verá que unos se justifican mejor por una y otros por la otra.

2.3. Las críticas a la doctrina objetiva

La doctrina objetiva ha recibido, a su turno, severas críticas, que importan otras tantas defensas de la doctrina clásica. Se destaca, en primer lugar, que es peligrosa. Si bien por una parte ampara a la víctima frente al daño ocasionado, facilitándole el cobro de la indemnización, por otro lado fomentaría la existencia de nuevas víctimas: si de todos modos habrá que reparar, puede introducirse en la conciencia general la idea de que ante el derecho da igual actuar con diligencia o sin ella, ya que siempre se responderá del daño que llegue a ocasionarse. Para defenderse de esa contingencia se contratarán seguros de riesgos a terceros, todo lo cual puede conducir a un aumento de los hechos ilícitos. El argumento es, en el fondo, de desincentivo: la responsabilidad objetiva suprimiría el estímulo a la diligencia. En segundo lugar, se señala que el subjetivismo informa todo el derecho civil, el cual no puede prescindir de la consideración de las personas para adoptar un criterio meramente material del efecto producido. Y se agrega que existen numerosas instituciones de desarrollo reciente impregnadas del mayor subjetivismo (el abuso del derecho, la causa ilícita), lo que revela que la tendencia del derecho privado no es la que la doctrina objetiva supone. Finalmente, y referido al problema de la relación entre la víctima y el autor, se sostiene que no es equitativo que siempre la primera resulte indemne: debe mirarse a ambas partes, y no sancionar a quien nada ha puesto de su parte para que el accidente ocurra. Esta última crítica es la más profunda, porque no ataca la eficacia del sistema, sino su justicia: recuerda que el demandado también es una persona, y que atribuirle un daño que no pudo evitar ni con la máxima diligencia exige una razón que la sola causalidad no proporciona.

2.4. Carácter excepcional y de derecho estricto

De todo lo anterior se sigue la conclusión que domina la materia y que debe enunciarse con firmeza: la responsabilidad estricta es un régimen especial y, como tal, de derecho estricto, que opera sólo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador. Su fuente es la ley, y sólo la ley. De ahí se derivan tres consecuencias prácticas que conviene extraer expresamente. La primera es que las normas que establecen responsabilidad objetiva no admiten aplicación analógica: no puede el juez extender el régimen a actividades que le parezcan igualmente riesgosas, porque la determinación de cuáles riesgos se someten a este estatuto es una decisión que el ordenamiento reserva al legislador. La segunda es que, fuera de esos ámbitos, rige íntegramente el régimen de la culpa, con todas sus exigencias. Y la tercera es que la mayor o menor extensión de la responsabilidad estricta dentro del ordenamiento dependerá de las decisiones que adopte el legislador, pero cualquiera sea su alcance corresponderá siempre a un régimen especial, porque resulta imposible un sistema en que la responsabilidad estricta tenga carácter de régimen general. En el derecho chileno están sujetas a este régimen, entre otras, la responsabilidad del propietario del vehículo motorizado por accidentes del tránsito, la del causante de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, la del explotador de instalaciones nucleares, la del empresario de aeronaves y la del que utiliza plaguicidas. A esos estatutos legales especiales se

agregan dos normas contenidas en el propio Código Civil, provenientes del derecho romano y de formulación más bien arcaica: el **artículo 2327**, conforme al cual el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será siempre imputable a quien lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño no será oído; y el **artículo 2328** inciso primero, en su primera parte, según el cual el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, dividiéndose entre ellas la indemnización. Ambos son casos de responsabilidad estricta, precisamente porque no aceptan la prueba de la diligencia como excusa del autor del daño. El examen pormenorizado de estos regímenes corresponde al Eje 17. Conviene, por último, un apunte de derecho comparado que permite medir la extensión del régimen chileno. En otros ordenamientos la responsabilidad estricta suele aplicarse a los daños ocasionados por productos defectuosos, a los daños causados al medio ambiente y, en algunos países como Francia, a la responsabilidad por accidentes del tránsito. En el derecho nacional, en cambio, todas esas materias se rigen por el sistema general de responsabilidad por negligencia. El dato es importante para no importar acríticamente soluciones foráneas: entre nosotros, el fabricante de un producto defectuoso responde por culpa, no por garantía.

3. EL SEGURO OBLIGATORIO: UNA TÉCNICA QUE NO ES UN MODELO DE ATRIBUCIÓN

Junto a los dos modelos anteriores suele mencionarse un tercero, el del seguro privado obligatorio, que garantiza la reparación de la víctima estableciendo el deber legal, para quien realiza la actividad susceptible de causar daño o corre el riesgo de accidente, de contratar un seguro de responsabilidad. **BARROS** advierte, con razón, que este sistema no constituye propiamente un modelo de atribución de responsabilidad civil, y la precisión es dogmáticamente importante. El seguro no responde a principios de responsabilidad, sino a una obligación contractual: la obligación de indemnizar a la víctima que pesa sobre la compañía aseguradora emana del contrato de seguro, y no del hecho ilícito. En vez de una fuente de responsabilidad, el seguro opera como un crédito contractual que cede en beneficio de la víctima. De allí que, si quien está obligado a asegurar desarrolla la actividad sin cumplir ese deber, se apliquen las normas generales de responsabilidad contractual o extracontractual, según el accidente se produzca en el ámbito de un contrato (como el de trabajo) o en el de relaciones espontáneas no sujetas a contrato. La observación tiene una consecuencia que conviene retener: el seguro obligatorio desplaza, pero no sustituye, a la responsabilidad civil. Ésta conserva un carácter supletorio o residual, pues la acción de responsabilidad subsiste para perseguir la indemnización de los daños no cubiertos por el seguro y, señaladamente, del daño moral, usualmente excluido de la cobertura. El régimen de los seguros obligatorios en materia de accidentes del trabajo y de accidentes del tránsito, así como la relación entre la acción del seguro y la acción indemnizatoria, se examinan en el Eje 17.

DATO DE GRADO

Por qué conviven la culpa y el riesgo como criterios de atribución

La discusión entre ambos modelos suele presentarse como una disputa entre la protección de la víctima y la libertad del agente, pero esa formulación, siendo cierta, es demasiado gruesa. Conviene precisarla. El argumento decisivo en favor de la culpa como régimen general no es dogmático ni histórico, sino funcional, y consiste en advertir qué ocurriría si la responsabilidad estricta se generalizara. La vida en sociedad reconoce múltiples acciones que causan perjuicios y que, sin embargo, estamos razonablemente dispuestos a soportar: el éxito empresarial de algunos, respetando las reglas del mercado, suele ser sinónimo del fracaso de otros; una noticia desfavorable puede dañar el prestigio de una personalidad pública. Un ordenamiento que adoptara la responsabilidad estricta como regla general (esto es, que hiciera responder por todo daño causalmente atribuible) transformaría por completo la forma en que nos relacionamos en sociedad, pues obligaría a indemnizar perjuicios que son el precio normal de la competencia, de la crítica y de la convivencia. De ahí que, no obstante haberse definido legalmente ámbitos de responsabilidad estricta con diversa extensión en los distintos sistemas jurídicos, se tienda universalmente a preservar la responsabilidad por culpa como régimen general: porque la culpa permite contar con un criterio para discriminar entre aquellos daños que deben ser indemnizados y aquellos que debe soportar la víctima. La responsabilidad estricta, en cambio, no discrimina: sólo delimita un ámbito de actividad. Sirve, por eso, allí donde el legislador ya ha decidido que todo daño producido en cierta esfera debe ser reparado; pero no puede erigirse en criterio general, porque carecería precisamente de criterio. Esta es la razón profunda por la cual la afirmación de **ALESSANDRI** (el Código consagra la responsabilidad subjetiva en toda su amplitud y no admite en caso alguno la teoría del riesgo) conserva vigencia más allá de su fundamento histórico. **ALESSANDRI** la funda en la fecha de dictación del Código, argumento que, tomado aisladamente, sería débil: de que en 1855 nadie discutiera la exigencia de culpa no se sigue que hoy no deba discutirse. Pero la conclusión resiste, porque el sistema de la culpa no es una supervivencia decimonónica, sino el único modelo capaz de operar como estatuto general. Lo que ha ocurrido desde 1855 no es el reemplazo del modelo, sino su complementación mediante estatutos objetivos especiales, dictados por el legislador para ámbitos acotados de riesgo, tal como lo demuestra la nómina de leyes que se examinará en el Eje 17. Con todo, la oposición entre ambos modelos es menos nítida en la aplicación que en el enunciado, y esta observación (que es de **BARROS**) constituye probablemente el punto más fino del eje. Por una parte, la culpa civil se ha objetivado: el juicio de culpa no consiste en un reproche moral al autor, sino en la comparación en abstracto entre la conducta efectiva y la conducta debida, de modo que se responde aunque el agente haya obrado con toda la diligencia de que personalmente era capaz, si esa diligencia era inferior a la exigible al hombre prudente. Por otra parte, la expansión de las presunciones de culpabilidad (materia de los Ejes 9 y 14) produce una ventaja estratégica en favor del demandante y desplaza sobre el demandado la carga de acreditar su diligencia, con lo cual el resultado práctico se aproxima considerablemente al de la responsabilidad estricta. La diferencia entre una culpa presumida y una responsabilidad objetiva termina siendo, en muchos casos, más conceptual que práctica: en la primera, el juicio de antijuridicidad recae sobre la conducta; en la segunda, sobre el resultado. Pero en ambas el demandado responde a menos que acredite una circunstancia de exoneración. La conclusión que debe formularse, entonces,

es matizada y de doble filo. El derecho chileno conserva la culpa como régimen común, y ello por razones que no son de inercia histórica sino de necesidad estructural. Pero la culpa que conserva ya no es la culpa moral de la doctrina clásica, sino un estándar objetivo de conducta; y su aplicación, mediada por presunciones, produce en no pocos casos resultados que un observador externo difícilmente distinguiría de los de un régimen objetivo. El modelo es el de la culpa; la práctica se sitúa en algún punto intermedio.

4. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el planteamiento correcto del problema: la responsabilidad civil debe explicar por qué el costo de un daño se atribuye a un sujeto distinto de la víctima, siendo el punto de partida del sistema que cada cual soporta sus propios riesgos y que la pérdida queda donde cae, salvo que exista una razón jurídica para desplazarla. Los modelos de atribución son las respuestas a esa pregunta. En segundo lugar, la responsabilidad por culpa: su fundamento está en la infracción de un deber de cuidado, deber que puede provenir de la ley (Ley del Tránsito, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente) o ser determinado por el juez, dada la imposibilidad de tipificar exhaustivamente las conductas dañosas, lo que marca la radical diferencia con el derecho penal. Es el régimen común y supletorio del derecho chileno, consagrado en los **artículos 2284, 2314 y 2329** del Código Civil, y así lo sostiene **ALESSANDRI** al afirmar que el Código acoge la teoría clásica en toda su amplitud y no admite la teoría del riesgo. Deben exponerse sus críticas (dificultad probatoria para la víctima, confusión con la responsabilidad moral y penal, y la crítica de justicia social nacida al calor de los accidentes del trabajo) y sus elementos, con la discusión entre la sistematización de **ALESSANDRI** (capacidad, culpa o dolo, daño y causalidad), la de **BARROS** (acción u omisión en lugar de capacidad, negando además autonomía a la antijuridicidad porque el concepto objetivo de culpa comprende la ilicitud), la de **RODRÍGUEZ GREZ** (hecho, antijuridicidad, imputabilidad, daño y causalidad) y la de **CORRAL**, que se seguirá en el desarrollo posterior. En tercer lugar, la responsabilidad estricta: su antecedente es el riesgo y no la negligencia; el juicio se reduce a verificar que el daño se produjo dentro del ámbito de la actividad y que existe causalidad, con analogía a las obligaciones de garantía (**artículos 1837** y siguientes del Código Civil). Su fundamento dogmático se construyó sobre las nociones de riesgo provecho y riesgo creado, superando la responsabilidad puramente causal. Debe exponerse su carácter especial y de derecho estricto, con fuente exclusivamente legal y sin aplicación analógica, y citarse los casos del propio Código Civil: el **artículo 2327** sobre el animal fiero, que no oye al tenedor que alega no haber podido evitar el daño, y el **artículo 2328** inciso primero sobre la cosa que cae de un edificio. Y deben mencionarse sus críticas: el desincentivo a la diligencia, el subjetivismo que informa al derecho civil y la inequidad de hacer responder a quien nada puso de su parte para que el accidente ocurriera. En cuarto lugar, la delimitación del seguro obligatorio, que no es un modelo de atribución sino una garantía contractual en beneficio de la víctima, y que deja subsistente la responsabilidad civil con carácter residual, señaladamente respecto del daño moral. Cerrar con la tensión: la culpa se conserva como régimen general no por inercia histórica, sino porque es el único modelo capaz de discriminar entre los daños que deben indemnizarse y los que constituyen el precio normal de la vida en sociedad (el éxito de unos supone el fracaso de otros, la crítica lesiona el prestigio), en tanto que la responsabilidad estricta sólo delimita ámbitos de actividad sin proporcionar criterio alguno. Pero

debe advertirse que la oposición entre ambos modelos se atenúa en la práctica, porque la culpa se ha objetivado y las presunciones de culpabilidad desplazan la carga de la prueba, de modo que la diferencia con la responsabilidad estricta termina siendo, en muchos casos, más conceptual que práctica: en una el juicio de antijuridicidad recae sobre la conducta, en la otra sobre el resultado.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 4. Sistemas o modelos de atribución de responsabilidad**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

E. LA CAPACIDAD DELICTUAL

Antes de preguntarse si una conducta fue culpable, si causó daño o si existe relación causal, el derecho debe resolver una cuestión previa: si el autor del hecho es alguien a quien pueda atribuírsele conducta alguna. La capacidad delictual responde a esa pregunta, y por eso constituye, en la sistematización de **CORRAL** que aquí se sigue, el presupuesto general de la responsabilidad, anterior a todos los demás elementos. Su fundamento merece atención, porque es el punto en que la responsabilidad civil revela un residuo que no se deja explicar por la pura lógica reparatoria. La capacidad constituye una condición de imputabilidad, y en tal sentido muestra el carácter retributivo que conserva la institución: la imputabilidad supone que el autor sea capaz, y ello exige algún grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo que es correcto. Si la responsabilidad civil persiguiera únicamente compensar a la víctima, no se advertiría razón alguna para dejarla sin reparación cuando el daño proviene de un demente o de un niño: el perjuicio es idéntico, y el patrimonio del incapaz puede ser incluso cuantioso. Que el ordenamiento exija, pese a ello, un mínimo de discernimiento demuestra que la atribución de responsabilidad no es una operación puramente causal, sino que supone dirigirse a alguien capaz de gobernar su conducta. La capacidad es, en definitiva, la aptitud de una persona para contraer la obligación de reparar un daño. De ahí se sigue la tensión que recorre todo el eje y que conviene anunciar desde el principio: cuanto más se acentúa la función reparatoria de la responsabilidad civil, tanto más incómoda resulta la irresponsabilidad del incapaz, porque deja a la víctima sin protección por una razón que nada tiene que ver con ella. La legislación comparada, bajo el influjo de la concepción objetiva, ha tendido precisamente a abolir en mayor o menor grado esa irresponsabilidad. El derecho chileno, en cambio, la conserva, y la compensa por una vía distinta: la responsabilidad personal del guardián.

1. LA REGLA GENERAL: LA CAPACIDAD

La regla general en materia extracontractual (y lo es más ampliamente aún que en otros campos del derecho civil) es la capacidad para responder de los daños ocasionados por un hecho ilícito. Esta amplitud tiene una explicación que conviene manejar, porque permite resolver varios problemas del eje: los requisitos de capacidad contractual son más exigentes que los de la capacidad aquiliana. Y ello es lógico. Para obligarse convencionalmente se requiere aptitud para administrar el propio patrimonio y para comprender el alcance económico de un acuerdo; para responder de un hecho ilícito basta con poder discernir el límite entre lo correcto y lo incorrecto, y apreciar mínimamente el riesgo de la propia acción. Lo primero exige mucho más que lo segundo. De esta regla general se sigue una consecuencia metodológica: el estudio de la capacidad delictual se resuelve enteramente en el análisis de las incapacidades establecidas en la ley. Y una consecuencia probatoria de la mayor importancia práctica: rigiendo la presunción de capacidad, la prueba de la incapacidad corresponde a quien la alega como excusa, esto es, al demandado. En la duda, el autor del daño es tenido por capaz.

Conforme al **artículo 2319** del Código Civil, las incapacidades en materia delictual o cuasidelictual pueden reducirse a dos causas: la falta de razón o demencia y la minoría de edad.

2. LA INCAPACIDAD POR PRIVACIÓN DE RAZÓN: LOS DEMENTES

2.1. Concepto

En términos generales, demente es aquella persona privada de razón. **ALESSANDRI** precisa que son dementes quienes, al tiempo de ejecutar el hecho, están privados de la razón por causas patológicas. La expresión “demencia” es genérica: designa diversas formas de privación de la razón, y comprende condiciones tan distintas entre sí como la imbecilidad, la esquizofrenia o los extremos estados maníaco-depresivos, en la medida en que médicamente traigan consigo los efectos que enseguida se indican. **BARROS** ofrece un criterio de contenido que resulta operativo y que conviene retener, porque permite decidir casos: debe asumirse que son constitutivas de demencia las graves deficiencias en la capacidad intelectual o volitiva. Está decisivamente afectada la capacidad intelectual si la persona carece de conciencia acerca de lo correcto o de discernimiento respecto de los riesgos de su acción; y está afectada la voluntad si el sujeto no puede ejercer un control racional sobre sus propios actos. La demencia, entonces, puede consistir tanto en no comprender como en no poder gobernarse. La determinación de la privación de razón es, ante todo, una cuestión de hecho, que debe ser probada al oponerse como excepción perentoria en el juicio de responsabilidad. Pero es también, y simultáneamente, una cuestión normativa, porque el concepto jurídico de demencia no es idéntico al de la medicina. Y por esa misma razón la noción jurídica de demencia no coincide necesariamente en materia contractual y extracontractual: al igual que ocurre con la edad, el umbral de deliberación exigido por el derecho puede diferir en una y en otra.

2.2. El valor del decreto de interdicción

Este es el punto más discutido del eje, y en él la doctrina nacional se divide. El problema surge de la asimetría entre ambos estatutos. En materia contractual, el decreto de interdicción produce efectos permanentes e irrevocables: excluye la capacidad negocial sin que sea posible alegar lucidez circunstancial, según se desprende de los **artículos 456 y 465** del Código Civil. Los actos del demente interdicto son nulos aunque se pruebe que fueron ejecutados en un intervalo lúcido. La pregunta es si ese mismo efecto se produce en sede extracontractual. **BARROS** sostiene que no: en materia extracontractual el decreto de interdicción es sólo un antecedente, que podrá servir de base para una declaración judicial específica de demencia en el juicio de responsabilidad, pero que no produce efectos necesarios. Su argumento es doble. Por una parte, uno de coherencia sistemática: si los requisitos de capacidad contractual son más exigentes que los de la responsabilidad aquiliana, no puede una declaración destinada a proteger al interdicto en la administración de sus bienes proyectar automáticamente sus efectos sobre un ámbito que exige menos. Por otra, uno sustantivo y decisivo: una persona puede ser incapaz de manejar sus bienes y, sin embargo, no tener perturbada su capacidad para discernir el límite entre lo correcto y lo incorrecto. La interdicción se decreta para proteger un patrimonio; la capacidad delictual mide otra cosa. De allí la conclusión, que **BARROS** formula con la cautela de quien advierte que es contraintuitiva: al menos teóricamente, el interdicto por demencia puede ser tenido por capaz para efectos de establecer su responsabilidad extracontractual. **ALESSANDRI** sostiene lo mismo. **DUCCI** adopta una posición intermedia, y su formulación es elegante: el decreto de interdicción tendría, en sede extracontractual, el valor de una prueba pericial. No vincula al juez, pero constituye un antecedente calificado, emanado de un procedimiento en que la demencia fue judicialmente establecida con auxilio de facultativos. La dife-

rencia con la tesis de **BARROS** es de intensidad probatoria, no de naturaleza: para ambos el decreto no obliga; para **DUCCI**, sin embargo, pesa considerablemente más que un simple antecedente. **RODRÍGUEZ GREZ** se pronuncia en contra, sosteniendo que el decreto de interdicción sí produce efectos en materia extracontractual. Debe advertirse, además, un problema conexo que suele preguntarse: el de los intervalos lúcidos. Ciertos autores afirman que el demente es responsable si ha actuado en un intervalo lúcido, precisamente porque en sede extracontractual el decreto no impide alegarlo, a diferencia de lo que ocurre en materia contractual conforme al **artículo 465**. La observación es correcta en su lógica jurídica, pero conviene formularla con una prevención de orden científico: la psiquiatría moderna tiende a negar la posibilidad de que existan realmente esas “lagunas de cordura” dentro de una enfermedad mental. El intervalo lúcido es, en buena medida, una construcción jurídica decimonónica sin correlato clínico, de modo que la discusión, siendo dogmáticamente pertinente, tiene menos rendimiento práctico del que su extensión doctrinaria sugiere. La tensión de fondo entre estas posiciones no es exegética, sino conceptual, y explicitarla es lo que distingue una buena respuesta. Quien sostiene que el decreto de interdicción vincula al juez civil está tratando la demencia como un estado (una condición jurídica declarada, estable, oponible). Quien sostiene que es un mero antecedente está tratando la demencia como un hecho que debe verificarse en el momento preciso de la ejecución del acto dañoso. Y la ley se inclina por lo segundo: el **artículo 2319** no exige interdicción alguna, sino privación de razón; y el propio **ALESSANDRI** define al demente como aquel que, al tiempo de ejecutar el hecho, está privado de razón. La capacidad delictual no se declara: se constata, y se constata respecto de un momento determinado.

2.3. Requisitos de la demencia como causal de exoneración

Para que la demencia excluya la imputabilidad se requiere que concurren los siguientes requisitos. Que sea actual. La discapacidad mental es, por lo general, una situación permanente, pero lo jurídicamente relevante es que al momento de ejecutarse el hecho el agente estuviera imposibilitado de deliberar normalmente. Este requisito es la traducción práctica de todo lo dicho a propósito del decreto de interdicción: lo que se juzga es un estado en un instante, no una condición declarada.

Que sea total. El sujeto debe estar absolutamente impedido de darse cuenta del acto y de sus consecuencias, hasta el punto de no poder determinar su voluntad conforme al conocimiento adquirido. Una perturbación parcial, que deje subsistente un mínimo de discernimiento sobre lo correcto y sobre el riesgo, no basta para exonerar. Que no sea imputable a la voluntad del sujeto. Este requisito no es generalmente admitido por los autores, y conviene exponerlo con esa reserva. Sin embargo, la regulación que el Código Civil hace de la situación del ebrio revela un principio general en la materia, y de ella puede inducirse la exigencia: no puede excusarse con la privación de razón quien se ha colocado voluntariamente en ese estado.

2.4. La ebriedad y la intoxicación

El **artículo 2318** del Código Civil dispone que el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito. La norma es tajante, y su fundamento es el que acaba de anunciarse: la responsabilidad del ebrio, pese a la privación de razón que eventualmente se sigue de su estado, se funda en que la ebriedad le es imputable, porque proviene de un acto voluntario. Es la aplicación civil del

principio de la *actio liberae in causa*: la conducta libre no es la que causó el daño, sino la que produjo el estado en que el daño se causó, y en esa conducta anterior se sitúa el reproche. De este fundamento se extrae la conclusión que la doctrina admite pese a la amplitud del precepto: el ebrio no responde si ha sido colocado en tal estado por obra de un tercero y contra su voluntad. Si la ebriedad no le es imputable, desaparece el fundamento de la norma, y la privación de discernimiento o de voluntad puede ser alegada como excepción de inimputabilidad. En tal caso la culpa corresponde a quien lo colocó en esa situación, sobre quien recae íntegramente la responsabilidad. **ALESSANDRI** precisa el alcance de la excepción con exactitud: el ebrio responde sea la ebriedad voluntaria o involuntaria, ya que el **artículo 2318** no distingue, salvo el caso de la persona a quien otro ha embriagado contra su voluntad por fuerza o por engaño, y siempre que la embriaguez le haya privado totalmente de razón. Nótese que la excepción exige, entonces, dos condiciones copulativas: que la ebriedad haya sido provocada por un tercero mediante fuerza o engaño, y que la privación de razón resultante haya sido total. Tanto **ALESSANDRI** como **DUCCI** sostienen, además, que aunque el **artículo 2318** se refiere solamente al ebrio, la norma se extiende por analogía a casos análogos, esto es, a todo aquel que comete un hecho ilícito durante un estado de privación de razón producido por una droga o por cualquier otra intoxicación. La solución es correcta: el precepto no consagra una regla sobre el alcohol, sino sobre la privación voluntaria de la razón. La jurisprudencia ha aplicado el criterio con precisión. La Corte Suprema, en fallo de 10 de octubre de 1985, conoció del caso de quien había participado en un robo tras haber ingerido alcohol al que su coautor había mezclado subrepticamente alcaloides y anfetaminas. El tribunal concluyó que el sujeto había participado en el hecho privado parcialmente de razón por causas independientes de su voluntad, precisamente porque la intoxicación no le era imputable: no se había colocado él en ese estado, sino que había sido colocado en él sin saberlo. El fallo confirma, entonces, que el fundamento del **artículo 2318** es la imputabilidad del estado, y no una regla de rigor objetivo contra el ebrio.

3. LA INCAPACIDAD POR MINORÍA DE EDAD

3.1. Las dos reglas del artículo 2319

El **artículo 2319** comprende dos reglas de estructura distinta, y conviene no confundirlas. Conforme al inciso primero, no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años, esto es, los infantes, según la definición del **artículo 26** del Código Civil. Se trata de una incapacidad absoluta y de pleno derecho: no admite prueba en contrario, y el juez carece de toda facultad de apreciación. El infante no responde nunca, por hábil que haya sido su conducta o por evidente que resulte que comprendía lo que hacía. Conforme al inciso segundo, tratándose de los mayores de siete y menores de dieciséis años, la inimputabilidad se determina judicialmente caso a caso: queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento. Aquí no hay incapacidad, sino una posibilidad de incapacidad sujeta a apreciación. De la combinación de ambas reglas resulta el esquema que debe retenerse: la plena capacidad delictual se adquiere a los dieciséis años, pero puede extenderse hacia atrás, hasta los siete, si el juez estima que el menor obró con discernimiento. Entre los siete y los dieciséis, en consecuencia, la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, pues, conforme al principio general ya enun-

ciado, en la duda el menor es tenido por responsable, salvo que se acredite su falta de discernimiento.

3.2. El contenido del discernimiento

¿Qué debe entenderse por discernimiento? **BARROS** ofrece el criterio, y es el mismo que rige para el demente: basta que el menor sea capaz de discernir la corrección y el riesgo que suponía su acción. En la responsabilidad por culpa, el discernimiento supone la capacidad para comprender que un acto es ilícito, junto a una mínima aptitud de apreciación del riesgo. La aplicación de ese criterio admite una regla práctica muy útil. La comprensión exigida puede presumirse respecto de acciones cuya incorrección es intuitivamente conocida por niños de la misma edad: un niño de diez años sabe que no debe arrojar piedras a quien pasa por la calle. A la conclusión contraria llegará razonablemente el juez si se trata de riesgos que el niño no está en condiciones de valorar. **BARROS** ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo: el de un niño de ocho años que, sin haber estado sujeto a experiencia tecnológica previa, presiona por curiosidad una tecla cualquiera de un computador que está a su alcance y borra información valiosa. El niño comprende perfectamente que no debe tocar lo ajeno, pero no está en condiciones de representarse la magnitud ni la naturaleza del riesgo que su acción envuelve. De aquí se sigue una precisión conceptual de la mayor importancia, y que suele ser objeto de confusión en el examen. El discernimiento sólo puede juzgarse en concreto, atendiendo a las particulares circunstancias del niño y del riesgo de que se trate. Pero, una vez despejada la pregunta por la capacidad, el estándar de cuidado que debía observarse en la situación de riesgo es una cuestión que pertenece al juicio de culpa, y ese juicio tiende a plantearse con prescindencia de las peculiaridades subjetivas del autor del daño. Es decir: se pregunta en concreto si este niño podía comprender la ilicitud y el riesgo; pero, establecido que podía, se le compara en abstracto con el estándar de conducta exigible. La subjetividad opera en el umbral de la capacidad, no en el juicio de culpa. Esta distinción se retomará en el Eje 8.

3.3. La crítica al juicio de discernimiento

El juicio de discernimiento es, en definitiva, una facultad prudencial del juez de la causa, expresiva de la liberalidad del derecho civil en materia de capacidad. Y esa discrecionalidad ha sido objeto de una crítica que conviene conocer, porque proviene de la evolución de otra rama del ordenamiento. **BARROS** observa que el ejercicio por el juez civil de la facultad de efectuar un juicio de discernimiento es casi desconocido en la práctica. Y añade un argumento comparativo de considerable peso: en materia penal el sistema del discernimiento fue abandonado como mecanismo para determinar la capacidad, por estimarse demasiado impreciso, de muy difícil determinación y por otorgar una facultad jurisdiccional excesivamente discrecional; así lo declaró el Mensaje presidencial que propuso su supresión. La deficiencia, concluye **BARROS**, parece extensible al ámbito civil. La incidencia real es que la doctrina y la jurisprudencia civiles han independizado por completo el concepto de discernimiento civil del penal, entendiéndolo simplemente como la aptitud del menor para percatarse del impacto perjudicial de su conducta, lo que permite que los menores de dieciséis años (pero mayores de siete) respondan civilmente si cuentan con patrimonio propio. La observación deja planteada una cuestión que el examinando puede aprovechar para cerrar con altura: si el discernimiento fue abandonado en sede penal por impreciso y arbitrario, y si en sede civil prácticamente no se ejerce, cabe preguntarse qué función cumple realmente el inciso segundo del

artículo 2319. La respuesta más plausible es que opera menos como filtro efectivo que como válvula de escape: una facultad que el juez conserva para los casos extremos, y que precisamente por su carácter excepcional rara vez utiliza.

3.4. La jurisprudencia sobre capacidad del menor

La jurisprudencia nacional ha sido tradicionalmente severa, y ha tendido a reconocer capacidad a menores de corta edad cuando el riesgo era intuitivamente comprensible. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 20 de junio de 1861, tuvo por responsable a un menor de doce años que dio muerte a una persona utilizando un arma de fuego. El fundamento de la decisión es especialmente ilustrativo del criterio que se ha expuesto: se le imputó no haber evitado la dirección del arma cargada hacia la víctima en el momento en que ésta pasaba frente a él. Esto es, el tribunal no discutió si el menor comprendía la teoría de la ilicitud, sino si estaba en condiciones de representarse el riesgo evidente que envuelve un arma cargada apuntada hacia una persona. Y lo estaba. La Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 9 de octubre de 1939, resolvió que comete cuasidelito el menor de doce años que atropella con el automóvil que conduce (sin contar con la autorización competente ni con la edad requerida por los reglamentos) a una persona, causándole la muerte. El fundamento vuelve a ser el mismo: quien conduce un vehículo sabiendo que no puede ni debe hacerlo está en condiciones de comprender el riesgo que genera. **ALESSANDRI** y **DUCCI** concuerdan con esta línea jurisprudencial.

3.5. La tendencia comparada

Bajo el influjo de la concepción objetiva de la responsabilidad, la legislación contemporánea tiende a abolir, en mayor o menor grado, la irresponsabilidad del incapaz, y conviene conocer las tres técnicas empleadas, porque muestran soluciones graduales al mismo problema. Algunas legislaciones establecen una responsabilidad subsidiaria: el incapaz debe reparar el daño cuando la reparación no ha podido obtenerse de quien lo tiene a su cuidado; tal es la solución del Código alemán. Otras confieren al juez una facultad de equidad: puede condenar al incapaz cuando la equidad lo exija, como ocurre en el Código suizo de las obligaciones. Y otras, finalmente, hacen al incapaz plenamente responsable, como el Código mexicano. El derecho chileno no ha seguido ninguno de esos caminos: mantiene íntegra la irresponsabilidad del incapaz. Y esa opción tiene una consecuencia dura que debe enunciarse sin eufemismos: frente al hecho de un incapaz, la víctima queda en principio privada de reparación, a menos que logre acreditar la negligencia de quien lo tenía a su cargo. La protección de la víctima no se obtiene, entre nosotros, alcanzando el patrimonio del incapaz, sino el del guardián, y sólo si éste fue negligente.

4. LA RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN DEL INCAPAZ

4.1. La regla del artículo 2319 inciso primero

En materia de responsabilidad, el término guardián designa a la persona que tiene a su cargo a otra o a una cosa y debe vigilarla; si no cumple ese deber, es responsable de los daños que ocasione esa persona o cosa, y su culpa consiste precisamente en haber faltado a dicha obligación. Así ocurre

con los incapaces. El **artículo 2319** inciso primero, tras declarar la incapacidad del demente y del infante, agrega que serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia. La frase final es decisiva y debe subrayarse: la responsabilidad del guardián no se presume; la víctima debe probar su negligencia.

4.2. Naturaleza: responsabilidad por el hecho propio

Este es el punto técnicamente más fino del eje, y su dominio distingue una respuesta completa. La responsabilidad del guardián del **artículo 2319** no es responsabilidad por el hecho ajeno. Es responsabilidad directa, personal y exclusiva por el hecho propio. La razón es rigurosa: como el incapaz no puede cometer hecho ilícito alguno (le falta el presupuesto de la capacidad), no hay hecho ajeno del cual responder. Lo que hay es un hecho propio del guardián, consistente en la infracción de su deber de vigilancia. El daño no es jurídicamente atribuible al incapaz, sino precisamente a quien lo tenía bajo su cuidado. De allí se sigue una diferencia doble con la responsabilidad por el hecho ajeno del **artículo 2320**, que conviene formular con precisión porque es la comparación que suele pedirse. En primer lugar, en el **artículo 2319** no hay hecho ilícito del incapaz, pues falta el requisito de la capacidad; lo hay únicamente del guardián, por su negligencia. En el **artículo 2320**, en cambio, existen dos responsabilidades: la de quien actúa provocando el daño (que debe probarse) y la de quien lo tiene bajo su dependencia o cuidado (que se presume); y ambos son perfectamente capaces. Así lo ha exigido expresamente la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 3 de junio de 1973, al declarar que la responsabilidad por el hecho ajeno requiere, entre otros requisitos, que ambas personas sean capaces de delito o cuasidelito. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, en la responsabilidad indirecta del **artículo 2320** se presume la culpa del responsable por el hecho ajeno, correspondiendo a él probar su ausencia de culpa; mientras que tratándose del hecho de un incapaz, la víctima debe probar la negligencia del guardián. La diferencia de régimen probatorio es sustancial, y a primera vista podría parecer injusta y odiosa (el guardián de un incapaz queda en mejor posición procesal que el padre de un adolescente capaz), pero responde a una diferencia estructural verdadera: en un caso se le imputa al demandado responder por la culpa de otro que también responde; en el otro, se le imputa una culpa exclusivamente suya, que como toda culpa debe ser probada por quien la alega. Conviene advertir, con todo, que la doctrina reconoce que ambos regímenes obedecen a una misma lógica de fondo, tal como lo ha expresado la Corte Suprema, en fallo de 29 de agosto de 1974, al declarar que quien responde por el hecho de otro satisface la indemnización no propiamente por el hecho ilícito ajeno, sino por su descuido personal como cuidador o empleador que debía estar vigilante del correcto desempeño de quienes se encuentran bajo su guarda o dependencia. La responsabilidad por el hecho ajeno es, en su fundamento, también responsabilidad por culpa propia; lo que la distingue del **artículo 2319** no es su naturaleza última, sino la técnica probatoria y la subsistencia de la responsabilidad del autor directo.

4.3. Ausencia de acción de reembolso

El guardián soporta definitivamente la indemnización: no puede repetir contra el incapaz. La conclusión se deduce a contrario sensu del **artículo 2325** del Código Civil, que confiere derecho a pedir restitución de lo pagado únicamente respecto de quien era capaz de delito o cuasidelito según el **artículo 2319**. ALESSANDRI explica el fundamento con claridad, y su razonamiento cierra cohe-

rentemente todo el sistema: el guardián que ha sido condenado a reparar el daño causado por el incapaz carece de derecho a ser indemnizado sobre los bienes de éste, aunque los tenga, porque está respondiendo de su propia culpa (consistente en la falta de vigilancia o cuidado del incapaz) y no de una culpa ajena; y no sería justo hacer recaer sobre el incapaz las consecuencias de una culpa que no es suya. La coherencia del sistema queda así demostrada: si el guardián respondiera por hecho ajeno, tendría acción de reembolso, como la tiene el tercero civilmente responsable del **artículo 2320**; pero como responde por hecho propio, no la tiene. La ausencia de repetición no es una asperreza de la ley: es la consecuencia necesaria de la naturaleza de su responsabilidad.

DATO DE GRADO**El criterio de capacidad tras el abandono del discernimiento penal**

El eje encierra una tensión estructural que conviene formular explícitamente, porque atraviesa todas sus cuestiones particulares.

La exigencia de capacidad es un residuo retributivo dentro de un sistema que, según se vio en el Eje 1, tiene por fin primordial la reparación. Si lo que importa es dejar indemne a la víctima, la aptitud de deliberación del autor debiera ser jurídicamente irrelevante: el daño causado por un demente duele igual y cuesta lo mismo que el causado por un hombre prudente. Que el derecho exija, pese a ello, un mínimo de discernimiento significa que la responsabilidad civil no ha renunciado del todo a dirigirse a un sujeto capaz de gobernarse, y que la atribución del daño supone algo más que la mera causalidad. Ahí reside la incomodidad del elemento, y ahí se explica que la legislación comparada (bajo el influjo de la concepción objetiva) tienda a suprimirlo o a atenuarlo mediante responsabilidades subsidiarias o de equidad. Ahora bien, el derecho chileno resuelve esa tensión de un modo peculiar, y comprenderlo es la clave del eje: no rebaja el umbral de capacidad, pero lo compensa en dos direcciones. Por una parte, fija ese umbral extraordinariamente bajo (basta discernir la corrección y el riesgo, mucho menos de lo que exige la capacidad negocial), con lo cual la irresponsabilidad por incapacidad queda reducida a hipótesis marginales; y aún dentro de esas hipótesis, hace responder al menor de dieciséis años salvo que se pruebe su falta de discernimiento, y priva de excusa al ebrio. Por otra parte, cuando la incapacidad efectivamente concurre, traslada la responsabilidad al guardián, aunque no le presume la culpa. De ahí que la discusión sobre el decreto de interdicción adquiera su verdadero sentido. Sostener, como **RODRÍGUEZ GREZ**, que la interdicción vincula al juez civil equivale a ampliar el ámbito de la irresponsabilidad: el interdicto no responde nunca, y la víctima queda entregada a la prueba, difícil, de la negligencia del guardián. Sostener, con **ALESSANDRI** y **BARROS**, que el decreto es un mero antecedente equivale a restringir esa irresponsabilidad al caso en que la privación de razón se acredite al tiempo del hecho y respecto de la aptitud específica de discernir lo correcto de lo incorrecto. La segunda solución es preferible, y no sólo por su coherencia con la mayor exigencia de la capacidad contractual: es preferible porque la interdicción persigue proteger el patrimonio del interdicto frente a sus propios actos, y sería paradójico que un instituto establecido en su favor terminara operando en perjuicio de terceros inocentes, privándolos de reparación por una declaración judicial ajena al hecho dañoso y anterior a él. Con todo, la solución chilena tiene un costo que no debe ocultarse, y señalarlo es una forma legítima de cerrar críticamente el eje: cuando el incapaz es efectivamente incapaz y el guardián no fue negligente, la víctima no obtiene reparación alguna. El daño queda donde cayó. Es la aplicación consecuente del principio examinado en el Eje 4 (a falta de razón jurídica para atribuirlo a un tercero, la pérdida permanece en la víctima), pero es también el punto en que ese principio resulta más difícil de justificar ante quien lo padece. Las soluciones del Código alemán (responsabilidad subsidiaria del incapaz) y del Código suizo (condena por equidad) son, precisamente, respuestas a ese costo.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir señalando que la capacidad es una condición de imputabilidad que revela el carácter retributivo que conserva la responsabilidad civil, pues supone un mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo correcto; y definirla como la aptitud para contraer la obligación de reparar un daño.

En segundo lugar, la regla general: en materia extracontractual la capacidad es la regla, y con mayor amplitud que en otros campos, porque los requisitos de la capacidad aquiliana son menos exigentes que los de la capacidad contractual. De ello se sigue que el estudio se reduce al análisis de las incapacidades legales y que la prueba de la incapacidad corresponde a quien la alega como excusa. Conforme al **artículo 2319** del Código Civil, las causales son dos: la privación de razón y la minoría de edad. En tercer lugar, la demencia: concepto (privación de razón por causas patológicas al tiempo de ejecutar el hecho, según **ALESSANDRI**; graves deficiencias en la capacidad intelectual o volitiva, según **BARROS**); su carácter de cuestión de hecho y a la vez normativa; y los requisitos de que sea actual, total y no imputable a la voluntad del sujeto. Debe exponerse aquí la discusión sobre el decreto de interdicción: mientras en materia contractual produce efectos permanentes e irrevocables, sin que quepa alegar lucidez circunstancial (**artículos 456 y 465** del Código Civil), en sede extracontractual **ALESSANDRI** y **BARROS** sostienen que constituye un mero antecedente, de modo que el interdicto puede ser tenido por capaz; **DUCCI** le atribuye el valor de una prueba pericial; y **RODRÍGUEZ GREZ** se pronuncia en contra. El argumento decisivo es que una persona puede ser incapaz de administrar sus bienes y conservar, sin embargo, la aptitud para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. En cuarto lugar, la ebriedad: el **artículo 2318** del Código Civil declara responsable al ebrio, y el fundamento es la *actio liberae in causa*, esto es, que el estado le es imputable por provenir de un acto voluntario. De allí que no responda quien fue embriagado por un tercero mediante fuerza o engaño y quedó totalmente privado de razón (así lo precisa **ALESSANDRI**), y que la norma se extienda por analogía a la intoxicación por drogas. Puede citarse el fallo de la Corte Suprema de 10 de octubre de 1985, que eximió a quien actuó bajo el efecto de alcohol adulterado subrepticamente por un tercero con alcaloides y anfetaminas, por hallarse privado de razón por causas independientes de su voluntad. En quinto lugar, la minoría de edad: son absolutamente incapaces los infantes, esto es, los menores de siete años (**artículos 2319** inciso primero y 26 del Código Civil); y respecto de los mayores de siete y menores de dieciséis, queda a la prudencia del juez determinar si obraron sin discernimiento (**artículo 2319** inciso segundo). La plena capacidad se adquiere, pues, a los dieciséis años, con la advertencia de que en la duda el menor es tenido por capaz. El discernimiento consiste en la aptitud para comprender la ilicitud del acto y para apreciar mínimamente su riesgo, y se juzga en concreto, a diferencia del estándar de cuidado, que se aprecia en abstracto. Puede citarse la jurisprudencia tradicional, que condenó al menor de doce años que dirigió un arma cargada hacia la víctima (Corte de Apelaciones de Santiago, 20 de junio de 1861) y al menor de doce años que atropelló causando la muerte conduciendo sin autorización ni edad reglamentaria (Corte de Apelaciones de Concepción, 9 de octubre de 1939). Y debe mencionarse la crítica de **BARROS** al juicio de discernimiento, por impreciso y excesivamente discrecional, apoyada en que el sistema fue abandonado en sede penal por esas mismas razones. En sexto lugar, la responsabilidad del guardián (**artículo 2319** inciso primero): responden los que tienen al incapaz a su cargo si pudiere imputárseles negligencia, la que debe ser probada por la víctima. Su naturaleza es de responsabilidad directa y por el hecho propio, y no por el hecho ajeno, porque el incapaz no comete ilícito alguno: lo que se sanciona es la infracción del

deber de vigilancia. De ello se siguen las dos diferencias con el **artículo 2320** (allí hay dos responsables y ambos capaces, y la culpa del tercero se presume) y la ausencia de acción de reembolso contra el incapaz, que se deduce a contrario sensu del **artículo 2325**, y que **ALESSANDRI** explica señalando que el guardián responde de su propia culpa y no sería justo hacer recaer sus consecuencias sobre el incapaz. Cerrar con la tensión: la exigencia de capacidad es un residuo retributivo en un sistema orientado a la reparación, y por eso el derecho comparado tiende a atenuarla mediante responsabilidades subsidiarias (Código alemán) o de equidad (Código suizo). El derecho chileno la conserva, pero fija el umbral muy bajo y traslada la responsabilidad al guardián; el costo de esa opción es que, si el incapaz es realmente incapaz y el guardián no fue negligente, la víctima no obtiene reparación alguna y el daño queda donde cayó.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 5. La capacidad delictual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

F. EL HECHO VOLUNTARIO. CASO FORTUITO Y PERSONAS JURÍDICAS

Despejada la capacidad, el juicio de responsabilidad debe verificar que exista conducta (y conducta atribuible a una voluntad). Éste es el segundo elemento en la sistematización que se sigue, y su formulación es la siguiente: la responsabilidad tiene por antecedente el acto humano, esto es, el hecho voluntario. No hay propiamente responsabilidad si no existe un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto, la que puede consistir en un hecho positivo (una acción) o en uno negativo (una omisión). El principio está recogido en nuestro derecho, y en particular en los **artículos 1437, 2284, 2314 y 2329** del Código Civil. El **artículo 1437** hace nacer obligaciones del hecho que ha inferido injuria o daño; el **artículo 2284** se refiere a las obligaciones que nacen del hecho voluntario de una de las partes, distinguiendo, según haya o no intención de dañar, el delito del cuasidelito; el **artículo 2314** obliga a indemnizar a quien ha cometido un delito o cuasidelito; y el **artículo 2329** manda reparar todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona. Los cuatro presuponen, como se advierte, un hacer humano libre. Dentro del hecho voluntario es posible distinguir dos elementos, y la distinción organiza todo el eje. Uno de carácter externo, consistente en la conducta del sujeto, que corresponde a su dimensión material, y que se manifiesta en la acción o en la omisión. Otro de carácter interno, referido a la voluntariedad, que expresa su dimensión subjetiva: la conducta sólo es voluntaria en la medida en que puede ser imputada a una persona como acción u omisión libre, lo cual supone que el autor tenga discernimiento. De aquí resulta una advertencia metodológica de importancia. Al examinar la capacidad delictual (Eje 5) se estudió, en rigor, la dimensión subjetiva del hecho voluntario en su aspecto permanente: quién es, en general, apto para responder. Corresponde ahora examinar los casos en que ese sujeto, siendo capaz, ha obrado sin voluntad en el caso concreto; y, sobre todo, los casos en que el daño no puede reconducirse a conducta humana alguna, que es lo propio del caso fortuito. La diferencia entre ambos planos (incapacidad e involuntariedad) no es meramente teórica, según se verá.

Conviene, por último, una precisión que delimita el campo. La ley puede imponer obligaciones que tengan por antecedente un hecho no voluntario: así ocurre con las obligaciones tributarias, o con la obligación de proporcionar alimentos a ciertas personas, que a menudo tienen como referente hechos puramente naturales, como el nacimiento o la muerte. En ninguno de esos casos puede hablarse de responsabilidad: se trata, como señala el propio **artículo 1437** del Código Civil, de obligaciones cuya fuente es la ley. Sólo una vez incumplidas esas obligaciones se da lugar a una acción de responsabilidad, y ello reconduce al problema del derecho común examinado en el Eje 3.

1. LA DIMENSIÓN MATERIAL: ACCIÓN Y OMISIÓN

Por regla general, los daños relevantes para el derecho son los producidos a consecuencia de una acción. La omisión, en cambio, se configura cuando el deber general de cuidado prescribía al agente asumir una determinada conducta y éste no la realizó. La asimetría entre una y otra no es casual, y su fundamento debe enunciarse desde ya, aunque su desarrollo corresponda al Eje 8. La pura omisión está sujeta a requisitos particularmente exigentes para dar lugar a responsabilidad: se requiere la existencia de un deber especial de actuar en beneficio de otro. La razón es evidente si se recuerda el principio examinado en el Eje 4: quien nada hace no crea riesgo alguno, de modo

que hacerlo responder por un daño que no provocó exige una razón adicional (un deber previo de intervenir) que la mera abstención no proporciona. De no ser así, todos seríamos responsables de todos los males que pudimos evitar y no evitamos, lo que suprimiría la libertad de acción que la responsabilidad civil está llamada a garantizar. Por eso el juicio de culpabilidad de una omisión, entendido como ilicitud o infracción de un deber de cuidado, plantea cuestiones diversas de las que suscita la acción, y por eso se estudia separadamente.

2. LA DIMENSIÓN SUBJETIVA: EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE VOLUNTAD

La doctrina suele asimilar a la demencia ciertos estados transitorios de pérdida del uso de la razón, como el de quien actúa bajo hipnosis o en estado de sonambulismo. **CORRAL** objeta esa asimilación, y su objeción es dogmáticamente correcta. Estos casos no deben asimilarse a la demencia, porque la demencia es una causal de incapacidad y, como tal, califica a una persona de un modo permanente. Los estados transitorios de falta de uso de razón son, más bien, causales de exoneración por falta de voluntariedad de la acción. La distinción, que podría parecer una sutileza terminológica, tiene consecuencias prácticas relevantes que conviene extraer. Si el sonámbulo fuese tratado como un incapaz, se estaría afirmando que carece de aptitud para responder, lo que proyectaría efectos sobre toda su actuación y abriría paso, además, a la responsabilidad de un eventual guardián conforme al **artículo 2319** inciso primero. Si, en cambio, se lo trata como un sujeto plenamente capaz que en el caso concreto obró sin voluntad, lo que se niega no es su aptitud, sino la existencia misma de una acción imputable: falta el hecho voluntario, y con él, el presupuesto de todo el juicio de responsabilidad. La capacidad califica al sujeto; la voluntariedad califica al acto.

3. EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

3.1. Concepto

El **artículo 45** del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto a que no es posible resistir, y ofrece como ejemplos un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. En materia extracontractual se aplica el mismo concepto que rige en el ámbito contractual, pero su función es distinta, y esa diferencia constituye el punto más fino de esta sección. En materia contractual, la fuerza mayor actúa como un concepto distinto del de la mera ausencia de culpa: el deudor de una obligación de resultado no se libera probando diligencia, sino acreditando un hecho que hizo imposible el cumplimiento. En materia extracontractual, en cambio, la situación es análoga a la de las obligaciones de medio, pues la ausencia de culpa excluye por sí sola la ilicitud. De ahí que, en sede aquiliana, baste probar la ausencia de culpa para eliminar la responsabilidad, sin necesidad de acreditar caso fortuito alguno. Surge entonces la pregunta que da sentido a la institución: si basta con probar diligencia, ¿para qué sirve el caso fortuito en materia extracontractual? La respuesta de **BARROS** es que la fuerza mayor no opera en sede de culpa, sino de causalidad. Su función propia consiste en excluir la atribución del daño aunque haya intervenido un acto culpable: el daño no resulta imputable a ese acto culpable, sino al caso fortuito. El ejemplo con que **BARROS** ilustra el punto es espe-

cialmente claro y conviene retenerlo. Un automovilista cruza la línea continua y choca con otro vehículo: hay, sin duda, culpa infraccional. Pero si esa infracción se produjo porque intentaba esquivar a un peatón que se cruzó imprevistamente, o porque el conductor sufrió un ataque cardíaco imprevisto, entonces el evento determinante del daño es el caso fortuito y no la culpa del agente directo. Nótese que la culpa infraccional subsiste (la línea continua fue cruzada); lo que falla es la atribución del daño a esa culpa. He aquí, precisamente, la utilidad de la institución.

3.2. La ubicación dogmática del caso fortuito

La cuestión de dónde situar el caso fortuito dentro de la estructura de la responsabilidad ha dividido a la doctrina, y conviene exponer las posiciones porque de ellas dependen consecuencias prácticas. Cierta doctrina afirma que el caso fortuito constituye una causal de exoneración por falta de antijuridicidad, o de culpa, o de nexo causal entre el hecho y el daño. **CORRAL** sostiene que lo más propio es ubicarlo como causal de supresión de la voluntariedad del hecho: cuando un daño se produce por caso fortuito, en rigor no puede ser vinculado a una voluntad humana. De ahí que se estudie, en la sistematización que aquí se sigue, dentro del hecho voluntario. **ALESSANDRI**, por su parte, lo incluye entre las que denomina eximentes de responsabilidad, junto a la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. Sobre esta clasificación debe formularse, sin embargo, una prevención: si bien todas esas causales determinan la inexistencia de responsabilidad, no lo hacen por la vía de excluir la ilicitud, sino actuando sobre otros elementos de la responsabilidad por negligencia, como la voluntariedad del acto. Ubicarlas entre las causales de justificación (según se verá en el Eje 7) sería, pues, un error de sistematización: no justifican una conducta ilícita; niegan que haya conducta, o que el daño le sea atribuible. **BARROS**, según se ha visto, lo sitúa derechamente en sede de causalidad. La tensión entre estas posiciones no es puramente ordenatoria, y explicitarla rinde en el examen. Si el caso fortuito se concibe como ausencia de culpa, entonces al demandado le basta acreditar que obró con la diligencia debida, y la institución se vuelve superflua en sede extracontractual. Si se lo concibe como supresión de la voluntariedad (**CORRAL**), se explica bien el caso del hecho de la naturaleza, pero mal el del automovilista que sí obró voluntariamente y hasta culpablemente. Y si se lo concibe como exclusión de la causalidad (**BARROS**), se explican todos los casos, incluidos aquellos en que concurre culpa del agente y, sin embargo, no responde. Esta última construcción es la más completa, y es también la que mejor da cuenta de la función que el caso fortuito cumple en los regímenes de responsabilidad estricta, donde el juicio de culpa está excluido por definición y, no obstante, la fuerza mayor conserva eficacia exoneratoria.

3.3. Los elementos del caso fortuito

Los elementos del caso fortuito o fuerza mayor son tres: la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la exterioridad. La Corte Suprema, en fallo de 9 de septiembre de 1992, los recogió al declarar que de la definición legal resulta necesaria la concurrencia, a lo menos, de un hecho imprevisto, irresistible para el deudor, y que no haya sido desencadenado por el hecho propio. La irresistibilidad. El carácter de irresistibilidad se expresa con claridad en el concepto mismo de fuerza mayor: lo que se exige es que se trate de un evento insuperable, cuyas consecuencias no sea posible evitar. El punto decisivo es cómo se mide esa imposibilidad, y aquí la doctrina es unánime: el límite de la irresistibilidad está dado por el deber de diligencia del actor, en forma similar a lo que ocurre con

la obligación contractual de medio. La irresistibilidad, entonces, no se mide en abstracto contra la naturaleza, sino en función del deber de cuidado que pesaba sobre el agente. La jurisprudencia ha sido exigente. La Corte Suprema, en fallo de 20 de junio de 1949, declaró que el hecho es irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias en términos tales que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo y evitarlo. El estándar es, pues, el del hombre prudente colocado en idéntica situación, y no el de las capacidades personales del demandado. En el mismo sentido se pronunció la Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 7 de noviembre de 1985, al sostener que la imposibilidad de prever o resistir el acontecimiento debe ser absoluta, y que una imposibilidad meramente relativa (que sólo diga relación con el autor, que únicamente a él afecte y no a otra persona colocada en la misma situación) le resta al acto el carácter de imprevisto o irresistible; agregando, con una fórmula que conviene retener por su claridad, que la presentación de una dificultad que puede subsanarse por un hombre prudente jamás puede tener el carácter de caso fortuito.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Fija los tres elementos del caso fortuito: hecho imprevisto, irresistible para el deudor, y no desencadenado por el hecho propio.

CORTE SUPREMA, 20 DE JUNIO DE 1949

El hecho es irresistible cuando ni el agente ni ninguna otra persona en las mismas circunstancias habría podido preverlo y evitarlo: el estándar es el del hombre prudente, no el de las capacidades personales del demandado.

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN, 7 DE NOVIEMBRE DE 1985

La imposibilidad debe ser absoluta; una imposibilidad meramente relativa al autor le resta al hecho el carácter de irresistible.

De aquí se sigue una regla que sintetiza bien la materia: al igual que la culpa, el caso fortuito se determina en concreto, pero se juzga en abstracto. Se atiende a las circunstancias efectivas del hecho, pero se pregunta si un hombre prudente colocado en ellas habría podido preverlo y resistirlo. La imprevisibilidad. También la imprevisibilidad se sitúa en las fronteras de la culpa, y la fórmula que la expresa es la más elegante de la materia: el caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión. No se trata de algo absolutamente imprevisible, sino de algo imprevisible para el autor del daño, atendido el nivel de diligencia que le es exigible. Es, por tanto, un concepto normativo: caso fortuito es aquello que el autor no estaba obligado a prever. Los ejemplos permiten fijar el criterio. Es caso fortuito el reventón del neumático de un automóvil nuevo, o el síncope de una persona sin antecedentes cardíacos; no lo es, en cambio, un temblor de grado cinco a seis en la zona central de Chile. La diferencia no está en la probabilidad estadística del suceso, sino en si el ordenamiento exigía al agente contar con él: quien vive en un país sísmico está obligado a prever los sismos de mediana intensidad, y quien conduce un vehículo nuevo no está obligado a prever la falla de un

neumático sin defecto conocido. La jurisprudencia ha aplicado exactamente ese criterio en un caso ilustrativo. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 10 de septiembre de 1940, conoció de la muerte de un transeúnte golpeado en la cabeza por un trozo de mampostería que se desprendió y cayó desde lo alto de un edificio. El tribunal razonó que, tratándose de un país como Chile, en el que son frecuentes los movimientos terrestres, no puede sostenerse que los temblores de mediana intensidad constituyan un imprevisto irresistible que configure fuerza mayor; y concluyó, en consecuencia, que la construcción y el cuidado de los edificios deben llegar hasta la adopción de todas las medidas que la prudencia aconseja para evitar daños a terceros por su deterioro. El fallo es un excelente ejemplo de cómo la imprevisibilidad se define por referencia al deber de cuidado: el temblor no exoneró, precisamente porque el deber de previsión del propietario lo comprendía. La exterioridad. El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente. Este requisito es el verdaderamente constitutivo del caso fortuito, pues pertenece al terreno de la estricta causalidad, mientras que los dos anteriores (irresistibilidad e imprevisibilidad) pueden reconducirse al terreno de la culpa. Es aquí, entonces, donde el caso fortuito adquiere autonomía conceptual. Es indiferente que el daño provenga de un hecho de la naturaleza o del hecho (culpable o no) de un tercero: lo decisivo es que sea ajeno al ámbito de cuidado del demandado. Y tiene también carácter de exterior la hipótesis de culpa de la víctima que resulta ser la causa jurídicamente excluyente de la ocurrencia del daño: respecto del autor, se trata de un hecho que está fuera de su control y por el cual no puede ser considerado responsable, aunque su acción constituya una remota causa necesaria del perjuicio. Este último punto enlaza con la pluralidad de causas, que se examina en el Eje 13. La exterioridad cobra importancia especial en los regímenes de responsabilidad estricta, y conviene explicar por qué. En ellos, la previsibilidad y la irresistibilidad pueden no ser excusa suficiente, en la medida en que haya intervenido como causa del daño el riesgo creado por la actividad: precisamente porque el régimen objetivo prescinde del juicio de culpa, de nada sirve alegar que el evento no pudo preverse ni resistirse si él pertenece al riesgo típico de la actividad. Pero la fuerza mayor sí pesará como excusa si el daño se debió a un hecho externo al ámbito de riesgo cubierto por la regla de responsabilidad estricta. Con todo, advierte **BARROS**, una responsabilidad estricta muy extensa puede llegar a comprender incluso el caso fortuito, en cuyo caso la exoneración desaparece por completo.

3.4. Efectos

El principio es que la fuerza mayor o caso fortuito excluyen la causalidad, aun cuando haya intervenido culpa de la víctima. La jurisprudencia ofrece una aplicación de particular interés, ya conocida del Eje 2: la Corte Suprema, en fallo de 5 de noviembre de 1970, resolvió un caso de destrucción de un inmueble producida como resultado de una pérdida momentánea de conocimiento del conductor del vehículo. El tribunal calificó el hecho de caso fortuito y, al no mediar dolo ni culpa, concluyó que no hubo hecho punible que originara obligaciones, extendiendo los efectos de esa declaración a la sede civil con alcance general. El fallo permite apreciar la doble proyección del caso fortuito: excluye la responsabilidad penal y la civil, y lo hace precisamente porque el daño deja de ser atribuible a conducta humana alguna.

4. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

4.1. El problema

Si la responsabilidad exige un hecho voluntario, y el hecho voluntario supone voluntad humana, surge de inmediato la pregunta acerca de la posibilidad de que respondan las personas jurídicas. El tema fue discutido, y lo fue especialmente para quienes sostienen que la persona jurídica es una mera ficción, pues desde esa premisa no cabría hablar de una “voluntad” real de la asociación, y sin voluntad no habría hecho voluntario ni, por tanto, responsabilidad.

4.2. La solución del derecho chileno

En Chile la cuestión está zanjada, y lo está por texto expreso. El **artículo 58** inciso segundo del Código Procesal Penal (que reprodujo en lo sustancial la regla del antiguo **artículo 39** del Código de Procedimiento Penal) dispone que la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales, y que por las personas jurídicas responden quienes hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare. La disposición deja en claro que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad civil, esto es, están obligadas a indemnizar los daños que sus órganos o representantes causen. La norma se sitúa en la hipótesis de que el hecho ilícito sea a la vez penal y civil: en su carácter penal afecta al individuo que obró (y él irá a la cárcel si ésa es la sanción del caso), mientras que la persona jurídica soportará la indemnización de perjuicios a que haya lugar. Debe advertirse, sin embargo, que la responsabilidad civil de la persona jurídica no depende de que el hecho constituya un ilícito penal. La doctrina y la jurisprudencia la aceptan aun cuando el hecho sea puramente civil, y así debe ser: el **artículo 58** del Código Procesal Penal no es la fuente de esa responsabilidad, sino tan sólo su reconocimiento formal en la hipótesis de concurso con lo penal. La fuente son las reglas generales del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, y ALESSANDRI invoca además el **artículo 545** del Código Civil, que al definir la persona jurídica como capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles no distingue entre obligaciones contractuales y extracontractuales. Conviene contrastar ambas evoluciones, porque la asimetría es notable y ya se anticipó en el Eje 2: mientras en materia penal la regla sigue siendo la incapacidad de las personas jurídicas (con la excepción del estatuto especial de la Ley N° 20.393), en materia civil la tendencia ha sido la creciente extensión de su responsabilidad.

4.3. La teoría del órgano y sus límites

Tradicionalmente se ha sostenido que la persona jurídica responde por el hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por un órgano en ejercicio de sus funciones. La construcción es importante y debe comprenderse bien: no se trata de que la persona jurídica responda por el hecho ajeno de sus dependientes (hipótesis del **artículo 2320**, que se estudia en el Eje 14), sino de que el acto del órgano es el acto de la persona jurídica. El órgano no representa a la persona jurídica: la constituye. Sin embargo, el concepto de órgano carece de límites bien definidos en materia civil, y ahí reside la dificultad práctica. En principio, son órganos de una persona jurídica todas las personas naturales que, actuando en forma individual o colectiva, están dotadas por la ley o por los estatutos de poder de decisión: así ocurre, por ejemplo, con la junta de accionistas, el directorio y el gerente en

una sociedad anónima. Pero la noción ha sido extendida a todas aquellas personas dotadas permanentemente de poder de representación, es decir, facultadas para expresar la voluntad de la persona jurídica. Lo determinante, en definitiva, es el poder autónomo y permanente de decisión, materia que constituye una cuestión de hecho y que debe ser analizada en concreto. La consecuencia de esa extensión es de la mayor importancia práctica, y conviene explicitarla porque anticipa una de las discusiones centrales del curso: cuanto más se amplía la noción de órgano, más hechos ilícitos quedan comprendidos en la responsabilidad directa de la persona jurídica y menos en la responsabilidad por el hecho ajeno. Y la diferencia no es menor: tratándose de responsabilidad por hecho ajeno, el empresario puede exonerarse acreditando que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere no pudo impedir el hecho (**artículo 2320** inciso final); tratándose de responsabilidad por hecho propio del órgano, esa excusa no procede, porque nadie se exonera alegando que no pudo impedir su propia conducta. La expansión de la teoría del órgano opera, entonces, como un mecanismo de agravación de la responsabilidad de las personas jurídicas, y es una de las vías por las cuales la doctrina moderna ha construido la llamada culpa en la organización, que se examinará en el Eje 15.

DATO DE GRADO

Dónde se traza la frontera de la voluntariedad

Este eje encierra dos tensiones que conviene formular con precisión.

La primera es la ubicación dogmática del caso fortuito, y su interés no es clasificatorio sino operativo. La doctrina que lo sitúa en la voluntariedad (**CORRAL**, y con él la sistematización que aquí se sigue) acierta al advertir que un daño producido por un terremoto no puede vincularse a voluntad humana alguna, y que por eso mismo no hay hecho del cual responder. Pero esa explicación resulta insuficiente frente a los casos más interesantes, que son precisamente aquellos en que sí hubo conducta voluntaria y hasta culpable y, sin embargo, el agente no responde: el automovilista que cruza la línea continua para esquivar a un peatón obró voluntariamente, con plena conciencia, e infringió una norma del tránsito. Su exoneración no puede explicarse por falta de voluntad, porque voluntad hubo. Sólo puede explicarse porque el daño no le es causalmente atribuible: la causa determinante fue el hecho externo. De ahí la superioridad explicativa de la tesis de **BARROS**. Y de ahí también que la clasificación de **ALESSANDRI** (que enumera el caso fortuito entre las “eximentes” junto a la culpa de la víctima y el hecho de un tercero) sea criticada con razón: no porque su enumeración sea errada en cuanto a los efectos, sino porque agrupa bajo un mismo rótulo instituciones que operan sobre elementos distintos de la responsabilidad. El caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho del tercero no excluyen la ilicitud de la conducta del demandado; excluyen la atribución del daño a esa conducta. Confundir ambos planos conduce a errores de carga probatoria: quien invoca una causal de justificación (Eje 7) debe acreditar la circunstancia que legitima su obrar; quien invoca caso fortuito debe acreditar un hecho externo, imprevisible e irresistible, lo que es cosa distinta y considerablemente más exigente que la simple prueba de la diligencia. La segunda tensión es la que subyace a la responsabilidad de las personas jurídicas. El requisito del hecho voluntario está construido sobre la imagen de una persona natural que delibera y decide; aplicado literalmente, conduciría a la irresponsabilidad de los entes colectivos, que es exactamente la conclusión a la que llegaba la teoría de la ficción. El derecho chileno rechaza esa conclusión, pero el precio que paga es una cierta artificialidad conceptual: se afirma que la persona jurídica actúa por medio de sus órganos y que el acto del órgano es su propio acto, lo cual es una construcción, no una constatación. Y esa construcción, además, se expande: la noción de órgano se extiende desde el directorio hasta toda persona dotada de poder autónomo y permanente de decisión. Lo relevante para el examen es advertir que esa expansión no es neutral. Cada avance de la noción de órgano desplaza hipótesis desde el régimen del **artículo 2320** (donde el empresario puede exonerarse probando que no pudo impedir el hecho) hacia el régimen de la responsabilidad directa, donde no existe tal excusa. Bajo una discusión aparentemente conceptual (qué es un órgano) se juega, en realidad, una decisión sobre la extensión de la responsabilidad empresarial. Comprender esto permite conectar este eje con el Eje 15 y mostrar que la evolución del derecho chileno en materia de responsabilidad de las personas jurídicas no ha operado por vía legislativa, sino por vía de una progresiva reinterpretación de la noción de hecho propio.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el principio: la responsabilidad tiene por antecedente el hecho voluntario, esto es, un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto, sea acción u omisión; principio recogido en los **artículos 1437, 2284, 2314 y 2329** del Código Civil. Debe distinguirse en él una dimensión material (la conducta) y una dimensión subjetiva (la voluntariedad); y precisarse que las obligaciones legales que nacen de hechos no voluntarios, como las tributarias o las alimenticias, no constituyen responsabilidad, sino obligaciones cuya fuente es la ley. En segundo lugar, la dimensión material: la regla general es la acción, en tanto que la omisión exige un deber especial de actuar en beneficio de otro, cuyo examen corresponde al juicio de culpa. En tercer lugar, la dimensión subjetiva y sus casos de exclusión: los estados transitorios de pérdida del uso de razón (hipnosis, sonambulismo) que **CORRAL**, con razón, se niega a asimilar a la demencia, porque ésta es causal de incapacidad y califica permanentemente a la persona, mientras que aquéllos son causales de exoneración por falta de voluntariedad del acto. En cuarto lugar, el caso fortuito. Concepto legal del **artículo 45** del Código Civil: el imprevisto a que no es posible resistir. Su ubicación dogmática es discutida (falta de antijuridicidad, de culpa o de nexo causal; supresión de la voluntariedad para **CORRAL**; eximente de responsabilidad para **ALESSANDRI**; exclusión de la causalidad para **BARROS**), debiendo advertirse que en sede extracontractual la mera ausencia de culpa ya excluye la ilicitud, de modo que la función propia del caso fortuito es impedir la atribución del daño aunque haya mediado culpa, como en el caso del conductor que cruza la línea continua para esquivar a un peatón. Sus elementos son tres: la irresistibilidad, medida en función del deber de diligencia; la imprevisibilidad, que es un concepto normativo, pues el caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión (es caso fortuito el reventón del neumático de un automóvil nuevo o el síncope de quien carece de antecedentes cardíacos, y no lo es un temblor de mediana intensidad en la zona central de Chile); y la exterioridad, que es el elemento verdaderamente constitutivo, pues pertenece al terreno de la causalidad. Puede citarse la jurisprudencia: la Corte Suprema, en fallo de 20 de junio de 1949, exigió que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias hubiese podido prever y evitar el hecho; la Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo de 7 de noviembre de 1985, declaró que una dificultad subsanable por un hombre prudente jamás constituye caso fortuito; y la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 10 de septiembre de 1940, rechazó la fuerza mayor invocada por el propietario de un edificio del que se desprendió un trozo de mampostería que dio muerte a un transeúnte, razonando que en un país sísmico los temblores de mediana intensidad son previsibles y que el deber de cuidado alcanza a todas las medidas que la prudencia aconseja. Debe cerrarse este punto señalando la relevancia de la exterioridad en los regímenes de responsabilidad estricta, donde la previsibilidad y la irresistibilidad no bastan si el daño pertenece al riesgo típico de la actividad. En quinto lugar, las personas jurídicas: superada la objeción derivada de la teoría de la ficción, el **artículo 58** inciso segundo del Código Procesal Penal reconoce expresamente su responsabilidad civil, la que además **ALESSANDRI** funda en el **artículo 545** del Código Civil, que no distingue entre obligaciones contractuales y extracontractuales. Responden por el hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por un órgano en ejercicio de sus funciones, siendo órganos quienes están dotados de poder autónomo y permanente de decisión, cuestión de hecho que se aprecia en concreto. Cerrar mostrando lo que está en juego: la expansión de la noción de órgano desplaza hipótesis desde la responsabilidad por el hecho ajeno (donde cabe la excusa del **artículo 2320** inciso final) hacia la responsabilidad directa, donde no la

hay; de modo que bajo una discusión aparentemente conceptual se decide, en realidad, la extensión de la responsabilidad de las empresas.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 6. El hecho voluntario. Caso fortuito y personas jurídicas**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

G. LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN

Para que haya responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento, contrario a lo justo. Así se deduce de dos normas: el **artículo 1437** del Código Civil, que señala como fuente de obligaciones el hecho que ha inferido injuria o daño; y el **artículo 2284**, que precisa que si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar constituye un delito, y si es culpable pero sin intención de dañar, un cuasidelito. El Código, como se ve, no se contenta con el daño: exige que el hecho sea ilícito. Ahora bien, admitido que la ilicitud es exigida, se plantea de inmediato el problema que domina este eje y que ya quedó anunciado al examinar los elementos de la responsabilidad (Eje 4): ¿constituye la antijuridicidad un elemento autónomo, distinto de la culpa, o queda absorbida en ella? La pregunta no es de mera arquitectura expositiva. De su respuesta depende que existan o no dos juicios sucesivos (uno sobre la conformidad objetiva de la conducta con el ordenamiento, otro sobre el reproche que merece su autor) y, con ello, la posición y la carga argumentativa de cada parte en el juicio. La valoración de la licitud de la conducta puede fundarse, en todo caso, en dos órdenes de consideraciones: en la infracción a un deber legal expreso, o en la transgresión del principio general de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro (*alterum non laedere*). Y a la inversa, el ordenamiento reconoce circunstancias que excluyen esa ilicitud, aunque la conducta haya causado daño: son las causales de justificación, cuyo estudio ocupa la segunda parte de este eje.

1. LA DISCUSIÓN SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD

En la doctrina nacional generalmente no se considera la antijuridicidad como un elemento autónomo de la responsabilidad, por cuanto se la subsume en otros dos: bien en la culpabilidad (si hay dolo o culpa, es porque hay ilicitud), bien en el daño (sólo se indemniza el daño injusto). **BARROS** lleva esta posición hasta sus últimas consecuencias, y su formulación es la más nítida: en la responsabilidad civil, la culpa es sinónimo de ilicitud, de modo que, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, no existen diferencias conceptuales relevantes entre culpabilidad y antijuridicidad. El hecho culpable es, por definición, antijurídico. Su fundamento es doble. Por una parte, dogmático: el concepto objetivo de culpa que rige entre nosotros (según se verá en el Eje 8, la culpa civil no es un reproche moral al autor, sino la comparación en abstracto entre la conducta efectiva y la conducta debida) incluye ya el conjunto de condiciones para dar por establecida la ilicitud. Preguntar si la conducta infringió el deber de cuidado exigible es preguntar si fue contraria a derecho. Por otra parte, comparado: en algunos ordenamientos la antijuridicidad sí constituye un requisito independiente, pero por una razón que no concurre en Chile. Así ocurre en el **artículo 823** del Código Civil alemán, conforme al cual no basta que la negligencia haya provocado un perjuicio a un mero interés, sino que debe haberse lesionado un derecho subjetivo; allí la antijuridicidad expresa, precisamente, esa lesión de un derecho. Donde el sistema protege intereses y no sólo derechos (como el chileno), la distinción pierde su función. **CORRAL** y **RODRÍGUEZ GREZ** sostienen la opinión contraria, y su argumento es que la ilicitud no va necesariamente vinculada a la culpabilidad ni al daño. Puede haber culpa sin ilicitud, y puede causarse un daño de manera justificada, en cuanto opere alguna causal de justificación. **RODRÍGUEZ GREZ** desarrolla esta posición con particular rigor: para él, la antijuridicidad es la contradicción entre una determinada con-

ducta y el ordenamiento normativo considerado en su integridad, y puede ser formal (si contradice una norma expresa) o material (si consiste en una violación del orden público o de las buenas costumbres); la culpa y el dolo, en cambio, serían meros factores de imputabilidad subjetiva. De ahí que sostenga, coherentemente, que lo que caracteriza a las causales de justificación es la presencia del dolo o de la culpa y la ausencia de antijuridicidad, atendido que la conducta dañosa, aunque culpable, no puede considerarse contraria a derecho, sino ajustada a él. Aquí está el corazón de la disputa, y conviene formularlo con toda precisión, porque es el punto que distingue una respuesta memorizada de una comprendida. Las dos posiciones describen el mismo fenómeno desde estructuras distintas. Para **RODRÍGUEZ GREZ**, quien mata en legítima defensa actúa culpablemente pero conforme a derecho: hay culpa, falta antijuridicidad. Para **BARROS**, quien mata en legítima defensa no actúa culpablemente en absoluto, porque el hombre prudente colocado en esa situación habría hecho lo mismo, y la culpa se mide precisamente contra ese estándar: la causal de justificación opera dentro del juicio de culpa, eliminándola. El resultado práctico es idéntico (no hay responsabilidad), pero la arquitectura del razonamiento es opuesta. ¿Tiene esto alguna consecuencia? Sí, y de dos órdenes. La primera es argumentativa: quien sostiene la autonomía de la antijuridicidad ordena el juicio en dos etapas, de modo que la causal de justificación se discute después de establecida la culpa, como una defensa que el demandado debe invocar y acreditar; quien la niega debe resolver el problema dentro del juicio de culpa, con el riesgo de que la determinación del estándar de conducta debida absorba cuestiones que merecerían tratamiento separado. La segunda es sistemática: si la culpa y la ilicitud coinciden, entonces la responsabilidad estricta (que prescinde de la culpa) quedaría teóricamente privada de todo juicio de antijuridicidad, lo que obliga a explicar por qué en ella también operan causales de justificación. La construcción de **BARROS** responde a esto señalando que en la responsabilidad estricta el juicio de antijuridicidad recae sobre el resultado y no sobre la conducta, según se vio en el Eje 4. Debe advertirse, con todo, que la disputa es menos aguda de lo que parece, y que **BARROS** mismo lo reconoce implícitamente al dedicar un párrafo autónomo a las causales de justificación: la diferencia es de arquitectura y no de resultado. En el examen conviene exponer ambas posiciones, mostrar su fundamento y advertir que la sistematización que aquí se sigue (la de **CORRAL**) trata la antijuridicidad separadamente, no porque la culpa civil sea un reproche moral, sino porque esa separación permite examinar con orden las circunstancias que legitiman un daño.

2. EL ILÍCITO CIVIL TÍPICO

Aunque, a diferencia del derecho penal, en materia civil no se exige tipicidad como requisito de la responsabilidad (punto ya establecido en los Ejes 2 y 4), en ciertas ocasiones la ley civil sí describe conductas que considera causantes de responsabilidad extracontractual. Se citan, entre otros, los **artículos 423, 631, 926, 934, 1287, 1336, 1768 y 1792-18** del Código Civil. En tales casos la doctrina habla de ilícito civil típico. La incidencia real de este catálogo es que la doctrina y la jurisprudencia civiles han independizado completamente el concepto de *discernimiento civil* del penal, entendiéndolo simplemente como la aptitud del menor para percatarse del impacto perjudicial de su conducta, lo que facilita que los menores de 16 años (pero mayores de 7) respondan civilmente si cuentan con patrimonio propio. La función que cumple esa tipificación es discutida, y la discusión reproduce, en pequeño, la del apartado anterior. **CORRAL** afirma que la tipificación cumple la función de ser un indicio de la antijuridicidad de la conducta. La descripción legal no crea la ilici-

tud ni la agota: la señala. De ahí que su concurrencia no dispense de examinar los demás elementos, ni excluya que conductas no descritas sean igualmente ilícitas conforme al principio general. **RODRÍGUEZ GREZ** sostiene, en cambio, que el ilícito civil típico funcionaría de un modo semejante a la responsabilidad objetiva. La tesis es más fuerte: acreditada la conducta descrita por la ley, la ilicitud quedaría establecida sin necesidad de mayor juicio, aproximándose el régimen al de la responsabilidad estricta, en la cual (según se vio) el juicio de antijuridicidad recae sobre el resultado. La preferencia por una u otra tesis depende, otra vez, de la posición que se adopte sobre la autonomía de la antijuridicidad. Si la ilicitud es un juicio separado, la tipificación puede operar como su indicio (**CORRAL**). Si la tipificación agota el juicio, entonces el ilícito típico se independiza de la culpa y se aproxima al modelo objetivo (**RODRÍGUEZ GREZ**). Conviene advertir, sin embargo, que esta última conclusión debe manejarse con cautela, porque (según se estableció en el Eje 4) la responsabilidad estricta es de derecho estricto y su fuente es la ley: extenderla por vía interpretativa a los ilícitos típicos supondría una expansión que el legislador no ha declarado.

3. LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN: NOCIONES GENERALES

3.1. Ausencia de regulación y fundamento

A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, donde el **artículo 10** del Código Penal enumera taxativamente las causales de justificación, la ley civil no ha reglamentado las causas eximentes de responsabilidad. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que las han identificado. **ALESSANDRI** funda su existencia en los principios generales de nuestro derecho, conforme a los cuales sólo se responde de los daños causados con dolo o culpa, según se desprende de los **artículos 2284 y 2314** del Código Civil. El argumento es sólido: si sólo se responde del daño culpable, entonces toda circunstancia que excluya el reproche excluye la responsabilidad, aunque la ley no la haya catalogado. **BARROS** precisa la función que cumplen en sede civil, y su formulación es la más útil: mientras en materia penal las causales de justificación excluyen la antijuridicidad del hecho, tratándose de la responsabilidad civil actúan sobre el ilícito eliminando la culpabilidad; su función es, por tanto, servir de excusa razonable para el hombre prudente. Esta caracterización es la que permite ordenar todo el catálogo: en cada una de las cuatro causales se trata de establecer que el hombre prudente, colocado en la situación del demandado, habría actuado del mismo modo.

3.2. Enumeración y delimitación

Las causales de justificación son cuatro: la ejecución de actos autorizados por el derecho, el consentimiento de la víctima, el estado de necesidad y la legítima defensa. **ALESSANDRI** incluye además, entre las que denomina “eximentes de responsabilidad”, el caso fortuito o fuerza mayor, la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. Debe formularse aquí la prevención que ya se anticipó en el Eje 6, porque es un error de sistematización frecuente en el examen: si bien esas causales determinan la inexistencia de responsabilidad, no lo hacen por la vía de excluir la ilicitud, sino actuando sobre otros elementos de la responsabilidad por negligencia. La violencia externa, en los términos del **artículo 1456** del Código Civil, excluye la libertad de la acción y, por tanto, la voluntariedad, tornando el acto inimputable. El caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero operan eliminando la causalidad. Y es notable

que el propio **ALESSANDRI** parezca confirmar esta lectura, pues al tratar el caso fortuito exige que éste sea la causa única del daño; al referirse al hecho de un tercero, que constituya la causa exclusiva del daño, esto es, que el demandado no haya contribuido a él con su dolo o culpa; y al tratar la culpa de la víctima, que sea igualmente la causa exclusiva. Las tres fórmulas son de causalidad, no de ilicitud. **DUCCI**, por lo demás, se refiere expresamente a estas causales como eximentes que operan eliminando el vínculo causal, señalando que el daño puede no tener como antecedente una falta del demandado, sino deberse a una causa extraña. La conclusión que debe retenerse es que la clasificación de **ALESSANDRI** es correcta en cuanto a los efectos (todas esas circunstancias excluyen la responsabilidad) pero equivocada en cuanto a la estructura, y que confundir ambos planos tiene costo probatorio: no es lo mismo acreditar una circunstancia que legitima el obrar propio que acreditar un hecho externo, imprevisible e irresistible que rompe la atribución causal.

4. PRIMERA CAUSAL: LA EJECUCIÓN DE ACTOS AUTORIZADOS POR EL DERECHO

Dentro de estos actos es posible distinguir tres grupos: los ejecutados en ejercicio de un derecho, los ejecutados en cumplimiento de un deber legal, y los autorizados por usos normativos.

4.1. El ejercicio de un derecho

El ejercicio de un derecho elimina la ilicitud de la acción que causa el daño. Por ello, en principio no hay ilicitud en el hecho de que un restaurante se instale a media cuadra de otro ya existente y le prive de parte de su clientela, siempre que respete las normas de la libre competencia. Del mismo modo, la jurisprudencia ha declarado que el mero ejercicio de una acción judicial, aunque los tribunales no la acojan en definitiva, no constituye injuria o daño por sí solo (así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de 1 de enero de 1925), criterio ratificado en materia concursal por la Corte Suprema, en fallo de 14 de enero de 1913, al declarar que la solicitud de quiebra que, acogida en principio, resulta finalmente rechazada, no impone responsabilidad si no se acredita que el solicitante obró con dolo o malicia. El fundamento de esta causal es evidente si se recuerda el Eje 4: el daño competitivo, el daño derivado de la crítica o el daño que sufre quien es demandado son costos normales de la vida en sociedad, y hacerlos indemnizables transformaría por completo la forma en que nos relacionamos. Quien ejerce un derecho no infringe deber de cuidado alguno: hace precisamente lo que el ordenamiento le permite. El abuso del derecho Pero el ejercicio de un derecho, en sí mismo justo, puede llegar a ser ilícito o injusto: puede causar daño ilegítimamente. Nace así la teoría del abuso del derecho, conforme a la cual el ejercicio abusivo de un derecho genera obligación de reparar los perjuicios producidos. El abuso es, entonces, el límite de esta causal de justificación: actuar formalmente dentro del marco del derecho que se ejercita, pero desviándose de sus fines. La discusión doctrinaria. **PLANIOL**, desde una posición individualista, negó de raíz la posibilidad misma de la figura, invocando el principio de no contradicción: el contenido del derecho es su único límite, pues no puede ejercerse a la vez un derecho que sea contrario a derecho, ya que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Para él, hablar de “abuso del derecho” es lógicamente imposible. **JOSSERAND** contradijo esa tesis e introdujo la teoría, postulando que se abusa de un derecho subjetivo cuando éste es ejercido contrarian-

do su función social y económica; en otras palabras, cuando el derecho subjetivo se ejerce en desacuerdo con el derecho objetivo, para lo cual será necesario indagar en los motivos que indujeron a obrar al titular o en el fin que se propuso alcanzar. **RIPERT** y los **MAZEAUD** (seguidos en nuestro medio por **ALESSANDRI**) entienden, en cambio, que el abuso del derecho es una culpa cometida en el ejercicio de ese derecho, lo que da lugar a responsabilidad civil conforme a las reglas comunes. Para **ALESSANDRI**, el abuso no es sino una especie de acto ilícito y, como tal, se resuelve con arreglo a criterios generales: habrá abuso cuando el titular de un derecho lo ejerza dolosa o culpablemente. **DUCCI** sostiene lo mismo, agregando el anclaje normativo: al ejercer cualquier derecho debemos abstenernos de ir contra la ley o contra el derecho ajeno, y si lo hacemos habremos traspasado el límite dentro del cual podemos hacerlo valer legítimamente, de modo que el derecho ya no nos conferirá aptitud jurídica para actuar y seremos responsables del daño causado. **RODRÍGUEZ GREZ** adopta una posición singular y que conviene manejar con cuidado, porque parece paradójica. Sostiene que lo que se ha llamado erradamente “abuso del derecho” no es más que el ejercicio de una apariencia jurídica, en la cual el sujeto, a pretexto de ejercer un derecho subjetivo, excede o desvía el interés jurídicamente protegido; el sujeto se coloca así al margen del derecho, de modo que el daño causado no tiene otro antecedente que un obrar ilícito, no de iure sino de facto. Y de allí deriva su conclusión más radical: quien ejerce un derecho (cualquiera que sea su posición subjetiva, dolosa o culpable) no incurre en responsabilidad, porque el perjuicio que desencadena está amparado o justificado en la norma que lo consagra; hablar de responsabilidad derivada del ejercicio doloso o culpable de un derecho constituiría, por ende, un error craso. La posición es coherente con su sistematización: si la antijuridicidad es un elemento autónomo, quien obra dentro de su derecho no es antijurídico, por dolosa que sea su intención; y si causa daño, es porque en verdad salió de su derecho, y entonces no hay “abuso” sino simple ilícito. **BARROS** formula una crítica al criterio tradicional que resulta decisiva y que conviene incorporar. Señala que resulta impreciso sostener que un derecho puede ser abusado cuando es ejercido con culpa, pues de lo contrario se arriesga que el ejercicio de un derecho quede desprovisto de sus características esenciales (especialmente de la facultad del titular de ejercerlo según su contenido). Si cualquier ejercicio negligente configurara abuso, el derecho subjetivo dejaría de ser tal. De ahí que la culpa en el abuso del derecho exija una especial calificación: el acto debe ser contrario a la buena fe o a las buenas costumbres, aunque formalmente corresponda al ejercicio de un derecho. **BARROS** añade que la buena fe expresa aquel núcleo de sentido que subyace a las normas atributivas de derechos, y que se muestra en los límites que la norma no expresa, pero da por supuestos. Buena parte de la doctrina converge hacia ese criterio: existirá abuso cuando el derecho sea ejercido de manera desleal, esto es, contrariando la buena fe y las buenas costumbres. Díez- Picazo lo formula señalando que el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe no sólo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual fue atribuido a su titular, sino también cuando se ejercita de una manera o en circunstancias que lo hacen desleal según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico; más allá de la buena fe, el acto es inadmisibles y se torna antijurídico. Y **FERREIRA RUBIO** observa que la buena fe indica un límite, algo que no debe sobrepasarse sin provocar consecuencias negativas. **BARROS** distingue, además, un sentido amplio de abuso, que resulta de gran utilidad conceptual: comete abuso quien ejerce un derecho lesionando otro de mayor envergadura. En tal caso la cuestión se plantea como una colisión de derechos, esto es, como el enfrentamiento de dos derechos simultáneamente cautelados por el ordenamiento: el de la víctima y el del autor del daño. En nuestro medio, el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la honra y a la privacidad es, con creciente relevancia, el ejem-

plo típico. La solución de estos conflictos supone sopesar los intereses involucrados y depende, en último término, de los valores culturales de cada sociedad, de modo que el ejercicio de un derecho actuará como justificación sólo en la medida en que ese derecho se considere de mayor entidad que el bien jurídico lesionado. En sentido estricto, en cambio, comete abuso quien ejerce un derecho con el único propósito de dañar a otro, hipótesis que se asimila a la definición legal de dolo del **artículo 44** del Código Civil y que, como tal, siempre genera responsabilidad. El anclaje normativo. El ordenamiento chileno contiene múltiples disposiciones que dan cuenta de las limitaciones al ejercicio del derecho subjetivo por excelencia, que es la propiedad. La Constitución Política establece en su **artículo 19** N° 24 que el ejercicio de la propiedad puede encontrar limitaciones derivadas de su función social, la que comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. El **artículo 582** del Código Civil, al definir el dominio, faculta para gozar y disponer arbitrariamente de la cosa, pero “no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno”; y esos límites se extienden a todas las cosas incorpóreas conforme al **artículo 583**. Además, el Código consagra casos de abuso fundados precisamente en la transgresión de la buena fe: así, los **artículos 2110 a 2112**, conforme a los cuales no vale la renuncia hecha de mala fe o intempestivamente en el contrato de sociedad, precisando que renuncia de mala fe el socio que lo hace para apropiarse de una ganancia que debía pertenecer a la sociedad, caso en el cual los demás socios podrán obligarle a partir con ellos las utilidades del negocio o a soportar exclusivamente las pérdidas, y excluirle de toda participación en los beneficios sociales. La jurisprudencia. Los tribunales estiman, en general, que el abuso del derecho constituye un ilícito civil que da lugar y se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual. La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 27 de julio de 1943, declaró que el ejercicio de un derecho, si de él deriva un daño mediando culpa o dolo, se transforma en la comisión de un delito o cuasidelito civil, que como fuente de obligaciones se rige por los preceptos del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. La formulación más completa se encuentra en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 9 de noviembre de 1992, cuya doctrina fue reiterada en 2007. Razonó el tribunal que la doctrina del abuso del derecho asume que el ejercicio de un derecho puede ser ilícito aunque el titular actúe dentro de los límites externos que establece el respectivo ordenamiento, y que sólo puede invocarse cuando el comportamiento del titular atenta contra estándares mínimos de conducta; que la jurisprudencia es constante en someter el ejercicio del derecho a las reglas de la responsabilidad civil y en exigir dolo o culpa para que se genere la obligación indemnizatoria; y que, cualquiera sea el ámbito de aplicación de la doctrina, debe existir de parte del agente un ánimo manifiesto de perjudicar, o una evidente falta de interés o de necesidad de lo que promueve, o un actuar motivado por el afán de causar perjuicio a su contraparte. Como ejemplos concretos de abuso reconocidos por los tribunales, la Corte Suprema, en fallo de 24 de julio de 1905, resolvió que el ejecutante que embarga animales de propiedad de un tercero, a sabiendas de que no pertenecían al deudor (y de lo que pudo cerciorarse antes del embargo con mediana diligencia), debe responder por las faltas del ganado que ha de restituir a aquel cuyo dominio fue reconocido. El caso ilustra bien el criterio: el embargo es el ejercicio de un derecho, pero ejercido con negligencia grave sobre bienes ajenos deviene en ilícito.

4.2. El cumplimiento de un deber legal

Quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno. Tal es el caso del agente de policía que priva de libertad al detenido, o del receptor judicial que traba un em-

bargo. **DUCCI** lo expresa señalando que el obrar en cumplimiento de una ley imperativa, o el abstenerse conforme a un precepto prohibitivo, constituyen los casos más claros e indiscutibles de proceder con aptitud jurídica. Más complejo es el problema de la observancia de órdenes emanadas de autoridad competente. El principio es que tales órdenes no actúan como eximentes por el mero hecho de emanar de la autoridad, correspondiendo al juez determinar cuándo justifican la exención. La regla general es que el cumplimiento de una orden de autoridad opera como causal de justificación siempre que la orden no sea manifiestamente ilegal: el límite está dado, pues, por la ilegalidad manifiesta. **ALESSANDRI** precisa el criterio con exactitud y conviene retener su formulación: el funcionario público o municipal, e incluso el simple particular, que ejecuta un acto en cumplimiento de órdenes emanadas de la autoridad administrativa o judicial (por ilegales que ellas sean) no responde del daño que así cause, a menos que la ilegalidad del acto sea tal que un hombre prudente se habría abstenido de ejecutarlo, o que el daño provenga de la forma en que se cumplió la orden, causándolo o agravándolo innecesariamente o con manifiesto descuido. La excusa cubre, entonces, el qué de la orden, pero no el cómo de su ejecución. Subsiste, sin embargo, una pregunta que la doctrina no resuelve unánimemente: ¿de qué modo debe el destinatario plantear la ilegalidad de la orden para beneficiarse de la excusa? ¿Basta la mera representación de la ilegalidad al superior, o es necesario rechazar la orden? **BARROS** estima que la cuestión pertenece al derecho administrativo, y ofrece como referencia una regla del derecho positivo: el Código de Justicia Militar dispone que queda exculpado el militar que cumple una orden de servicio que supone un hecho punible si ha suspendido su ejecución y ha representado previamente al superior la ilegalidad. **CORRAL**, por su parte, propone un criterio sustantivo distinto: lo relevante sería determinar el grado de coerción de la orden, esto es, si ella es capaz de suprimir la voluntariedad del acto (lo que, advierte, raramente ocurrirá). Obsérvese que ambas soluciones no operan en el mismo plano, y explicitarlo es valioso: la de **BARROS** mantiene el problema en sede de justificación (la orden legitima el obrar si el subordinado hizo lo que podía hacer para oponerse); la de **CORRAL** lo traslada a la voluntariedad (la orden exonera sólo si eliminó la libertad de la acción). Bajo el criterio de **CORRAL**, la excusa se estrecha considerablemente, porque una orden de servicio rara vez suprime la voluntad de quien la recibe.

4.3. Los actos autorizados por usos normativos

Más allá de las fuentes formales, la ilicitud en materia civil se refiere a aquello que es generalmente considerado como impropio. De este modo, queda excluida la culpa cuando la conducta da cuenta de usos o prácticas que son tenidos comúnmente por correctos. Los dos ejemplos clásicos son la incisión que hace el médico al operar conforme a las prescripciones de su *lex artis*, y las lesiones que ocasiona el futbolista que ejecuta una acción violenta, pero tolerada por las reglas del juego. Ninguno de esos hechos constituye ilícito, pese a lesionar la integridad física de otro. El criterio que gobierna toda esta causal debe formularse con precisión, porque es de gran rendimiento: el límite está dado por los deberes de cuidado que rigen cada actividad, de modo que sólo la infracción a esos deberes (y no la lesión producida) acarrea responsabilidad. La causal no consiste, entonces, en una autorización para dañar, sino en el reconocimiento de que dentro de ciertas prácticas socialmente aceptadas el estándar de conducta debida es el que la propia práctica define. El cirujano responde si se aparta de la *lex artis*, no por haber cortado; el futbolista responde si sale de las reglas del juego, no por haber disputado el balón con vigor.

5. SEGUNDA CAUSAL: EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA

5.1. Planteamiento

Tratándose de responsabilidad extracontractual, lo normal es que no exista relación previa entre la víctima y el autor del daño: los encuentros son, por regla general, casuales. Sin embargo, nada obsta a que existan acuerdos previos entre el potencial autor del daño y la eventual víctima, sea en la forma de autorizaciones para realizar un determinado acto (caso en el cual el acuerdo es, en rigor, un acto jurídico unilateral), sea en la de convenciones sobre responsabilidad, mediante las cuales se acepta un cierto nivel de riesgo, se modifican las condiciones de responsabilidad o se limitan los daños indemnizables. Es el principio *volenti non fit iniuria*: a quien consiente no se le hace injuria. Se ha discutido la validez de las estipulaciones destinadas a suprimir o modificar la responsabilidad del autor del daño, hipótesis que en materia extracontractual puede presentarse, por ejemplo, si antes de una carrera automovilística los participantes convienen su recíproca irresponsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir, o si entre vecinos se pacta lo mismo respecto de daños previsibles. Se distinguen dos clases de convenciones: las que eximen de toda obligación de indemnizar y las que la limitan en cierta forma, por ejemplo, a una determinada suma de dinero. Debe hacerse aquí una precisión que enlaza con el Eje 3 y que suele preguntarse: la existencia de una estipulación sobre responsabilidad no convierte a ésta en contractual, porque la responsabilidad contractual supone una obligación previa que no se ha cumplido, y aquí no la hay. La convención modula el régimen extracontractual; no lo sustituye por otro.

5.2. Los límites de la disposición

Cuando la víctima potencial presta su consentimiento autorizando la ejecución de un acto que puede causarle daño, realiza un acto de disposición, que como tal está sujeto a los límites establecidos por las reglas generales que rigen la validez de los actos jurídicos. El consentimiento no puede validar un acto ilegal o contrario a las buenas costumbres, conforme al **artículo 1461** del Código Civil. De allí se siguen dos límites precisos: la autorización no puede importar condonación del dolo futuro, por prohibirlo el **artículo 1465** del Código Civil (y ello comprende la culpa grave, por su equivalencia con el dolo conforme al **artículo 44**); y no puede significar la renuncia de derechos indisponibles, como la vida o la integridad física, en virtud de lo dispuesto en el **artículo 12** del mismo Código. 6.3. La distinción decisiva: renuncia de un derecho y aceptación de un riesgo Aquí se encuentra la clave de toda la causal, y su dominio es indispensable. La situación es distinta según que la víctima renuncie a un derecho o solamente asuma un riesgo. En principio, sólo puede hablarse de disposición en el primer caso y, en consecuencia, sólo a él se aplican los límites recién señalados. Tratándose de la simple aceptación de un riesgo razonable, el acto debe entenderse autorizado aun cuando se refiera a bienes indisponibles. Así ocurre respecto de quien realiza vuelos de prueba, o de quien participa en experimentos con fármacos en desarrollo: en ambos casos se asume el riesgo de un daño probable respecto de bienes que no son disponibles (la vida, la integridad física), y sin embargo la autorización es válida. El fundamento de esta solución lo formula **BARROS** con una observación de considerable finura: el principio de autonomía no obliga a la víctima al mismo nivel de cuidado respecto de sí misma que respecto de terceros. El ordenamiento puede exigirle prudencia frente a los demás sin exigirle la misma prudencia frente a mí mismo, porque en esta última esfera lo que está en juego es mi propia libertad de disponer de mi vida y de

mis riesgos. Con todo, el límite existe: si la probabilidad del daño es muy alta y hace que el riesgo devenga en temerario, excediendo lo razonable, entonces habrá en verdad un acto de disposición respecto de bienes o derechos irrenunciables, y como tal la autorización de la víctima no será válida. La frontera entre aceptar un riesgo y disponer de la vida es, pues, una cuestión de grado, y el criterio para trazarla es la razonabilidad del riesgo asumido.

5.4. La asunción de riesgos deportivos

Marginalmente distintos de la aceptación de un riesgo (donde hay una voluntad específica) son los casos de asunción voluntaria de riesgo, típicos de las actividades deportivas. **BARROS** observa que el deporte riesgoso constituye hoy un área especial de la responsabilidad, precisamente porque combina por naturaleza el placer con el peligro. Los riesgos que se entienden asumidos en el deporte son aquellos que surgen de las reglas del juego. Pero (y esto es importante) la mera infracción a la regla no basta para dar por establecida la culpa, precisamente porque quien participa en un deporte riesgoso asume también el riesgo de las desviaciones que razonablemente pueden esperarse en el marco de la competencia o del desafío personal. El futbolista asume no sólo las entradas reglamentarias, sino las faltas que ordinariamente ocurren en un partido. Esto se aprecia con especial claridad en los deportes particularmente riesgosos. **BARROS** ofrece dos ejemplos que conviene retener: no puede atribuirse culpa al empresario que administra un centro de esquí y accede a la petición de un esquiador de ser llevado a una zona conocidamente peligrosa; ni a la empresa que suministra una canoa a quien desea navegar por rápidos especialmente riesgosos. Y establece el contraste que da sentido al criterio: distinto es el cuidado debido en la mantención de las canchas o en las excursiones abiertas a todo público, donde nadie ha asumido riesgo extraordinario alguno.

5.5. Los deberes de información y el consentimiento presunto

Para que la aceptación voluntaria del riesgo opere como causal de justificación es necesario que el autor del daño haya proporcionado a la víctima información suficiente acerca del riesgo y de sus componentes (su intensidad y su probabilidad), siéndoles aplicables íntegramente las reglas generales sobre la buena fe. La razón la formula **BARROS** con una frase que conviene citar por su exactitud conceptual: no puede entenderse que asume voluntariamente un riesgo quien conocidamente no está en situación de medirlo. De ahí que los deberes de información sean particularmente exigentes cuando existe asimetría entre el conocimiento de quien ofrece o facilita la actividad riesgosa y el que cabe esperar de quien la realiza; y de ahí, también, que quien conoce un riesgo que es desconocido para las potenciales víctimas pueda incurrir en responsabilidad si no lo informa. La causal de justificación se transforma así, por vía de la información, en una fuente de deberes positivos. De particular importancia es el consentimiento presunto, esto es, el que se supone prestado cuando la víctima no estaba en condiciones de otorgarlo: situación típica en materia de responsabilidad médica (el paciente inconsciente que requiere una intervención urgente). **BARROS** propone en la materia una regla de razonabilidad pasiva: se trata de una modalidad de la pregunta acerca de la conducta hipotética de una persona razonable y prudente, referida a cómo habría decidido respecto de la asunción del riesgo si hubiese estado en condiciones de hacerlo, atendidas las circunstancias.

5.6. La renuncia posterior al daño

Cosa enteramente distinta es que, una vez producido el hecho ilícito, la víctima renuncie a la indemnización, la componga directamente con el responsable o transija con él. En tales casos no hay condonación del dolo futuro, sino del ya ocurrido; ni se comercia con la personalidad humana, sino con un efecto meramente pecuniario: la indemnización, que es netamente patrimonial. La distinción es esencial y enlaza con lo que se dirá en el Eje 22 sobre la extinción de la acción: antes del daño, la renuncia anticipada choca con los **artículos 12 y 1465** del Código Civil; después del daño, la acción indemnizatoria es plenamente renunciable y transigible conforme a la regla general del **artículo 12**, porque su objeto ya no es la vida ni la integridad física, sino un crédito.

6. TERCERA CAUSAL: EL ESTADO DE NECESIDAD

6.1. Concepto y fundamento

El estado de necesidad es aquel en que una persona se ve obligada a ocasionar un daño a otra para evitar uno mayor, a sí misma o a un tercero. Se trata de una excusa que se basa en la desproporción de los bienes en juego: la víctima soporta un daño sustancialmente menor que aquel que el autor pretendía evitar. Desde la perspectiva de la culpa, el estado de necesidad opera como causal excluyente de responsabilidad en cuanto es propio del hombre prudente optar por un mal menor para evitar un mal mayor. **ALESSANDRI** lo formula con nitidez: es indispensable que el daño que se trata de evitar sea mayor que el causado para evitarlo, pues un hombre prudente no sacrifica un bien ajeno para salvar uno suyo que vale lo mismo o menos.

6.2. Requisitos

Son dos, y ambos tienen fundamento propio. Que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable de quien alega la justificación. La razón es evidente: si el estado de necesidad proviene de la propia culpa del agente, hay culpa en el origen del supuesto estado de necesidad, y nadie puede excusarse invocando una situación que él mismo creó. Es la misma lógica de la *actio liberae in causa* que se examinó a propósito del ebrio (Eje 5).

Que no existan medios inocuos o menos dañinos para evitar el daño. Si los había, el estado de necesidad queda descartado en razón de la desproporción del medio empleado: quien pudiendo evitar el mal mayor con un daño menor optó por uno mayor, no obró como habría obrado el hombre prudente.

6.3. La jurisprudencia: dos casos que conviene contrastar

Los tribunales chilenos han resuelto dos casos notablemente simétricos, y su comparación permite fijar con exactitud el alcance de la causal. En el primero, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 21 de octubre de 1890, conoció del caso de un funcionario policial que, ante la falta de agua y temiendo que un incendio se propagara a los inmuebles vecinos, derramó el contenido de unas pipas de aguardiente que se hallaban en el interior de uno de ellos. Demandado por el dueño del aguardiente, el policía fue declarado exento de responsabilidad, por haber actuado destruyendo

la propiedad privada de un individuo para salvar la de muchos. El fundamento es exactamente el de la desproporción de bienes: el aguardiente valía menos que las casas. En el segundo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 11 de enero de 1908, conoció del caso de la fuerza pública que custodiaba un puerto y que, obedeciendo una orden superior, arrojó al mar cajones de cerveza de propiedad de un particular para impedir que cayeran en poder de unos huelguistas. Aquí el Fisco sí fue declarado responsable, y el fundamento es el segundo requisito: razonó el tribunal que el deber de la autoridad de mantener el orden público no la faculta para adoptar el primer medio que se le presente, ni la exime de la obligación de recurrir, entre varios, a los que menos daños ocasionen al derecho de los particulares; y no se acreditó que arrojar la cerveza al mar fuese el medio necesario y único de impedir su apropiación. El contraste es didáctico: en ambos casos hubo destrucción de propiedad ajena por la autoridad para evitar un mal; en el primero no había medio menos dañino disponible (faltaba el agua); en el segundo no se acreditó que lo fuera. El estado de necesidad no es una licencia para dañar, sino la autorización para escoger el mal menor cuando no hay alternativa.

6.4. Delimitación, fundamento normativo y efectos

El estado de necesidad se diferencia del caso fortuito en que, si bien hay un hecho imprevisto, éste no es irresistible: puede resistirse, pero a costa de un daño propio. La distinción es fina y conviene retenerla, porque el examinando suele confundirlas: en el caso fortuito el agente no pudo evitar el daño; en el estado de necesidad pudo, pero sólo a costa de sufrir un mal mayor. Al igual que la fuerza mayor, el estado de necesidad puede presentarse también en sede contractual. En cuanto a su fundamento normativo, debe advertirse una carencia: nuestra legislación no contempla esta institución para efectos civiles. El Código Penal sí la establece como eximente, en el número 7 de su **artículo 10**. De modo que, para acogerla en sede civil, debe asimilársela a alguna otra situación reglamentada, como la ausencia de culpa, el caso fortuito o la fuerza mayor. Esta ausencia de regulación explica, dicho sea de paso, por qué su construcción es enteramente doctrinaria y jurisprudencial.

Y en cuanto a sus efectos, rige una regla de la mayor importancia práctica: el estado de necesidad excluye la acción indemnizatoria de la víctima por el daño ocasionado, pero no obsta al ejercicio de la acción restitutoria, pues el derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de quien salva un bien propio con cargo a un patrimonio ajeno. **RODRÍGUEZ GREZ** precisa el alcance de esa restitución: la responsabilidad no se extenderá a todos los perjuicios sufridos, sino única y exclusivamente a la compensación de los daños materiales que haga posible restaurar el equilibrio existente entre ambos patrimonios antes de que surgiera el estado de necesidad. **BARROS** añade la explicación dogmática de esa limitación, que enlaza directamente con el Eje 3: ello es resultado de que la acción de quien sufre el daño es restitutoria, impide el enriquecimiento sin causa, y no indemnizatoria. He aquí, entonces, una nueva aplicación de la distinción que allí se estableció: no se mide por el daño de la víctima, sino por el provecho del beneficiado.

7. CUARTA CAUSAL: LA LEGÍTIMA DEFENSA

La legítima defensa opera en derecho civil de modo análogo a como lo hace en derecho penal. Acúa en legítima defensa quien ocasiona un daño obrando en defensa de su persona o derechos, a

condición de que concurran las siguientes circunstancias: que la agresión sea actual e ilegítima, de modo que no cabe invocar la causal frente a una agresión ya consumada, hipótesis que sería de venganza, ni frente a una agresión legítima, como la del receptor que traba embargo; que no haya mediado provocación suficiente por parte del agente, pues quien provocó la agresión no puede esculparse en ella; que la defensa sea necesaria y proporcionada al ataque, requisito que reproduce, en esta sede, la exigencia de emplear el medio menos dañino que ya se examinó a propósito del estado de necesidad; que el daño se haya producido a causa de la defensa, esto es, que exista relación causal entre una y otro; y que la defensa se dirija contra el agresor, y no contra terceros, pues el daño causado a un tercero inocente no queda cubierto por esta causal, sino a lo sumo por el estado de necesidad. Debe formularse, para cerrar, una advertencia procesal de considerable importancia práctica, que enlaza con el Eje 2 y que suele olvidarse. Lo usual será que el demandado oponga la legítima defensa como causal eximente de responsabilidad penal, en el juicio en que se investigue esa responsabilidad. Pues bien: aun cuando la excusa sea acogida en sede penal, la absolución no producirá cosa juzgada en materia civil, en virtud de lo dispuesto en el **artículo 179** del Código de Procedimiento Civil. Y la razón es la ya conocida: la absolución fundada en una circunstancia eximente de responsabilidad criminal está expresamente excluida por la primera circunstancia de esa norma. El demandado que fue absuelto penalmente por legítima defensa deberá, por tanto, volver a acreditarla en el juicio civil.

DATO DE GRADO

Si la antijuridicidad es o no un elemento autónomo

Este eje encierra una tensión que atraviesa todas sus cuestiones particulares, y que conviene formular con precisión porque en ella se juega el punto más alto de la respuesta. La disputa sobre la autonomía de la antijuridicidad parece, a primera vista, un debate de arquitectura sin consecuencias. Y en gran medida lo es: quien mata en legítima defensa no responde, sostenga uno que faltó la antijuridicidad (**RODRÍGUEZ GREZ, CORRAL**) o que faltó la culpa (**BARROS**). Pero la disputa deja de ser inocua apenas se advierte lo que cada construcción implica. Si la antijuridicidad es autónoma, entonces las causales de justificación son defensas que operan sobre un hecho ya calificado de culpable: primero se establece que el demandado obró con culpa, y luego se examina si alguna circunstancia legitima ese obrar. La carga de invocarlas y acreditarlas es del demandado, y el juicio se estructura en dos tiempos. Ésta es, además, la construcción que mejor se acomoda al hecho de que las causales de justificación operen también en la responsabilidad estricta, donde por definición no hay juicio de culpa: si la justificación excluyera la culpa, no se advertiría cómo podría funcionar allí donde la culpa es irrelevante. Si, en cambio, la culpa es la ilicitud, **BARROS**, entonces las causales de justificación no son defensas externas, sino elementos internos del juicio de culpa: forman parte de la determinación del estándar de conducta debida. Preguntar si hubo legítima defensa es preguntar qué habría hecho el hombre prudente colocado en esa situación. Esta construcción tiene la virtud de la economía conceptual, evita duplicar juicios que en el derecho chileno recaen sobre lo mismo, y de explicar por qué el catálogo de causales no está regulado en la ley civil: no hace falta, porque todas ellas se reducen a la pregunta única por la razonabilidad de la conducta. El punto decisivo, y el que conviene explotar en el examen, es que el propio **RODRÍGUEZ GREZ** ofrece la mejor prueba de que la disputa sí tiene consecuencias. Su tesis sobre el abuso del derecho, quien ejerce un derecho no incurre en responsabilidad cualquiera sea su posición subjetiva, dolosa o culpable, siendo un “error craso” sostener lo contrario, es la conclusión rigurosa de su premisa: si la antijuridicidad es autónoma y consiste en la contradicción con el ordenamiento, entonces quien obra dentro de su derecho jamás es antijurídico, por perversa que sea su intención. Y por eso debe explicar el abuso como una apariencia jurídica, esto es, como un obrar de facto y no de iure: no hay ejercicio abusivo del derecho, sino simulación de ejercicio. La construcción es coherente, pero paga un precio alto, porque niega la existencia misma de la figura que pretende explicar. **ALESSANDRI**, en cambio, al reducir el abuso a una culpa cometida en el ejercicio del derecho, resuelve el problema con las reglas comunes, pero incurre en el defecto que **BARROS** denuncia: si cualquier ejercicio negligente configurara abuso, el derecho subjetivo quedaría desprovisto de sus características esenciales, y en particular de la facultad del titular de ejercerlo según su contenido. Un derecho que sólo puede ejercerse con la máxima diligencia respecto de los intereses ajenos ya no es un derecho, sino una carga. De ahí la superioridad de la solución de **BARROS**, que exige para el abuso una especial calificación de la culpa: el acto debe ser contrario a la buena fe o a las buenas costumbres. Esta fórmula conserva la figura del abuso, contra **RODRÍGUEZ GREZ**, sin disolver el derecho subjetivo en un deber genérico de cuidado, contra **ALESSANDRI**. Y proporciona, además, el criterio operativo para los casos de colisión de derechos, que son hoy los más importantes de la materia: el ejercicio de un derecho justifica el daño sólo en la medida en que ese derecho se considere de mayor entidad que el

bien jurídico lesionado, lo que remite a una ponderación de intereses y, en último término, a los valores de cada sociedad. La discusión sobre libertad de expresión y honra no se resuelve, entonces, con la lógica formal de **PLANIOL**, sino sopesando.

8. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el fundamento normativo: la responsabilidad exige que el daño provenga de un comportamiento objetivamente ilícito, según se desprende de los **artículos 1437**, “hecho que ha inferido injuria o daño”, y 2284 del Código Civil, y esa ilicitud puede fundarse en la infracción de un deber legal expreso o en la transgresión del principio *alterum non laedere*. En segundo lugar, la discusión sobre su autonomía: la doctrina nacional mayoritaria subsume la antijuridicidad en la culpabilidad, si hay dolo o culpa, hay ilicitud, o en el daño, sólo se indemniza el daño injusto; **BARROS** la niega expresamente, sosteniendo que la culpa es sinónimo de ilicitud y que el concepto objetivo de culpa comprende ya las condiciones de la antijuridicidad, con el argumento comparado de que en Alemania sí es requisito autónomo (**artículo 823** del BGB) porque allí se exige la lesión de un derecho subjetivo y no de un mero interés; **CORRAL** y **RODRÍGUEZ GREZ** sostienen lo contrario, pues puede haber culpa sin ilicitud y daño causado justificadamente. Debe mencionarse el ilícito civil típico y la doble lectura que admite: indicio de antijuridicidad para **CORRAL**, funcionamiento análogo a la responsabilidad objetiva para **RODRÍGUEZ GREZ**. En tercer lugar, las causales de justificación: no están reguladas en la ley civil, a diferencia del **artículo 10** del Código Penal, y **ALESSANDRI** funda su existencia en los principios generales de los **artículos 2284** y **2314**. Su función, según **BARROS**, es servir de excusa razonable para el hombre prudente. Son cuatro, y debe advertirse que **ALESSANDRI** agrega el caso fortuito, la violencia, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, los cuales, sin embargo, no excluyen la ilicitud, sino la voluntariedad o la causalidad, como lo confirma el propio **ALESSANDRI** al exigir que el caso fortuito sea la “causa única” del daño. Enseguida, cada causal. Los actos autorizados por el derecho, con sus tres especies: el ejercicio de un derecho, el restaurante que compite, el litigante que pierde, cuyo límite es el abuso del derecho, materia en la que debe exponerse la negación de **PLANIOL**, la tesis funcional de **JOSSERAND**, la reducción a la culpa de **RIPERT**, los **MAZEAUD**, **ALESSANDRI** y **DUCCI**, la peculiar posición de **RODRÍGUEZ GREZ**, el abuso es apariencia jurídica, un obrar de facto, y la exigencia de **BARROS** de una especial calificación de la culpa como acto contrario a la buena fe o a las buenas costumbres, con el anclaje normativo del **artículo 19** N° 24 de la Constitución, de los **artículos 582** y **583** y de los **artículos 2110** a **2112** del Código Civil, y la jurisprudencia que exige ánimo manifiesto de perjudicar; el cumplimiento de un deber legal, con el problema de las órdenes de autoridad, cuyo límite es la ilegalidad manifiesta, precisando **ALESSANDRI** que la excusa no cubre la forma en que la orden se ejecuta; y los usos normativos, *lex artis* médica, reglas del juego deportivo, donde el límite está dado por los deberes de cuidado de cada actividad.

El consentimiento de la víctima, con sus límites de los **artículos 1461**, **1465** y **12** del Código Civil, y la distinción decisiva entre renuncia de un derecho y simple aceptación de un riesgo razonable, piloto de pruebas, sujeto de experimentos farmacológicos, admisible incluso respecto de bienes indisponibles, porque la autonomía no obliga a la víctima al mismo nivel de cuidado respecto de sí

misma que respecto de terceros; con el límite de que un riesgo temerario configura verdadera disposición; con la exigencia de deberes de información sobre la intensidad y probabilidad del riesgo, pues no asume voluntariamente un riesgo quien no está en condiciones de medirlo; y con la advertencia de que la renuncia posterior al daño es plenamente válida, porque recae sobre un crédito patrimonial y no sobre la persona. El estado de necesidad, con sus dos requisitos, que el peligro no tenga origen en acción culpable del que lo invoca, y que no existan medios menos dañinos, ilustrado con el contraste jurisprudencial entre el caso del aguardiente derramado para contener un incendio, donde se eximió de responsabilidad, y el de los cajones de cerveza arrojados al mar para sustraerlos de unos huelguistas, donde el Fisco respondió porque no se acreditó que fuese el medio necesario y único; su diferencia con el caso fortuito, pues aquí el hecho es imprevisto pero no irresistible; su falta de consagración civil, que obliga a asimilarlo a otras figuras; y su efecto característico: excluye la acción indemnizatoria pero no la restitutoria, que se mide por el enriquecimiento y no por el daño. Y la legítima defensa, con sus requisitos, agresión actual e ilegítima, ausencia de provocación suficiente, necesidad y proporcionalidad de la defensa, relación causal, y que se dirija contra el agresor, cerrando con la advertencia de que su acogida en sede penal no produce cosa juzgada civil conforme al **artículo 179** del Código de Procedimiento Civil, de modo que deberá acreditarse nuevamente en el juicio de responsabilidad. Cerrar con la tensión: la disputa sobre la autonomía de la antijuridicidad es más de arquitectura que de resultado, pero no es inocua, y la mejor prueba es el abuso del derecho: **RODRÍGUEZ GREZ** debe negar la figura misma para ser coherente con su premisa; **ALESSANDRI**, al reducirla a culpa, arriesga vaciar el derecho subjetivo de contenido; y sólo la exigencia de una calificación especial de la culpa, como contrariedad a la buena fe, permite conservar la figura sin disolver el derecho.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 7. La antijuridicidad y las causales de justificación**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

H. LA CULPABILIDAD: DOLO Y CULPA

No basta con que el hecho sea antijurídico para que nazca la obligación de indemnizar: es preciso, además, que pueda dirigirse un juicio de reproche personal a quien lo ejecutó. Este es el sentido de la culpabilidad como elemento de la responsabilidad extracontractual, y su fundamento normativo se encuentra en el mismo conjunto de disposiciones que ya sirvió para fundar la exigencia de antijuridicidad: el **artículo 1437** del Código Civil, que menciona el hecho que ha inferido injuria o daño como fuente de las obligaciones, y el **artículo 2284**, que distingue, dentro de los hechos ilícitos, aquellos cometidos con intención de dañar, que constituyen delito, de aquellos meramente culpables, que constituyen cuasidelito. El **artículo 2314**, por su parte, impone a quien ha cometido un delito o cuasidelito la obligación de indemnizar el daño causado.

De estas normas se sigue algo más que la exigencia de un reproche: se sigue una *summa divisio* dentro del ilícito civil, según que el reproche se funde en dolo o en culpa. La pregunta que organiza este eje es, entonces, doble. En primer lugar, qué se entiende por cada uno de esos conceptos y cómo se determinan en concreto: el dolo, exigiendo indagar la subjetividad del autor; la culpa, exigiendo compararla con un patrón de conducta. En segundo lugar, qué consecuencias prácticas se siguen de calificar un ilícito como delito o como cuasidelito, puesto que, si bien ambos generan la misma obligación indemnizatoria, no son en todo equivalentes.

La materia tiene, además, una dimensión de método que conviene explicitar desde ya. La responsabilidad civil por culpa, que es, según se vio en el Eje 4, el régimen general y supletorio del derecho chileno, ha experimentado una evolución que la aleja del reproche moral propio del derecho penal y la acerca a un juicio de comparación objetiva. Entender esa evolución, y las tensiones que deja sin resolver, es indispensable para comprender por qué la culpa civil, a pesar de llamarse subjetiva en el lenguaje corriente, no exige indagar el fuero interno del agente.

1. LA EXIGENCIA DE CULPABILIDAD Y LA DISTINCIÓN ENTRE DELITO Y CUASIDELITO CIVIL

El hecho voluntario examinado en el Eje 6, y la antijuridicidad examinada en el Eje 7, no bastan por sí solos para comprometer la responsabilidad de su autor. Es necesario, adicionalmente, que ese hecho ilícito le sea reprochable, en el sentido de haber sido ejecutado con infracción a un deber de conducta que le era exigible. Ese reproche admite dos grados: si el agente obró con la intención positiva de causar el daño, hay dolo, y el ilícito se llama delito civil; si obró sin esa intención, pero incurriendo en negligencia, hay culpa, y el ilícito se llama cuasidelito civil.

Conviene precisar de inmediato que esta distinción, capital en materia penal, tiene en sede civil una relevancia mucho más acotada. Delito y cuasidelito generan idéntica obligación de indemnizar todo el daño causado, sin que el grado de reproche incida, como regla general, en la extensión de la reparación. La distinción, sin embargo, no carece de consecuencias, y son tres las que la doctrina identifica de manera constante.

La primera consiste en que solo el dolo autoriza la acción contra el tercero que, sin haber sido autor ni cómplice del delito, ha obtenido provecho de él. Los **artículos 1458** inciso segundo y 2316 inciso segundo del Código Civil habilitan a la víctima para dirigirse contra quien se ha beneficiado

del dolo ajeno, hasta el monto de ese provecho. Se trata de una acción de naturaleza restitutoria y no propiamente indemnizatoria, cuyo desarrollo y límites, en particular la prueba del beneficio y de la relación de causalidad entre el ilícito y el provecho obtenido, corresponde examinar al tratar la legitimación pasiva en el Eje 21; baste aquí con dejar establecido su fundamento y con anotar que la acción restitutoria contra el tercero beneficiado no exige que este haya participado del ilícito, sino solamente que se haya aprovechado de él a sabiendas o, cuando menos, sin título que lo justifique.

La segunda consiste en que las cláusulas de irresponsabilidad, admisibles en general respecto de la culpa, no proceden respecto del dolo: el **artículo 1465** del Código Civil declara que la condonación del dolo futuro no vale. El fundamento es de orden público: permitir que un contratante se exonere anticipadamente de su propio dolo equivaldría a autorizar de antemano la comisión de un ilícito intencional, lo que el ordenamiento no tolera aun cuando sí tolere, dentro de ciertos límites, la exoneración anticipada de la culpa.

La tercera consiste en que determinados ilícitos típicos exigen dolo, de manera que la sola negligencia no basta para configurarlos. El ejemplo constante en la doctrina nacional es el del consejo malicioso, a que se refieren los **artículos 1768 y 2119** del Código Civil: quien aconseja la celebración de un acto o contrato no responde por la sola circunstancia de haber errado en su consejo, sino únicamente si lo dio con la intención de perjudicar a quien lo siguió.

2. EL DOLO

El **artículo 44** del Código Civil, situado en el Título Preliminar y por ello de alcance general a todo el ordenamiento civil, define el dolo como "la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro". Esta definición única se proyecta sobre los tres ámbitos en que el dolo cumple una función relevante en derecho civil: como vicio del consentimiento, como agravante de la responsabilidad contractual y como elemento del delito civil. Se trata, según explica la teoría unitaria del dolo, de una y la misma noción en los tres casos: la intención del agente de causar daño a otro, cualquiera sea el contexto en que esa intención se manifieste.

Definido en estos términos, el dolo civil es un concepto extremadamente estricto, que corresponde únicamente al dolo directo: aquel en que el autor no solo ha previsto y aceptado el daño, sino que además lo ha querido como resultado de su acción. La definición legal deja fuera, en consecuencia, el dolo eventual, esto es, la hipótesis en que el agente se representa el daño como una posibilidad de su conducta, sin perseguirlo directamente, pero aceptándolo para el caso de que llegue a producirse. La Corte Suprema ha reconocido esta figura, señalando en un fallo de 21 de abril de 1960 que existe dolo eventual cuando el sujeto se representa la posibilidad de un resultado que no se proponía causar, pero que en definitiva acepta para el caso de que llegue a producirse. Años más tarde, en sentencia de 3 de junio de 2002, la misma Corte calificó de dolosa, bajo la forma de dolo eventual, la conducta de quien disparó un arma de alto poder ofensivo contra una persona sin perseguir su muerte, pero habiéndosela representado como posibilidad y persistiendo, no obstante, en su acción.

La exclusión legal del dolo eventual no es, sin embargo, tan drástica en la práctica como podría suponerse a partir del tenor del **artículo 44**. **RODRÍGUEZ GREZ** ha sostenido que una visión mo-

derna del derecho exige incorporar el dolo eventual a la definición legal, argumentando que debe tenerse por dolosa toda conducta en que el autor haya previsto el daño como cierto o probable y haya admitido su realización pudiendo evitarlo. La posición mayoritaria no sigue este camino de ampliar la definición legal, pero llega a un resultado práctico equivalente por una vía distinta: la asimilación de la culpa grave al dolo que dispone el mismo **artículo 44** en su inciso final. **BARROS** ha explicado con particular claridad que la distinción entre dolo directo y dolo eventual carece de importancia práctica relevante, precisamente porque la culpa grave, el descuido extremo, que consiste en no emplear siquiera el cuidado que las personas negligentes emplean en sus propios negocios, se encuentra en la frontera con el dolo y recibe, por disposición del **artículo 44**, sus mismos efectos. De este modo, quien se representa un daño altamente probable y persiste en su conducta responde igual sea que se entienda que aceptó el resultado, dolo eventual, o que simplemente lo ignoró con extrema desconsideración por el interés ajeno, culpa grave, porque el derecho civil no exige, para estos efectos, distinguir entre ambas hipótesis.

La jurisprudencia exige, en todo caso, que el dolo se traduzca en actos o manifestaciones de voluntad positivos y formalmente determinados a causar el daño reclamado, según lo resolvió la Corte de Santiago en fallo de 1 de enero de 1925, confirmado por la Corte Suprema al conocer de un recurso de casación en el fondo el 3 de marzo de 1927. La exigencia de intencionalidad no se limita, sin embargo, al propósito exclusivo de dañar por dañar: la Corte de Santiago, en sentencia de 21 de abril de 1993, calificó de dolosa la conducta de quien incurrió en una simulación absoluta en perjuicio de un acreedor, no obstante que la finalidad perseguida por el simulante era evitar la ejecución forzada de sus bienes y no, en rigor, causar un mal a su acreedor por el solo placer de causarlo. De estos fallos se sigue que el dolo civil se satisface con la utilización consciente del perjuicio ajeno como medio para un fin propio, y no exige que el perjuicio mismo sea el fin último de la conducta.

A diferencia de la culpa, que según se dirá se aprecia en abstracto, el dolo se aprecia in concreto, porque su determinación exige examinar la subjetividad del agente: su conciencia, su voluntad, los móviles que guiaron su conducta. De ello se sigue una consecuencia probatoria de importancia práctica considerable: el dolo no se presume jamás, y su prueba corresponde íntegramente a quien lo alega, sin que existan, a diferencia de lo que ocurre con la culpa, presunciones legales que relevan a la víctima de esa carga.

3. LA CULPA

3.1. Concepto y fundamento legal

A diferencia de lo que ocurre con el dolo, el Código Civil no contiene, entre las disposiciones sobre delitos y cuasidelitos, una definición especial de la culpa aplicable a la responsabilidad extracontractual. Rige, en consecuencia, la definición general del **artículo 44**, situada también en el Título Preliminar, que describe tres grados de culpa, grave, leve y levísima, tomando como referencia sendos patrones abstractos de conducta: el hombre de poca prudencia para la culpa grave, el buen padre de familia para la culpa leve, y el hombre juicioso o esmeradamente cuidadoso para la culpa levísima. Puede definirse la culpa, siguiendo esta línea, como la omisión de la diligencia a

que el agente estaba jurídicamente obligado, o bien como la falta de aquel cuidado que las personas prudentes emplean ordinariamente en sus propios negocios.

Esta construcción, de raíz romana, se aparta deliberadamente de un concepto moral de culpa asociado a la idea de reproche personal. La evolución de la noción hacia la objetividad no es un fenómeno reciente ni exclusivamente chileno: el propio derecho romano describió la culpa mediante patrones abstractos de conducta, y solo bajo la influencia posterior del derecho canónico se transformó transitoriamente en un criterio moral, próximo a la idea de pecado, antes de que el derecho moderno retomara la objetividad clásica. El fundamento de esa opción es tan antiguo como sencillo: cada cual debe hacerse cargo de sus propias limitaciones, compensándolas con un actuar diligente, de manera que ni la inexperiencia ni la impericia personal sirven de excusa frente a quien confió razonablemente en que se emplearía el cuidado exigible.

3.2. Apreciación en abstracto y consideración de las circunstancias

La doctrina nacional es prácticamente unánime en sostener que la culpa extracontractual se aprecia en abstracto: se compara la conducta efectiva del agente con la que habría observado, en su lugar, una persona prudente, el buen padre de familia del **artículo 44**, y no con la conducta que ese mismo agente, atendidas sus capacidades personales, habría podido desplegar. La apreciación en concreto, propia del dolo, es ajena a este juicio.

Ahora bien, que la culpa se aprecie en abstracto no significa que se prescinda por completo de las circunstancias del caso. El estándar del hombre prudente no es una vara fija, sino una vara que se aplica considerando la situación externa en que actuó el agente y el rol social o la calidad que este invocaba. Así, para juzgar si un médico obró con la diligencia debida al practicar una intervención de urgencia, se compara su conducta con la de un médico prudente colocado en esa misma situación de urgencia, y no con la de un médico prudente que dispusiera de tiempo y recursos ilimitados; el nivel de cuidado exigible a quien atiende espontáneamente a un accidentado en la vía pública no es el mismo que el exigible a quien opera con dos meses de anticipación en pabellón. Esta consideración de las circunstancias externas y del rol asumido por el autor no convierte la apreciación en subjetiva, porque sigue tratándose de una comparación con un tipo abstracto, el profesional prudente en esa situación, y no con las capacidades reales del sujeto concreto.

Esta precisión permite disolver una confusión terminológica frecuente, que **BARROS** denuncia con particular insistencia: la costumbre de llamar "responsabilidad subjetiva" a la responsabilidad por culpa, en contraposición a la responsabilidad objetiva o estricta. Dos sentencias ilustran el error con nitidez: la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 21 de agosto de 1940, sostuvo que el estatuto de los delitos y cuasidelitos civiles se basa en la imputabilidad del que ejecuta el hecho ilícito y en la responsabilidad subjetiva; la Corte de Apelaciones de La Serena, en sentencia de 3 de mayo de 1978, reiteró que el principio de la responsabilidad subjetiva inspira las normas sobre indemnización de perjuicios, salvo los casos excepcionales de responsabilidad legal objetiva. Ambas resoluciones incurren en el mismo desliz: la responsabilidad por culpa es objetiva precisamente porque no exige un juicio de reproche personal al sujeto, sino la comparación de su conducta con un patrón general y abstracto; llamarla subjetiva confunde la circunstancia histórica de que la culpa alguna vez exigió ese reproche personal con la estructura que efectivamente tiene hoy el juicio de culpabilidad en el derecho chileno. Como se explicará en el apartado siguiente, esta mis-

ma tensión entre objetividad de principio y residuos de subjetividad reaparece, bajo otra forma, en la discusión sobre el grado de culpa del que se responde.

A falta de reglas generalmente aceptadas que fijen de antemano el contenido del deber de cuidado en cada actividad, su determinación concreta es una tarea esencialmente argumentativa, que exige ponderar los bienes e intereses en conflicto, de un lado, la libertad de actuar; del otro, el derecho de la víctima a no sufrir daños injustos, y que se sirve, para ello, de criterios que la jurisprudencia nacional y comparada ha ido decantando caso a caso, sin que ninguno opere de manera aislada ni excluyente de los demás. Uno de esos criterios es la intensidad del daño previsible: el descuido asociado a daños severos a la integridad física se juzga con mayor rigor que aquel del que solo se sigue un perjuicio material, al punto que la sola magnitud del daño ha servido, en ciertos casos, para presumir la culpa e invertir el peso de la prueba en contra del demandado. Los accidentes ferroviarios resueltos por la jurisprudencia nacional durante la primera mitad del siglo veinte ilustran con elocuencia este criterio: frente a la colisión de dos trenes de una misma empresa, se ha resuelto que el solo hecho del choque revela que sus empleados no emplearon la prudencia debida, porque nada justifica el choque de dos convoyes que debían movilizarse en condiciones de no colisionar entre sí, llegando la jurisprudencia de la época a sostener que la culpa delictual civil origina responsabilidad aunque sea levísima, en un pasaje que ilustra por sí solo cómo la aplicación rigurosa de las presunciones de culpabilidad puede situar a la responsabilidad por culpa en el límite mismo de la responsabilidad estricta.

Un segundo criterio es la probabilidad de que el daño se produzca, variable distinta de la previsibilidad en sentido estricto: mientras esta última se satisface con que el resultado dañoso pudiera representarse como posible, la probabilidad mide el grado de esa posibilidad, exigiendo un cuidado tanto mayor cuanto más probable sea el resultado lesivo dada la conducta que se despliega. Un tercer criterio, de especial interés porque conecta la determinación del deber de cuidado con consideraciones que exceden lo puramente técnico, es el valor social de la actividad que provoca el daño: el cuidado exigible para ejecutar una acción socialmente neutra suele ser mayor al que se demanda tratándose de una acción de reconocido valor social. La Corte Suprema de los Estados Unidos, al fallar en 1964 el caso *New York Times Co. contra Sullivan*, resolvió que, atendido el valor constitutivo de la libertad de expresión, los medios de prensa solo responden por los daños causados a la honra de las personas cuando actúan con completa desaprensión respecto de la verdad de lo informado, esto es, conforme a un estándar próximo a la culpa grave y no a la culpa leve ordinaria; el fallo, aunque extranjero, ilustra con nitidez cómo el valor social atribuido a una actividad puede elevar el umbral de cuidado exigible para que nazca la responsabilidad. El mismo criterio explica el tratamiento benigno que reciben los llamados casos de rescate: quien interviene espontáneamente para socorrer a la víctima de un accidente en la vía pública, quien causa daños a una propiedad ajena para contener un incendio, o quien se arroja al agua para auxiliar a alguien que se ahoga, son juzgados con un rigor atenuado, precisamente por el valor social que reviste su intervención.

3.3. El estándar de cuidado: culpa leve

Parece razonable sostener que, en materia extracontractual, se responde de culpa leve: el descuido en que incurre quien no emplea el cuidado que un hombre prudente, el buen padre de familia, emplea ordinariamente en sus propios negocios. Esta conclusión se apoya en el propio **artículo 44** inciso segundo del Código Civil, conforme al cual "culpa o descuido, sin otra calificación, significa

culpa o descuido leve", de manera que, ante la ausencia de una calificación especial en las normas sobre delitos y cuasidelitos, corresponde aplicar por defecto ese grado intermedio.

Frente a esta posición, una parte de la doctrina nacional ha sostenido, siguiendo un antiguo proverbio recogido también por la doctrina francesa, que en materia extracontractual se responde de toda culpa, incluida la levisima, porque la graduación tripartita del **artículo 44** tendría una aplicación estrictamente contractual y no se proyectaría al ámbito de los delitos y cuasidelitos. El argumento no carece de apoyo textual: la clasificación de la culpa se formula, en efecto, a propósito de las obligaciones contractuales, y solo se explica esa ubicación por el escaso desarrollo que la responsabilidad extracontractual había experimentado al tiempo en que se redactó el Código. Con todo, esta explicación histórica no priva de generalidad a la norma del **artículo 44**, que el propio legislador enuncia sin referirla a una materia determinada, de manera que su extensión a los delitos y cuasidelitos no requiere de un texto especial que la autorice: basta con que no exista uno que la excluya.

La discusión, aunque de apariencia dogmática, tiene consecuencias prácticas considerables, que se examinarán en el apartado siguiente.

3.4. La previsibilidad como elemento de la culpa

La culpa supone siempre la previsibilidad de las consecuencias dañosas de la conducta, porque el modelo del hombre prudente remite a una persona que delibera y actúa razonablemente, y lo imprevisible, por definición, no puede ser objeto de deliberación. La previsibilidad es, así, la línea que separa la culpa del caso fortuito examinado en el Eje 6: mientras este último se caracteriza por consecuencias imprevistas e irresistibles que escapan a toda posibilidad de deliberación, la culpa exige que el daño causado haya podido preverse.

La jurisprudencia nacional ha reconocido de manera constante esta exigencia. La Corte Suprema, en fallo de 24 de octubre de 1963, definió la culpa como la producción de un resultado que pudo y debió ser previsto y que, por negligencia, imprudencia o impericia del agente, causó un efecto dañoso, reiterando el mismo concepto en sentencia de 15 de septiembre de 1964. En fallo de 17 de octubre de 1972, sostuvo que es de la esencia de la culpa la previsibilidad, y que no hay culpa cuando el hecho no pudo razonablemente ser previsto. Y en sentencia de 23 de enero de 1975, definió la culpa extracontractual como el no evitar aquello que pudo preverse y evitarse, esto es, como una negligencia consistente en no haber anticipado las consecuencias dañosas de la propia conducta.

Que la previsibilidad sea condición de la culpa tiene, además, una consecuencia sobre la extensión de la reparación: si el autor solo pudo obrar imprudentemente respecto de los daños que le era dado prever, son en principio esos daños previsibles, y no otros, los que quedan comprendidos en su obligación de indemnizar.

3.5. Culpa infraccional

Existe culpa infraccional cuando los deberes de cuidado que se estiman infringidos han sido establecidos, con antelación al hecho dañoso, por el legislador o por otra autoridad dotada de potestad

normativa, mediante una ley, un reglamento o una ordenanza. Los ejemplos más frecuentes en la práctica se encuentran en la Ley N° 18.290, de Tránsito, típicamente, los límites de velocidad y las reglas sobre prioridad de paso, así como en la normativa sobre seguridad en instalaciones peligrosas, sobre control de medicamentos y en la legislación medioambiental.

El principio que gobierna esta categoría es que la infracción de la norma de cuidado torna per se ilícito el acto que la contraviene, sin que sea necesario efectuar un juicio adicional de reproche. Como explica **ALESSANDRI**, cuando el accidente se produce a consecuencia de la infracción de una de estas reglas, existe culpa por el solo hecho de haberse ejecutado el acto prohibido o de no haberse ejecutado el ordenado por la ley o el reglamento, porque esa infracción revela, por sí misma, que se omitieron las medidas de prudencia que el legislador o la autoridad estimaron necesarias para evitar el daño. Con todo, la sola infracción normativa no basta para dar por establecida la responsabilidad: es indispensable, además, que exista una relación de causalidad directa entre la infracción y el daño, de manera que este se haya producido precisamente a consecuencia de aquella.

3.6. Culpa por omisión

La culpa puede consistir en un obrar positivo indebido, culpa de acción o de comisión, o en un dejar de obrar debiendo hacerlo, culpa por omisión o abstención. La distinción entre ambas modalidades no es meramente descriptiva, porque el riesgo que subyace a cada una es de naturaleza distinta: en la acción, el daño es resultado de un riesgo creado por el propio agente; en la omisión, el riesgo es autónomo, esto es, existe con independencia de la conducta de quien luego se abstiene de intervenir. De esa diferencia cualitativa se sigue, a su vez, una distinción entre dos categorías de omisión.

La primera es la omisión en la acción, que se presenta dentro del ámbito más amplio de una conducta positiva: quien ejecuta una acción omite adoptar, dentro de ella, la precaución que las circunstancias exigían, como ocurre con el automovilista que vira sin señalizar previamente su intención de hacerlo. Se trata, en rigor, de un defecto de la acción, y no de un delito o cuasidelito autónomo de omisión, por lo que su tratamiento no difiere del de la culpa por acción propiamente dicha. La casuística nacional es abundante: se ha resuelto que incurre en esta forma de culpa quien no señaliza ni cierra el sitio en que ejecuta excavaciones en la vía pública, según fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 30 de noviembre de 1907; quien olvida reponer la tapa de un pozo en reparación sin advertir de su existencia, conforme a sentencia de la misma Corte de 3 de diciembre de 1948; el maquinista que omite advertir con campana y silbato la aproximación del tren, según fallo de la Corte Suprema de 15 de octubre de 1920; el dueño de un edificio dañado por un sismo que omite ejecutar en él las reparaciones necesarias, resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago el 10 de septiembre de 1940; y el anestesista que abandona a su paciente durante el efecto de la anestesia, permitiendo que sobrevenga un daño cerebral irreversible a consecuencia de un paro cardíaco, según sentencia de la Corte Suprema de 4 de octubre de 1984.

La segunda categoría es la omisión propiamente tal, en que el agente se abstiene de actuar frente a un riesgo enteramente autónomo, que nada tiene que ver con su propia conducta, pudiendo evitar o disminuir el daño. Rige aquí, como principio general, la máxima según la cual la ley obliga a obrar con prudencia, pero no impone un deber de caridad: a nadie puede exigírsele que sacrifique su per-

sona o sus bienes en beneficio ajeno, y por ello el hombre prudente no tiene, como regla, un deber genérico de actuar para evitar daños a terceros. La responsabilidad por la pura abstención es, en consecuencia, excepcional, y solo se genera en tres hipótesis: cuando la omisión es dolosa, porque el dolo nada justifica; cuando la ley ordena expresamente ejecutar el acto omitido, configurándose entonces una culpa infraccional por omisión; y cuando, atendidas las circunstancias, existe un deber especial de cuidado hacia la víctima, fundado en una relación de cercanía entre esta y quien omite actuar.

Este eje anunció ya, al examinar la dimensión material del hecho voluntario, la razón por la cual la omisión está sujeta a exigencias más estrictas que la acción para dar lugar a responsabilidad: quien nada hace no crea riesgo alguno, de manera que hacerlo responder por un daño que no provocó exige una razón adicional, un deber previo de intervenir, que la mera abstención no proporciona por sí sola. De no exigirse ese deber especial, cualquier persona sería responsable de todos los males que pudo evitar y no evitó, lo que suprimiría la libertad de acción que la responsabilidad civil está llamada a garantizar y no a restringir. Por eso la responsabilidad por omisión solo procede, además de los casos en que la propia ley establece un deber positivo de conducta, cuando concurre una razón especial para que el agente debiera cuidar de la víctima.

Esa razón especial no requiere, en todo caso, de un vínculo contractual entre las partes, porque en tal caso la responsabilidad quedaría de todos modos sujeta a otras reglas. Se trata, más bien, de vínculos que sin dar lugar a una obligación en sentido técnico generan, no obstante, un deber especial de respeto hacia los intereses de un tercero. Los casos más claros se presentan en relaciones de analogía contractual: los deberes del dueño de un establecimiento respecto de quienes acceden a él como clientes; los del fabricante que, luego de introducir un producto en el mercado, descubre en él un defecto capaz de dañar a los consumidores; los del capitán de una nave respecto de sus pasajeros. También ciertos vínculos afectivos, como la amistad, pueden originar un deber semejante, según ocurre cuando dos amigos son víctimas de un mismo asalto y uno de ellos omite el auxilio que habría evitado la muerte del otro. Se reconoce, asimismo, un deber de esta naturaleza en quien intervino sin culpa en un accidente que dejó a uno de los afectados en grave estado, y en quien se encuentra en una posición exclusiva para impedir un mal grave, como el médico que participa circunstancialmente en un siniestro. Lo común a todos estos supuestos es la existencia de una relación especial que, sin fundarse en un contrato, confiere a la víctima la expectativa legítima de ser protegida, expectativa que no puede exigirse, en cambio, como regla general en el ámbito de las relaciones anónimas de la vida social.

La jurisprudencia nacional ofrece un ejemplo elocuente de esta construcción. La Corte Suprema, en sentencia de 28 de enero de 1999, confirmó la responsabilidad de un médico de turno en un hospital que, ante el llamado de un paramédico por una urgencia, se negó a concurrir durante la noche y, visitado luego en su domicilio por los padres de un menor enfermo, también se negó a atenderlo, con la consecuencia de que una afección médicamente tratable derivó en la muerte del niño. La circunstancia determinante en el fallo fue que el médico se encontraba de turno en el hospital al momento de los hechos, lo que revela que el deber especial de actuar no nace de la sola calidad profesional, sino de la posición concreta, de turno, de guardia, de exclusiva disponibilidad, en que el agente se encontraba respecto de la víctima.

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE CULPABILIDAD

La jurisprudencia nacional tendió inicialmente a calificar el juicio de culpabilidad como una cuestión de hecho, entregada a la soberanía de los jueces del fondo. En la actualidad no existe un criterio absolutamente uniforme, aunque se advierte una tendencia creciente a calificarlo como una cuestión de derecho, mientras que la doctrina se manifiesta de manera prácticamente unánime en este mismo sentido, por estimar que la culpa es un concepto normativo, susceptible en consecuencia de revisión por la Corte Suprema mediante el recurso de casación en el fondo.

La distinción que permite conciliar ambas afirmaciones es la que separa la fijación de los hechos de su calificación jurídica. Determinar si hubo o no colisión, si existía o no una señal de "Pare", cuál era la velocidad a la que circulaba el conductor, corresponde privativamente a los jueces del fondo, y sus conclusiones sobre estos puntos escapan al control de casación, salvo que se hayan establecido con infracción de las leyes reguladoras de la prueba. Pero calificar esos hechos ya establecidos, esto es, resolver si ellos configuran dolo, culpa o caso fortuito, es una operación distinta, porque el dolo y la culpa son conceptos legales, definidos por el **artículo 44** del Código Civil, y precisar si unos hechos determinados encuadran o no en esos conceptos legales es, precisamente, la operación que el recurso de casación en el fondo está destinado a controlar.

DATO DE GRADO**El alcance del estándar de cuidado**

El eje entero puede leerse como el despliegue de una misma pregunta bajo dos formas distintas: hasta dónde se extiende, en materia civil, la exigencia de cuidado que pesa sobre cada persona en sus relaciones con los demás. Esa pregunta se plantea, en un primer plano, respecto del límite superior de la culpa, si se responde de culpa leve o de toda culpa, incluida la levísima, y, en un segundo plano, respecto del límite inferior del dolo, si la distinción entre dolo directo y dolo eventual conserva alguna relevancia práctica frente a la asimilación de la culpa grave al dolo. Conviene detenerse en la primera, porque es la que concentra el mayor desacuerdo doctrinario, y advertir después que la segunda expresa, en el fondo, la misma tensión desde el extremo opuesto de la graduación.

La posición que limita la responsabilidad extracontractual a la culpa leve invoca a su favor el propio texto del **artículo 44** inciso segundo, que hace de la culpa leve la calificación por defecto ante la ausencia de una mención especial, y encuentra respaldo adicional en la coherencia interna del sistema: si la culpa se aprecia comparando la conducta del agente con la de un hombre prudente, no se ve razón para exigirle, al mismo tiempo, el nivel de diligencia reservado por el propio **artículo 44** al hombre juicioso en sus negocios más importantes, que es justamente el parámetro de la culpa levísima. Sostener ambas cosas a la vez, apreciación en abstracto según el estándar del hombre prudente, y exigibilidad de un cuidado propio del hombre esmeradamente cuidadoso, incurre en una contradicción interna, porque se trata de niveles de diligencia asimétricos que no pueden predicarse simultáneamente del mismo sujeto de comparación.

La posición contraria, que extiende la responsabilidad hasta la culpa levísima, se apoya en un argumento de origen histórico y sistemático: puesto que la graduación tripartita del **artículo 44** se formuló pensando en la responsabilidad contractual, donde el grado de diligencia exigible varía según a quién beneficie el contrato, su aplicación no se extendería sin más al campo delictual y cuasidelictual, ajeno por completo a esa lógica de beneficio recíproco; de ahí que, fuera del contrato, no habría razón para limitar la responsabilidad a un grado intermedio de cuidado, y correspondería responder de cualquier negligencia, por leve que fuese.

Lo que está en juego detrás de esta disputa, aparentemente técnica, es la cercanía o lejanía entre la responsabilidad por culpa y la responsabilidad estricta. Si se exige culpa levísima, el estándar de conducta debida se acerca al máximo nivel de diligencia concebible, y la diferencia práctica entre responder por negligencia y responder objetivamente, sin necesidad de acreditar negligencia alguna, tiende a desdibujarse: extender la responsabilidad hasta la culpa levísima obligaría, en la práctica cotidiana, a emplear en cada una de las propias actividades el cuidado más esmerado que un hombre juicioso reserva para sus negocios más importantes, lo que llevaría a la responsabilidad por culpa hacia los límites mismos de la responsabilidad estricta examinada en el Eje 4. Si, en cambio, se exige culpa leve, subsiste una zona de riesgos ordinarios de la vida social que cada cual debe tolerar sin derecho a indemnización, y la responsabilidad por culpa conserva una función y una identidad distintas de la responsabilidad objetiva. La jurisprudencia, de hecho, ha tendido a resolver la disputa en la práctica sin

necesidad de zanjarla en el plano dogmático: aun los fallos que declaran adherir a la tesis de la culpa levísima acuden, al momento de definir en concreto el cuidado exigible, al mismo parámetro del hombre prudente o buen padre de familia propio de la culpa leve, lo que sugiere que la controversia tiene menos consecuencias prácticas de las que su formulación teórica haría suponer, aunque no carece por completo de ellas en los casos límite en que el estándar aplicado resulta decisivo para el resultado del juicio.

La misma tensión entre objetividad del estándar y residuos de exigencia subjetiva reaparece, según se anticipó, en el extremo del dolo. Que la ley circunscriba el dolo civil al dolo directo, y que sin embargo sus efectos se extiendan de hecho a la culpa grave por la vía de la asimilación del **artículo 44**, revela una misma preferencia de fondo: la de construir el reproche civil sobre bases primordialmente objetivas, la comparación con un estándar de conducta, y reservar la indagación de la subjetividad del agente, propia del dolo directo, para los casos en que resulte estrictamente indispensable. **RODRÍGUEZ GREZ**, al proponer incorporar el dolo eventual a la definición legal del **artículo 44**, se mueve en la dirección contraria a la que sigue la asimilación con la culpa grave, porque busca ensanchar el concepto subjetivo de dolo en lugar de resolver el problema por la vía objetiva del estándar de cuidado; que la doctrina mayoritaria no haya seguido ese camino, prefiriendo la vía de la culpa grave, confirma que la tendencia dominante en materia de culpabilidad civil es la de minimizar, en todo lo posible, la necesidad de un juicio sobre el fuero interno del autor del daño.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir situando el fundamento normativo de la culpabilidad: la responsabilidad exige, además de un hecho voluntario y antijurídico, que este sea reprochable, sea a título de dolo, intención positiva de dañar, o de culpa, negligencia, según se desprende de los **artículos 1437, 2284 y 2314** del Código Civil, y de esa alternativa se sigue la distinción entre delito y cuasidelito civil, que si bien no incide en la extensión de la reparación, sí determina tres consecuencias: la procedencia de la acción restitutoria contra quien recibe provecho del dolo ajeno (**artículos 1458 y 2316**), la ineficacia de las cláusulas de irresponsabilidad respecto del dolo (**artículo 1465**), y la exigencia de dolo en ciertos ilícitos típicos, como el consejo malicioso (**artículos 1768 y 2119**).

En segundo lugar, el dolo: definido por el **artículo 44** como intención positiva de inferir injuria, corresponde únicamente al dolo directo, con exclusión del dolo eventual reconocido por la jurisprudencia; su relevancia práctica se ve, sin embargo, atenuada porque la culpa grave, el descuido extremo, recibe del mismo **artículo 44** los efectos del dolo, según destaca **BARROS**, aunque **RODRÍGUEZ GREZ** haya propuesto en cambio ampliar la propia definición legal para comprender el dolo eventual. El dolo se aprecia in concreto y no se presume, correspondiendo su prueba íntegramente a quien lo alega.

En tercer lugar, la culpa: omisión de la diligencia debida según el **artículo 44**, apreciada en abstracto conforme al patrón del buen padre de familia, pero considerando las circunstancias externas y el rol social del agente sin que ello la torne subjetiva, de ahí el error, denunciado por **BARROS**, de llamar "subjetiva" a la responsabilidad por culpa. Debe exponerse la discusión sobre el grado de

culpa exigible (leve, según el argumento textual del **artículo 44** inciso segundo, o toda culpa incluida la levísima, según el argumento histórico-sistemático que niega proyección extracontractual a la graduación tripartita), explicando que lo que está en juego es la cercanía de la responsabilidad por culpa a la responsabilidad estricta. Debe mencionarse la previsibilidad como elemento esencial, que distingue la culpa del caso fortuito; la culpa infraccional, con el ejemplo de la Ley de Tránsito y la exigencia adicional de causalidad entre la infracción y el daño; y la culpa por omisión, que exige un deber especial de actuar en beneficio de otro, hilo ya anunciado al examinar el hecho voluntario, ilustrado con los supuestos de relaciones de analogía contractual, vínculos afectivos e intervención fortuita en el accidente ajeno, y con el caso jurisprudencial del médico de turno que se niega a atender una urgencia.

Cerrar con la naturaleza del juicio de culpabilidad como cuestión de derecho, revisable por la vía de la casación en el fondo en cuanto se trate de calificar hechos ya establecidos conforme a los conceptos legales de dolo y culpa, y con la tensión de fondo que atraviesa el eje entero: la disputa sobre el grado de culpa exigible y la disputa sobre la relevancia del dolo eventual son dos caras de una misma pregunta acerca de hasta dónde se extiende, en materia civil, la exigencia de cuidado hacia los demás, resuelta en ambos extremos con una marcada preferencia por la objetividad del juicio por sobre la indagación de la subjetividad del agente.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 8. La culpabilidad: dolo y culpa**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

I. PRUEBA DE LA CULPA Y PRESUNCIONES DE CULPABILIDAD POR EL HECHO PROPIO (ART. 2329)

Que la culpa deba probarse por quien la alega no es una regla neutra: coloca a la víctima en una posición estratégica desventajosa frente al autor del daño, porque por lo general carecerá de los instrumentos para demostrar que este no empleó la diligencia debida y, en los casos más complejos, ni siquiera estará en condiciones de determinar cuál era, en concreto, el deber de cuidado exigible. El Código Civil responde a esta dificultad con un sistema de presunciones de culpabilidad que invierte el peso de la prueba en beneficio de la víctima, sin alterar por ello la naturaleza de la responsabilidad, que sigue fundada en la negligencia o el dolo del demandado.

Ese sistema comprende tres grupos de presunciones: las que se refieren al hecho propio (**artículo 2329**), las que se refieren al hecho de las cosas (**artículos 2323, 2324, 2326, 2327 y 2328**) y las que se refieren al hecho ajeno (**artículos 2320 y 2322**). En rigor, las tres son presunciones de culpabilidad por un hecho del demandado: en la primera, se presume que el daño causado directamente por él se debe a su propia negligencia; en la segunda, que el daño causado por una cosa se debe al descuido de quien la tiene o es su dueño; en la tercera, que el daño ocasionado por otra persona es imputable a la falta de vigilancia de quien la tiene bajo su cuidado. Este eje examina la primera de estas presunciones, dejando las otras dos para su tratamiento en los Ejes 14 y 16, respectivamente.

La pregunta central que organiza el desarrollo es doble. En primer lugar, cuál es el fundamento y el alcance de la presunción del **artículo 2329**, cuya interpretación ha sido objeto de una evolución doctrinal considerable desde que se la consideró una simple repetición del **artículo 2314** hasta que se la reconoció como una verdadera regla de clausura del sistema de presunciones del Código. En segundo lugar, cuál es la naturaleza técnica exacta de esa presunción, cuestión que no es meramente teórica, porque de su respuesta depende cuán exigente es la prueba que el demandado debe rendir para exonerarse.

Conviene anticipar, por último, por qué el legislador no se conformó con la regla general del hecho propio y estimó necesario disponer, además, presunciones específicas para el hecho de las cosas y para el hecho ajeno. La razón se encuentra en la distancia causal entre el demandado y el daño: cuando el propio autor del hecho es quien lo ejecuta directamente, la experiencia permite inferir su negligencia a partir de las circunstancias externas del hecho mismo, según se verá en este eje. Pero cuando el daño lo causa una cosa de la que el demandado es dueño o tenedor, o una persona que se encuentra bajo su cuidado, esa inferencia inmediata se debilita, porque media un tercer elemento, la cosa, o la conducta ajena, entre el demandado y el resultado dañoso, y por eso el Código optó por anclar esas presunciones en un vínculo jurídico expreso y verificable, la propiedad o tenencia de la cosa, la relación de dependencia o cuidado, antes que dejarlas libradas a la sola inferencia fáctica que basta en el caso del hecho propio.

1. PRUEBA DE LA CULPA: REGLAS GENERALES

La culpabilidad, dolosa o culposa, debe ser probada por quien la alega, en aplicación del principio general del **artículo 1698** del Código Civil, según el cual incumbe probar las obligaciones, y, en

este caso, la obligación de indemnizar, a quien reclama su existencia. Quien demanda la indemnización afirma que el demandado incurrió en un acto u omisión doloso o culpable que le causó daño, y debe, en consecuencia, acreditar los elementos constitutivos de esa pretensión, entre ellos la culpa o el dolo del demandado.

La prueba de estos hechos no está sujeta a restricción alguna, porque se trata de acreditar hechos y no actos o contratos: pueden emplearse presunciones, testigos, confesión, peritajes, y cualquier otro medio probatorio, sin que rijan las limitaciones a la prueba testimonial de los **artículos 1708** y siguientes del Código Civil, que se aplican únicamente a los actos y contratos respecto de los cuales la parte estuvo en condiciones de procurarse por anticipado una prueba escrita, circunstancia que no concurre en materia de ilícitos civiles.

2. LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD POR EL HECHO PROPIO: ORIGEN DE SU INTERPRETACIÓN

La presunción general de culpabilidad por el hecho propio se construye a partir del **artículo 2329** del Código Civil, cuyo antecedente se remonta, según las propias notas de **BELLO** al Proyecto de 1853, a las Siete Partidas, que hacían responder por trampas colocadas en lugares de tránsito habitual, por perjuicios causados por rebaños en estampida y por incendios provocados al quemar rastrojos con viento fuerte, hipótesis que tienen en común tratarse de accidentes evitables mediante el cuidado debido.

Inicialmente, tanto la doctrina como cierta jurisprudencia consideraron que el **artículo 2329** no era sino una repetición, en términos más absolutos, de la regla del **artículo 2314**, cuya única peculiaridad residía en agregar algunos ejemplos de aplicación del principio general de responsabilidad por culpa. Así lo sostuvo la Corte Suprema en fallo de 3 de agosto de 1932, y en el mismo sentido se había pronunciado ya el 24 de julio de 1905.

Esta lectura fue superada por **DUCCI**, quien en 1936 formuló la primera explicación del **artículo 2329** bajo la hipótesis de una verdadera presunción de culpa, sosteniendo que la norma se aplicaba cuando el daño provenía de actividades caracterizadas por su peligrosidad: se trataría de actuaciones cuya sola peligrosidad implica culpa, sin necesidad de prueba adicional, porque esta va implícita en el daño causado. Esta interpretación, formulada en una memoria de prueba, no surgió en el vacío: se inspiró en la jurisprudencia de la Corte de Casación de Colombia, que, interpretando el **artículo 2356** del Código Civil de ese país, idéntico en su texto al **artículo 2329** chileno, por la común filiación de ambos códigos en el proyecto de **BELLO**, había llegado ya a la conclusión de que la norma establece una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de actividades peligrosas. La coincidencia no es casual: al compartir la misma fuente legislativa, los tribunales de ambos países se han visto confrontados con idéntico problema de redacción, y la solución colombiana ofreció al derecho chileno un punto de apoyo comparado para superar la lectura que reducía el **artículo 2329** a una simple repetición del **artículo 2314**.

ALESSANDRI extendió después el ámbito de esa presunción, formulándola en términos más amplios: el **artículo 2329** establecería una presunción de culpabilidad cada vez que el daño provenga de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, sea susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente, y no solamente cuando derive de una actividad peligrosa en

sentido estricto. El ejemplo con que suele ilustrarse esta lectura ampliada es el del choque de trenes, porque los convoyes de una misma empresa deben movilizarse en condiciones de no colisionar entre sí, de manera que el solo hecho de la colisión revela, por sí mismo, la falta de la diligencia debida.

Frente a estas dos posiciones, una tercera lectura, sostenida por **MEZA BARROS**, propone leer el inciso primero del **artículo 2329** como una simple reiteración del principio de la culpa probada, y reservar únicamente para los casos enumerados en el inciso segundo el carácter de presunciones específicas de culpabilidad, en cuanto se apartarían de la regla general enunciada en el encabezado, lectura que encontraría apoyo en el término "especialmente" con que se introducen los ejemplos. Esta interpretación, sin embargo, no explica satisfactoriamente por qué el inciso primero habría de leerse con independencia de los ejemplos que lo siguen, cuando ambos incisos forman una unidad normativa, y por eso la doctrina mayoritaria prefiere la lectura amplia de **ALESSANDRI**, que además resulta más coherente con la evolución seguida por el derecho comparado en esta materia.

La superioridad de la interpretación de **ALESSANDRI** se sostiene en cuatro órdenes de argumentos. El primero es exegético: la ubicación del **artículo 2329**, inmediatamente después de las normas que presumen la culpabilidad por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas, y el enunciado con que se abre, "por regla general todo daño...", sugieren que el legislador quiso establecer una regla de clausura del sistema de presunciones, que comprendiera los casos análogos que pudiesen haberse omitido en las disposiciones precedentes; de no ser así, la norma sería una repetición innecesaria del **artículo 2314**, que ya formula con suficiente generalidad el principio de que todo daño causado con malicia o negligencia debe repararse. El segundo es textual: la norma no se refiere a todo daño causado por malicia o negligencia, sino a "todo daño que pueda imputarse" a ellas, expresión que alude a una conducta que por sí misma tiende naturalmente a ser negligente, sin que sea necesario acreditar previamente esa negligencia; así lo confirman los propios ejemplos del inciso segundo, todos los cuales describen hechos que por sí solos son expresivos de culpa: el peligro implícito en disparar un arma de fuego, la manifiesta omisión que supone remover las losas de una acequia sin las precauciones necesarias, o mantener en mal estado un puente que atraviesa un camino. El tercero apela a la experiencia y al sentido común: se atribuye responsabilidad cuando la experiencia muestra que, en las circunstancias descritas, el daño usualmente se debe a culpa o dolo del que lo causa, idea que el derecho anglosajón expresa con la máxima *res ipsa loquitur*, dejad que las cosas hablen por sí mismas. El cuarto es de justicia correctiva: la presunción resulta, con frecuencia, el único camino práctico para construir la responsabilidad del autor del daño, en particular en accidentes originados en un proceso industrial o de servicios complejo, donde no es posible determinar el acto u omisión concreto que lo provocó, como ocurre característicamente con los productos defectuosos.

La jurisprudencia coincide, además, en que la enumeración del inciso segundo no es taxativa, y ha reconocido como reveladores de negligencia otros hechos no mencionados expresamente en la norma, tales como los derrumbes ocurridos durante la demolición de un edificio que dañan a terceros, la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica tendida en condiciones peligrosas, la existencia de un pozo descubierto sin señales de advertencia, o el volcamiento de un carro de ferrocarril por el mal estado de la vía férrea.

3. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN

La presunción de responsabilidad por el hecho propio reconoce, en la elaboración de la doctrina y la jurisprudencia nacionales, tres grupos de casos en que procede su aplicación, que no operan de manera excluyente sino que con frecuencia concurren en un mismo litigio.

El primero es la peligrosidad desproporcionada de la acción. Quien actúa en ámbitos particularmente riesgosos está obligado a adoptar resguardos extremos para evitar el accidente, y por eso la jurisprudencia dio tempranamente por establecida la culpa por el solo hecho de ocurrir un choque de trenes: así lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de 12 de octubre de 1909, señalando que el choque de dos trenes de la misma empresa no solo revela el incumplimiento de las obligaciones de sus empleados, sino la ausencia de la menor prudencia, puesto que nada justifica la colisión de dos convoyes; en el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema el 14 de diciembre de 1923, calificando el choque de "inexcusable", y nuevamente el 11 de agosto de 1932, en un fallo que llevó la presunción hasta el límite mismo de la responsabilidad estricta, al sostener que la colisión se produce generalmente por negligencia de los empleados de la empresa demandada, salvo caso fortuito, cuya existencia no había sido siquiera alegada. El propio ejemplo del disparo de un arma de fuego que menciona el inciso segundo del **artículo 2329** ilustra este primer criterio con particular nitidez, porque concurren en él todos los factores que intensifican el deber de cuidado: el daño puede ser muy grave, su probabilidad no es insignificante, y la acción se ejecuta usualmente en el solo beneficio de quien la realiza. Otro tanto ocurre con actividades que, sin ser mencionadas expresamente en la norma, comparten esa peligrosidad intrínseca, como sucedió en el caso resuelto por la Corte de Concepción el 4 de noviembre de 1997, confirmado por la Corte Suprema al conocer de la casación en el fondo el 3 de noviembre de 1998, relativo a una empresa de gas que no adoptó los resguardos necesarios para evitar filtraciones que causaron la muerte de tres personas.

JURISPRUDENCIA
LA SAGA DE LOS CHOQUES DE TRENES: LA PRESUNCIÓN LLEVADA AL LÍMITE
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 12 DE OCTUBRE DE 1909
El choque de dos trenes de la misma empresa revela por sí solo el incumplimiento de sus empleados: <i>nada justifica</i> la colisión.
CORTE SUPREMA, 14 DE DICIEMBRE DE 1923
Reitera el criterio, calificando el choque de <i>inexcusable</i> .
CORTE SUPREMA, 11 DE AGOSTO DE 1932
La colisión se presume negligente salvo caso fortuito alegado y probado, en un fallo que lleva la presunción de culpabilidad hasta el límite mismo de la responsabilidad estricta.

La jurisprudencia más antigua sobre accidentes ferroviarios e industriales, anterior incluso a la formulación doctrinal de **DUCCI**, había aplicado ya de manera intuitiva esta misma idea de peligrosi-

dad como indicio de culpa. Así, se resolvió que incurre en negligencia quien permite que los trabajadores transiten junto a cachuchos de salitre hirviendo sin que estos se hallen protegidos por rejas, según fallo de la Corte de Apelaciones de Tacna de 21 de marzo de 1905; que la falta de aparatos de seguridad para la carga y descarga de un buque hace responsable a la compañía naviera y a su capitán, conforme a sentencia de la misma Corte de 4 de septiembre de 1905; que un motorista que imprime a su tranvía una velocidad superior a la reglamentaria, sin prever el estado de los frenos que debían permitirle detenerlo, incurre en una negligencia que la Corte Suprema calificó, en fallo de 29 de agosto de 1917, de a lo menos levísima; y que la operación de cargar y descargar carbón, por su peligrosidad intrínseca para quienes en ella se ocupan, hace presumir la culpa de quien la organiza sin las precauciones debidas, según resolvió la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 1 de mayo de 1918. Estos fallos muestran que el criterio de la peligrosidad no es una elaboración exclusivamente doctrinal, sino una máxima de la experiencia que los tribunales venían aplicando, con mayor o menor conciencia teórica, desde los orígenes mismos de la responsabilidad civil por accidentes industriales en Chile.

El derecho comparado ofrece, a este respecto, un dato útil para calibrar la intensidad del criterio: en varios ordenamientos, las actividades particularmente peligrosas están sujetas derechamente a un estatuto de responsabilidad estricta, y las condiciones que allí se exigen para calificar una actividad como "anormalmente peligrosa", la magnitud del riesgo, la probabilidad del daño, la imposibilidad de eliminarlo mediante un cuidado razonable, y la medida en que el peligro que genera supera el beneficio que reporta a la comunidad, son, en sustancia, las mismas que la jurisprudencia nacional pondera al aplicar la presunción del **artículo 2329** bajo este primer criterio. La diferencia entre uno y otro sistema es, en este punto, más de técnica que de resultado: donde el derecho comparado prescinde derechamente de la culpa, el derecho chileno la presume con una fuerza tal que, en los hechos, produce un desenlace equivalente.

El segundo grupo se funda en el control de los hechos por parte del demandado. Cuando el daño proviene de una actividad o de un proceso que el demandado controla íntegramente, es él quien se encuentra en mejor posición para explicar sus causas precisas, y exigir a la víctima que pruebe en detalle dónde residió el error de conducta equivaldría, en la práctica, a convertir su derecho a la reparación en una cuestión puramente teórica. Este criterio ha sido determinante en casos de responsabilidad empresarial y hospitalaria en que no es posible, o no es razonable exigir, identificar al dependiente concreto que incurrió en la negligencia: así, se ha resuelto que no es necesario que la víctima identifique y demande al específico agente sanitario que con dolo o culpa causó el daño, bastando probar que alguien dentro de la organización hospitalaria incurrió en culpa y que esa negligencia fue la causa del perjuicio, según sentencia de la Corte de Concepción de 10 de agosto de 2000, confirmada por la Corte Suprema el 24 de enero de 2002; en sentido análogo, se ha declarado que la falta de adopción de medidas mínimas de precaución por una sociedad, actuando a través de sus propios órganos, configura culpa por omisión propia, sin que sea necesario acreditar la acción u omisión de algún dependiente en particular, conforme a lo resuelto por la Corte de Santiago el 17 de julio de 1998.

Este criterio del control tiene, sin embargo, un límite negativo que conviene precisar, porque su omisión desvirtuaría por completo su fundamento: la presunción no puede operar si, conforme a los hechos de la causa, la propia víctima tuvo un rol causal relevante en la producción del daño, porque en tal caso el riesgo ya no puede calificarse de exclusivamente controlado por el demanda-

do. La exigencia de control supone, en efecto, que el demandado se encontraba bajo un deber de cuidado respecto de la fuente del riesgo, y ese control constituye el fundamento causal de la presunción; pero el solo control no basta para dar la culpa por establecida, porque puede haber intervenido efectivamente en la producción del daño sin que le sea atribuible negligencia alguna, como ocurre con frecuencia en los juicios de responsabilidad profesional. Es necesario, además, que se trate de un accidente que, en el curso ordinario de los acontecimientos, no suele producirse en ausencia de negligencia, requisito que, según se ha visto, ya está presente en los propios ejemplos del inciso segundo del **artículo 2329**. La necesidad de excluir la incidencia causal de la propia víctima anticipa una cuestión que se examinará con detalle al tratar la causalidad en el Eje 13: la culpa de la víctima, cuando interrumpe o comparte la cadena causal, incide tanto en la procedencia de la presunción del hecho propio como en la extensión de la reparación finalmente concedida.

Conviene precisar, además, en qué consiste exactamente la prueba que corresponde al demandado una vez que la presunción se ha tenido por aplicable, porque de ello depende su verdadera fuerza práctica. El demandado puede desvirtuarla por dos caminos distintos. El primero consiste en acreditar su propia diligencia, esto es, mostrar que empleó el cuidado que las circunstancias exigían, con lo cual queda establecido que el daño no obedeció a su negligencia sino a una causa ajena a su conducta. El segundo, más frecuente en la práctica y menos exigente en su prueba, consiste en ofrecer una explicación alternativa del accidente que resulte razonable atendidas las circunstancias, la concurrencia de caso fortuito, examinada en el Eje 6, o de alguna de las causales de justificación estudiadas en el Eje 7, sin que sea necesario acreditar además, de manera positiva, cuál fue el estándar de diligencia efectivamente observado. Esta segunda vía es la que mejor revela el carácter de prueba en principio de la presunción: no se exige del demandado una demostración categórica de su inocencia, sino solamente que rompa la inferencia inicial mostrando que el resultado dañoso es compatible con una versión de los hechos distinta de la negligencia, devolviendo entonces a la víctima la carga de acreditar lo que la presunción, en un comienzo, la había relevado de probar.

El tercer grupo descansa en el rol de la experiencia, en el sentido de que, conforme a lo que usualmente ocurre, cierto tipo de accidentes se debe con mayor frecuencia a negligencia que a un caso fortuito. Bajo este criterio se ha aplicado la presunción en casos como el de los empleados municipales que omitieron reponer la tapa de un sumidero en reparación, sin señalizarlo, exponiendo a los transeúntes a un riesgo grave y constante, según resolvió la Corte de Valparaíso el 3 de diciembre de 1948, confirmada por la Corte Suprema el 4 de agosto de 1952; o el de un hoyo profundo, contiguo a un colector de aguas lluvias, sin protección ni señalización alguna, en un fallo de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2001; o el de las baldosas de una acera municipal que sobresalían del nivel del suelo, provocando la caída de un peatón, conforme a sentencia de la Corte de Concepción de 25 de enero de 2002, confirmada por la Corte Suprema el 7 de mayo del mismo año. Un supuesto especialmente instructivo de aplicación de este criterio es el de las excavaciones profundas para la construcción de edificios en zonas urbanas: se ha resuelto que la normalidad, en esta clase de obras, consiste precisamente en que no se produzcan daños en las construcciones colindantes, de modo que la anormalidad representada por la aparición de esos daños permite presumir, conforme al **artículo 2329**, que la constructora demandada no empleó la diligencia debida, correspondiéndole a ella probar que adoptó las medidas adecuadas, según lo declaró la Corte de Santiago el 7 de septiembre de 2000. La misma lógica explica por qué se ha tenido por reveladores de negligencia, sin necesidad de un ejemplo expreso en el inciso segundo, los derrumbes ocurridos durante la demolición de un edificio que dañan a terceros, según fallo de la Corte Suprema de 13 de enero

de 1937, y la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica tendida en condiciones peligrosas, conforme a sentencia de la misma Corte de 14 de junio de 1945: en ambos casos, la experiencia indica que ese tipo de siniestros no suele producirse si quien tiene a su cargo la obra o la instalación emplea el cuidado que las circunstancias exigen.

DATO DE GRADO

La naturaleza jurídica exacta de la presunción

Establecido que el **artículo 2329** contiene una presunción de culpabilidad y no una mera repetición del **artículo 2314**, queda por resolver una cuestión de la que la doctrina se ha ocupado con menor frecuencia, pero que decide, en la práctica, cuán favorable es la presunción para la víctima: si se trata de una presunción legal en sentido técnico, con los efectos rigurosos que a esa figura atribuyen las reglas generales sobre presunciones, o si se trata más bien de una prueba en principio o apariencia de culpa, de efectos más moderados y flexibles.

La primera alternativa exigiría aplicar con rigor la doctrina general de las presunciones: en las legales, es la propia ley la que efectúa la inferencia y fija su consecuencia probatoria a partir del hecho conocido que describe; en las judiciales, en cambio, es el juez quien debe construir el razonamiento presuntivo, mostrando que concurren los requisitos de gravedad, precisión y concordancia que exigen los **artículos 1712** del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil. Examinado bajo este prisma, el **artículo 2329** inciso primero establece una inferencia más bien indeterminada, cuyo antecedente, un daño "que pueda imputarse" a negligencia, carece de la nitidez propia de otras presunciones legales, sin que por ello puedan exigirse tampoco los requisitos más estrictos reservados a las presunciones judiciales, porque hacerlo privaría a la regla de su función natural, que es precisamente evitar que la víctima deba construir esa inferencia caso a caso.

De ahí que una parte de la doctrina comparada prefiera entender la regla como una prueba en principio: una apariencia de culpa fundada en la experiencia de que ese tipo de accidentes usualmente se debe a negligencia del demandado, cuyo único efecto es alterar el riesgo de la prueba mientras el demandado no ofrezca una explicación razonable acerca de cómo el accidente pudo haber ocurrido por una causa distinta de su propia culpa. Bajo esta lectura, si el demandado logra desbaratar la apariencia inicial mostrando una causa alternativa plausible, la carga de probar la negligencia vuelve a recaer sobre el demandante, conforme a las reglas generales; si no lo logra, resultará responsable sobre la base de esa prueba en principio, sin que sea necesario que el demandante acredite, además, cuál fue el error de conducta específico. Así, por ejemplo, si una persona resulta herida por un disparo, a falta de explicación en contrario se tendrá el hecho por negligente; pero si el demandado acredita que disparó con ocasión de una legítima defensa frente a un asalto, la prueba de la negligencia vuelve a corresponder a quien demanda.

Esta forma de razonar tiene expresiones equivalentes en otros ordenamientos, lo que confirma que no se trata de una peculiaridad puramente local, sino de una respuesta funcional a un mismo problema probatorio. El derecho alemán habla, en supuestos semejantes, de una "prueba por apariencia" (Anscheinbeweis); el derecho francés, de una "culpa virtual", categoría que se aplica igualmente en materia extracontractual. La propia fórmula res ipsa loquitur, con que el derecho anglosajón designa esta clase de inferencia, proviene de un caso paradigmático en que un barril cayó desde la ventana superior de un establecimiento y golpeó a un transeúnte que pasaba por la vía pública: nadie pudo explicar el mecanismo preciso por el cual el barril cayó, pero la sola circunstancia de que un barril no suele caer de una ventana sin que medie negligencia de quien lo tenía bajo su control bastó para hacer responsable al

demandado, a menos que este ofreciera una explicación alternativa satisfactoria. La estructura de este razonamiento, de un hecho que, por no ocurrir ordinariamente sin negligencia, autoriza a inferirla mientras no se pruebe lo contrario, es exactamente la misma que subyace a la interpretación amplia del **artículo 2329**, lo que sugiere que la regla chilena no es una rareza dogmática, sino una manifestación particular de una necesidad común a todo sistema de responsabilidad por culpa: la de no dejar a la víctima desprovista de remedio frente a daños cuyo origen preciso escapa, por su propia naturaleza, a la prueba directa. Un caso resuelto por el más alto tribunal civil alemán ilustra la misma lógica desde otro ángulo: ante la muerte masiva de aves de corral tras una campaña de vacunación, sin que pudiera identificarse el defecto preciso de las vacunas, se resolvió que quien causó el daño se encuentra en mejor posición que quien lo sufrió para explicar cómo pudo producirse el resultado sin que mediara su propia culpa, razonamiento que es, en esencia, el mismo que aplica la jurisprudencia nacional al criterio del control de los hechos.

Con todo, la lectura de la presunción como prueba en principio no está exenta de objeciones, y conviene exponer la más seria de ellas, porque agrega una tercera voz a la disputa. Se ha observado que entender el **artículo 2329** como una presunción legal en sentido estricto conduce, en rigor, a una tautología: si lo que la norma hace es alterar la posición estratégica de las partes a partir de la constatación de que, bajo circunstancias ordinarias, un hecho de esa naturaleza suele ser culpable, entonces no se está frente a una verdadera inferencia legal, que parte de un hecho conocido para dar por acreditado otro, distinto, mediante una operación que la ley misma realiza, sino frente a una valoración de la prueba disfrazada de presunción. Esta objeción no niega que la regla altere el riesgo probatorio en favor de la víctima, pero sí pone en entredicho que sea correcto describirla con el aparato conceptual, gravedad, precisión, concordancia, reservado a las presunciones legales y judiciales propiamente dichas, precisamente el mismo aparato conceptual cuya aplicación rigurosa, según se explicó, resulta poco natural frente al texto del **artículo 2329**. La objeción, lejos de resolver la disputa, confirma su punto de partida: cualquiera sea la etiqueta dogmática que se prefiera, lo verdaderamente decisivo es que la regla exige del demandado algo menos que la prueba plena de su propia diligencia, y algo más que el silencio.

Esta segunda lectura tiene, frente a la primera, dos virtudes que conviene explicitar, porque son las que están efectivamente en juego en la disputa. La primera es de coherencia textual: se aviene mejor con el tenor del **artículo 2329** inciso primero, que alude a un daño imputable a negligencia, esto es, a una apariencia construida sobre la experiencia, antes que a una inferencia legal de efectos automáticos y rígidos. La segunda es de equilibrio entre las partes: permite a la víctima evitar una prueba diabólica sobre el error de conducta específico del demandado, sin imponer a este último, sin embargo, la carga extrema de probar afirmativamente su propia diligencia en términos absolutos, bastándole con ofrecer una explicación alternativa razonable de lo ocurrido. La primera lectura, en cambio, si se aplicara con el rigor propio de toda presunción legal, dejaría al demandado en una posición extraordinariamente desfavorable, porque la única vía de defensa efectiva pasaría por acreditar el caso fortuito o su propia diligencia con un grado de certeza difícil de alcanzar en procesos industriales o de servicios complejos, precisamente los casos en que la presunción cumple su función más importante.

Esta tensión conecta, además, con una cuestión más general ya anunciada al examinar los sistemas o modelos de atribución de responsabilidad: la diferencia entre la culpa presumida y la responsabilidad estricta es, en no pocos casos, más conceptual que práctica. Los fallos sobre choque de trenes son el ejemplo más elocuente: al exigir del demandado, para exonerarse, la prueba de un caso fortuito cuya sola alegación ya se echa de menos, la jurisprudencia sitúa en los hechos la responsabilidad por culpa presumida en el mismo lugar que ocuparía una responsabilidad objetiva pura, aunque formalmente se siga hablando de negligencia. La misma observación se aplicará, en su oportunidad, a la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno del **artículo 2320**, donde la posibilidad de que el civilmente responsable se exonere probando que no pudo impedir el hecho ha sido interpretada, según se verá, en términos igualmente estrictos.

4. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir situando el problema estratégico que la presunción resuelve: la regla general del **artículo 1698** impone la prueba de la culpa a quien la alega, colocando a la víctima en desventaja frente al autor del daño, razón por la cual el Código establece un sistema de tres presunciones de culpabilidad (hecho propio, **artículo 2329**; hecho de las cosas, **artículos 2323 a 2328**; y hecho ajeno, **artículos 2320 y 2322**) que invierten el peso de la prueba sin alterar la naturaleza de la responsabilidad por culpa. Debe mencionarse que la prueba de la culpa no está sujeta a limitación alguna, a diferencia de la prueba de los actos y contratos.

En segundo lugar, la evolución de la interpretación del **artículo 2329**: descartada la lectura que lo reducía a una repetición del **artículo 2314**, debe exponerse la tesis de **DUCCI**, presunción limitada a actividades peligrosas, su ampliación por **ALESSANDRI**, presunción general cada vez que el daño provenga de un hecho que por su naturaleza o circunstancias sea atribuible a culpa o dolo, ilustrada con el choque de trenes, y la lectura minoritaria de **MEZA BARROS**, explicando por qué prevalece la interpretación amplia, con sus cuatro fundamentos: exegético, textual, de experiencia (res ipsa loquitur) y de justicia correctiva.

En tercer lugar, los tres grupos de condiciones de aplicación, peligrosidad de la acción, control de los hechos por el demandado y rol de la experiencia, cada uno ilustrado con jurisprudencia (choque de trenes y filtraciones de gas para la peligrosidad; responsabilidad hospitalaria y empresarial sin necesidad de identificar al dependiente concreto para el control; pozos sin tapar, hoyos sin señalizar y excavaciones que dañan construcciones colindantes para la experiencia), y la advertencia de que la enumeración del inciso segundo no es taxativa.

Cerrar con la tensión sobre la naturaleza técnica de la presunción: presunción legal en sentido estricto, con las exigencias rigurosas de gravedad, precisión y concordancia, o prueba en principio basada en la experiencia, que solo exige al demandado una explicación alternativa razonable. De esa elección depende cuán favorable es la regla para la víctima. Y advirtiendo, para terminar, que la aplicación más severa de la presunción, particularmente en los casos de peligrosidad desproporcionada, sitúa a la responsabilidad por culpa presumida en un punto prácticamente indistinguible

de la responsabilidad estricta, cuestión que se retomará al examinar la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno en el Eje 14.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 9. Prueba de la culpa y presunciones de culpabilidad por el hecho propio (art. 2329)**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

J. EL DAÑO: CONCEPTO Y REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD

Ningún hecho, por ilícito y culpable que sea, genera responsabilidad civil si de él no se sigue un daño. Así lo exigen los **artículos 1437 y 2314** del Código Civil, y de esa exigencia se sigue una consecuencia que conviene formular con toda precisión desde el inicio: pueden concurrir la antijuridicidad y la culpabilidad, e incluso puede existir responsabilidad penal por la sola tentativa, pero mientras no haya daño no habrá delito ni cuasidelito civil. De ahí que el delito frustrado, que sí compromete la responsabilidad penal de su autor, no genere por sí solo obligación civil de indemnizar.

El daño no es, entonces, un elemento más entre otros: es la condición de la que depende el nacimiento mismo de la pretensión indemnizatoria, que solo existe una vez que el daño se ha manifestado. La jurisprudencia lo ha dicho con toda claridad, al resolver que tratándose de un cuasidelito civil, para que nazca el derecho a la reparación es necesario que concurra el daño, y que si este elemento falta, el derecho a demandar perjuicios sencillamente no ha nacido. La única excepción a esta regla de posterioridad se encuentra en la acción por daño contingente del **artículo 2333**, que permite a la responsabilidad civil operar preventivamente, antes de que el daño se produzca, cuando su producción es inminente; su examen corresponde, sin embargo, al Eje 19.

Definido el daño y reconocida su indispensabilidad, la pregunta que organiza este eje es qué condiciones debe reunir ese daño para ser jurídicamente resarcible, porque no basta con que exista un detrimento cualquiera: la doctrina y la jurisprudencia han ido decantando, caso a caso, un conjunto de requisitos de resarcibilidad que filtran qué perjuicios dan lugar a reparación y cuáles, aunque reales, quedan fuera del ámbito de protección de la responsabilidad civil.

1. CONCEPTO DE DAÑO

En la legislación chilena los términos "daño" y "perjuicio" son sinónimos y se emplean indistintamente, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, donde se reserva la primera expresión para el daño emergente y la segunda para el lucro cesante, distinción que el derecho francés expresa, en cambio, mediante la fórmula "daños e intereses".

El concepto más difundido de daño lo define como todo detrimento o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio o en su persona física o moral. La jurisprudencia ha acogido esta noción amplia, definiendo el daño como todo menoscabo que experimenta un individuo en su persona y bienes, esto es, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial.

2. REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD DEL DAÑO

2.1. El daño debe lesionar un derecho o un interés legítimo

Existe amplio consenso en que el daño es resarcible en cuanto lesiona un derecho subjetivo. Esta concepción originaria se ha ampliado con el tiempo, admitiéndose la indemnización no solo cuando se vulnera un derecho en sentido estricto, sino también cuando se lesiona un interés en la satisfacción de necesidades o bienes humanos de carácter privado, aunque ese interés no esté configurado como un derecho subjetivo autónomo. Así se resolvió en el caso de un padre que, sin ser heredero de su hijo ilegítimo por no haber sido instituido en su testamento, ni tener tampoco derecho legal a alimentos de este, vivía sin embargo a sus expensas; fallecido el hijo atropellado por un tren, la Corte Suprema, en sentencia de 9 de septiembre de 1946, acogió la demanda de indemnización del padre, reconociendo que el interés lesionado, la subsistencia que el hijo le procuraba de hecho, era digno de protección aunque no derivara de un derecho formalmente reconocido.

Con todo, no cualquier interés basta: debe tratarse de un interés legítimo, esto es, tutelado de alguna manera por el derecho, y no contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. La legitimidad del interés funciona, en este sentido, más como un límite negativo que como una condición positiva: en principio, todo interés valioso para la víctima es objeto de protección, salvo que resulte ilegítimo. Bajo este prisma se ha discutido tradicionalmente la situación de los convivientes: una posición doctrinal, que sostuvo **ALESSANDRI** siguiendo la jurisprudencia francesa de su época, rechazó que el conviviente pudiera cobrar indemnización por los daños patrimoniales que le siguen de la muerte de su pareja, por estimar que ello supondría invocar en su favor los beneficios de su propia situación irregular. Esta posición ha ido cediendo terreno, en la medida en que la convivencia se reconoce crecientemente como una situación de hecho productora de efectos civiles, incluso patrimoniales, en la legislación laboral y en la de seguros de accidentes; puede afirmarse hoy que el conviviente tiene un interés legítimo en la vida y salud de su pareja, siempre que concurren ciertos requisitos que den cuenta de la seriedad del vínculo: estabilidad en el tiempo, reciprocidad patrimonial y de auxilio, y, si los hay, hijos criados en común. En esta misma línea de flexibilización, se ha resuelto que el llamado daño por rebote o repercusión no exige que exista un vínculo jurídico formal entre la víctima directa y quien reclama la indemnización por repercusión, según sentencia de la Corte de Concepción de 4 de diciembre de 2000, confirmada por la Corte Suprema el 5 de marzo de 2002.

2.2. El daño debe ser cierto

Que el daño sea cierto significa que debe ser real y efectivo, esto es, tener existencia, aunque sea futura. Se rechaza, en consecuencia, la indemnización del daño eventual o meramente hipotético, del que no puede saberse si llegará o no a producirse. Esta exigencia de certeza no equivale, sin embargo, a exigir actualidad: es indemnizable el daño futuro, siempre que al momento de dictarse la sentencia exista certeza de que necesariamente sobrevendrá, de manera que la certidumbre debe ser actual aunque el perjuicio mismo sea futuro. Sobre esta misma base se admite la reparación del daño contingente, que aún no ha ocurrido pero amenaza con producirse si no se adoptan medidas preventivas, caso en el cual la certidumbre exigida recae sobre la inminencia de su producción y no sobre el daño mismo.

La certidumbre del daño solo puede resultar de su prueba, y en esto se sigue el principio general de que corresponde al demandante acreditar los hechos en que funda su pretensión, según ya se examinó al tratar la prueba de la culpa en el Eje 9; así lo ha exigido reiteradamente la jurisprudencia, entre otros en fallo de la Corte Suprema de 16 de octubre de 1954. Con todo, la exigencia de certidumbre opera con distinta intensidad según se trate de daño patrimonial o de daño moral: mientras el primero debe probarse conforme a las reglas generales, el segundo suele darse por acreditado mediante presunciones judiciales, al punto que en los casos más característicos, las lesiones corporales graves, o el dolor por la muerte de un familiar cercano, la jurisprudencia ha llegado a afirmar que se trata de un hecho tan evidente que no requiere prueba alguna, según lo declaró la Corte de San Miguel en sentencia de 8 de agosto de 1989. Esta flexibilización probatoria, propia del daño moral, se explica precisamente por la dificultad de acreditar con medios objetivos un padecimiento que, por su naturaleza, pertenece al fuero íntimo de quien lo sufre.

El criterio con que se mide esa certidumbre, tratándose de daño futuro, no exige una certeza matemática, que rara vez puede predicarse de lo que ha de ocurrir, sino que el derecho se conforma con que el daño futuro constituya la prolongación natural de un estado de cosas ya actual: así ocurre característicamente con los gastos médicos futuros que demandará un tratamiento en curso, o con el lucro cesante calculado sobre la base de proyectar, con una probabilidad razonable, los ingresos que la víctima habría seguido percibiendo de no mediar el accidente. Distinto es el caso del daño puramente eventual, en que la incertidumbre no recae sobre la extensión de un perjuicio ya en curso, sino sobre si el perjuicio mismo llegará alguna vez a manifestarse, como ocurre con los ingresos que se esperaban de una carrera profesional recién iniciada al momento del accidente, o con el riesgo de contraer una enfermedad futura por la sola exposición a un agente nocivo. Entre uno y otro extremo, el lucro cesante de altísima probabilidad, prácticamente asimilable a la certeza, y el daño de probabilidad remota, que se tiene por eventual, existe una zona intermedia de casos en que la ganancia esperada tiene una probabilidad significativa, pero no elevada, de materializarse, y en los cuales resulta más razonable indemnizar una fracción del perjuicio, proporcional a esa probabilidad, que negar por completo la reparación o concederla en su integridad; el ejemplo clásico es el del animal de carreras que resulta lesionado por hecho imputable a un tercero antes de la competencia, cuyo dueño sufre un perjuicio que se mide, no por el total del premio, sino por la probabilidad estadística que el animal tenía de obtenerlo.

Conviene distinguir, dentro de este mismo ámbito, la pérdida de una oportunidad del daño puramente eventual, porque aunque ambas categorías comparten el vocabulario de la incertidumbre, resuelven problemas distintos. En el daño eventual, la incertidumbre recae sobre si el perjuicio mismo llegará a producirse. En la pérdida de una oportunidad, en cambio, el daño final ya se ha producido, la muerte del paciente, la pérdida del pleito, la no adjudicación del contrato, y lo que resulta incierto es si ese daño es atribuible causalmente al hecho del demandado o a otra causa: el enfermo fallecido habría podido sobrevivir de haber recibido un diagnóstico oportuno, el litigante habría podido ganar el juicio de no haber sido abandonado por su abogado, pero en ninguno de los dos casos puede afirmarse con certeza que, de no mediar la negligencia, el resultado favorable se habría producido efectivamente. Por eso la pérdida de una chance no es, en rigor, un problema de certidumbre del daño sino un problema de prueba de la relación causal bajo condiciones de incertidumbre, que el derecho resuelve indemnizando, no el resultado final que se esperaba, sino el valor de la oportunidad perdida de alcanzarlo, ponderado según la probabilidad seria que existía de obtenerlo.

Entre el daño cierto y el daño meramente eventual se sitúa, así, una categoría intermedia que la doctrina y la jurisprudencia nacionales han terminado por aceptar como daño autónomo: la pérdida de una oportunidad o chance, que tiene lugar cuando la conducta culpable del demandado priva a la víctima de la posibilidad, más o menos probable pero nunca cierta, de obtener un beneficio o de evitar una pérdida. Se trata de casos en que no puede afirmarse con certeza que el demandado causó el resultado dañoso final, pero sí puede afirmarse que destruyó una oportunidad seria de evitarlo o de alcanzarlo, de manera que lo efectivamente cierto, y lo único que se indemniza, no es el beneficio esperado, sino la chance misma, avaluada en un porcentaje del valor total de ese beneficio. La Corte Suprema, en sentencia de reemplazo de 6 de enero de 2025, aplicó esta figura a un caso en que una empresa había sido indebidamente rebajada en su puntaje dentro de un proceso de licitación pública por una actuación ilegal del organismo licitante, lo que no le impidió obtener el contrato con certeza, porque nunca puede saberse si, corregido el vicio, habría resultado efectivamente adjudicataria, pero sí le impidió figurar entre las oferentes con mejor puntaje y opciones reales de adjudicación. La Corte calificó este perjuicio como un daño autónomo e independiente del resultado final de la licitación, distinto del daño emergente, del lucro cesante y del daño moral, y ordenó evaluarlo prudencialmente: no en el monto total de la utilidad que la demandante habría obtenido de adjudicarse el contrato, sino en una fracción de ese monto, correspondiente a la probabilidad real que tenía de resultar adjudicataria entre el número de oferentes que, según la prueba pericial rendida, se encontraban en condiciones ciertas de disputar la adjudicación.

2.3. Debe existir una relación directa con el hecho ilícito

El daño indemnizable debe ser consecuencia cierta y necesaria del hecho ilícito, sin la interposición de eslabones causales adicionales. Los daños secundarios o indirectos no son indemnizables, no porque la ley los excluya expresamente, sino porque respecto de ellos falla la relación de causalidad, que es un elemento indispensable y autónomo de la responsabilidad civil, según se examinará en el Eje 13. Esta exigencia de inmediación reproduce, en el ámbito extracontractual, una lógica semejante a la que el **artículo 1558** consagra expresamente para la responsabilidad contractual, aunque, como se dirá al examinar la previsibilidad, esa norma no sea aplicable como tal a los delitos y cuasidelitos civiles.

Para precisar el alcance de esta exigencia conviene distinguir entre el daño inmediato y los daños mediatos que de él se siguen. El daño inmediato es la lesión directa del bien afectado por el hecho del demandado, la cosa destruida, la lesión corporal, la privacidad vulnerada, y constituye la condición misma de que exista responsabilidad, según se dijo al plantear este eje. De ese daño inmediato, sin embargo, suelen derivarse otros daños mediatos o consecuentes, que no siempre comparten la naturaleza del daño inicial: de una lesión corporal se siguen los gastos médicos y la pérdida de ingresos durante la incapacidad; de la lesión a un bien puramente ideal como la honra pueden seguirse tanto una pérdida patrimonial, la disminución de los ingresos futuros del difamado, como un perjuicio extrapatrimonial, el menoscabo de su consideración social. La distinción tiene una utilidad práctica precisa: el daño inmediato es el fundamento del juicio de responsabilidad, mientras que el daño inmediato sumado a los daños mediatos que de él derivan son, en conjunto, los perjuicios efectivamente indemnizables, y es precisamente al determinar hasta qué punto esos daños mediatos siguen siendo indemnizables donde opera el requisito de que el daño sea directo: en algún momento la cadena de consecuencias se vuelve tan remota que deja de ser razonable imputarla al

hecho culpable inicial del demandado, y esa es la función que cumple, en este punto, la exigencia de directividad.

2.4. El daño no debe estar indemnizado

No puede exigirse la reparación de un perjuicio ya reparado. La aplicación práctica más frecuente de esta regla se presenta cuando existen varios responsables solidarios del mismo hecho ilícito, conforme al **artículo 2317**: la víctima puede cobrar el total de la indemnización a cualquiera de ellos, pero satisfecha por uno no puede volver a exigirla de los demás. La misma lógica gobierna la responsabilidad por el hecho ajeno, examinada en el Eje 14: la víctima puede dirigirse contra el autor material del daño o contra el civilmente responsable, pero no puede exigir de cada uno el pago íntegro y acumulativo de la indemnización.

Distinto es el problema del llamado cúmulo de indemnizaciones, que se presenta cuando la víctima ha obtenido de un tercero ajeno al hecho ilícito, una compañía aseguradora, un organismo de seguridad social, una reparación total o parcial del mismo daño. La solución generalmente aceptada es que, en la medida en que esos beneficios tiendan efectivamente a reparar el daño sufrido, este se extingue y no puede exigirse nuevamente su reparación al autor del ilícito; sin perjuicio de que la entidad que pagó ese beneficio se subrogue en los derechos de la víctima para repetir en contra del hechor, de manera que este último no queda, en definitiva, liberado de su obligación, sino que esta se traslada al patrimonio del asegurador o de la entidad que indemnizó en primer lugar.

2.5. El daño debe ser de una magnitud suficiente

Aunque el Código Civil se refiere a "todo daño" como objeto de la obligación de indemnizar, la doctrina reconoce que no toda incomodidad o molestia recíproca propia de la vida en común, las relaciones de vecindad son el ejemplo constante, alcanza a configurar un daño jurídicamente relevante; de aceptarse lo contrario, el sistema judicial colapsaría bajo el peso de reclamaciones por perjuicios triviales. La jurisprudencia ha aplicado este criterio para rechazar, por ejemplo, la indemnización de las molestias que genera para una persona el solo hecho de verse envuelta en un juicio, según sentencia de la Corte de Santiago de 31 de marzo de 1970.

Esta exigencia de un umbral mínimo de significación no es, sin embargo, unánime, porque coexiste con la posición de **ALESSANDRI**, quien rechazó expresamente que la magnitud del daño condicionara su resarcibilidad, sosteniendo que basta con que exista una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo de un interés legítimo, aunque su cuantía sea insignificante o de difícil apreciación, para que proceda la indemnización. La tensión entre ambas posiciones es menor de lo que parece si se advierte que quienes exigen un umbral de significación lo hacen, ante todo, pensando en el daño moral, donde la dificultad de valoración pecuniaria y la dispersión de los montos que la jurisprudencia reconoce corren el riesgo de transformar cualquier frustración personal en un daño indemnizable; tratándose del daño patrimonial, en cambio, el límite práctico de la insignificancia lo impone más bien el costo mismo de litigar por una suma exigua que una exigencia dogmática autónoma. La jurisprudencia alemana ofrece, en este punto, una categoría útil para nombrar el fenómeno: la de los daños de bagatela, con que se designa a las turbaciones pequeñas y transitorias del bienestar del demandante, incluidas ciertas heridas leves o privaciones de libertad de pocas horas con ocasión de un procedimiento policial, que quedan excluidas de reparación aun cuando, en

sentido estricto, exista un detrimento real; la utilidad de reconocer expresamente esta categoría es evitar que cualquier molestia, frustración personal o simple malestar pasajero se transforme, a fuerza de reclamarse ante los tribunales, en un daño moral indemnizable.

2.6. El daño debe ser previsible

Existe en este punto una discusión doctrinal de fondo, cuyos términos conviene exponer con precisión porque de ella depende la extensión misma de la reparación. El **artículo 1558** del Código Civil, situado a propósito de los efectos de las obligaciones, distingue entre perjuicios previstos e imprevistos, disponiendo que el deudor contractual que ha incurrido en culpa solo responde de los primeros, respondiendo de ambos únicamente si ha mediado dolo o culpa grave.

La doctrina tradicional, representada por **ALESSANDRI**, sostiene que esta distinción es enteramente ajena a la responsabilidad extracontractual, porque el **artículo 1558** se refiere a las obligaciones contractuales, donde las partes han podido prever al tiempo de contratar los daños que se seguirían de su incumplimiento; tratándose de un hecho ilícito, en cambio, esa previsión anticipada no es posible, porque el daño extracontractual es por su propia naturaleza un daño imprevisto para quien lo sufre. De ahí que, según esta posición, sea el propio **artículo 2329**, al ordenar la reparación de "todo daño", el que exige indemnizar tanto los perjuicios previstos como los imprevistos, sin distinción alguna.

Frente a esta lectura, se sostiene que la previsibilidad no puede ser ajena al juicio de responsabilidad extracontractual, porque constituye un elemento esencial de la propia culpabilidad, según se examinó en el Eje 8: el modelo del hombre prudente remite a una persona que delibera y actúa razonablemente, y como lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación alguna, dentro del ámbito de la prudencia solo cabe considerar lo previsible. Si la previsibilidad es condición de la culpa misma, se sigue una consecuencia directa sobre la extensión de la reparación: puesto que el autor del daño solo pudo obrar imprudentemente respecto de las consecuencias que le era dado prever, solo esos daños previsibles, y no otros, deberían quedar comprendidos en su obligación de indemnizar.

Conviene precisar, para no simplificar en exceso los términos de la disputa, que la previsibilidad reaparece en el juicio de responsabilidad extracontractual por dos vías distintas, que conviene no confundir. La primera es la que se acaba de describir: la previsibilidad del daño inmediato incide en la determinación misma de si hubo o no negligencia, porque el estándar de cuidado se mide precisamente en función de los riesgos que el hombre prudente podía anticipar. La segunda vía, distinta de la anterior, opera al momento de decidir cuáles de los daños mediatos o consecuentes que se siguen de ese daño inmediato pueden todavía calificarse de directos, y por tanto quedar comprendidos en la reparación: aun aceptando que el **artículo 1558** no rige en materia extracontractual, la previsibilidad de esas consecuencias más remotas es, en la práctica, uno de los criterios que se emplean para trazar el límite de lo que cuenta como consecuencia directa del hecho ilícito, según se explicó al tratar ese requisito. De modo que negar la aplicación literal del **artículo 1558** no equivale a expulsar por completo la previsibilidad del juicio de responsabilidad extracontractual, sino a redistribuir el lugar en que esta opera: ya no como una regla expresa sobre extensión de la reparación, sino como un ingrediente que reaparece, primero, al calificar la conducta como culpable, y, después, al decidir hasta dónde llega la cadena de daños mediatos que se tienen por directos.

2.7. El daño debe haber sido personalmente sufrido por la víctima

La exigencia de que el daño esté radicado en quien acciona excluye la indemnización de los daños difusos, esto es, aquellos que afectan a personas indeterminadas sin que pueda identificarse a una víctima concreta. De esta exigencia se sigue el problema del daño por repercusión o rebote: aquel que sufre una persona a consecuencia del daño experimentado directamente por otra, como ocurre con quien pierde los ingresos que la víctima directa le proporcionaba a título de alimentos, incluso sin tener derecho legal a ellos, según se ha visto al tratar el interés legítimo, o con quien sufre el dolor moral por la pérdida de un ser querido.

El problema central que plantea esta clase de daño es determinar quiénes están legitimados para reclamarlo, porque la cadena de personas afectadas por un mismo hecho dañoso puede extenderse de manera prácticamente ilimitada. Tratándose del daño patrimonial por repercusión, la jurisprudencia ha tendido a reconocer acción a quien efectivamente dependía económicamente de la víctima directa, exista o no entre ambos un vínculo jurídico formal de alimentos. Tratándose del daño moral por repercusión, en cambio, el derecho tiende a exigir un grado de parentesco que justifique razonablemente la indemnización, restringiendo la acción usualmente al cónyuge, los ascendientes y los descendientes, para evitar que el círculo de legitimados activos se extienda indefinidamente.

La exigencia de que el daño sea personal plantea, además, un problema distinto cuando el perjuicio, en lugar de concentrarse en una sola víctima, se reparte en pequeñas porciones entre un número indeterminado de personas, como ocurre con ciertos daños ambientales o con la competencia desleal que afecta a los miembros de un mismo gremio: cada porción individual del daño puede ser tan reducida que no alcance, por sí sola, el umbral de significación exigido, y aun cuando lo alcance, el costo de litigar individualmente por una suma exigua desalienta a cada afectado de accionar por separado. El derecho comparado ha ensayado dos soluciones distintas para este problema de los intereses difusos: permitir que una persona jurídica, un colegio profesional, una asociación de consumidores, represente corporativamente el interés compartido por sus asociados, camino que en el derecho chileno es de derecho estricto y solo procede cuando una ley especial lo autoriza expresamente, como ocurre con la legislación de protección al consumidor, de propiedad intelectual, de copropiedad inmobiliaria (Ley N° 21.442) y de reorganización y liquidación de activos (Ley N° 20.720, que regula el rol del Liquidador en representación de la masa de acreedores); o bien facilitar los medios procesales para que los propios afectados ejerzan conjuntamente una acción que sigue siendo, desde el punto de vista sustantivo, individual de cada uno de ellos, como ocurre con las acciones colectivas de origen norteamericano.

DATO DE GRADO**Previsibilidad y extensión de la reparación**

La disputa sobre la previsibilidad del daño es, de las siete que atraviesan este eje, la que tiene mayores consecuencias prácticas, porque de ella depende directamente cuánto debe pagar el responsable. Conviene precisar en qué consiste exactamente el desacuerdo, porque no se trata de dos lecturas puramente dogmáticas del **artículo 1558**, sino de dos concepciones distintas acerca de qué es lo que la responsabilidad extracontractual está llamada a reparar.

La posición que sostiene que se indemnizan tanto los daños previstos como los imprevistos se apoya en un argumento a la vez textual y sistemático: el **artículo 1558** pertenece al título de los efectos de las obligaciones contractuales, donde tiene pleno sentido distinguir según lo previsto al momento de contratar, porque las partes pudieron entonces negociar y asignarse recíprocamente los riesgos de un eventual incumplimiento; en el ilícito civil no existe ese momento de negociación previa entre víctima y autor del daño, de modo que trasladar mecánicamente la distinción contractual carecería de fundamento, y el mandato del **artículo 2329** de reparar "todo daño" debe leerse, en consecuencia, en su sentido más amplio.

La posición que limita la reparación a los daños previsibles no niega que el **artículo 1558** sea, en cuanto tal, inaplicable a la responsabilidad extracontractual; lo que sostiene es algo distinto y más radical: que la previsibilidad no ingresa al juicio de responsabilidad civil por la vía de una norma sobre extensión de la reparación, como ocurre en materia contractual, sino por la vía de la culpa misma, que es previa y estructuralmente inseparable de toda idea de previsibilidad. Bajo esta óptica, no se trata de aplicar por analogía una regla pensada para el contrato, sino de extraer una consecuencia necesaria del propio concepto de culpa: si actuar culpablemente consiste en no prever lo que un hombre prudente habría previsto, carece de sentido imputar al mismo tiempo, a título de responsabilidad por culpa, consecuencias que ni el agente ni el hombre prudente puesto en su lugar habrían podido anticipar en absoluto. Sostener que se indemnizan los daños imprevistos junto con los previsibles equivaldría, en el límite, a hacer responder al agente culpable en términos más amplios que los que resultarían de una responsabilidad estricta, porque ni siquiera esta prescinde por completo de algún grado de conexión razonable entre el riesgo creado y el daño finalmente producido.

Lo que está en juego, entonces, no es una cuestión de técnica de imputación, sino el alcance mismo del reproche que la culpa extracontractual formula: si se acepta que la previsibilidad es interna al juicio de culpabilidad, la responsabilidad por negligencia queda naturalmente acotada a aquello que el reproche de imprudencia puede razonablemente abarcar; si se la rechaza, la responsabilidad por culpa se acerca, en su extensión reparatoria, a una responsabilidad por el resultado, indiferente a lo que el agente pudo o no anticipar, lo que resulta en tensión con la propia estructura de un régimen que se dice fundado en la negligencia y no en el mero acaecimiento del daño.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir afirmando la indispensabilidad del daño como requisito de la responsabilidad civil, conforme a los **artículos 1437 y 2314** del Código Civil, de donde se sigue que el delito frustrado no genera responsabilidad civil y que la pretensión indemnizatoria nace únicamente una vez manifestado el daño, salvo la excepción del daño contingente del **artículo 2333**, examinada en el Eje 19. Debe mencionarse el concepto amplio de daño acogido en Chile, sinónimo de perjuicio, y comprensivo de todo menoscabo patrimonial o extrapatrimonial.

En segundo lugar, exponer los siete requisitos de resarcibilidad: que el daño lesione un derecho o interés legítimo, con el caso del padre que vivía a expensas de su hijo ilegítimo y la evolución hacia el reconocimiento del interés del conviviente; que sea cierto (distinguiendo daño eventual, daño futuro y daño contingente, y desarrollando la pérdida de una chance como categoría autónoma, con el caso de la licitación pública resuelto por la Corte Suprema en 2025); que exista relación directa con el hecho ilícito, excluyendo los daños indirectos; que no esté ya indemnizado, con el problema del cúmulo de indemnizaciones y la subrogación del asegurador; que tenga una magnitud suficiente, exponiendo la posición de **ALESSANDRI** en contrario; que sea previsible, exponiendo ambas posiciones y su fundamento; y que haya sido personalmente sufrido por la víctima, con el problema del daño por rebote o repercusión y la exigencia de parentesco para el daño moral reflejo.

Cerrar con la tensión sobre la previsibilidad, explicando que no se trata de una disputa sobre la aplicabilidad de una norma contractual al ámbito extracontractual, sino sobre si la previsibilidad ingresa al juicio de responsabilidad por la vía de la culpa misma, en cuyo caso la reparación queda acotada a lo previsible, o si el mandato de reparar "todo daño" del **artículo 2329** impone prescindir de esa limitación, con la consecuencia de que, en ese segundo caso, la responsabilidad por culpa se acerca en su extensión reparatoria a una responsabilidad por el resultado.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 10. El daño: concepto y requisitos de resarcibilidad**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

K. CLASES DE DAÑO (I): EL DAÑO PATRIMONIAL

Reconocido el daño como requisito indispensable de la responsabilidad civil y precisadas las condiciones que debe reunir para ser resarcible, corresponde examinar sus clases. La distinción tradicional, atendida la naturaleza del bien lesionado, separa dos grandes categorías: el daño patrimonial o material, que consiste en una pérdida pecuniaria, y el daño moral o extrapatrimonial, que afecta bienes que no tienen un valor de mercado. Este eje se ocupa exclusivamente de la primera; el daño moral, con sus propias dificultades de concepto, prueba y evaluación, se examina en el Eje 12.

El daño patrimonial se define como aquel que consiste en un detrimento del patrimonio de la víctima, y se manifiesta en la diferencia entre la posición económica que esta tiene después de ocurrido el hecho ilícito y la posición hipotética en que se encontraría de no haber ocurrido. Definido así, el problema central que organiza este eje no es tanto identificar qué cuenta como daño patrimonial, cuestión relativamente sencilla en sus casos típicos, sino resolver dos preguntas de mayor calado: cómo se determina, en concreto, esa diferencia patrimonial, y qué relación guarda la extensión de la reparación con el grado de culpa del responsable.

1. FUNDAMENTO NORMATIVO Y CLASIFICACIÓN LEGAL

El Código Civil no contiene, dentro del título de los delitos y cuasidelitos, una norma expresa que distinga entre daño emergente y lucro cesante como lo hace el **artículo 1556** a propósito de la responsabilidad contractual. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, de manera unánime, entienden que esa clasificación se aplica igualmente en materia extracontractual, atendida la generalidad de los términos en que están redactadas las normas del Título XXXV: el **artículo 2314** impone la obligación de indemnizar el "daño" causado, sin distinción alguna, y el **artículo 2329** ordena reparar "todo daño" imputable a una persona, mientras que el **artículo 2331** menciona expresamente, para el caso especial de las injurias, ambas clases de daño. La jurisprudencia más antigua ya había resuelto, en este sentido, que dada la generalidad de los términos en que está concebido el **artículo 1556**, esta norma puede regir no solo las obligaciones derivadas de contratos, sino también las que nacen de un delito o cuasidelito, conforme a lo declarado por la Corte Suprema en fallo de 19 de junio de 1928.

De esta misma base normativa se ha extraído un principio más general, que gobierna la determinación de la indemnización patrimonial en su conjunto: el principio de la reparación integral del daño, conforme al cual todo daño debe ser reparado, y reparado en toda su extensión. La Corte Suprema lo declaró expresamente en fallo de 8 de noviembre de 1971, al sostener que la reparación tiene por objeto restituir al demandante a la misma situación en que se encontraría de no haber sido víctima del hecho del demandado. De este principio se siguen dos consecuencias: que debe repararse el total de los daños sufridos, y que la extensión de la reparación no depende del grado de culpa del responsable, de manera que quien incurre en una negligencia levísima que causa un daño enorme queda obligado, en principio, a la misma reparación íntegra que si hubiera actuado con la mayor imprudencia. La reparación integral tiene, con todo, un límite que opera por una vía distinta: no puede convertirse en fuente de enriquecimiento para quien la recibe. Así lo ha declarado la jurisprudencia, señalando que la indemnización del daño emergente no puede constituir ocasión de

enriquecimiento injusto para la víctima, según fallo de la Corte de Santiago de 5 de octubre de 2000, y reiterando, específicamente a propósito del lucro cesante, que la indemnización del daño material debe ser íntegra, pero no puede transformarse en ocasión de ganancia para su beneficiario, principio que debe tenerse presente al computar el perjuicio derivado de esa clase de daño, conforme a sentencia de la misma Corte de 2 de noviembre de 2001.

DOMÍNGUEZ sitúa el origen de este principio en la Lex Aquilia del derecho romano, aunque su formulación con la universalidad que hoy se le reconoce es tributaria del derecho codificado, particularmente del francés posterior a 1804; en Chile, sostiene que el principio no ha sido incorporado directamente por la Constitución, pero que se encuentra reforzado por ella, en cuanto encuentra apoyo en las garantías de integridad física y psíquica y de propiedad de los números 1, 2 y 24 del **artículo 19**. La fórmula que mejor resume su contenido es la de que la reparación debe ser todo el daño y nada más que el daño: la primera parte exige indemnizar íntegramente el perjuicio sufrido; la segunda, que aquí importa destacar, supone el abandono de toda finalidad punitiva de la indemnización, porque el monto reparatorio no debiera exceder la medida del daño efectivamente causado. **DOMÍNGUEZ** advierte, sin embargo, que esta conclusión general se ve matizada en la práctica: la apreciación prudencial que la ley entrega a los jueces del fondo permite que, tras la fachada de una reparación puramente compensatoria, se esconda en los hechos un uso punitivo de la indemnización, observación que se retomará, con mayor desarrollo, al examinar la valuación del daño moral en el Eje 12.

2. EL DAÑO EMERGENTE

El daño emergente consiste en el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona, de manera que a consecuencia de él el activo patrimonial pesa menos que antes del hecho ilícito. La jurisprudencia lo ha definido en términos sustancialmente equivalentes, calificándolo como el empobrecimiento real y efectivo padecido por quien reclama la indemnización, según fallo de la Corte de Santiago de 7 de diciembre de 1984, y como el desmedro real y efectivo experimentado en el patrimonio de la víctima, conforme a sentencia de la Corte Suprema de 2 de marzo de 1977.

Tratándose de la destrucción de una cosa, la indemnización corresponde a su valor de reposición, considerando el estado en que se encontraba inmediatamente antes del hecho; si la cosa solo sufrió deterioro, la indemnización debe cubrir la suma necesaria para su reparación completa, más la compensación por el menor valor que la cosa conserve una vez reparada, puesto que aun una reparación perfecta suele dejar una desvalorización residual. En los casos en que la reparación resulte más costosa que el valor de la cosa misma, lo que ocurre con cierta frecuencia tratándose de vehículos, el restablecimiento del estado patrimonial anterior al accidente se logra pagando a la víctima el precio de la cosa, y no el costo, superior, de repararla. También constituyen daño emergente los gastos en que la víctima debe incurrir a causa del accidente: hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, o el arriendo de un vehículo sustituto mientras dura la reparación del propio.

Distinta de estas hipótesis, en que el daño recae sobre una cosa determinada, es la categoría de los daños puramente económicos o patrimoniales, que no se traducen en el detrimento de un bien corporal específico, pero que afectan igualmente al patrimonio de la víctima. El ejemplo constante en

la doctrina nacional es el del comerciante víctima de competencia desleal, cuyo negocio pierde valor a consecuencia de publicidad engañosa de un competidor, sin que exista cosa corporal alguna que se haya destruido o deteriorado: el detrimento recae directamente sobre el valor económico de la actividad comercial como tal. A esta misma categoría pertenecen otras hipótesis de similar estructura, como la del tercero que interfiere en una relación contractual ajena impidiendo al deudor cumplir su obligación, o la del profesional que entrega un informe erróneo que induce a otros a incurrir en pérdidas patrimoniales por haber confiado razonablemente en su exactitud.

Esta categoría de daño patrimonial puro merece una precisión adicional, porque en un número importante de ordenamientos comparados, el derecho alemán entre ellos, su indemnización está sujeta a requisitos especiales y más exigentes que los que rigen para el daño derivado de la lesión de una cosa corporal o de la persona: se exige, por ejemplo, que el demandado haya actuado de una manera contraria a las buenas costumbres, y no basta la culpa ordinaria que satisface el estatuto general de responsabilidad. La razón de este tratamiento diferenciado es comprensible: al no existir una cosa corporal o un derecho de la personalidad claramente delimitado que sirva de referencia, resulta más difícil trazar la línea entre el daño patrimonial puro indemnizable y el ejercicio legítimo de actividades económicas, como competir lealmente por la clientela de otro, que inevitablemente producen pérdidas patrimoniales a terceros sin que exista en ello ilicitud alguna. El derecho chileno, sin embargo, no ha seguido este camino restrictivo: siguiendo en esto la tradición francesa y española, que emplean un concepto genérico de daño sin distinciones de esta naturaleza, el daño patrimonial puro se rige por las mismas reglas generales que cualquier otro daño patrimonial, sin que se le impongan requisitos adicionales de ilicitud cualificada; la línea divisoria entre la competencia lícita y la desleal se traza, en consecuencia, íntegramente dentro del juicio ordinario de culpabilidad examinado en el Eje 8, y no mediante un estatuto especial y más restrictivo aplicable únicamente a esta clase de perjuicios.

3. EL LUCRO CESANTE

El lucro cesante puede definirse como la pérdida del incremento neto que habría experimentado el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual el demandado es responsable. La jurisprudencia ha caracterizado esta clase de daño señalando que se produce por aquello que el actor deja de percibir como consecuencia del hecho ilícito, y que, tratándose de la privación del uso de un capital, lo constituyen los intereses de ese capital, en cuanto miden el monto real y efectivo del perjuicio causado.

También constituye lucro cesante la pérdida de las oportunidades de uso y goce de una cosa dañada, aun cuando esa pérdida no se traduzca todavía en un perjuicio económico presente y verificable: así ocurre con la víctima que, a consecuencia del deterioro de su automóvil, se ve privada de usarlo mientras dura la reparación, sin necesidad de que arriende un vehículo sustituto, porque si lo arrendara, ese gasto se calificaría, en cambio, de daño emergente. La calificación de un mismo perjuicio económico como daño emergente o como lucro cesante depende, entonces, de la forma concreta en que la víctima decide gestionar la privación temporal del bien, y no de una diferencia sustancial entre ambas categorías: se trata, en el fondo, de dos maneras distintas en que un mismo detrimento patrimonial puede manifestarse.

La determinación del lucro cesante exige siempre proyectar, con un grado razonable de probabilidad, el curso normal que habrían seguido los acontecimientos de no mediar el hecho ilícito, atendidas las circunstancias particulares de la víctima. Existen casos en que esa probabilidad es cercana a la certeza, como ocurre, en general, con el dinero, cuyo lucro cesante equivale sencillamente al interés que la víctima habría obtenido de no mediar el hecho; pero en la generalidad de los casos la probabilidad de la ganancia futura es más incierta, razón por la cual la jurisprudencia ha exigido que, para avaluar el lucro cesante, se proporcionen antecedentes más o menos ciertos que permitan determinar la ganancia probable que se dejó de percibir a consecuencia del delito o cuasidelito. La exigencia de certidumbre del daño, examinada en el Eje 10 como requisito general de resarcibilidad, debe matizarse tratándose del lucro cesante, porque rara vez existirá certeza absoluta de que el provecho esperado se habría efectivamente producido; de ahí que su determinación exija, inevitablemente, un cálculo probabilístico de su ocurrencia, y no la prueba de un hecho ya consumado como ocurre con el daño emergente.

4. DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL: EL PROBLEMA DE LA COMPARACIÓN

Puesto que el daño patrimonial se define como la diferencia entre dos estados de un mismo patrimonio, surge la pregunta de qué es exactamente lo que debe compararse para establecer esa diferencia, y aquí la doctrina ha seguido dos caminos distintos.

El primero, desarrollado por la doctrina alemana del siglo diecinueve, propone un concepto abstracto de daño: la indemnización resultaría de comparar el valor total del patrimonio de la víctima antes y después del hecho, considerado como una universalidad contable, sin atender al valor de los bienes individualmente afectados. Este concepto abstracto presenta, sin embargo, dos dificultades que han llevado a su abandono progresivo. La primera es que una valoración meramente global del patrimonio diluye los conceptos precisos de daño, arriesgando que la indemnización resulte, según los casos, por defecto o por exceso, incompatible con el propio principio de reparación integral que se pretende aplicar; por esta razón se exige que la sentencia condenatoria exprese el resultado de la suma de partidas de daño específicas, y no una valoración global de la diferencia patrimonial. La segunda dificultad es más radical: puede existir un daño indemnizable aun cuando no se verifique una disminución objetiva del patrimonio total de la víctima, como ocurre con quien tenía contratado un seguro de daños propios que cubre íntegramente el perjuicio sufrido; en tal caso, la comparación puramente contable del patrimonio antes y después del hecho no arrojaría diferencia alguna, y sin embargo nada justifica que ese seguro, contratado y pagado por la propia víctima, ceda en beneficio del tercero que causó negligentemente el accidente.

Frente a estas dificultades, prevalece en Chile, como en el derecho francés y español, un concepto concreto de daño, según el cual la indemnización se determina sobre la base de perjuicios específicos, individualizados uno a uno como partidas de daño emergente o de lucro cesante, cada una de las cuales debe justificarse según su propio mérito probatorio. El cálculo en concreto exige, en consecuencia, ponderar los intereses realmente afectados de la víctima, y se opone a cualquier apreciación estandarizada en que el valor del perjuicio esté predeterminado genéricamente para cada tipo de daño con independencia de las circunstancias del caso, estandarización que, como se

dirá al tratar el daño moral en el Eje 12, sí encuentra justificación en ese otro ámbito, por razones que no operan tratándose del daño patrimonial.

Con todo, el propio sistema reconoce excepciones puntuales a la determinación en concreto. La más importante está establecida por la ley respecto de la privación del goce del dinero: conforme al **artículo 1559** del Código Civil, el daño producido por la falta de pago oportuno de una suma de dinero se mide, sin más, por los intereses corrientes, de manera que el demandante no puede alegar que perdió oportunidades de negocios de mayor valor, así como el demandado tampoco puede alegar que el demandante no habría obtenido siquiera esos intereses. También suelen estar estandarizadas las reparaciones que garantizan ciertos regímenes de responsabilidad estricta o de seguridad social, donde el monto de la indemnización está fijado de antemano por la ley y no se determina en concreto atendiendo a las circunstancias particulares de cada víctima; fuera de esos regímenes especiales, y siempre que el daño sea atribuible a la culpa del demandado, rige sin restricciones el principio de la reparación integral en su determinación concreta.

5. FUENTES DEL DAÑO PATRIMONIAL Y SU PRUEBA

Atendiendo al bien inmediatamente afectado por el hecho ilícito, el daño patrimonial puede provenir de tres fuentes distintas, que conviene distinguir porque cada una plantea sus propias dificultades de determinación. La primera es el daño a las cosas, cuyo efecto patrimonial inmediato es el costo de reposición o de reparación ya examinado, al que suelen sumarse otras partidas conexas, el gasto de un medio de transporte sustitutivo, la pérdida de ingresos o del beneficio de uso mientras dura la reparación, de manera que un mismo accidente sobre una cosa corporal se descompone, en la práctica, en varias partidas diferenciadas de daño patrimonial. La segunda es el daño a las personas, que puede presentarse bajo la forma de un daño corporal o de un daño a bienes ideales como la honra; en ambos casos los efectos patrimoniales del daño inmediato a la persona son, con frecuencia, tan relevantes como sus efectos extrapatrimoniales, según se verá con más detalle en el Eje 12: las lesiones corporales generan gastos médicos y pérdida de ingresos, mientras que el atentado contra el honor suele acarrear, junto con el daño moral propiamente dicho, una pérdida patrimonial derivada de la disminución de la reputación de quien lo sufre. La tercera fuente es el daño patrimonial puro, en que el hecho del demandado produce un efecto de significado estrictamente patrimonial sin que medie lesión alguna a una cosa corporal o a la persona de la víctima (el caso, ya mencionado, de la competencia desleal, al que puede añadirse la interferencia de un tercero en una relación contractual ajena que impide al deudor cumplir su obligación, o la información errónea que un profesional entrega y que hace incurrir en pérdidas a quien confió en ella). Esta última categoría, aunque se ajusta sin dificultad a las clases de daño emergente y lucro cesante ya examinadas, suele plantear preguntas adicionales en sede de culpa, porque el hecho ilícito solo puede configurarse trazando una línea divisoria frente a conductas lícitas de contenido económico semejante, como el ejercicio legítimo de la libertad de competir.

La prueba de estas distintas partidas de daño corresponde siempre al demandante, en aplicación de la regla general del **artículo 1698** ya examinada en el Eje 9 a propósito de la prueba de la culpa. Tratándose del daño emergente ya ocurrido, la prueba no presenta mayor dificultad conceptual, porque puede rendirse sobre la base de los gastos efectivamente incurridos o de una estimación prudencial de las pérdidas sufridas, permitiendo un grado elevado de objetividad. Distinta es la si-

tuación del daño emergente futuro, como los cuidados profesionales que requerirá de por vida quien ha quedado inválido a consecuencia del accidente: aunque sea cierto que esos cuidados serán necesarios, suelen ser inciertos tanto el tiempo durante el cual se prolongarán como el costo futuro de prestarlos, de manera que la certidumbre exigida al daño no se extiende, en este caso, ni al plazo ni al monto exacto de la suma necesaria para cubrirlos; la prueba debe entonces recurrir a antecedentes estadísticos, expectativas de sobrevivencia, costos previsibles de mantención, que permitan construir una presunción razonable sobre el monto estimado del daño, y una alternativa frecuente para hacerse cargo de esta incertidumbre consiste en conceder la indemnización bajo la forma de una renta periódica en lugar de una suma alzada única.

Tratándose del lucro cesante, la dificultad probatoria es todavía mayor, porque este tipo de daño envuelve siempre un elemento contingente: se funda en la hipótesis, por definición indemostrable con certeza absoluta, de que la víctima habría obtenido ciertos ingresos de no haber ocurrido el hecho que genera la responsabilidad del demandado. Por esta razón, el cálculo del lucro cesante no puede exigir una prueba estrictamente individual y concreta de la ganancia que se dejó de percibir, sino que recurre a un componente necesariamente típico u objetivo: se proyectan los ingresos netos que razonablemente pueden esperarse de una persona en la situación del demandante, conforme al curso normal de los acontecimientos, prescindiendo de las circunstancias más detalladas y específicas que podrían haber alterado esos ingresos futuros. Esta objetivación del cálculo, lejos de debilitar la posición de la víctima, cumple una función probatoria protectora: le permite mostrar un procedimiento razonable de cálculo del lucro cesante sin tener que acreditar, de manera imposible, qué habría ocurrido exactamente en el futuro de no mediar el hecho ilícito.

DATO DE GRADO**El alcance del principio de reparación integral**

La disputa entre el concepto abstracto y el concepto concreto de daño patrimonial no es una discusión meramente técnica sobre el método de cálculo, sino que expresa una tensión más profunda dentro del propio principio de reparación integral, que conviene explicitar.

Si se adoptara el concepto abstracto, la comparación puramente contable del patrimonio total antes y después del hecho, el principio de reparación integral se aplicaría con máxima coherencia formal: se repararía exactamente la diferencia patrimonial neta, ni un peso más ni un peso menos. Pero esa misma coherencia formal es la que produce los dos problemas señalados: permite que beneficios ajenos al hecho ilícito, como el pago de un seguro propio, reduzcan artificialmente la indemnización debida por el responsable, y dificulta el control judicial de cada partida de daño, porque una cifra agregada no permite verificar si el tribunal efectivamente indemnizó todo el daño sufrido o incurrió en excesos o defectos compensados entre sí. El concepto concreto sacrifica esa pureza formal, la indemnización ya no resulta de una sola operación contable, sino de la suma de partidas heterogéneas, cada una determinada con su propio estándar de prueba, a cambio de un control más preciso sobre cada perjuicio individual, y de la posibilidad de excluir de la ecuación beneficios que, aunque reducen en los hechos el detrimento patrimonial neto de la víctima, no provienen del hecho del demandado ni deben, por consideraciones de justicia correctiva, beneficiarlo.

Esta misma tensión, entre la coherencia formal de una regla aplicada sin excepciones y la necesidad práctica de intervenir sobre casos específicos que la regla, aplicada literalmente, resolvería mal, reaparece en el reconocimiento de las excepciones a la determinación en concreto. El **artículo 1559** estandariza el daño por la mora en el pago de dinero precisamente para evitar los costos probatorios y la incertidumbre que supondría exigir, en cada caso, la prueba concreta de las oportunidades de inversión perdidas por el acreedor; los regímenes de responsabilidad estricta hacen lo mismo por razones de previsibilidad y de eficiencia administrativa. En ambos casos se sacrifica algo de precisión individual a cambio de certeza y de ahorro de costos de litigación, exactamente en el sentido opuesto al que inspira el rechazo del concepto abstracto: mientras este último se abandona porque su generalidad diluye el detalle necesario para una reparación verdaderamente integral, las excepciones puntuales se aceptan porque, en esos casos específicos, es preferible una determinación estandarizada y previsible a la prueba individualizada de cada perjuicio concreto. El principio de reparación integral no es, entonces, una regla de aplicación mecánica, sino un ideal regulativo que el sistema aproxima de maneras distintas según el tipo de daño de que se trate, ponderando en cada caso la precisión de la reparación individual contra el costo y la incertidumbre de exigirla.

6. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir situando el daño patrimonial dentro de la clasificación general de los daños, patrimonial y moral, y su fundamento normativo: aunque el **artículo 1556** está situado a propósito de los efectos de las obligaciones contractuales, se aplica igualmente en materia extracontractual aten-

dida su generalidad, confirmada por la jurisprudencia desde 1928, y de los **artículos 2314, 2329 y 2331** se extrae el principio de la reparación integral del daño, con sus dos consecuencias, reparación del total del daño, con independencia del grado de culpa, y su límite, no puede constituir enriquecimiento para la víctima.

En segundo lugar, exponer el daño emergente (empobrecimiento real y efectivo, con sus reglas sobre valor de reposición y de reparación de cosas dañadas, gastos conexos al accidente, y la categoría de los daños puramente económicos, con el ejemplo de la competencia desleal) y el lucro cesante (pérdida del incremento neto que se habría producido, con su exigencia de un cálculo probabilístico del curso normal de los acontecimientos), y la advertencia de que un mismo perjuicio puede calificarse de una u otra clase según la forma en que la víctima gestiona la privación del bien.

En tercer lugar, exponer las tres fuentes del daño patrimonial: daño a las cosas, daño a las personas y daño patrimonial puro, y las particularidades de su prueba: la del daño emergente ya ocurrido, relativamente sencilla por fundarse en gastos o pérdidas verificables; la del daño emergente futuro, que exige recurrir a antecedentes estadísticos y admite la fórmula de la renta periódica; y la del lucro cesante, que por su naturaleza contingente se determina mediante un cálculo típico u objetivo del curso normal de los acontecimientos, y no mediante prueba individual y exacta de la ganancia perdida.

En cuarto lugar, desarrollar el problema de la determinación del daño patrimonial: el concepto abstracto de origen alemán, comparación contable del patrimonio total, y sus dos defectos, dilución de partidas específicas y posible indemnización pese a ausencia de disminución neta, como en el caso del seguro propio, frente al concepto concreto que prevalece en Chile, suma de partidas individualizadas de daño emergente y lucro cesante, con sus excepciones puntuales de determinación estandarizada, **artículo 1559** sobre intereses corrientes, y los regímenes de responsabilidad estricta o de seguridad social.

Cerrar con la tensión de fondo: el principio de reparación integral no se aplica de manera uniforme, sino que oscila entre la precisión individualizada del concepto concreto, preferida como regla general, porque permite un control más riguroso de cada partida de daño y evita que beneficios ajenos al hecho ilícito reduzcan la responsabilidad del demandado, y la estandarización excepcional, aceptada allí donde la certeza y el ahorro de costos de prueba superan el valor de una determinación estrictamente individual, de modo que la reparación integral funciona, en la práctica, como un ideal que el sistema aproxima de maneras distintas según el tipo de daño de que se trate.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 11. Clases de daño (I): el daño patrimonial**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

L. CLASES DE DAÑO (II): EL DAÑO MORAL

El daño moral es, junto al daño patrimonial examinado en el Eje 11, la segunda gran categoría de perjuicio resarcible, y también la más resistente a la sistematización, porque el Código Civil no contiene una definición del concepto ni tampoco lo menciona expresamente como rubro indemnizable. Su reconocimiento es, además, relativamente reciente: durante buena parte de la vigencia del Código se discutió si correspondía siquiera indemnizarlo, y solo en el último siglo la doctrina y la jurisprudencia terminaron aceptándolo sin discusión, aunque no sin dejar zonas de fricción que persisten hasta hoy, como se verá al examinar el **artículo 2331**.

Este eje debe resolver, en consecuencia, varias preguntas encadenadas: qué es el daño moral y cómo se lo distingue del patrimonial; por qué, pese al silencio del Código, se admite su reparación; qué categorías comprende esa noción, notoriamente más fragmentada que la del daño patrimonial; cómo se prueba un perjuicio que por definición no deja rastro material; y, sobre todo, cómo se avalúa en dinero un perjuicio que, en teoría, es inconmensurable en dinero. Esta última pregunta tiene una importancia que trasciende lo puramente técnico, porque en ella reaparece, según se explicará en el análisis de la tensión, la función punitiva que la propia definición del daño extracontractual pretendía excluir desde el Eje 1: la retribución, expulsada por la puerta del concepto, reingresa por la ventana de la evaluación.

1. CONCEPTO DE DAÑO MORAL

El daño moral ha sido tradicionalmente definido como el dolor, pesar o molestia que una persona sufre en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos, o en su calidad de vida, definición que se identifica con la expresión latina *pretium doloris*, el precio del dolor. Esta noción, sin embargo, resulta demasiado estrecha, porque dejaría fuera manifestaciones del daño extrapatrimonial ampliamente reconocidas en el derecho comparado, como el perjuicio estético o la alteración de las condiciones de vida, que no siempre suponen dolor en sentido estricto.

Por esta razón, cierta jurisprudencia ha preferido definir el daño moral de manera restrictiva, como la lesión de un derecho extrapatrimonial de la víctima, entendiendo por tal el agravio, efectuado culpable o dolosamente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial inherente a la persona. Pero esta definición, calcada sobre la exigencia de un derecho subjetivo, resulta demasiado estrecha para la tradición jurídica chilena, que, según se examinó al tratar los requisitos de resarcibilidad del daño en el Eje 10, no restringe la indemnización a la lesión de derechos, sino que la extiende a la de intereses legítimos. De ahí que resulte preferible una definición amplia, que entienda por daño moral la lesión de los intereses extrapatrimoniales de la víctima, comprendiendo así todas las categorías de perjuicio moral y no solamente el *pretium doloris* original. En rigor, y dada la dificultad de una definición positiva satisfactoria, suele ser más útil definir el daño moral en términos negativos: todo menoscabo no susceptible de evaluación pecuniaria, es decir, todo daño no patrimonial.

La Corte Suprema ha recogido esta noción amplia en su jurisprudencia reiterada, señalando que el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes, o un agravio a sus afecciones legítimas, de un dere-

cho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra; un daño que no es de naturaleza económica y que no implica, por tanto, un deterioro real en el patrimonio susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva, conforme a sentencia de 7 de agosto de 2007, dictada al conocer un recurso de casación en el fondo bajo el rol N° 2821-2007.

CORTE SUPREMA, 7 DE AGOSTO DE 2007, ROL N.º 2821-2007
CONCEPTO DE DAÑO MORAL

El daño moral es la lesión culpable o dolosa que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes, o un agravio a sus afecciones legítimas: un daño de naturaleza eminentemente subjetiva, no económica, que no implica un deterioro real del patrimonio susceptible de prueba y determinación directa.

2. RESARCIBILIDAD DEL DAÑO MORAL

Durante décadas se resistió la procedencia de la indemnización del daño moral, invocando tres argumentos principales: que la indemnización tiene por objeto hacer desaparecer el daño, cosa imposible tratándose de un perjuicio moral; que su monto es extremadamente difícil de fijar con criterios objetivos; y que admitirla abriría la puerta a una avalancha de demandas de familiares y allegados de la víctima, todos alegando su propia aflicción.

La doctrina y la jurisprudencia terminaron por descartar estos reparos, sobre la base de cinco argumentos que hoy son unánimemente aceptados. Primero, no toda indemnización debe ser necesariamente pecuniaria: también es posible una reparación en especie, como la publicación de la sentencia condenatoria en casos de ofensas al honor o al crédito. Segundo, la dificultad de fijar el monto y el riesgo de abusos no puede servir de pretexto para negar la compensación, porque esos mismos problemas se presentan, en menor medida, respecto del daño material. Tercero, las disposiciones que establecen la indemnización en materia extracontractual, los **artículos 2314** y **2329**, están redactadas en términos amplios, que no distinguen entre clases de daño y ordenan reparar todo perjuicio. Cuarto, la legislación posterior al Código Civil confirma esta amplitud, al mencionar expresamente el daño moral entre los rubros indemnizables: así lo hacen el **artículo 19** N° 7 letra i) de la Constitución, el **artículo 69** de la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo, el **artículo 40** inciso segundo de la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información, y el **artículo 3** letra e) de la Ley N° 19.496 sobre protección de los consumidores. Quinto, y de manera más indirecta, se observa que si el legislador negó expresamente la indemnización del daño moral en un caso particular, el **artículo 2331**, a propósito de las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito, ello supone que en los demás casos ese daño sí se indemniza, porque de lo contrario la exclusión expresa sería una norma sin sentido.

Precisamente el **artículo 2331** ha sido, en las últimas dos décadas, el escenario de una de las controversias jurisprudenciales más vivas de toda la materia, y conviene exponerla con detalle porque no está definitivamente resuelta. La lectura tradicional de esa norma, que si las imputaciones inju-

riosas no producen menoscabo patrimonial, no cabe reclamar indemnización en dinero, por más pesar que hayan causado a la víctima en su honor, llevó a que los demandantes plantearan, en juicios de responsabilidad por imputaciones injuriosas, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma. El Tribunal Constitucional acogió esta impugnación en sentencia de 10 de junio de 2008, resolviendo que aplicar el **artículo 2331** en esos términos priva a los atentados contra la honra que no constituyen delitos específicos de la protección general que sí reciben otras lesiones a derechos igualmente no delictuales, las cuales dan lugar a indemnización de todo daño patrimonial y moral conforme a la regla general del **artículo 2329**; y que esa discriminación resulta inconstitucional porque el **artículo 19** N° 26 de la Constitución prohíbe que una ley limite el contenido esencial de un derecho constitucional, en este caso el derecho a la honra del **artículo 19** N° 4. Ese razonamiento se reiteró en fallos posteriores del mismo tribunal.

El giro más significativo, sin embargo, se produjo directamente en sede de interpretación legal y no solo constitucional: la Corte Suprema, en sentencia de 7 de junio de 2021, dictada bajo el rol N° 6296-2019, resolvió que el propio **artículo 2331** no restringe la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas, invocando tres razones: el principio de reparación integral del daño examinado en el Eje 11; que la norma no excluye expresamente el daño moral, sino que simplemente no lo menciona, lo que se explica porque a la época de dictación del Código ese rubro indemnizatorio ni siquiera se contemplaba, como lo confirma el propio **artículo 1556**, que solo se refiere al daño emergente y al lucro cesante, siendo la reparación del daño moral una construcción jurisprudencial posterior; y que interpretar la norma en el sentido tradicional infringiría las garantías constitucionales de integridad física y psíquica y de protección de la vida privada y de la honra. Con todo, esta lectura no puede darse todavía por consolidada de manera uniforme: apenas dos meses después, la misma Corte Suprema, en sentencia de 10 de agosto de 2021, rol N° 22.901-2019, volvió a aplicar el razonamiento tradicional. La materia sigue, en consecuencia, en un estado de tensión jurisprudencial abierta, y conviene tenerlo presente al construir cualquier respuesta de examen sobre el punto. **DOMÍNGUEZ**, la principal expositora nacional de esta materia, va todavía más allá de la posición mayoritaria: sostiene que el **artículo 2331** debe tenerse por virtualmente derogado por la Constitución, en cuanto su aplicación restrictiva contradice el mandato de tutela amplia de la persona que se desprende de las garantías constitucionales y el propio principio de reparación integral del daño, de manera que la discusión no debiera resolverse caso a caso por la vía de declaraciones de inaplicabilidad, sino asumirse derechamente como una incompatibilidad estructural entre la norma decimonónica y el orden constitucional vigente.

Conviene situar esta controversia en su desarrollo histórico completo, porque el reconocimiento del daño moral en Chile es, en su origen, enteramente jurisprudencial: el Código Civil no contiene referencia alguna a esta clase de perjuicio, y los propios codificadores identificaban el daño únicamente con el daño material, como lo confirma el **artículo 1556**, que solo menciona el daño emergente y el lucro cesante. La primera sentencia que ordenó indemnizar el daño moral en Chile data de 1907, bajo la idea de un perjuicio al sentimiento y al valor de afección, doctrina que la Corte Suprema reiteró en 1922 y que, desde entonces, se transformó en uno de los pilares de la indemnización civil en el país, aunque, según observa **DOMÍNGUEZ**, ese reconocimiento se produjo sin cuestionamientos en sede extracontractual, mientras que su aceptación en el ámbito contractual fue considerablemente más tardía y solo puede darse por consolidada a partir de la década de 1990.

3. CATEGORÍAS DE DAÑO MORAL

Entendido en su sentido amplio como todo daño extrapatrimonial que sufre una persona, el daño moral ha dado lugar a una tipología abierta de categorías, no del todo delineadas ni unánimemente aceptadas, entre las que la doctrina nacional suele distinguir las siguientes. El daño emocional es el concepto original, el *pretium doloris* clásico: la indemnización busca paliar, hasta donde sea posible, el sufrimiento psíquico causado por el hecho ilícito. La lesión de un bien o derecho de la personalidad se configura con independencia del dolor psíquico efectivamente experimentado, bastando que se lesione en forma directa o ilegítima un derecho de la personalidad, la honra, la intimidad, la imagen, el derecho de autor; esta categoría permite explicar, según se verá, que las personas jurídicas, que no pueden sentir dolor alguno, puedan sin embargo sufrir un daño moral en este sentido más objetivo. El *préjudice d'agrément*, de origen francés, conocido en el derecho inglés como *loss of amenities of life*, consiste en la privación de las satisfacciones de orden social, mundano o deportivo de las que se beneficia una persona de similar edad y condición a la víctima, y se incrementa si esta cultivaba con éxito alguna capacidad creativa o talento particular. El daño corporal o fisiológico afecta la integridad física y psíquica de la persona, distinguiéndose del daño puramente moral en que no recae solo en la esfera emotiva, y puede generar además consecuencias patrimoniales indemnizables por separado, como los gastos médicos y el lucro cesante por incapacidad; **ELORRIAGA** ha propiciado en Chile la autonomía de esta categoría, situándola como un daño extrapatrimonial de carácter personal independiente del daño moral en sentido estricto. El daño estético, consecuencia frecuente del daño corporal, compensa el sufrimiento que experimenta la víctima al sentir negativamente modificado su aspecto físico.

Una categoría particularmente delicada, de desarrollo comparado más reciente, es la que agrupa los casos de *wrongful birth* y *wrongful life*. Los primeros se refieren a los padres que reclaman por tener que asumir las responsabilidades derivadas de un nacimiento imprevisto, imputando a un profesional médico la negligencia o falta de información en la práctica de una esterilización o de un aborto frustrado; en Chile se acogió una demanda de esta naturaleza en el caso de una mujer que concibió y dio a luz dos niñas después de que el médico tratante le practicara una ligadura de trompas sin informarle que había sido solo parcial, otorgándose indemnización por daño emergente y moral, según sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de 2 de mayo de 2012, rol N° 373-2011. Los casos de *wrongful life* son considerablemente más discutibles: en ellos se pretende que el error en un diagnóstico prenatal, que impidió advertir a la madre una malformación o discapacidad del hijo que gestaba, privó a esta de la posibilidad de decidir la interrupción del embarazo, configurando una suerte de pérdida de una chance. Sobre este punto, la doctrina nacional, siguiendo a **CORRAL**, rechaza decididamente esta calificación, por entender que reconocer el nacimiento de un ser humano como daño, económico o moral, contradice la dignidad esencial de la persona como fin en sí misma, que exige un respeto incondicionado ajeno a todo cálculo utilitarista; nada de ello obsta, en cambio, a que el propio hijo reclame por el daño corporal sufrido in utero, o por la falla en un diagnóstico que, de haberse hecho correctamente, habría permitido un tratamiento oportuno de su propia dolencia, ni a que casos de esta naturaleza sean atendidos mediante prestaciones de seguridad social que faciliten la integración del niño discapacitado, en lugar de reducir su existencia a la categoría de un daño indemnizable.

Conviene advertir, con todo, que esta multiplicación de categorías, fenómeno que se agudiza notablemente en algunos ordenamientos comparados, donde se han llegado a distinguir más de cuaren-

ta variantes de daño moral, tiene un grado importante de artificialidad, porque los bienes extrapatrimoniales no admiten divisiones tan nítidas como las que la tipología sugiere: una misma cicatriz dejada por un accidente puede constituir a la vez perjuicio estético, afectar la vida de relación de quien la porta, dificultar sus posibilidades afectivas y sumarse al sufrimiento físico propiamente dicho, de manera que fragmentar excesivamente el daño moral en categorías que en el fondo se superponen arriesga una doble o triple reparación del mismo perjuicio bajo distintos nombres. Parece, en consecuencia, más productivo asumir que pertenece a la categoría general del daño moral toda consecuencia adversa que afecte la constitución física o espiritual de la víctima, ya se exprese en un mal positivo, dolor, angustia, malestar, ya en la privación de un bien de cuyo disfrute la víctima queda excluida, sin que la reparabilidad dependa de encasillar el perjuicio en alguna subcategoría específica, sino de que reúna la certidumbre y la gravedad suficientes ya examinadas como requisitos generales del daño en el Eje 10.

Ligada a esta discusión sobre las categorías se encuentra la pregunta, menos explorada, por la naturaleza objetiva o subjetiva del daño moral, que se plantea con particular crudeza respecto de víctimas que se encuentran privadas de conciencia, como ocurre en los estados vegetativos. Una primera tesis, subjetiva, exige que la víctima tenga conciencia efectiva del daño que sufre como condición indispensable para su reparación, porque sin esa conciencia no habría, en rigor, sufrimiento que compensar. Una segunda tesis, objetiva, sostiene que el principio de reparación integral no admite excepción por la sola circunstancia de que la víctima carezca de conciencia de la pérdida sufrida. Una tesis intermedia distingue según el tipo de perjuicio moral de que se trate: la conciencia de la víctima no sería necesaria ni para el daño patrimonial, dada su objetividad, ni para el *pretium doloris* en sentido estricto, puesto que incluso una víctima sin conciencia puede padecer sufrimiento corporal; mayores reservas plantearía, en cambio, la reparación de perjuicios como el daño estético, la pérdida del goce de la vida o los daños fisiológicos, que parecen presuponer más claramente una experiencia consciente de la privación. **DOMÍNGUEZ** reporta, en este sentido, un caso en que la Corte Suprema debió pronunciarse sobre la reparación del daño moral que sufrieron dos hijas recién nacidas por la muerte de su padre, resolviendo que la falta de conciencia de las menores acerca de la pérdida experimentada no podía impedir que recibieran compensación por el *pretium doloris*, porque se trata de una pérdida que, cualquiera sea la edad o el grado de conciencia de quien la sufre, afecta necesariamente a toda persona conforme a la experiencia común. La jurisprudencia nacional ha optado, de este modo, por la concepción objetiva del daño moral, apreciándolo in abstracto y con independencia de la conciencia efectiva de la víctima, solución que **DOMÍNGUEZ** valora positivamente por resolver la cuestión en el sentido más favorable a la protección de la persona, misión que atribuye como primera al derecho civil en su conjunto.

4. EL DAÑO MORAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS

Durante buena parte del siglo pasado la jurisprudencia de los tribunales superiores fue uniforme en negar toda reparación de daño moral a las personas jurídicas, por la razón evidente de que una sociedad o una corporación no puede experimentar dolor ni aflicción. Sin embargo, desde hace algunas décadas se advierte una tendencia distinta, aunque todavía no unánime, orientada a reconocer que estas entidades pueden sufrir un daño extrapatrimonial en un sentido más objetivo que el *pretium doloris* original: no un dolor propiamente dicho, sino un menoscabo a bienes inmateriales propios de su personalidad jurídica, como su reputación o buen nombre comercial.

La fórmula más aceptada en Chile y en el derecho comparado condiciona la indemnización de este perjuicio a que, aunque no incida directamente en el patrimonio de la persona jurídica, proyecte consecuencias nocivas sobre ese patrimonio: es el caso de la empresa que ve reducida su clientela por publicidad infundada sobre la calidad de sus productos, o el de aquella que es incluida indebidamente en un registro de deudores morosos, viendo afectado su acceso al crédito. Esta doctrina ha debido enfrentar una crítica de cierto peso, si el daño repercute finalmente en el patrimonio, mal puede calificárselo de extrapatrimonial, a la que se responde distinguiendo el resultado del hecho generador: un mismo comportamiento ilícito puede producir consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales simultáneamente, ambas indemnizables si concurren sus respectivos requisitos, sin que ello suponga confundir una categoría con la otra.

La jurisprudencia nacional muestra, en todo caso, una tendencia bastante consistente en las últimas dos décadas. La Corte Suprema descartó, en fallo de 9 de diciembre de 2003, que una persona jurídica pudiera sufrir perjuicios exclusivamente extrapatrimoniales, admitiendo la indemnización únicamente cuando el prestigio o la confianza comercial afectados tuvieran consecuencias patrimoniales verificables. En esa misma línea se ha resuelto que lo que debe verse afectado es la reputación de la persona jurídica solo en cuanto tenga trascendencia en su situación económica, y no por el solo hecho de lesionar su reputación, según fallo de la Corte de Apelaciones de Talca de 18 de octubre de 2011; que respecto de las personas jurídicas cabe descartar el concepto de daño moral puro y centrarse en el daño moral con consecuencias patrimoniales, conforme a sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 23 de noviembre de 2009; y que para obtener indemnización por daño a la imagen de una empresa es necesario acreditar, de manera cierta, las consecuencias económicas en que se tradujo el desprestigio, según fallo de la Corte Suprema de 31 de octubre de 2012. Existen, con todo, sentencias minoritarias que han denegado derechamente este rubro de perjuicios, como la dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 29 de septiembre de 2008.

DOMÍNGUEZ critica esta jurisprudencia predominante por resultar demasiado restrictiva, y por incurrir en el mismo error conceptual que denuncia a propósito del concepto general de daño moral: condicionar la reparación del daño extrapatrimonial de las personas jurídicas a que este proyecte consecuencias patrimoniales verificables equivale, a su juicio, a seguir asimilando el daño moral al pretium doloris, que las personas jurídicas, en efecto, no pueden experimentar, en circunstancias de que el daño moral, correctamente entendido en su sentido amplio, no es sinónimo únicamente de atentados a los sentimientos, sino de todo atentado extrapatrimonial, categoría dentro de la cual el prestigio o la credibilidad de una persona jurídica constituyen solo un ejemplo más. Sostiene, además, que el reconocimiento constitucional del daño moral no ofrece fundamento alguno para excluir a las personas jurídicas de su protección, y que negárselo dejaría en la práctica sin contenido otra garantía igualmente constitucional, como el derecho de asociación.

5. PRUEBA DEL DAÑO MORAL

A diferencia del daño patrimonial, cuya prueba sigue las reglas generales y recurre principalmente a documentos, peritajes e informes técnicos, el daño moral plantea una dificultad probatoria estructural: por su propia naturaleza, no deja huella material verificable de manera directa. La jurisprudencia mayoritaria ha resuelto esta dificultad sosteniendo que, en determinadas situaciones, el

daño moral no requiere acreditación por medios formales, porque su existencia se desprende de las circunstancias mismas en que ocurre el hecho y de las relaciones entre los partícipes, como sucede característicamente con la muerte de un hijo, donde el dolor de sus padres no necesita demostrarse porque se infiere razonablemente de la sola relación de filiación. Una posición más extrema sostiene, incluso, que el daño moral no requeriría prueba alguna, bastando la sola constatación de la lesión a un derecho extrapatrimonial para que el juez quede facultado para evaluar directamente su existencia y magnitud.

Con todo, la posición más rigurosa, y la que mejor se concilia con el carácter del daño como requisito general de la acción de responsabilidad, examinado en el Eje 10, sostiene que el daño moral, como cualquier otro, debe probarse, aunque su prueba deba acomodarse a su naturaleza especial: si se alega un daño corporal, corresponde acreditar la lesión y sus consecuencias; si se trata de un daño estético, corresponde que el juez aprecie directamente su realidad; si se trata de la aflicción psíquica, la prueba debe orientarse a acreditar los hechos que, ordinariamente, habrían producido ese sufrimiento en una persona normal colocada en la misma situación. La prueba por presunciones adquiere, en este contexto, una relevancia central, siempre que se funde en hechos conocidos y efectivamente probados en el proceso, y que el juez explicita el razonamiento lógico que permite, a partir de esos hechos conocidos, tener por establecido el hecho ignorado que se pretende acreditar.

6. AVALUACIÓN DEL DAÑO MORAL

La evaluación del daño moral enfrenta a los tribunales con la dificultad de traducir a una suma de dinero un concepto que, por definición, es intangible. Existe consenso en que esa evaluación es una facultad privativa de los jueces del fondo, no susceptible de revisión por la vía de la casación (a diferencia, según se examinó en el Eje 8, de la calificación jurídica de la culpa, que sí es controlable por esa vía, precisamente porque se trata de aplicar conceptos legales definidos por el **artículo 44** del Código Civil, mientras que la determinación del monto de la reparación moral carece de un parámetro legal equivalente al que referirla).

Los criterios que los tribunales emplean para esta evaluación son diversos y no siempre explícitos: las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales que se derivan del daño causado; las condiciones personales de la víctima; el grado de cercanía o de relación afectiva que unía al demandante con la víctima directa; la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredido; pero también, y esto merece atención especial, la gravedad de la conducta del autor que causó el perjuicio y la situación patrimonial tanto del ofendido como del ofensor.

DOMÍNGUEZ ha sido especialmente crítica de la forma en que los tribunales chilenos ejercen esta facultad discrecional, identificando dos problemas que reclaman revisión urgente. El primero es la práctica de las condenas en globo: la fijación de una suma única y genérica por concepto de daño moral, sin precisar qué tipos de perjuicio extrapatrimonial se pretende reparar bajo ese título ni cuáles fueron los criterios empleados para llegar a esa cifra, lo que impide todo control posterior sobre la coherencia y proporcionalidad de la indemnización. El segundo es la variedad y multiplicidad absoluta de los criterios que efectivamente emplean los tribunales, hasta el punto de que en un número importante de sentencias ni siquiera se mencionan los factores considerados para fijar el monto. Sobre este último punto, **DOMÍNGUEZ** formula una advertencia que conviene retener para el análisis que sigue: sostiene expresamente que la condena pecuniaria por daño moral no es,

en algunos casos, exclusivamente reparadora, sino claramente punitiva, y que ello se revela en que los jueces toman en cuenta la capacidad económica de las partes o la gravedad del hecho ilícito, factores que, en su opinión, ninguna función debieran cumplir dentro de un esquema que se declara puramente resarcitorio.

DATO DE GRADO**La función punitiva que reingresa por la evaluación**

Este último par de criterios, la gravedad de la conducta del demandado y su propia situación patrimonial, merece un examen detenido, porque contradice de manera flagrante la premisa con que se abrió este eje y, más atrás, con la que se abrió todo el material desde el Eje 1: que la responsabilidad civil no cumple una función retributiva o sancionatoria, sino puramente reparatoria, y que su medida debe ser el daño efectivamente sufrido por la víctima, no la culpabilidad del ofensor ni su capacidad de pago. No se trata, además, de una inferencia puramente analítica: **DOMÍNGUEZ**, según ya se adelantó, lo constata directamente en la práctica de nuestros tribunales, denunciando que la condena por daño moral no siempre es exclusivamente reparadora y que, en no pocos casos, resulta abiertamente punitiva.

Repárese en lo que efectivamente ocurre cuando un tribunal, al evaluar el daño moral, atiende a cuán grave o reprochable fue la conducta del demandado. Ese criterio no dice nada sobre la intensidad del sufrimiento de la víctima: dos personas pueden padecer un dolor idéntico, la pérdida de un hijo en un accidente de tránsito, y, sin embargo, recibir indemnizaciones distintas según que el conductor responsable haya actuado con una negligencia leve o con una imprudencia temeraria y reiterada. Si la función de la indemnización fuera puramente compensatoria del padecimiento de la víctima, la gravedad de la conducta del autor sería, sencillamente, irrelevante para fijar el monto: lo único que importaría es cuánto sufrió quien reclama, no cuán reprochable fue quien causó ese sufrimiento. Que los tribunales atiendan, sin embargo, a esa gravedad revela que, en los hechos, la evaluación del daño moral incorpora un juicio de reproche sobre la conducta del demandado que es ajeno a la lógica puramente reparatoria.

Lo mismo, y con mayor nitidez todavía, ocurre con el criterio de la situación patrimonial del ofensor. Que la capacidad económica del demandado incida en el monto de la indemnización no tiene ninguna relación con el daño sufrido por la víctima, el dolor de esta no aumenta ni disminuye según cuán rico sea quien se lo causó, pero sí tiene una relación directa con una consideración disuasiva: para que una indemnización cumpla efectivamente una función preventiva, disuadiendo conductas negligentes futuras, su monto debe ser lo bastante significativo en relación con el patrimonio de quien debe pagarla; una suma que representaría una sanción severa para una persona de escasos recursos puede resultar completamente indiferente, y por tanto carente de todo efecto disuasivo, para quien dispone de un patrimonio considerable. Este es, precisamente, el razonamiento que subyace a toda pena o sanción dirigida a desincentivar una conducta, y no el que corresponde a una reparación dirigida a restituir a la víctima a su situación anterior.

Esta observación no es una crítica externa al sistema chileno, sino la constatación de algo que el propio sistema hace sin declararlo abiertamente: la función punitiva o preventiva de la responsabilidad civil, expresamente excluida de su definición desde el Eje 1 y reexaminada en la tensión sobre responsabilidad civil y penal del Eje 2, no ha desaparecido del todo del estatuto de los delitos y cuasidelitos civiles; simplemente ha sido expulsada del concepto y del fundamento formal de la institución, para reingresar, silenciosamente, en el momento discrecional de la evaluación del daño moral, precisamente porque ese es el único punto del siste-

ma en que los tribunales gozan de un margen de apreciación lo bastante amplio como para dar cabida, sin necesidad de reconocerlo expresamente, a consideraciones que exceden la pura compensación del padecimiento sufrido. La inconmensurabilidad misma del daño moral en dinero, que impide someter su evaluación a un cálculo verificable como el que rige el daño patrimonial, es la que abre este espacio: al no existir un valor de mercado contra el cual contrastar la suma fijada, nada impide, ni nada permite tampoco descartar del todo, que en esa suma se filtren consideraciones ajenas a la intensidad del sufrimiento efectivamente padecido por quien reclama.

7. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el concepto de daño moral: silencio del Código, su origen enteramente jurisprudencial desde 1907, definición restringida del *pretium doloris* frente a la definición amplia de lesión de intereses extrapatrimoniales, y la fórmula negativa de todo menoscabo no susceptible de evaluación pecuniaria, con la definición jurisprudencial de 2007, seguido de su resarcibilidad, exponiendo los cinco argumentos que la justifican y, con particular detalle, la controversia sobre el **artículo 2331**: la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en 2008, el giro jurisprudencial de la Corte Suprema en 2021, la persistencia, en el mismo año, de fallos que mantienen la lectura tradicional, y la posición de **DOMÍNGUEZ**, que sostiene la derogación virtual de la norma por la Constitución.

En segundo lugar, exponer las categorías de daño moral: daño emocional, lesión de un derecho de la personalidad, *préjudice d'agrément*, daño corporal, daño estético, y los casos de *wrongful birth* y *wrongful life*, con el caso chileno de 2012 y el rechazo doctrinal a la segunda categoría por razones de dignidad de la persona, advirtiendo el riesgo de fragmentación excesiva y de doble reparación que esta tipología comporta, y la discusión sobre la naturaleza objetiva o subjetiva del daño moral, ilustrada con el problema de las víctimas sin conciencia y la solución objetiva que ha adoptado la jurisprudencia nacional. Debe tratarse también el daño moral en las personas jurídicas, con su condicionamiento jurisprudencial a que el menoscabo extrapatrimonial proyecte consecuencias patrimoniales verificables, la jurisprudencia constante en ese sentido desde 2003, y la crítica de **DOMÍNGUEZ** a esa restricción.

En tercer lugar, exponer la prueba del daño moral, flexibilizada por su naturaleza especial, admitiendo presunciones fundadas en las circunstancias del caso, y su evaluación, facultad privativa de los jueces del fondo no revisable por casación, con sus criterios habituales y, en particular, la gravedad de la conducta del ofensor y la situación patrimonial de ambas partes, sumando las críticas de **DOMÍNGUEZ** a las condenas en globo y a la falta de criterios explícitos en la práctica judicial.

Cerrar con la tensión de fondo: esos dos últimos criterios de evaluación son incompatibles con una concepción puramente reparatoria del daño moral, porque no miden la intensidad del sufrimiento de la víctima sino el reproche que merece la conducta del demandado y su capacidad de sentir el peso disuasivo de la condena, revelando que la función punitiva excluida de la definición de la responsabilidad civil desde el Eje 1 reingresa, sin reconocerse expresamente, en el momento de ava-

luar el daño moral, precisamente porque la inconmensurabilidad de ese daño en dinero es lo que hace posible, y a la vez imposible de descartar, esa infiltración.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 12. Clases de daño (II): el daño moral**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

M. LA CAUSALIDAD

Para que un hecho doloso o culpable genere responsabilidad, no basta con que exista un daño resarcible: es necesario, además, que entre ese hecho y ese daño exista un vínculo, una relación de causa a efecto. El hecho ilícito debe constituir una causa del daño, y el daño debe ser un efecto del hecho ilícito. Aunque el requisito no está reglamentado como tal en el Código Civil, diversas normas del título de los delitos y cuasidelitos lo presuponen de manera implícita: el **artículo 2314** exige que el delito o cuasidelito haya "inferido daño a otro"; el **artículo 2318** responsabiliza al ebrio por el daño "causado por su delito o cuasidelito"; los **artículos 2319 y 2325** se refieren a los "daños causados". A ello se suma el **artículo 1558**, norma de la responsabilidad contractual cuya aplicación una parte importante de la doctrina extiende al ámbito extracontractual, y que exige responder de los perjuicios que fueron "consecuencia inmediata y directa" del incumplimiento.

La causalidad cumple, en este sentido, una doble función que conviene distinguir desde el inicio, porque de esa distinción depende buena parte de la complejidad de la materia. Por un lado, opera como requisito de la responsabilidad: exige que el hecho del demandado sea condición necesaria del daño, cuestión que en su formulación más elemental pertenece al terreno de la pura observación empírica. Por otro lado, opera como límite de la responsabilidad: no basta una relación puramente descriptiva entre el hecho y el daño, sino que se exige además una apreciación normativa que permita calificar ese daño como una consecuencia directa del hecho ilícito, y no como una consecuencia remota o extraña a la que el derecho no está dispuesto a extender la obligación de indemnizar. La determinación del daño directo no es, entonces, un problema puramente técnico o pericial: exige un juicio normativo sobre la razonable proximidad entre el daño y el hecho, un juicio que las diversas teorías examinadas en este eje intentan sistematizar.

La complejidad práctica del problema se aprecia con claridad en ciertos casos límite que la doctrina suele emplear para poner a prueba cualquier teoría causal: si un peatón atropellado por un conductor ebrio sufre, a consecuencia del atropello, una lesión menor por la cual acude a un hospital, y allí se le suministra un antibiótico al que resulta alérgico, muriendo por esa reacción, ¿es el conductor causante de esa muerte? ¿Y si, en cambio, muere porque la ambulancia que lo trasladaba colisiona con otro vehículo? Estas dificultades no son exclusivas del derecho civil: buena parte de las teorías examinadas en este eje provienen originalmente de la ciencia penal, y han sido adaptadas por la doctrina civil para resolver el mismo problema estructural.

1. TEORÍAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD

Las múltiples doctrinas elaboradas para determinar la causa en materia de responsabilidad pueden agruparse en dos grandes corrientes: las teorías empiristas o naturalísticas, que intentan localizar el momento causal observando los fenómenos físicos y emplazando la conducta humana dentro del cortejo de acontecimientos que ocurren en la naturaleza; y las teorías normativas, que si bien parten también de la observación del suceder causal empírico, estiman imprescindible efectuar, además, valoraciones jurídicas que superen el marco de la mera causalidad física.

1.1. Teorías empiristas

La teoría de la equivalencia de las condiciones, también llamada de la *condictio sine qua non*, es la más clásica y postula que no es posible distinguir, entre las varias condiciones que concurren para producir un daño, cuál es más causa que las demás: todas son equivalentes. Para determinar si un factor es condición del resultado, y por tanto causa, se emplea el procedimiento de la supresión mental hipotética: se reconstruye mentalmente la situación sin ese factor, y si el resultado igualmente se habría producido, el factor no era condición; si, en cambio, el resultado no se habría producido, el factor sí es condición y, por tanto, causa. Aplicando este criterio, si en un resultado dañoso interviene una secuencia de causas necesarias, como en el caso de lesiones de tránsito que devienen mortales por un tratamiento médico erróneo, cada una de ellas da lugar a un vínculo causal relevante, sin perjuicio de que quien deba indemnizar íntegramente a la víctima pueda repetir contra los demás responsables por la parte que a cada uno corresponda, conforme a la regla de solidaridad del **artículo 2317**. Esta teoría ha sido ampliamente empleada por la jurisprudencia nacional, especialmente por su simplicidad: se ha resuelto, por ejemplo, que si una persona fallece de una gangrena sobrevenida a causa de un accidente, el daño debe indemnizarse igualmente, porque civilmente se responde tanto de los daños inmediatos como de los mediatos que sean consecuencia necesaria del hecho, en el sentido de que, de no mediar este, aquellos no habrían ocurrido.

La teoría ha sido, sin embargo, objeto de tres críticas severas. La primera advierte que la supresión mental hipotética solo funciona si previamente se sabe si el factor suprimido es o no causa del resultado, incurriendo en una petición de principio: para saber si un medicamento causó una malformación, es necesario primero saber si es causalmente apto para producirla, y si eso ya se sabe, la operación de suprimirlo mentalmente resulta superflua. La segunda crítica surge de los casos de causalidad acumulativa, en que dos causas independientes concurren y cada una, por sí sola, habría bastado para producir el resultado: si se suprime mentalmente cualquiera de ellas, el resultado de todos modos se habría producido por obra de la otra, de manera que ninguna de las dos calificaría como causa, produciendo una conclusión absurda de impunidad, así ocurre, en el ejemplo clásico, con el padre que dispara y mata al asesino de su hijo el mismo día en que este iba a ser fusilado por un pelotón de ejecución. La tercera crítica advierte que, aplicada con rigor, la teoría conduce a una extensión desmesurada de la responsabilidad, porque cualquier hecho situado en la cadena de acontecimientos que antecede al resultado podría calificarse de causa, hasta el extremo de poder imputar causalmente un homicidio a los propios padres que engendraron al homicida.

La teoría de la causa adecuada intenta corregir estas deficiencias distinguiendo, entre todas las condiciones que concurren en la producción del daño, aquella que normalmente ha de producirlo: debe preferirse el acontecimiento que desempeñó el papel preponderante en la ocurrencia del perjuicio. Conforme a esta doctrina, la atribución de un daño supone que el hecho del autor sea generalmente apto, según la experiencia, para producir esas consecuencias dañosas; si desde la perspectiva de un observador objetivo la ocurrencia del daño es una consecuencia verosímil del hecho, existe causa adecuada; si, en cambio, el resultado depende de factores intervinientes que resultan casuales o extraordinarios según el curso normal de los acontecimientos, la causa no es adecuada. Aunque esta doctrina tiene el mérito de limitar la extensión desmesurada que produce la equivalencia de las condiciones, presenta también dificultades importantes. La primera es que introduce, en sede de atribución causal, un elemento de previsibilidad propio de la culpabilidad, confundiendo dos juicios que deberían mantenerse analíticamente distintos. La segunda es que recurre a la fi-

gura de un observador externo que juzga ex post cuáles consecuencias pertenecen al desarrollo natural de los acontecimientos y cuáles a circunstancias extraordinarias, y ese observador cuenta, casi inevitablemente, con más información que la que tenía disponible el agente al momento de actuar, lo que distorsiona el juicio: la jurisprudencia alemana ha tendido, en este sentido, a construir un observador óptimo dotado de información perfecta, con lo cual la responsabilidad termina extendiéndose más allá de lo que era previsible según la experiencia general de la vida, desnaturalizando la función misma que la doctrina de la causa adecuada pretendía cumplir.

1.2. Teorías normativas

La teoría de la relevancia jurídica intenta conciliar las dos doctrinas anteriores, reconociendo la validez de la equivalencia de las condiciones en el plano puramente empírico, todas las condiciones son causas naturales, pero sosteniendo que, jurídicamente, no todas esas causas son equivalentes: para el derecho solo son relevantes aquellos procesos causales que, conforme a criterios de previsibilidad tomados de la teoría de la adecuación, alcanzan cierta significación jurídica. Precisamente por intentar conciliar dos doctrinas distintas, esta teoría no ha sido acogida de manera plena.

La teoría de la imputación objetiva, desarrollada originalmente por **LARENZ** y elaborada después con mayor detalle por el penalista **ROXIN**, entiende la relación de causalidad como una investigación acerca de la existencia de una imputación: se trata de delimitar, dentro de los acontecimientos accidentales, un hecho que pueda considerarse propio de una persona, esto es, imputable a ella. Habrá causalidad, en este sentido, cuando el hecho y sus consecuencias fueron previsibles y dominables por el agente. La formulación de **ROXIN** agrega un criterio adicional, decisivo para acotar el ámbito de la imputación: existe en toda vida en sociedad un nivel de riesgo general que no puede evitarse, e incluso riesgos que deben tolerarse o fomentarse en beneficio de la colectividad; mantenerse dentro de ese riesgo general de la vida no puede considerarse causa de un resultado dañoso. Solo la creación de un riesgo superior a ese riesgo general, y que, además, resulte jurídicamente desaprobado, puede imputarse al autor y generar responsabilidad.

2. LA CAUSALIDAD COMO UN TEMA EMPÍRICO Y NORMATIVO

La doctrina nacional contemporánea estima, en general, que la relación de causalidad no puede analizarse desde una perspectiva puramente naturalística ni puramente normativa, sino que exige combinar ambas dimensiones. **BARROS** ha explicado con particular claridad esta doble función: la causalidad opera, por un lado, como requisito, exigiendo que el hecho sea condición necesaria del daño; por otro, como límite, exigiendo una apreciación normativa que permita calificar el daño como consecuencia directa del hecho ilícito.

EJEMPLO**Los cuatro casos de BARROS sobre imputación objetiva**

- (i) Si una persona atropellada debe acudir a un hospital y allí se contagia de influenza (sin que el accidente hubiera aumentado su disposición a contraerla), no hay responsabilidad del autor del accidente, porque la influenza no tiene por causa adecuada el accidente.
- (ii) Si un bocinazo provoca un ataque cardíaco en un conductor de edad avanzada, tampoco hay responsabilidad, porque la debilidad particular de la víctima es una circunstancia exorbitante, ajena al riesgo creado.
- (iii) Si, en cambio, la ambulancia que traslada a gran velocidad al herido colisiona y causa daños a un tercero, sí existe responsabilidad del causante del accidente original, porque ese riesgo queda comprendido dentro del riesgo que su propio hecho creó.
- (iv) Si el mal estado de un camino provoca un choque en el que un empresario queda atrapado camino a cerrar un negocio, el Estado responde de los daños de las víctimas inmediatas, pero no de la pérdida del negocio: ese perjuicio es ajeno al fin protector de la norma de cuidado infringida (doctrina del ámbito de protección de la norma).

CORRAL aporta, por su parte, una precisión de orden conceptual: es necesario distinguir entre el actuar humano propiamente dicho y el resto de la causalidad de la naturaleza física, porque un ser humano puede intervenir en un proceso causal sin que su voluntad pueda reputarse causa responsable del acontecimiento. Lo que interesa, en materia de responsabilidad, es cómo puede atribuirse un proceso causal a una voluntad humana en cuanto voluntad, y no en cuanto mera intervención física de un cuerpo humano dentro de la cadena de sucesos naturales. De ahí que la teoría de la equivalencia de las condiciones y su test de supresión mental hipotética sean útiles para descartar lo que ciertamente no es causa, pero resulten insuficientes para determinar, entre lo que sí lo es en sentido empírico, qué cuenta además como causa jurídicamente relevante: para ello es necesario complementar el análisis con la previsibilidad del resultado y con la determinación de si hubo o no un incremento del riesgo ordinario de la vida en común, en el sentido ya explicado por la teoría de la imputación objetiva.

3. PLURALIDAD DE CAUSAS

Existen diversas hipótesis en que el daño no puede atribuirse a una sola causa aislada. La primera se presenta cuando dos o más personas intervienen en su producción, ya ejecutando un mismo hecho, ya ejecutando cada una un hecho distinto que contribuye al resultado. La segunda ocurre cuando el daño se debe en parte al hecho del demandado y en parte a la intervención de la propia víctima. La tercera se presenta cuando el daño se debe a un hecho externo al autor, que respecto de él constituye caso fortuito o fuerza mayor.

3.1. Caso fortuito o fuerza mayor

El problema se plantea cuando coexisten, en la producción del daño, un acontecimiento inevitable, imprevisible e irresistible, el caso fortuito, y un comportamiento imprudente del demandado. La pregunta decisiva es si ese comportamiento imprudente puede considerarse causa del daño con independencia de la existencia del caso fortuito: si la acción del demandado hubiera causado el perjuicio aun sin la intervención de la fuerza mayor, debe afirmarse la relación de causalidad y, con ella, la responsabilidad; si, a la inversa, la causa del daño es el caso fortuito, y este se habría producido con independencia del comportamiento negligente del demandado, no existe relación de causalidad entre esa conducta y el daño. Cuando el caso fortuito y el comportamiento negligente actúan como concausas necesarias y simultáneas, sin que pueda aislarse cuál de los dos determinó por sí solo el resultado, parece más justo no absolver totalmente al agente, sino reducir el monto de la indemnización en proporción a la entidad de su aporte causal.

Este eje retoma aquí un hilo ya anunciado al examinar el hecho voluntario y el caso fortuito: lo que en aquella sede se identificó como el requisito de la exterioridad, que el hecho invocado como fuerza mayor sea ajeno a la esfera de acción y de control del demandado, es, precisamente, lo que explica por qué el caso fortuito excluye la relación de causalidad, y no solamente la culpa. Y por la misma razón se advirtió entonces que la culpa de la víctima comparte ese mismo carácter exterior: respecto del autor del hecho, la conducta de la víctima que resulta ser la causa determinante del daño es un hecho ajeno a su ámbito de control, por el cual no puede considerársele responsable, aun cuando su propia acción constituya, en un sentido puramente empírico, una causa remota y necesaria del perjuicio.

3.2. Pluralidad de agentes

Cuando varios responsables actúan simultáneamente ejecutando un mismo hecho, todos ellos responden solidariamente, conforme al **artículo 2317** del Código Civil; la misma solidaridad rige entre quien responde por el hecho de un tercero bajo su dependencia y el autor material del daño, conforme a los **artículos 2320 y 2322**, aun cuando los deberes de cuidado infringidos por uno y otro sean distintos, negligencia en la ejecución del hecho, en el primer caso; negligencia en la vigilancia, en el segundo, porque el hecho generador de la responsabilidad es, en definitiva, el mismo. El Código no contiene, sin embargo, una regla general sobre las relaciones internas entre los coautores solidarios: no resulta aplicable la regla de contribución del **artículo 1522**, pensada para la solidaridad contractual en función del interés de cada deudor en la operación que dio origen a la obligación, y la única norma especial en sede extracontractual es el **artículo 2325**, aplicable exclusivamente a la responsabilidad por el hecho ajeno, que da al tercero civilmente responsable acción de reembolso contra el autor material, siempre que este sea capaz, que aquel no haya incurrido en culpa personal, y que no haya mediado una orden suya que el autor del hecho debiera obedecer. Fuera de ese caso especial, parece preferible distribuir la contribución a la deuda entre los coautores en proporción a la intensidad de la culpa y de la causalidad de cada uno, por analogía con el criterio que el **artículo 2330** emplea para la reducción de la indemnización cuando ha mediado culpa de la víctima.

Cuando, en cambio, existen varios responsables por hechos distintos, cada uno de los cuales constituye, individualmente, causa necesaria y suficiente del daño, no resulta aplicable en sentido lite-

ral el **artículo 2317**, porque no se trata de un solo delito o cuasidelito sino de ilícitos separados que generan responsabilidad de manera independiente para cada autor. Sin embargo, puesto que cada uno de ellos debería en principio responder de la totalidad del daño, y la víctima no puede en caso alguno obtener una reparación que exceda el monto de los perjuicios efectivamente sufridos, es necesario dividir la responsabilidad entre los distintos autores en proporción a su respectiva participación, produciéndose en la práctica un efecto análogo al de la solidaridad del **artículo 2317**, sin perjuicio de la acción de reembolso de cada uno contra los demás.

Mayor dificultad presenta la denominada causa difusa, que se produce cuando el daño se debe al hecho culpable de alguno entre varios candidatos a responsable, sin que resulte posible determinar cuál de ellos lo desencadenó efectivamente, situación que puede presentarse en choques múltiples, en accidentes por productos defectuosos o en daños ambientales. El derecho chileno no contiene una regla general para este problema, y solo reconoce reglas especiales de responsabilidad difusa a propósito de la ruina de edificios y de la caída de objetos, que establecen una distribución proporcional entre los posibles responsables, constituyendo una excepción puntual al principio general de solidaridad del **artículo 2317**. Esa misma regla de distribución, aplicada por analogía mientras no se pruebe a cuál hecho concreto es atribuible el daño, parece la solución más razonable también para los demás casos de causa difusa no expresamente regulados.

3.3. Concurrencia de culpa de la víctima

Corresponde examinar, en primer lugar, si la culpa de la víctima fue la única causa del daño, caso en el cual no existe responsabilidad alguna del demandado, precisamente porque de su parte no hubo culpa: así ocurre con el peatón que cruza de improviso la calzada a mitad de cuadra y es atropellado por un vehículo que circulaba respetando todas las exigencias reglamentarias.

Distinto es el caso en que existe un verdadero concurso de culpas, esto es, tanto de quien causa el daño como de la víctima que contribuyó a padecerlo. Esta situación está expresamente prevista en el **artículo 2330** del Código Civil, que dispone que la apreciación del daño está sujeta a reducción si quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente. Los criterios para determinar esa reducción son la intensidad relativa de las culpas de una y otra parte y la intensidad relativa de sus respectivas contribuciones causales, ambos sujetos a una evaluación prudencial de los tribunales del fondo.

Una cuestión especialmente discutida es si esta reducción opera únicamente respecto de la víctima directa que se expuso imprudentemente, o si alcanza también a quienes reclaman indemnización de daño moral por repercusión a consecuencia de su muerte o lesiones. La jurisprudencia se ha pronunciado en ambos sentidos. Una línea sostiene que la reducción se extiende también a las víctimas por repercusión, argumentando que no sería equitativo ni racional imponer al demandado la reparación total de un daño que solo causó parcialmente, y que de resolverse lo contrario las víctimas indirectas obtendrían una reparación superior a la que habría correspondido a la propia víctima directa. Otra línea sostiene que, si quienes reclaman el daño moral no fueron ellos mismos quienes se expusieron imprudentemente, no corresponde aplicarles la reducción, porque su acción es propia e independiente de la de la víctima directa; se ha resuelto, en este sentido, que la disminución que forzosamente afecta a la víctima imprudente no puede aplicarse a sus progenitores, por no haber sido ellos los causantes de esa imprudencia. En ciertos casos los tribunales han buscado, en cambio, fundar la reducción no en la conducta de la víctima directa, que puede carecer de capa-

cidad delictual, como ocurre con un menor de edad, sino en la propia imprudencia de quienes reclaman por repercusión: así se ha resuelto, tratándose de la muerte de un infante en un accidente ocurrido en un sitio donde se realizaban faenas de excavación, que no procede reducción alguna respecto de la víctima por su incapacidad, pero sí respecto de sus padres, que incurrieron en manifiesta imprudencia al ausentarse del hogar y dejarlo solo en ese lugar.

Se discute, finalmente, si la reducción del **artículo 2330** exige que la víctima tenga capacidad delictual. **CORRAL** sostiene que no, porque en esta hipótesis no se trata propiamente de una eximente de responsabilidad del autor fundada en la responsabilidad civil de la víctima, lo que exigiría acreditar todos los elementos de esa responsabilidad, incluida su capacidad, sino de una conducta de la víctima que interviene el proceso causal que desemboca en el daño, con total independencia de si esa conducta le es o no imputable a título de responsabilidad civil propia. Sería, en efecto, difícil de sostener que una misma conducta autorice la rebaja de la indemnización cuando la despliega una víctima capaz, y la excluya cuando la despliega un menor o un incapaz. La jurisprudencia, sin embargo, tiende a exigir capacidad delictual en la propia víctima menor para aplicarle directamente la reducción, aunque deja abierta la posibilidad de fundarla, en cambio, en la negligencia de quienes tenían a su cargo el cuidado del menor.

4. PRUEBA DE LA CAUSALIDAD

Los hechos que dan lugar a la relación causal deben ser probados por el demandante, en aplicación de la regla general del **artículo 1698** ya examinada en el Eje 9 a propósito de la prueba de la culpa. Esa carga se extiende tanto a la demostración de que el hecho del demandado fue condición necesaria del daño, causalidad en sentido estricto, como a las circunstancias que permiten calificar el daño como directo, la imputación normativa ya examinada en la sección 3.

En los casos más complejos, particularmente aquellos que involucran causas múltiples o procesos tecnológicos complejos, no existe otra manera práctica de acreditar la causalidad que recurriendo a presunciones judiciales, construidas cuando existe, según la experiencia, una probabilidad razonable de que el hecho del demandado haya causado el daño. Las mismas razones que justifican la presunción legal de culpabilidad por el hecho propio del **artículo 2329**, examinada en el Eje 9, rigen también para dar por acreditada la causalidad: si conforme a la experiencia el daño puede ser imputado objetivamente al hecho de un tercero, este resulta responsable, a menos que logre desvirtuar esa presunción con la prueba en contrario que a él le corresponde aportar. La norma del **artículo 2329** puede entenderse, en este sentido, como una presunción legal comprensiva a la vez de la culpa y de la causalidad, o de ambas según las circunstancias del caso, siempre que se cumpla su requisito general de aplicación: que, conforme a la experiencia, la ocurrencia de ese tipo de daño se deba usualmente a un hecho del demandado.

5. CALIFICACIÓN DE LA CAUSALIDAD

La jurisprudencia ha entendido tradicionalmente que la determinación de la causalidad es una cuestión de hecho, privativa de los jueces del fondo y, por tanto, ajena al control de casación. Esta afirmación, sin embargo, solo es exacta respecto del primer aspecto de la causalidad, su condición

de requisito, esto es, la constatación de que el hecho fue condición necesaria del daño. La atribución normativa del daño al hecho ilícito, es decir, la calificación del daño como directo, es en cambio una cuestión de derecho, susceptible de revisión por la Corte Suprema mediante el recurso de casación en el fondo, en términos análogos a los ya examinados respecto de la calificación de la culpa en el Eje 8 y de la culpabilidad en general.

DATO DE GRADO**La disputa entre lo empírico y lo normativo en la causalidad**

El desarrollo de este eje puede leerse como el relato de un mismo problema abordado sucesivamente desde perspectivas incompatibles entre sí, y conviene identificar con precisión en qué consiste esa incompatibilidad, porque de ella depende la elección misma del método con que debe resolverse cualquier caso de causalidad compleja.

La teoría de la equivalencia de las condiciones tiene la virtud de la honestidad empírica: describe la causalidad tal como efectivamente opera en el mundo físico, sin introducir ningún juicio de valor ajeno a la pura constatación de que, sin el hecho del demandado, el daño no se habría producido. Mantiene, además, una separación analítica nítida entre causalidad y culpabilidad, evitando cualquier confusión entre ambos requisitos de la responsabilidad. El precio de esa honestidad, sin embargo, es una extensión desmesurada de la responsabilidad potencial, que en el límite alcanza a los padres del homicida, y que produce resultados absurdos en los casos de causalidad acumulativa, donde la aplicación mecánica de la supresión mental hipotética exonera precisamente a quien, desde cualquier intuición razonable, debería responder.

Las teorías correctivas, causa adecuada, relevancia jurídica, imputación objetiva, nacen exactamente para resolver ese problema de sobreextensión, y lo consiguen, pero pagando un precio distinto: todas ellas reintroducen, bajo una u otra forma, un elemento de previsibilidad o de valoración normativa que pertenece, en rigor, al juicio de culpabilidad ya examinado en el Eje 8. La crítica más certera a la teoría de la causa adecuada lo señala expresamente: preguntar si el daño era una consecuencia verosímil del hecho, según un observador objetivo, es formular una pregunta estructuralmente idéntica a la que se formula al determinar si el daño era previsible para un hombre prudente colocado en la situación del agente. Si la causalidad exige ya, en su propia determinación, un juicio sobre lo previsible, la distinción entre causalidad y culpabilidad, presentada al inicio de este material como dos requisitos autónomos y sucesivos de la responsabilidad, corre el riesgo de convertirse en una distinción según qué momento del análisis se privilegie, y no según una diferencia sustancial entre dos preguntas verdaderamente distintas.

Lo que está en juego, en consecuencia, es la arquitectura misma del juicio de responsabilidad. Si causalidad y culpabilidad se mantienen rigurosamente separadas, causalidad como hecho, culpabilidad como reproche normativo, la teoría de la equivalencia de las condiciones sería la única coherente con esa separación, y el problema de su sobreextensión debería resolverse en otra sede, no contaminando el juicio causal con consideraciones de previsibilidad que pertenecen a la culpa. Si, en cambio, se acepta que la causalidad jurídicamente relevante no puede prescindir de un componente normativo, la imputación objetiva, el ámbito de protección de la norma, la razonable proximidad exigida por el concepto de daño directo, entonces debe reconocerse abiertamente que el juicio de responsabilidad no se divide limpiamente en etapas sucesivas y autónomas, sino que la previsibilidad reaparece, como ya se observó al examinar el daño en el Eje 10, en más de un punto del análisis, cumpliendo funciones distintas según el requisito en que se la invoque: primero para calificar la culpa del agente, después para decidir qué consecuencias de esa culpa cuentan como daño directo, y ahora, en sede de

causalidad, para decidir si el hecho del demandado puede siquiera considerarse la causa jurídicamente relevante del resultado. La doctrina nacional, al adoptar la síntesis de lo empírico y lo normativo que proponen **BARROS** y **CORRAL**, opta decididamente por esta segunda vía, asumiendo el costo conceptual de una previsibilidad que atraviesa transversalmente varios requisitos de la responsabilidad, a cambio de evitar los resultados absurdos a que conduce la aplicación rigurosa y aislada de la equivalencia de las condiciones.

6. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir situando el fundamento normativo implícito de la causalidad (**artículos 2314, 2318, 2319 y 2325** del Código Civil, y la aplicación analógica del **artículo 1558**) y su doble función, como requisito y como límite de la responsabilidad, ilustrando la complejidad del problema con algún caso de causación compleja.

En segundo lugar, exponer las teorías empiristas, equivalencia de las condiciones, con su test de supresión mental hipotética y sus tres críticas (petición de principio, causalidad acumulativa, extensión desmesurada), y la causa adecuada, con su corrección mediante el criterio del observador objetivo y sus propias dificultades (confusión con la culpabilidad, distorsión del observador ex post). Luego, las teorías normativas, relevancia jurídica e imputación objetiva de **LARENZ** y **ROXIN**, con el criterio del riesgo general de la vida, cerrando con la síntesis nacional de lo empírico y lo normativo propuesta por **BARROS** y **CORRAL**, ilustrada con los cuatro ejemplos de este primero (influenza contagiada en el hospital, bocinazo y ataque cardíaco, choque de la ambulancia, camino en mal estado) y la doctrina del ámbito de protección de la norma.

En tercer lugar, desarrollar la pluralidad de causas: el caso fortuito como hecho externo que excluye la causalidad, cerrando aquí el hilo de la exterioridad anunciado al examinar el caso fortuito en el Eje 6, y su vínculo con la culpa de la víctima como hecho igualmente exterior; la pluralidad de agentes, distinguiendo el mismo hecho (solidaridad del **artículo 2317**), los hechos distintos (división proporcional) y la causa difusa (aplicación analógica de los **artículos 2323 y 2328**); y la concurrencia de culpa de la víctima del **artículo 2330**, con la discusión sobre su extensión a las víctimas por repercusión y sobre la exigencia de capacidad delictual de la víctima imprudente.

Cerrar con la prueba y calificación de la causalidad (carga del demandante, presunciones judiciales, aplicación analógica de la presunción del **artículo 2329**, y la distinción entre causalidad como cuestión de hecho y calificación normativa del daño directo como cuestión de derecho casable) y con la tensión de fondo: la disputa entre una causalidad puramente empírica, que evita confundir causalidad y culpabilidad pero produce resultados absurdos, y una causalidad normativamente corregida, que evita esos resultados al precio de reconocer que la previsibilidad, lejos de agotarse en el juicio de culpa, atraviesa transversalmente varios requisitos distintos de la responsabilidad civil.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 13. La causalidad**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

N. RÉGIMEN GENERAL Y CASOS PARTICULARES DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO (ART. 2320)

La regla general en el derecho chileno, aplicable tanto al ámbito contractual como al extracontractual, es que una persona no solo responde por los daños que ocasiona ella misma, sino también por los perjuicios ocasionados por quienes de ella dependen. En materia extracontractual, este principio está consagrado en el **artículo 2320** inciso primero del Código Civil: "toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". La norma opera como principio general en un doble sentido: se aplica genéricamente a toda relación de dependencia o cuidado, de manera que las hipótesis específicas que enumeran los incisos siguientes son meramente ejemplares y no taxativas; y, establecida la relación de dependencia respecto de quien ejecuta un hecho generador de responsabilidad, presume la culpabilidad de quien debía ejercer ese cuidado, quien solo puede exonerarse probando que, con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere, no habría podido impedir el hecho.

La pregunta que organiza este eje es, en consecuencia, cuál es la estructura de esta responsabilidad, qué se presume, qué debe probarse y por quién, y qué requisitos deben concurrir para que opere en sus distintas hipótesis particulares. El desarrollo específico de la responsabilidad del empresario, que ha experimentado en las últimas décadas una transformación conceptual de primera importancia, se reserva para un tratamiento separado en el Eje 15.

1. NOCIONES GENERALES

En diversos sistemas comparados, el common law y el derecho francés, entre otros, la responsabilidad por el hecho ajeno se construye como una forma de responsabilidad estricta, habitualmente denominada vicaria: establecida la relación de dependencia y el hecho ilícito del dependiente, quien lo tiene bajo su dirección responde sin que se examine su propia culpa. El derecho chileno sigue, en cambio, una construcción distinta, basada en un doble ilícito civil: el del dependiente, que causa el daño directamente, y el de quien lo tiene bajo su dirección o cuidado, el guardián, cuya culpa la ley presume. Esa culpa del guardián consiste en no haber empleado el cuidado necesario para evitar que el dependiente ocasionara el daño, ya sea al elegirlo, instruirlo o vigilarlo.

El fundamento de esta construcción radica en que quien tiene autoridad sobre otra persona está en posición de impedir el hecho dañoso mediante el ejercicio de esa autoridad, de manera que la omisión de ese cuidado, culpa in vigilando o culpa in eligendo, según se trate del deber de vigilancia o del deber de correcta selección, justifica hacerlo responder por una culpa que, aunque desplazada desde el agente material del daño, sigue siendo, en definitiva, una culpa propia del guardián y no ajena.

2. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

La doctrina identifica tres requisitos para que proceda esta responsabilidad: la capacidad delictual tanto del dependiente como del guardián, la comisión de un hecho ilícito por parte del primero, y la existencia de un vínculo de subordinación o dependencia entre ambos.

2.1. Capacidad delictual del hechor y del responsable

El **artículo 2319**, que fija el requisito general de capacidad examinado en el Eje 5, no distingue entre responsabilidad por el hecho propio y por el hecho ajeno, y se aplica, en consecuencia, a ambos. Esto significa que tanto quien comete el hecho ilícito como quien lo tiene a su cuidado deben ser plenamente capaces para que opere el régimen del **artículo 2320**.

Conviene detenerse en esta exigencia, porque permite trazar con precisión la línea que separa esta institución de la examinada a propósito del guardián del incapaz en el Eje 5, con la que guarda un evidente parecido estructural pero de la que difiere en su fundamento. Si quien comete el hecho ilícito es incapaz, no se aplica el régimen del **artículo 2320**, sino directamente el **artículo 2319**: responden únicamente quienes tienen a su cuidado al incapaz, y solo si puede imputárseles negligencia, que debe probarse por quien la alega. La diferencia central entre ambos regímenes es, entonces, esta: en la hipótesis del **artículo 2319**, hay un solo responsable, el guardián del incapaz, cuya responsabilidad es directa, por su propio hecho negligente, y respecto de la cual la culpa debe acreditarse, no se presume; en la hipótesis del **artículo 2320**, hay en cambio dos responsables potenciales, el hechor y el guardián, ambos plenamente capaces, y la culpa de este último se presume por el solo hecho de establecerse la relación de dependencia. La distinción no es meramente teórica: como se examinará más adelante, el **artículo 2325** concede al tercero civilmente responsable que ha debido pagar la indemnización una acción de reembolso contra el autor material del daño, acción que presupone precisamente la capacidad de este último; cuando el autor material es incapaz, la hipótesis del **artículo 2319**, esa acción de regreso sencillamente no existe, porque no puede exigirse a quien no tiene capacidad delictual que restituya lo pagado por su guardián.

La incapacidad puede presentarse, además, en el extremo opuesto: si la persona a quien pretende hacerse responsable por el hecho ajeno es ella misma incapaz, el propio **artículo 2319** lo impide, porque esa norma excluye de toda obligación de indemnizar, tanto por el hecho propio como por el ajeno o el de las cosas, a quien carece de capacidad delictual. Así, el padre demente no responde de los hechos de sus hijos menores que vivan con él, porque mal puede ejercer un cuidado eficaz sobre otra persona quien no puede ni siquiera atender a su propia persona.

2.2. Comisión de un hecho ilícito por la persona de cuyos actos se responde

La responsabilidad por el hecho ajeno supone la comisión, por parte del dependiente, de un delito o cuasidelito civil que reúna todos los requisitos generales de la responsabilidad extracontractual ya examinados en los ejes anteriores. La víctima debe probar ese hecho ilícito, acción u omisión culpable o dolosa, daño y relación de causalidad, conforme a las reglas generales, salvo que exista a su respecto alguna otra presunción legal aplicable. La única particularidad de este régimen es que, una vez establecido el hecho ilícito del dependiente, la víctima queda liberada de acreditar además la culpa del tercero civilmente responsable, porque esa culpa se presume. De ahí que se haya resuelto que no existe responsabilidad del tercero si el hechor ha sido absuelto por falta de culpa: la responsabilidad por el hecho ajeno no puede subsistir sin un ilícito civil del dependiente que le sirva de sustento.

2.3. Vínculo de subordinación o dependencia

Debe existir, entre el responsable y el hechor, un vínculo de subordinación y dependencia, porque si el fundamento de esta responsabilidad es la falta de vigilancia, resulta indispensable que quien deba responder tenga autoridad sobre la persona por la cual responde. En los casos expresamente enumerados por la ley este vínculo se presume, así, el padre que quiera eximirse deberá probar que no tenía al hijo bajo su cuidado; en los demás casos, corresponde probarlo a quien invoca la responsabilidad por el hecho ajeno. Aplicando esta exigencia, se ha resuelto que el ejecutante no responde de los hechos del depositario definitivo, ni quien encarga una obra responde de los hechos del contratista que la ejecuta por su propia cuenta, ni el mandante responde de los hechos ilícitos del mandatario, porque los mandatos se otorgan para ejecutar actos lícitos, y el mandatario no se encuentra, en rigor, bajo el cuidado de quien le confirió el poder. El vínculo de dependencia no exige, con todo, una formalización jurídica, especialmente tratándose de dependientes de un empresario: basta una situación fáctica caracterizada por la autorización, expresa o tácita, del principal para que otro gestione en su interés un negocio determinado siguiendo sus instrucciones u orientaciones.

3. CASOS PARTICULARES REGLAMENTADOS POR EL CÓDIGO

Sin perjuicio de la regla general del **artículo 2320** inciso primero, el propio Código reglamenta hipótesis específicas de responsabilidad por el hecho ajeno, cuyo tratamiento común exige acreditar los requisitos generales ya examinados, con las particularidades propias de cada vínculo.

La responsabilidad del padre, y a falta de este de la madre, por los hechos de los hijos menores que habiten en la misma casa exige que se trate de hijos menores de dieciocho años (de manera que no responden los padres por los hechos de un hijo mayor, ni siquiera en el caso especial del hijo de familia que administra su propio patrimonio profesional o industrial, porque a este respecto la ley lo mira como mayor de edad); que el hijo habite efectivamente con sus padres, porque solo así estos pueden ejercer la vigilancia necesaria, sin perjuicio de la excepción examinada a continuación; y que el padre o la madre, con la autoridad y cuidado que su calidad les confiere, no haya podido impedir el hecho. Los dos primeros requisitos debe probarlos el demandante; el tercero se presume, correspondiendo al padre o a la madre acreditar la imposibilidad de haberlo impedido. Esa prueba, sin embargo, no se admite en la hipótesis especial del **artículo 2321**, que declara a los padres siempre responsables de los delitos o cuasidelitos de sus hijos menores que conocidamente provengan de su mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir: al emplear la expresión "siempre", la norma consagra en este caso una verdadera presunción de derecho, de manera que, acreditado el hecho ilícito y que este proviene notoriamente de esas causas, ninguna prueba en contrario, ni siquiera la de que el hijo no vivía con el padre, o que fue imposible impedir el hecho, exonera a los padres mientras el hijo sea menor de edad.

La responsabilidad del tutor o curador por la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado corresponde al tutor por los hechos del impúber mayor de siete años que hubiere obrado con discernimiento, y a los curadores generales del menor adulto que hubiere obrado con discernimiento si tenía menos de dieciséis años, del disipador y del sordomudo que no puede darse a entender por escrito; no así del demente, atendida su incapacidad extracontractual general. El guarda-

dor de un incapaz, en cambio, solo responde si se le prueba negligencia, conforme al **artículo 2319** y a la distinción ya explicada en la sección anterior. A diferencia de la responsabilidad de los padres, la ley no exige que el pupilo viva en la misma casa del guardador, bastando que se encuentre bajo su dependencia y cuidado, por lo que esta responsabilidad no alcanza a los curadores adjuntos, de bienes o especiales, que carecen de esa función de cuidado personal; y el guardador se exonera probando, conforme a la regla general, que con la autoridad y vigilancia que su cargo le confiere no pudo impedir el hecho.

La responsabilidad de los jefes de colegios y escuelas por sus discípulos afecta a quien ejerce ese cargo o uno equivalente, director, rector, por los hechos ilícitos de sus discípulos, sean mayores o menores de edad, puesto que la norma no distingue en este punto, y subsiste solo mientras los discípulos permanezcan bajo su cuidado, esto es, en el establecimiento o bajo su control; se exonera, igualmente, probando que con su autoridad y cuidado no habría podido impedir el hecho.

La responsabilidad del artesano por sus aprendices se funda, según se ha observado, más en la relación casi patriarcal que tradicionalmente ha existido entre uno y otro que en un vínculo estrictamente laboral; subsiste mientras el aprendiz se encuentre bajo la vigilancia del artesano, con independencia de que sea mayor o menor de edad y de que exista o no un contrato de trabajo entre ambos, y se exonera del mismo modo que los casos anteriores.

4. EXONERACIÓN DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

La regla general de exoneración está contenida en el inciso final del **artículo 2320**: cesa la obligación del tercero responsable si, con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere y prescribe, no hubiere podido impedir el hecho. La víctima no necesita, en consecuencia, probar la culpa del tercero civilmente responsable, porque esta se presume; es el tercero quien debe acreditar la imposibilidad de haber impedido el hecho para liberarse. La jurisprudencia ha sido, en este punto, particularmente estricta: exige una imposibilidad total de evitar el hecho para admitir la exoneración, calificando además esta determinación como una cuestión de hecho, privativa de los jueces del fondo.

En ciertos casos la ley niega derechamente toda posibilidad de prueba en contrario, transformando la presunción simplemente legal en una presunción de derecho: así ocurre, según ya se explicó, con los padres cuyos hijos menores cometen ilícitos que provienen notoriamente de su mala educación o de hábitos viciosos que les permitieron adquirir. A ello se agrega, con fundamento en el **artículo 2325**, que tampoco cabe exoneración cuando el subordinado obró por orden del propio tercero civilmente responsable, caso en el cual este pasa a ser coautor del ilícito y responde solidariamente junto con el hechor material, conforme a las reglas generales sobre pluralidad de agentes examinadas en el Eje 13.

5. ACCIÓN DE REGRESO CONTRA EL SUBORDINADO

El **artículo 2325** concede a quien ha debido indemnizar por el hecho ajeno una acción para ser reembolsado sobre los bienes de quien perpetró el daño, siempre que concurran cuatro circunstancias. Primero, que el acto ilícito haya sido cometido por una persona capaz, porque el guardián de

un incapaz que debe pagar la indemnización por la negligencia propia que le es imputable no tiene acción de regreso alguna contra este, en la medida en que el incapaz no es responsable frente a nadie, ni siquiera frente a su propio guardián. Segundo, que el responsable haya efectivamente pagado la indemnización, porque de lo contrario carecería de fundamento la acción, cuyo objeto es precisamente evitar el enriquecimiento sin causa del hechor a costa de quien pagó en su lugar. Tercero, que el hecho se haya ejecutado sin orden de la persona a quien el hechor debía obediencia, porque si actuó por orden de su superior, a este se le niega la posibilidad de repetir en su contra, coherente con la regla ya examinada, según la cual quien ordena el hecho pasa a ser coautor solidario y no puede, por tanto, trasladar íntegramente las consecuencias a quien simplemente obedeció. Cuarto, que el hechor tenga bienes sobre los cuales hacer efectivo el reembolso, requisito que no condiciona la procedencia de la acción sino, más bien, su eficacia práctica.

6. LA RESPONSABILIDAD DEL HECHOR NO SE EXCLUYE

La responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del propio hechor. La ley no lo dice expresamente, pero se sigue de las reglas generales: el hechor ha cometido un acto ilícito y es plenamente capaz, quedando comprendido sin necesidad de norma especial en las disposiciones generales de los **artículos 2314 y 2329**. La responsabilidad del guardián solo extingue la del hechor en la medida en que aquel pague efectivamente la indemnización; si la víctima no la ha percibido del tercero civilmente responsable, puede dirigirse contra el hechor, aunque en la práctica lo habitual sea lo contrario, precisamente porque uno de los fundamentos de este régimen es la probable insolvencia del autor material del daño frente a la solvencia de quien lo tenía bajo su cuidado.

DATO DE GRADO

La presunción del artículo 2320 y su cercanía con la responsabilidad estricta

Este eje permite retomar, en un contexto distinto, la misma observación ya anunciada al examinar la presunción de culpabilidad por el hecho propio en el Eje 9: la diferencia entre la culpa presumida y la responsabilidad estricta es, en la práctica, más conceptual que real, y la responsabilidad por el hecho ajeno lo confirma con particular nitidez.

En el plano de los principios, el derecho chileno se aparta deliberadamente de los sistemas que construyen la responsabilidad por el hecho ajeno como una responsabilidad vicaria en sentido estricto, sin necesidad de acreditar culpa alguna del guardián, bastando la sola relación de dependencia y el hecho ilícito del dependiente. La opción chilena, se ha visto, exige un doble ilícito civil: el del hechor y el del guardián, cuya culpa por falta de vigilancia o de selección es la que, en definitiva, justifica su responsabilidad. Formalmente, entonces, el sistema chileno sigue siendo un sistema de responsabilidad por culpa, y no un sistema de responsabilidad objetiva por el mero hecho de la dependencia.

Sin embargo, el modo en que la jurisprudencia ha interpretado la cláusula de exoneración del inciso final del **artículo 2320** erosiona en la práctica esa distinción formal. Exigir una imposibilidad total de evitar el hecho para admitir la prueba liberatoria del tercero responsable equivale, en los hechos, a convertir en prácticamente irrefutable una presunción que, en el papel, admite prueba en contrario. Así, tratándose de la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos menores, se ha resuelto que no basta acreditar que no se autorizó al hijo a conducir el vehículo familiar ni que el hecho ocurrió en ausencia del padre, si no se prueba además que este ejerció "siempre y en todo momento" una vigilancia acuciosa y constante, según fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 25 de marzo de 1958; que el deber de cuidado se manifiesta no solo cuando el padre está presente, sino también, y en mayor medida, en su ausencia, porque deriva de una obligación anterior al hecho ilícito mismo, conforme a sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 2 de diciembre de 1988; y que no basta probar que los hijos recibieron una buena educación, sino que es necesario acreditar una verdadera y real imposibilidad de impedir el daño, según fallo de la Corte Suprema de 11 de julio de 1978. Solo en supuestos verdaderamente extremos, como el de una riña entre menores en que el hecho se desarrolló de un modo que ningún ejercicio de autoridad paterna habría podido prever ni impedir, la jurisprudencia ha acogido la excusa, según antiguo fallo de la Corte Suprema de 30 de noviembre de 1921, lo que confirma, por contraste, cuán excepcional resulta en la práctica la exoneración exitosa.

Si el guardián solo puede exonerarse demostrando que ninguna medida de autoridad o cuidado, por extrema que fuese, habría bastado para impedir el hecho de su dependiente, la diferencia entre esa presunción "simplemente legal" y una responsabilidad objetiva pura se reduce, en la mayoría de los casos concretos, a una cuestión de mera terminología. Y en las hipótesis en que la ley transforma abiertamente la presunción en una presunción de derecho, los padres cuyos hijos delinquen por su mala educación o sus hábitos viciosos, la aproximación a la responsabilidad estricta deja de ser una tendencia jurisprudencial para convertirse en una decisión legislativa explícita: allí no hay siquiera la apariencia de una prueba liberatoria disponible.

Esta observación permite, además, calibrar con precisión la distinción trazada en la sección 3.1 entre el régimen del **artículo 2319** y el del **artículo 2320**. Aunque ambos regímenes exigen un juicio de negligencia del guardián, el régimen del hecho ajeno, con su presunción de culpa y su exigencia jurisprudencial de imposibilidad total para exonerarse, se sitúa sistemáticamente más cerca del polo objetivo que el régimen del guardián del incapaz, donde la culpa debe probarse afirmativamente por quien la alega, sin presunción alguna que la respalde. La arquitectura del sistema chileno de responsabilidad por el hecho ajeno revela así una gradación, más que una dicotomía tajante entre responsabilidad por culpa y responsabilidad estricta: desde la culpa probada del **artículo 2319**, pasando por la culpa presumida, pero formalmente rebatible, del **artículo 2320** en su régimen general, hasta la presunción de derecho, irrefutable en los hechos, del **artículo 2321**.

7. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con la regla general del **artículo 2320** inciso primero y la construcción chilena de esta responsabilidad sobre la base de un doble ilícito civil, del hechor y del guardián, a diferencia de los sistemas de responsabilidad vicaria estricta del derecho comparado, fundándola en la culpa in vigilando o in eligendo del guardián.

En segundo lugar, exponer los tres requisitos: la capacidad delictual de ambos, hechor y guardián (cerrando aquí el hilo anunciado en el Eje 5 sobre la distinción entre el guardián del incapaz del **artículo 2319**, de responsabilidad directa y sin acción de reembolso, y el tercero civilmente responsable del **artículo 2320**, con dos responsables capaces y culpa presumida); la comisión de un hecho ilícito por el dependiente, con todos sus requisitos generales; y el vínculo de subordinación o dependencia, presumido en los casos legales y exigido de prueba en los demás, con los ejemplos de relaciones que no lo configuran, ejecutante y depositario, mandante y mandatario, quien encarga una obra y el contratista.

En tercer lugar, desarrollar los casos particulares reglamentados por el Código, padres, con la presunción de derecho del **artículo 2321**; tutores y curadores; jefes de colegios y escuelas; artesanos, y la exoneración del tercero responsable, con la exigencia jurisprudencial de imposibilidad total y los casos de improcedencia, **artículo 2321** y coautoría por orden del **artículo 2325**, junto con la acción de regreso contra el subordinado capaz que pagó sin orden del responsable, y la subsistencia de la responsabilidad del propio hechor.

Cerrar con la tensión de fondo: la presunción de culpa del **artículo 2320**, interpretada por la jurisprudencia con una exigencia de imposibilidad total para su exoneración, se aproxima en la práctica a una responsabilidad estricta pese a construirse formalmente sobre la culpa, revelando una gradación, y no una dicotomía tajante, entre la culpa probada del **artículo 2319**, la culpa presumida del **artículo 2320** y la presunción de derecho del **artículo 2321**.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 14. Régimen general y casos particulares de responsabilidad por el hecho ajeno (art. 2320)**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

O. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO

Al examinar la responsabilidad de las personas jurídicas se anticipó ya, en el Eje 6, una distinción que este eje debe ahora desarrollar en toda su extensión práctica: la persona jurídica puede responder por el hecho ajeno de sus dependientes, conforme al régimen general del **artículo 2320**, o puede responder por el hecho propio de sus órganos, en cuanto el acto del órgano se tiene por acto de la persona jurídica misma y no por el acto de un tercero del que ella debe cuidar. Se advirtió entonces que la diferencia no es meramente clasificatoria: tratándose de responsabilidad por el hecho ajeno, el empresario puede exonerarse probando que no pudo impedir el hecho; tratándose de responsabilidad por el hecho propio del órgano, esa excusa no procede, porque nadie se exonera alegando que no pudo impedir su propia conducta. Cuanto más se expande la noción de órgano, más hipótesis quedan comprendidas en el segundo régimen, sin excusa posible, y menos en el primero.

Este eje examina ambas vías con el detalle que merecen, comenzando por la responsabilidad del empresario por el hecho ajeno de sus dependientes, que ha experimentado una evolución conceptual de primera importancia, desde un criterio estrictamente jerárquico hasta uno funcional y organizacional, y examinando después la responsabilidad por el hecho propio de la organización empresarial, que es el terreno donde la llamada culpa en la organización, ya anunciada en el Eje 6, adquiere su desarrollo más concreto.

1. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO POR EL HECHO AJENO: EVOLUCIÓN DEL CRITERIO DE DEPENDENCIA

El fundamento legal de esta responsabilidad se encuentra en el **artículo 2320** inciso cuarto del Código Civil, que hace responsables a los empresarios por el hecho de sus dependientes mientras estén a su cuidado, y en el **artículo 2322**, que la jurisprudencia extendió tempranamente a esta materia pese a referirse literalmente a la relación entre amos y criados. Las expresiones "empresario" y "dependiente" no son términos técnicamente precisos en la legislación, pero los tribunales las han interpretado en un sentido cada vez más amplio, en uno de los campos donde la jurisprudencia ha mostrado mayor desarrollo en las últimas décadas: precisar quiénes se encuentran sometidos a la autoridad del empresario, cuestión de la que depende directamente cuántas personas responden por sus actos.

Una primera interpretación, dominante hasta hace pocas décadas, exigía que existiera entre el empresario y el dependiente un vínculo de subordinación jerárquica propiamente tal, que autorizara al primero a impartir instrucciones exigibles al segundo. Esta lectura respondía a la realidad económica vigente al dictarse el Código, agrícola, desintegrada y artesanal, en la que el empresario contaba efectivamente con la preparación necesaria para instruir a sus subordinados sobre el modo de realizar su trabajo. El desarrollo tecnológico y la transformación de las estructuras empresariales modernas, que exigen encargar a profesionales calificados actividades cada vez más complejas y especializadas, hicieron insostenible ese criterio: **ZELAYA** ha explicado que el criterio de la subordinación jerárquica viene siendo reemplazado, en buena parte de la actividad empresarial contemporánea, por el criterio del control empresarial o poder organizativo sobre la actividad de los dependientes o auxiliares. Ya no se exige una relación jurídica estable en cuya virtud el principal ejerza autoridad efectiva sobre los medios técnicos que emplea el dependiente, muchas veces

ni siquiera es conveniente que la ejerza, sino solamente la posibilidad o facultad potencial de intervenir de algún modo en el resultado final del encargo. Se tiene por empresario, en consecuencia, a quien controla una organización que se beneficia del trabajo de terceros que forman parte de ella, con prescindencia de que actúen por instrucción expresa o en virtud de un vínculo jurídico de subordinación propiamente dicho: se ha pasado, en síntesis, de una dependencia jerárquica a una dependencia funcional. El derecho comparado ofrece, para operacionalizar este criterio funcional, un catálogo de índices que los tribunales suelen ponderar conjuntamente: el grado de control del empresario sobre la actividad del agente; la relación entre el giro del empresario y la actividad de quien causó el daño; el nivel de especialización de este último; quién suministró los materiales e instrumentos de trabajo; la propiedad del lugar donde se causó el daño; la duración del encargo y su exclusividad; la existencia y el sistema de pago de la remuneración; si el trabajo forma parte del giro ordinario del empresario; la forma en que las partes se autodenominan; y si el tercero se obligó a un resultado o solo a prestar servicios.

Esta ampliación del concepto de dependencia tiene, con todo, un límite tradicionalmente reconocido: la subcontratación. Cuando el subcontratista ejecuta una obra por precio alzado, con la autonomía propia de esa forma de contratación, no existe entre él y quien encarga la obra la relación de dependencia que haría presuntivamente responsable a este último; así se ha resuelto respecto de quien encarga la construcción de un edificio a un contratista que asume por su cuenta las responsabilidades laborales correspondientes a su personal. Nada obsta, sin embargo, a que se tenga por establecida la responsabilidad si el subcontratista es, en los hechos, un mero encargado que actúa bajo las órdenes, instrucciones o coordinación del empresario principal, porque la apreciación de la dependencia debe hacerse siempre en concreto y no según la sola naturaleza formal del vínculo contractual invocado.

2. REQUISITOS DE LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD DEL EMPRESARIO

La presunción de culpabilidad del empresario es una especie del género de las presunciones de culpa por el hecho ajeno, pero plantea, dentro de cada uno de sus elementos, preguntas propias que conviene examinar separadamente.

El primer requisito es que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil, juzgado según las reglas generales: la víctima debe acreditar el hecho voluntario, la culpa o el dolo, el daño y la relación causal. Las exigencias probatorias del régimen de culpa enfrentan, sin embargo, a la víctima con la difícil tarea de individualizar, dentro de organizaciones productivas cada vez más complejas, al dependiente concreto que causó el daño. Por esta razón la doctrina y la jurisprudencia han aceptado la noción de culpa difusa o anónima, en virtud de la cual no es necesario identificar al autor concreto, bastando que la culpa se atribuya a la organización empresarial considerada en su conjunto: se ha resuelto reiteradamente que no es de rigor que la sentencia determine quién en particular causó el daño, bastando acreditar su existencia y que no se habría producido sin la negligencia de alguien dentro de la organización. Conviene notar, sin embargo, que esta figura plantea una pregunta conceptual de fondo: cuando la culpa se atribuye difusamente a la organización en su conjunto, sin individualizar a ningún dependiente concreto, cabe preguntarse si lo que en realidad se está construyendo no es ya una responsabilidad por el hecho ajeno, que por definición requiere individualizar el ilícito de un tercero, sino una responsabilidad directa de la empresa por

el hecho propio de su organización deficiente, pregunta que se retomará en la sección siguiente, porque es exactamente el mismo fenómeno que la teoría del órgano describe desde otro ángulo.

El segundo requisito es la relación de cuidado o dependencia ya examinada, que la jurisprudencia entiende como una cuestión de hecho que no exige vínculos formales y que se expresa en la capacidad de impartir órdenes o de vigilar la actividad ajena.

El tercer requisito es que el daño se ocasione en el ámbito de la dependencia o en ejercicio de las funciones encomendadas al dependiente. La jurisprudencia nacional ha entendido esta exigencia de conexión en términos amplios, estimando suficiente que el hecho se cometa con ocasión del desempeño de esas funciones y no exclusivamente en su ejercicio estricto: así se ha declarado responsable al empresario por los hurtos cometidos por sus obreros aprovechando la ocasión que les proporciona el desempeño de su trabajo, mientras que se ha excluido esa responsabilidad cuando el dependiente causa el daño en actividades enteramente inconexas de su relación de dependencia, como al trasladarse a su lugar de trabajo. La jurisprudencia comparada exige, en todo caso, que exista una relación de causalidad o conexidad entre el hecho dañoso y la función encomendada, criterio que la Corte de Casación francesa ha formulado con particular precisión al sostener que el empresario responde de la actividad de su dependiente ejercida más allá del fin que le fue fijado, o incluso cuando este utilizó con un fin ajeno a su función los medios que el empresario le proporcionó, siempre que exista esa conexidad mínima entre el hecho y la función.

3. DESCARGA DE LA PRESUNCIÓN Y SU CERCANÍA CON LA RESPONSABILIDAD Estricta

Cumplidos estos tres requisitos, se presume la culpabilidad del empresario, quien para exonerarse debe probar, conforme a la regla general ya examinada en el Eje 14, que con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere no pudo impedir el hecho. La jurisprudencia ha juzgado esta excusa con un rigor extremo, exigiendo que el empresario acredite haber ejecutado actos positivos y concretos dirigidos a impedir el hecho culpable del dependiente, orientados a evitar errores en todos los ámbitos relevantes de la actividad empresarial: la elección e instrucción del personal, la organización de la actividad y la vigilancia de los dependientes. Se ha resuelto, en este sentido, que no basta acreditar que se tomaron algunas medidas de prudencia si no se demuestra que ellas eran de tal naturaleza como para evitar efectivamente el hecho, según fallo de la Corte Suprema de 14 de noviembre de 1950; que no basta alegar que la naturaleza del trabajo, como conducir en la vía pública, hace imposible el control del dependiente, si no se demuestra que se tomó toda clase de precauciones especiales, conforme a sentencia de la misma Corte de 24 de marzo de 1958; que responde el empresario que designa y mantiene en funciones a un dependiente que por su estado de salud no puede desempeñarse con la eficiencia y competencia técnica necesarias, según fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 22 de julio de 1957; y que la falta de diligencia de un servicio de salud puede consistir, incluso, en el solo hecho de haber encomendado a un estudiante de quinto año de medicina la atención exclusiva de un proceso anestésico múltiple, conforme a sentencia de la Corte Suprema de 4 de octubre de 1984. En la práctica, la exigencia de acreditar una imposibilidad de esta magnitud resulta análoga a exigir la prueba de un caso fortuito, y explica que la jurisprudencia tienda a aceptar, en los hechos, el principio de la representación en la acción del dependiente formulado por la doctrina francesa, según el cual el dependiente actúa, para estos efectos,

como si fuera el propio empresario, de manera que este no puede separarse de las consecuencias de su actuar, principio que es característico de los regímenes de responsabilidad vicaria propiamente dicha y no de un régimen de culpa presumida en sentido estricto.

Conviene contrastar este resultado con el fundamento de política pública que, en el derecho comparado, ha llevado a la generalidad de los sistemas jurídicos, con la notable excepción del alemán, que mantiene una regla de culpa presumida análoga a la chilena, a construir derechamente la responsabilidad del empresario como una responsabilidad estricta o vicaria. Se invocan, en ese sentido, razones tanto de justicia como de eficiencia: parece justo que quien se beneficia de la actividad de sus dependientes asuma también los riesgos de sus errores; la responsabilidad estricta permite además superar el grave inconveniente que representa la insolvencia habitual del dependiente, que en la práctica transforma a la responsabilidad civil en una cuestión puramente teórica si se dirige únicamente contra él; y, desde la perspectiva de las políticas públicas, el empresario es quien está en mejor posición para controlar los riesgos de su actividad, de manera que hacerlo responder de manera estricta constituye un incentivo a la inversión en seguridad y a la contratación de seguros, además de facilitar la internalización del costo de los accidentes en el precio del producto, distribuyéndolo entre todos los consumidores.

4. COMPARACIÓN ENTRE EL ARTÍCULO 2320 INCISO CUARTO Y EL ARTÍCULO 2322

Aunque ambas normas han sido aplicadas conjuntamente por la jurisprudencia a la responsabilidad empresarial, presentan diferencias de alcance que conviene precisar. El **artículo 2322**, referido literalmente a la relación entre amos y criados, define de manera más estricta el ámbito de responsabilidad, exigiendo que el daño se cause en el ejercicio de las funciones del dependiente; el **artículo 2320** inciso cuarto, en cambio, se refiere en términos más generales a la relación de cuidado o dependencia, entendida como una forma de vigilancia personal que se extiende, según ya se explicó, también a los hechos cometidos con ocasión de esas funciones. Las excusas disponibles para exonerarse son igualmente distintas: el **artículo 2322** exige probar que el dependiente ejerció sus funciones de un modo impropio que el empresario no tenía medio de prever ni impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente, mientras que la excusa del **artículo 2320** está formulada en términos más generales, aludiendo sin más a la relación entre el deber de cuidado y la posibilidad de haber impedido el hecho. Esta distinción, en todo caso, no ha impedido que la jurisprudencia mayoritaria funde la responsabilidad del empresario indistintamente en ambos preceptos, sin extraer de sus diferencias textuales consecuencias prácticas decisivas.

5. LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Junto a esta responsabilidad por el hecho ajeno existe, como ya se anticipó en el Eje 6, una vía enteramente distinta para comprometer la responsabilidad de una persona jurídica: la responsabilidad directa por el hecho propio de sus órganos, en la que el acto del órgano no se imputa a la persona jurídica por vía de representación de un tercero, sino que se tiene derechamente por su propio acto. La consecuencia práctica de esta distinción, ya señalada, es decisiva: tratándose de responsabilidad

por el hecho ajeno, el empresario dispone de la excusa del **artículo 2320** inciso final, por rigurosa que sea su aplicación jurisprudencial; tratándose de responsabilidad por el hecho propio del órgano, esa excusa sencillamente no existe, porque nadie puede exonerarse alegando que no pudo impedir su propia conducta culpable.

La responsabilidad por el hecho propio de las personas jurídicas se sirve, además de la teoría del órgano ya examinada, de la misma noción de culpa difusa o anónima explicada a propósito de la presunción del hecho ajeno, pero llevada aquí a sus últimas consecuencias: cuando el daño se atribuye no ya a un dependiente individualizable, ni siquiera a un órgano en sentido técnico, sino a un defecto de la organización empresarial considerada en su conjunto, un sistema de control de calidad insuficiente, protocolos de seguridad mal diseñados, una estructura de decisiones que diluye las responsabilidades individuales, el ilícito se atribuye directamente a la persona jurídica misma, con fundamento implícito en los mismos criterios que permiten construir la presunción de culpabilidad por el hecho propio del **artículo 2329** examinada en el Eje 9, y no en las normas sobre el hecho ajeno de los **artículos 2320** o 2322. Esta vía, aunque más difícil de acreditar por exigir probar un defecto genuinamente organizacional y no la sola negligencia de un dependiente identificable, tiene la ventaja, para la víctima, de no dejar espacio alguno para la excusa de imposibilidad de impedir el hecho: la organización deficiente es, precisamente, el hecho propio que se le reprocha.

Una cuestión de creciente importancia práctica, en este mismo terreno, es si puede comprometerse la responsabilidad extracontractual de una sociedad controladora por los actos de la sociedad que controla. A diferencia de lo que ocurre en materia contractual, donde es posible perseguir a la matriz mediante garantías personales o, excepcionalmente, mediante el descorrimiento del velo de la personalidad jurídica en casos de abuso, en materia extracontractual la vía es más directa: basta con establecer, como cuestión de hecho, que la sociedad controlada carece de autonomía funcional y patrimonial propia, de manera que en verdad se encuentra bajo el cuidado o la dirección de la controladora. El solo control accionario no basta para ello, en la medida en que la sociedad controlada desarrolle su actividad con autonomía funcional y patrimonial real; pero si esta actúa como el mero instrumento con que la controladora despliega una actividad productiva riesgosa cuya dirección efectiva permanece radicada en esta última, puede sostenerse que la controladora debe responder por los daños de esa actividad, aplicando los mismos principios generales de la responsabilidad por el hecho ajeno, solo que el sujeto de cuidado es, en este caso, una persona jurídica y no una persona natural, sin necesidad de recurrir a ninguna doctrina especial sobre descorrimiento del velo societario.

DATO DE GRADO

Dos caminos hacia un mismo destino

El Eje 6 dejó planteada una tensión que este eje permite ahora resolver en términos concretos: la expansión de la noción de órgano desplaza hipótesis desde el régimen del hecho ajeno, donde existe una excusa, por estricta que sea su aplicación, hacia el régimen de la responsabilidad directa, donde no existe excusa alguna. Lo que este eje añade a esa observación es la constatación de que el propio régimen del hecho ajeno, examinado en detalle, se comporta como si esa excusa apenas existiera: la exigencia jurisprudencial de acreditar actos positivos y concretos en todos los frentes de la gestión empresarial, análoga a la prueba de un caso fortuito, deja al empresario en una posición de exoneración casi tan estrecha como la de quien carece derechamente de toda excusa.

Se advierte, entonces, que ambas vías, el hecho ajeno interpretado con un rigor que lo aproxima a la responsabilidad estricta, y el hecho propio del órgano o de la organización, que directamente la excluye por regla, convergen hacia el mismo resultado práctico: una responsabilidad empresarial que, cualquiera sea la etiqueta dogmática bajo la que se construya en cada caso concreto, deja escaso margen real a la exoneración del empresario. Esta convergencia no es casual, sino que revela un mismo juicio de fondo, coherente con las razones de justicia y de eficiencia que en el derecho comparado han llevado a construir derechamente esta responsabilidad como estricta: quien organiza una actividad productiva y se beneficia de ella debe asumir también, en la práctica totalidad de los casos, el riesgo de los daños que esa actividad genera a terceros, con independencia de si el vehículo dogmático empleado para llegar a esa conclusión es la presunción de culpa del hecho ajeno, la culpa difusa atribuida a la organización, o la teoría del órgano en su versión más expansiva. La disputa conceptual sobre cuál de estas tres vías es la correcta en cada caso, disputa que ocupa buena parte de la doctrina nacional y comparada, importa, en consecuencia, menos de lo que su intensidad teórica sugiere, porque las tres convergen en la misma conclusión práctica: la responsabilidad del empresario chileno es, en los hechos, mucho más cercana a la responsabilidad estricta que a la responsabilidad por culpa que formalmente la sustenta.

6. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir recordando la distinción anticipada en el Eje 6 entre responsabilidad por el hecho ajeno del dependiente y responsabilidad por el hecho propio del órgano, y anunciar que este eje examina en detalle ambas vías aplicadas específicamente a la actividad empresarial.

En segundo lugar, exponer la evolución del criterio de dependencia, de la subordinación jerárquica a la dependencia funcional, con la teoría de **ZELAYA** sobre el control empresarial y los índices comparados para determinarla, los tres requisitos de la presunción (hecho ilícito del dependiente, con la figura de la culpa difusa; relación de cuidado; y daño ocasionado en el ejercicio o con ocasión de las funciones, con el criterio de conexidad de la jurisprudencia comparada) y la exigencia jurisprudencial extrema para la descarga de la presunción, que la aproxima al principio de repre-

sentación en la acción propio de la responsabilidad vicaria. Debe mencionarse también la comparación entre los **artículos 2320** inciso cuarto y 2322, con sus diferencias de alcance y de excusa.

En tercer lugar, desarrollar la responsabilidad por el hecho propio de la organización, culpa difusa llevada a sus últimas consecuencias, defectos organizacionales atribuidos directamente a la persona jurídica sin excusa posible, y el problema de la responsabilidad de las sociedades controladoras por las controladas, resuelto mediante el criterio de la autonomía funcional y patrimonial de la sociedad controlada, sin necesidad de recurrir al descorrimiento del velo societario.

Cerrar con la tensión de fondo: la convergencia práctica entre un régimen de hecho ajeno interpretado con un rigor que lo acerca a la responsabilidad estricta y un régimen de hecho propio del órgano que directamente la excluye, ambos conduciendo al mismo resultado, una responsabilidad empresarial que, cualquiera sea su fundamento dogmático, deja escaso margen real de exoneración, en línea con las razones de justicia y eficiencia que en el derecho comparado justifican tratar derechamente esta responsabilidad como estricta.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 15. Responsabilidad del empresario**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

P. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS: ANIMALES, RUINA DE EDIFICIO, COSAS QUE CAEN O SE ARROJAN

A diferencia de la responsabilidad por el hecho propio y por el hecho ajeno, que cuentan con presunciones generales de culpabilidad, los **artículos 2329 y 2320** del Código Civil, examinados en los Ejes 9 y 14, la responsabilidad por el hecho de las cosas no dispone en el derecho chileno de una presunción genérica equivalente. El Código Civil se aparta, en este punto, del modelo francés, cuyo **artículo 1384** establece como regla general que se responde por el hecho de las cosas que se tienen bajo custodia. En Chile, la ley contempla únicamente presunciones específicas, referidas a tres hipótesis puntuales: los daños causados por animales, los causados por la ruina de un edificio, y los causados por una cosa que cae o se arroja desde la parte superior de un edificio. Fuera de estos casos particulares, solo cabe acudir a la presunción general de culpabilidad por el hecho propio del **artículo 2329**, siempre que el daño causado por una cosa sea de aquellos que, razonablemente y según la experiencia, puedan atribuirse a negligencia, conforme a los criterios ya examinados en el Eje 9.

Conviene tener presente, antes de examinar cada hipótesis, que tras toda presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas subyace, en verdad, una presunción de culpabilidad del hecho de su dueño o custodio, que puede en principio exculparse probando su propia diligencia, salvo en aquellos casos puntuales en que la ley construye derechamente una responsabilidad estricta, prescindiendo por completo de esa posibilidad.

1. DAÑOS CAUSADOS POR UN ANIMAL

1.1. Regulación del Código Civil

El **artículo 2326** presume la culpabilidad del dueño por los daños causados por un animal, aun después de que este se haya soltado o extraviado. El dueño puede exculparse probando que el daño, la soltura o el extravío no se deben a su culpa ni a la del dependiente encargado de su guarda. Esta misma presunción se aplica a quien se sirve de un animal ajeno, quien responde en los mismos términos que el dueño frente a la víctima, ambos solidariamente, sin perjuicio de su acción de reembolso contra este último si el daño se debió a un vicio del animal que el dueño conocía y no le informó.

Tratándose de animales fieros, de los que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, el **artículo 2327** establece una regla distinta y más severa: una responsabilidad estricta de quien tenga el animal, fundada en la tenencia física y no en el dominio, respecto de la cual la víctima solo debe probar la naturaleza fiera e inútil del animal y su tenencia por el demandado, resultando inadmisibles cualquier excusa de diligencia.

1.2. La Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía

La Ley N° 21.020, de 2 de agosto de 2017, conocida popularmente como "Ley Cholito", emplea la expresión "responsabilidad" en dos sentidos distintos: uno amplio, que comprende todos los deberes que asume quien acepta o mantiene una mascota, registrarla, proporcionarle alimento y cuidados veterinarios, adoptar las medidas necesarias para evitar que cause daños, y uno específico, que es propiamente la responsabilidad civil extracontractual por el daño que el animal causa a una persona determinada.

La norma central en esta materia, el **artículo 13** de la ley, dispone que "todo responsable de un animal... responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal". Son legitimados pasivos, en primer término, el dueño o poseedor del animal; subsidiariamente, quien lo tenga a su cuidado al momento del daño sin ser su dueño ni poseedor, quien responde en calidad de fiador y goza, en consecuencia, del beneficio de excusión propio de ese contrato; y, de manera principal y no subsidiaria, el organizador de espectáculos o exhibiciones de animales.

La expresión "siempre" ha suscitado una duda interpretativa relevante: ¿estableció esta ley una responsabilidad estricta u objetiva para toda mascota, desplazando la presunción simplemente legal del **artículo 2326** del Código Civil? La duda parece reforzarse por el hecho de que la propia ley contempla, en su **artículo 13** inciso segundo, una causal específica de exoneración, cuando el animal causa lesiones graves o la muerte a quien se encontraba cometiendo ciertos delitos contra la propiedad o la persona, lo que sugiere que, fuera de esa hipótesis puntual, no cabrían otras excusas.

Con todo, un examen más detenido de la historia de la ley y de su texto conduce a una conclusión distinta. La moción parlamentaria original establecía expresamente una responsabilidad "de manera objetiva"; durante su tramitación en el Senado se prefirió, en cambio, remitirse derechamente a los **artículos 2326 y 2327** del Código Civil; y solo en el segundo trámite constitucional, sin que conste en la historia fidedigna de la ley una explicación de ese cambio, se sustituyó ese texto por la fórmula "responderá siempre" que finalmente se aprobó. A falta de una intención legislativa clara, no parece razonable concluir que esa sola expresión haya bastado para introducir un régimen de responsabilidad objetiva. A ello se suma un argumento sistemático decisivo: si el **artículo 13** estableciera ya una responsabilidad estricta general, carecería de sentido el **artículo 6** de la misma ley, que dispone que la mascota calificada como "potencialmente peligrosa" se considerará "un animal fiero para todos los efectos legales", remisión cuyo único sentido práctico es hacerle aplicable la responsabilidad estricta que el **artículo 2327** del Código Civil reserva, precisamente, para los animales fieros; esa remisión sería enteramente superflua si todas las mascotas, peligrosas o no, ya respondieran siempre y sin excusa posible. A esto se agrega que el propio **artículo 2** N° 7 de la ley, al definir la tenencia responsable, la hace consistir en la obligación de "adoptar todas las medidas necesarias para evitar" el daño, formulación que presupone precisamente un juicio sobre el cuidado debido, esto es, sobre la culpa.

La conclusión que se impone, en consecuencia, es que la Ley N° 21.020, lejos de reforzar el régimen del Código Civil, más bien lo atenúa: solo las mascotas calificadas de animales potencialmente peligrosos quedan sujetas a la responsabilidad estricta del animal fiero, siempre que además se acredite que no reportan utilidad para la guarda o servicio de un predio; respecto de las demás mascotas o animales de compañía, deberá probarse que su dueño o poseedor no adoptó las medi-

das necesarias para evitar el daño, por aplicación de la ley especial con preferencia sobre la presunción del **artículo 2326** del Código Civil. Si el animal causante del daño no puede calificarse siquiera de mascota o animal de compañía en los términos de la ley, sigue rigiendo sin más la presunción de culpa presumida del **artículo 2326**.

2. DAÑOS CAUSADOS POR LA RUINA DE UN EDIFICIO

Las expresiones "edificio" y "ruina" se emplean, en esta materia, en un sentido amplio: la primera comprende toda construcción adherida al suelo de manera permanente, y la segunda no exige la destrucción íntegra de la obra, bastando que una parte cualquiera de ella, adherida al conjunto, sufra un deterioro que cause daño a terceros.

2.1. Acciones preventivas

El Código Civil concede, en esta materia, dos acciones de carácter preventivo: la querella de obra ruinosa, regulada en los **artículos 932 a 935** como acción posesoria especial, y la acción general de prevención por daño contingente de los **artículos 2333 y 2334**, cuyo examen se reserva para el Eje 19.

2.2. Acciones indemnizatorias

El **artículo 934** dispone que si, notificada la querella de obra ruinosa, el edificio cae por efecto de su mal estado, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos; pero si cae por caso fortuito, una avenida, un rayo, un terremoto, no habrá lugar a indemnización, a menos que se pruebe que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo habría derribado; y en todo caso, sin notificación previa de la querella, no procede indemnización alguna conforme a esta norma específica.

Quienes no hayan ejercido esa acción disponen, en cambio, de la acción indemnizatoria general de los **artículos 2323 y 2324**. El **artículo 2323** hace responsable al dueño del edificio cuando la ruina proviene de haber omitido las reparaciones necesarias o de haber faltado, de cualquier otro modo, al cuidado de un buen padre de familia. Aunque el tenor literal de la norma exige, en apariencia, que se acredite la culpa del dueño, la doctrina y la jurisprudencia la han interpretado como una verdadera presunción de culpabilidad, correspondiendo al dueño probar su propia diligencia o la concurrencia de un caso fortuito para exonerarse. Si el edificio pertenece proindiviso a dos o más personas, la indemnización se divide entre ellas a prorrata de sus cuotas de dominio, constituyendo esta regla una excepción puntual al principio general de solidaridad del **artículo 2317**.

Cuando el daño proviene específicamente de un vicio de construcción, el **artículo 2324** remite a la regla tercera del **artículo 2003**, propia de la responsabilidad contractual del constructor frente al dueño de la obra, extendiéndola también a los terceros afectados por la ruina. Esta responsabilidad especial del constructor exige que la ruina, total o parcial, ocurra dentro de los cinco años siguientes a la entrega de la obra, y que se deba a vicios de la construcción, a vicios del suelo que el constructor debió conocer en razón de su oficio, a vicios de los materiales que él mismo suministró, o a vicios de los materiales suministrados por el dueño cuando el constructor, debiendo conocerlos por su oficio, no dio aviso oportuno de ellos.

3. DAÑOS CAUSADOS POR UNA COSA QUE CAE O SE ARROJA

También en esta materia el Código Civil concede una acción preventiva y otra indemnizatoria. La primera es una acción pública para que se remuevan, de la parte superior de un edificio u otro paraje elevado, los objetos que amenacen caída y daño; se dirige indistintamente contra el dueño, el arrendatario, o la persona a quien pertenezca la cosa o se sirva de ella, en términos análogos a la querrela de denuncia de obra ruinosa.

La acción indemnizatoria está contenida en el **artículo 2328** inciso primero, que presume la culpabilidad de todas las personas que habitan la parte del edificio desde la cual cayó o fue arrojado el objeto dañoso. Si son varios los candidatos a responsables, porque no puede individualizarse el lugar preciso desde el cual cayó el objeto, la indemnización se divide entre todos ellos, en una nueva excepción al principio de solidaridad del **artículo 2317**. La única excusa que la norma admite consiste en probar que la caída se debió a la culpa o mala intención de una persona exclusivamente determinada, caso en el cual solo esta responde.

DATO DE GRADO**La verdadera naturaleza de la responsabilidad del artículo 2328**

Conviene examinar con detenimiento en qué consiste exactamente la excusa que el **artículo 2328** admite, porque de esa precisión depende una discusión doctrinal de fondo sobre la naturaleza misma de esta responsabilidad. La norma no permite exonerarse probando diligencia en el cuidado del objeto que cayó: la única vía de exculpación consiste en probar que la caída se debió, con exclusividad, a la culpa o mala intención de una persona identificada, lo que en la práctica equivale a probar que uno mismo no intervino en el curso causal del accidente, señalando el lugar preciso desde el cual el objeto cayó. En otras palabras, quien habita la parte del edificio desde la que pudo haber caído el objeto no puede liberarse acreditando que actuó con el cuidado de un buen padre de familia respecto de ese objeto: solo puede liberarse demostrando que, en los hechos, no fue él quien lo dejó caer.

Esta observación ha llevado a una parte de la doctrina, encabezada por **BARROS**, a sostener que, pese a describirse tradicionalmente como una presunción de culpabilidad, la responsabilidad del **artículo 2328** es, en su estructura real, una responsabilidad estricta: no existe, en rigor, ninguna prueba de diligencia que sirva de excusa suficiente, porque la única defensa disponible opera en el plano de la causalidad, quién causó el daño, y no en el plano de la culpa, si el demandado actuó o no con el cuidado debido. Frente a esta lectura, **ALESSANDRI** y, en el mismo sentido, **CORRAL** sostienen que se trata simplemente de una presunción de culpa, aunque de difícil desvirtuación práctica, sin que ello altere su naturaleza dogmática.

Lo que está verdaderamente en juego en esta disputa, más allá de la etiqueta que se prefiera, es la misma cuestión que ha reaparecido a lo largo de este material a propósito de las presunciones del hecho propio y del hecho ajeno, examinadas en los Ejes 9 y 14: la distancia entre la culpa presumida y la responsabilidad estricta se reduce, en no pocos casos concretos, a una cuestión de terminología antes que de sustancia práctica. El **artículo 2328** constituye, en este sentido, el ejemplo más nítido de todo el sistema, porque en él la propia estructura de la norma, una excusa formulada enteramente en términos causales, y no en términos de diligencia, hace innecesario indagar, caso a caso, cuán exigente ha sido la jurisprudencia al juzgar la prueba liberatoria: la ley misma, en su redacción, no deja espacio para una defensa fundada en el cuidado empleado. Si en los **artículos 2320** y **2329** la aproximación a la responsabilidad estricta era el resultado de una interpretación jurisprudencial particularmente rigurosa de una excusa que, en el papel, sí admitía la prueba de la diligencia, en el **artículo 2328** esa aproximación está en el texto mismo de la norma, y no requiere de ningún desarrollo jurisprudencial adicional para producirse.

4. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir señalando la ausencia, en el derecho chileno, de una presunción genérica de culpabilidad por el hecho de las cosas, a diferencia del modelo francés, y la existencia en cambio de tres presunciones específicas, animales, ruina de edificio, cosas que caen o se arrojan, con la advertencia de que fuera de ellas rige la presunción general del **artículo 2329** examinada en el Eje 9.

En segundo lugar, exponer el régimen de los daños causados por animales: la presunción de culpa del dueño del **artículo 2326**, con su acción de reembolso contra el dueño por vicios conocidos y no informados; la responsabilidad estricta de los animales fieros del **artículo 2327**; y la Ley N° 21.020, explicando por qué, pese a la expresión "siempre" de su **artículo 13**, no introdujo una responsabilidad objetiva general, sino que atenuó el régimen del Código Civil, reservando la responsabilidad estricta solo para los animales calificados de potencialmente peligrosos.

En tercer lugar, desarrollar los daños causados por la ruina de un edificio (querrela de obra ruinosa y acción de daño contingente como acciones preventivas; **artículo 934** y **artículos 2323-2324** como acciones indemnizatorias, con la división proporcional entre copropietarios y la remisión al **artículo 2003** regla tercera para los vicios de construcción) y los daños causados por una cosa que cae o se arroja, con su acción preventiva y su presunción del **artículo 2328**, dividida entre los habitantes cuando no puede individualizarse el lugar de la caída.

Cerrar con la tensión sobre la naturaleza del **artículo 2328**: la disputa entre **BARROS**, que lo tiene por una responsabilidad estricta encubierta bajo el nombre de presunción, y **ALESSANDRI** y **CORRAL**, que insisten en calificarla de culpa presumida, mostrando que esta norma lleva al extremo, ya en su propio texto, la misma aproximación entre culpa presumida y responsabilidad estricta que atraviesa transversalmente el sistema chileno de presunciones de culpabilidad.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 16. Responsabilidad por el hecho de las cosas: animales, ruina de edificio, cosas que caen o se arrojan**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

Q. RÉGIMENES LEGALES DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA

A diferencia del modelo general de responsabilidad por culpa o negligencia, examinado en los ejes anteriores, la responsabilidad estricta u objetiva tiene como antecedente el riesgo generado por una determinada actividad, y no la negligencia con que esta se desarrolló, de modo que resulta indiferente el juicio de valor sobre la conducta de su autor. Basta que el daño se produzca dentro del ámbito de la actividad sujeta a este régimen especial y que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño, prescindiendo por completo del juicio de negligencia propio del régimen general.

Los ejes anteriores han mostrado, sin embargo, que la distancia entre la culpa presumida y la responsabilidad estricta se reduce, en la práctica, mucho más de lo que la dogmática formal sugiere: la exigencia jurisprudencial de una imposibilidad total para exonerarse de las presunciones de los **artículos 2320 y 2329**, examinadas en los Ejes 9 y 14, y la propia estructura del **artículo 2328**, examinada en el Eje 16, aproximan considerablemente esas presunciones a un régimen objetivo. Este eje examina, en cambio, los casos en que esa objetivación no es fruto de una interpretación jurisprudencial más o menos extensiva, sino de una decisión legislativa explícita: los regímenes especiales en que la ley misma declara que no se exige culpa alguna para que nazca la obligación de indemnizar. La pregunta que este eje debe responder no es solo cuáles son esos regímenes, sino, más de fondo, qué los justifica frente al régimen general de responsabilidad por culpa, que, según se explicará, tiene la ventaja de poder cubrir, en principio, cualquier ámbito de la actividad humana.

1. NOCIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA

En el plano dogmático, la construcción teórica de la responsabilidad objetiva se apoyó tempranamente en el concepto de riesgo, en dos versiones distintas: la del riesgo-provecho, según la cual quien realiza una actividad riesgosa de la que obtiene un beneficio económico debe responder de los perjuicios que ella cause; y la del riesgo-creado, según la cual quien dirige una actividad generadora de riesgos en su propio interés, sea o no de contenido pecuniario, debe responder de los daños que produzca. Por esta razón suele emplearse, como sinónimo de responsabilidad objetiva, la expresión responsabilidad por riesgo.

La doctrina objetiva ha recibido, con todo, críticas serias, que constituyen otras tantas defensas del régimen clásico de responsabilidad por culpa. Se ha señalado, en primer lugar, que resulta peligrosa: si el resultado dañoso habrá de repararse de todos modos, puede instalarse la idea de que, ante el derecho, da lo mismo actuar con diligencia o sin ella, fomentando así, paradójicamente, la multiplicación de accidentes que la responsabilidad civil debería prevenir. Se ha observado, en segundo lugar, que el subjetivismo informa transversalmente el derecho civil, incluso en instituciones de desarrollo reciente, el abuso del derecho, la causa ilícita, de manera que prescindir por completo de la conducta del demandado resultaría extraño a esa tradición. Y se ha advertido, finalmente, que no resulta equitativo que la víctima quede siempre indemne, sin mirar en ningún caso su propia conducta, porque ello equivale a no sancionar a quien, en los hechos, nada puso de su parte para evitar el accidente.

Precisamente porque no es un régimen sin costos, la responsabilidad estricta se construye en el derecho chileno como un régimen especial y, en consecuencia, de derecho estricto: opera únicamente respecto de los ámbitos de conducta o los tipos de riesgo que el legislador ha definido previamente, y su fuente exclusiva es la ley.

2. CATÁLOGO DE RÉGIMENES LEGALES DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA

La legislación chilena reconoce numerosos casos de responsabilidad sin culpa, la mayoría de los cuales puede justificarse por referencia a la teoría del riesgo-provecho o a la del riesgo-creado, además de las ya examinadas en el Eje 16 respecto de los animales fieros y de las cosas que caen o se arrojan desde lo alto de un edificio.

La Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, hace coexistir un principio de responsabilidad estricta del empleador con un sistema de seguro social obligatorio: define el accidente del trabajo como toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión de su trabajo, incluidos los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo, exceptuando únicamente la fuerza mayor extraña al trabajo y los accidentes provocados intencionalmente por la propia víctima. Estos accidentes están cubiertos por un seguro financiado principalmente por el empleador, y la negligencia inexcusable del trabajador no excluye su responsabilidad, dando lugar únicamente a una multa. Si el accidente se debe a culpa o dolo del empleador, la víctima conserva acción para reclamar una indemnización complementaria por todo perjuicio no cubierto por el seguro, incluido el daño moral, y el organismo administrador del seguro tiene a su vez acción de reembolso contra el empleador.

La Ley N° 18.290, de Tránsito, mantiene como regla general la responsabilidad por culpa del conductor, complementada por un listado de presunciones de responsabilidad que corresponden, en rigor, a hipótesis de culpa infraccional que solo admiten como excusa la fuerza mayor. A ello se agrega, sin embargo, un régimen de responsabilidad estricta del propietario del vehículo por los daños ocasionados por su conductor, quien responde solidariamente con este y solo puede exonerarse probando que el vehículo le fue tomado sin su conocimiento o autorización, circunstancia asimilable a un caso de fuerza mayor; y un sistema de seguro obligatorio que coexiste con el seguro de accidentes personales por circulación de vehículos motorizados y con el de accidentes de pasajeros de la locomoción colectiva.

El Código Aeronáutico establece, respecto del explotador de aeronaves, dos ámbitos de responsabilidad sin culpa: uno contractual, por los daños a pasajeros y carga, sujeto a límites cuantitativos expresados en unidades de fomento; y otro extracontractual, por los daños ocasionados a terceros en la superficie a consecuencia de una aeronave en vuelo o de su caída, que solo admite como excusa las causales de fuerza mayor que la misma ley define, y cuyo monto está igualmente sujeto a un límite determinado según el peso de la aeronave, por sobre el cual rigen las reglas comunes de responsabilidad por culpa.

El régimen especial sobre aplicación de plaguicidas sujeta a quien los aplica a responsabilidad estricta por todos los daños que se sigan de esa aplicación, incluidos los causados en forma accidental, es decir, sin culpa, alcanzando incluso al organismo público encargado de la erradicación de

plagas, con un plazo especial de prescripción, un año desde que se detectan los daños, y en todo caso no más de dos años desde la aplicación del plaguicida.

El régimen sobre derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar establece una responsabilidad estricta solidaria del dueño, armador u operador de la nave o artefacto naval causante del derrame, con una excusa de fuerza mayor limitada a causales tasadas por la propia ley, actos de guerra o insurrección, fenómenos naturales excepcionales e irresistibles, o el hecho doloso o culpable de un tercero extraño, un límite cuantitativo a la indemnización que desaparece si medió culpa del propietario, naviero u operador, y un sistema de seguro obligatorio para las naves de mayor tonelaje.

La Ley de Seguridad Nuclear declara expresamente que la responsabilidad civil por daños nucleares "será objetiva", alcanzando incluso a los daños producidos por caso fortuito o fuerza mayor, con la sola excepción de que el accidente se deba directamente a hostilidades de un conflicto armado exterior, insurrección o guerra civil; también aquí la ley fija un límite máximo de responsabilidad, reajutable en el tiempo, y exige que la indemnización por daños a las personas sea, cuando menos, el doble de la que correspondería aplicando las tablas del seguro de accidentes del trabajo.

Finalmente, el Código de Minería, como correlato de la amplia facultad que reconoce a toda persona para catar y cavar en busca de sustancias minerales, sujeta a quien ejerce esa facultad, y, en los mismos términos, al titular de una concesión de exploración, a responsabilidad estricta por los daños que cause en su ejercicio.

DATO DE GRADO**Por qué la responsabilidad estricta necesita una justificación distinta de la culpa**

Conviene preguntarse, antes de aceptar sin más este catálogo de regímenes especiales, por qué el derecho necesita apartarse del régimen general de responsabilidad por culpa, si este último tiene la virtud, que ningún régimen de responsabilidad estricta comparte, de poder cubrir, en principio, cualquier ámbito de la acción humana: la negligencia consiste en poner en riesgo a los demás más allá de lo razonable, y ese criterio puede aplicarse a cualquier actividad, mientras que el riesgo, empleado como criterio autónomo, solo tiene sentido respecto de actividades específicamente calificadas como riesgosas. Esta es, precisamente, la razón por la cual la responsabilidad por culpa ha persistido durante dos milenios como el régimen general y supletorio de la responsabilidad civil: su justificación, desde la perspectiva de la justicia correctiva, es sencilla y de aplicación universal, porque el reproche recae directamente sobre lo injusto de la conducta del demandado.

Conviene precisar, sin embargo, que incluso el régimen de culpa contiene ya un elemento de objetividad que conviene no perder de vista, y que se ha repetido a lo largo de este material desde el Eje 8: el juicio de responsabilidad civil no admite, por lo general, las excusas fundadas en las debilidades particulares del demandado que sí admitiría un juicio estrictamente moral, porque el derecho privado exige sacrificar lo individual en pos de un orden de expectativas recíprocas conocido y estable. En este sentido, puede decirse que la responsabilidad por culpa es ya, en cierto grado, una responsabilidad estricta, porque puede imponerse aunque el demandado no haya estado, en los hechos, en condiciones subjetivas de actuar del modo que el derecho le exige.

Lo que distingue, entonces, a los regímenes de responsabilidad estricta propiamente dichos no es la presencia de un elemento objetivo, que la culpa civil ya posee, sino el fundamento mismo de la responsabilidad: mientras en la responsabilidad por culpa la justificación se encuentra en lo injusto de la conducta del demandado, en la responsabilidad estricta debe buscarse, en cambio, en lo injusto de que sea la víctima quien soporte el riesgo de un daño que no provocó. Se trata de una distinción entre el injusto de la acción y el injusto del resultado, que remite, en último término, a un conflicto entre dos bienes igualmente dignos de protección: la libertad de quien actúa y la seguridad de quien puede resultar dañado por esa actividad. Resulta significativo que esta misma conclusión pueda alcanzarse desde perspectivas filosóficas opuestas: tanto desde un individualismo radical, que concibe los derechos como una forma de propiedad cuya interferencia debe dar lugar a reparación con independencia de la culpa del interferente, como desde una perspectiva distribucionista, que valora la responsabilidad estricta como un mecanismo eficiente para repartir entre toda la sociedad el costo de los accidentes inevitables de una actividad. Esta convergencia de fundamentos filosóficos contrapuestos hacia la misma conclusión práctica es un patrón que ya se observó, en otro contexto, al examinar en el Eje 15 la responsabilidad del empresario: distintos caminos dogmáticos, hecho ajeno interpretado con rigor extremo, hecho propio de la organización, conducían igualmente a una responsabilidad empresarial de escaso margen real de exoneración.

Con todo, ninguna de estas justificaciones generales de la responsabilidad estricta puede sostenerse como fundamento de una práctica universal, porque no es concebible una sociedad en

la que se responda de todas las consecuencias dañosas de la propia acción sin ningún criterio adicional de atribución: ese es, precisamente, el fundamento último, incluso pragmático, del principio de que los daños se radican, por regla general, en el patrimonio de quien los sufre, a menos que exista una razón específica para trasladarlos a un tercero. Por eso la responsabilidad estricta, a diferencia de la culpa, no puede generalizarse como criterio único de atribución, y su reconocimiento se limita, en la práctica comparada, a ciertos grupos de casos recurrentes que sí ofrecen esa razón específica: las actividades especialmente peligrosas, de donde provienen históricamente los ferrocarriles, la aeronavegación y la energía nuclear, precisamente los ejemplos examinados en la sección anterior, donde quien impone a los demás un riesgo excesivo debe asumir sus costos aunque haya actuado con la máxima diligencia; la responsabilidad vicaria por el hecho de los dependientes, ya examinada en los Ejes 14 y 15, que combina consideraciones correctivas, el principal controla la actividad de su dependiente, y distributivas, es él quien se beneficia económicamente de ella; las situaciones de asimetría estratégica entre las partes, como ocurre entre trabajadores y empleadores, o entre consumidores y productores, donde la igualdad formal que presupone el régimen de culpa deja de ser una descripción realista de la relación entre ambas partes; y los bienes especialmente valiosos o vulnerables, que la sola responsabilidad por negligencia no protege de manera suficiente.

El catálogo examinado en la sección anterior, accidentes del trabajo, accidentes de tránsito, aeronavegación, plaguicidas, hidrocarburos, energía nuclear, minería, puede leerse, a la luz de esta explicación, no como una lista arbitraria de excepciones al régimen general, sino como la aplicación reiterada de estos mismos criterios: en casi todos los casos concurre una actividad de riesgo tecnológico elevado, cuya introducción el legislador autorizó precisamente a condición de someterla a un régimen de responsabilidad estricta, en una composición de intereses que rara vez se revierte una vez que el riesgo se muestra, con el tiempo, más controlable de lo que inicialmente se temía.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con el concepto de responsabilidad estricta y su fundamento en la teoría del riesgo, riesgo-provecho y riesgo-creado, sus críticas, fomento de la negligencia, extrañeza al subjetivismo del derecho civil, inequidad hacia el demandado, y su carácter de régimen especial y de derecho estricto, de fuente exclusivamente legal.

En segundo lugar, exponer el catálogo de regímenes especiales chilenos: accidentes del trabajo, con su seguro obligatorio y su acción complementaria por culpa o dolo del empleador; accidentes de tránsito, con la responsabilidad estricta del propietario del vehículo; aeronavegación, con su doble ámbito contractual y extracontractual; plaguicidas, hidrocarburos y energía nuclear, cada uno con sus propias excusas tasadas y límites cuantitativos; y la facultad de catar y cavar del Código de Minería.

En tercer lugar, y esto es lo más importante para el examen, exponer la tensión de fondo: por qué la responsabilidad estricta requiere una justificación distinta de la culpa, pese a que la propia culpa

civil ya contiene un elemento objetivo que la acerca a ella; la distinción entre el injusto de la conducta y el injusto de que la víctima soporte el riesgo; la convergencia de fundamentos individualistas y distributivos hacia la misma conclusión; y los cuatro grupos de casos, actividades peligrosas, responsabilidad vicaria, asimetría estratégica entre las partes, bienes especialmente valiosos o vulnerables, que explican, en el derecho comparado y en el derecho chileno, por qué ciertos riesgos y no otros quedan sometidos a este régimen excepcional.

Cerrar señalando que la responsabilidad estricta, precisamente por no admitir generalización, coexiste con el régimen general de responsabilidad por culpa sin sustituirlo, y que su fuente exclusivamente legal es la que impide que su expansión quede entregada, como ocurre en cambio con las presunciones de los **artículos 2320, 2328 y 2329** examinadas en los ejes anteriores, a la sola interpretación jurisprudencial.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 17. Regímenes legales de responsabilidad objetiva**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

R. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La responsabilidad del Estado constituye un capítulo que, en su estudio acabado, corresponde propiamente al derecho administrativo, pero que exige aquí una síntesis, porque presenta un caso especialmente instructivo de lo que este material ha llamado objetivación de sectores de responsabilidad: se trata de hipótesis que, sin llegar a constituir en todos los casos una responsabilidad estricta en sentido pleno, mantienen todavía alguna relación con el concepto de culpabilidad, aunque profundamente transformado respecto del que rige entre particulares.

Conviene distinguir, dentro de esta materia, tres ámbitos: la responsabilidad de la Administración del Estado y de las municipalidades, la responsabilidad por error judicial, y la responsabilidad por actos legislativos. El desarrollo histórico del derecho público ha conocido, en relación con el primero de estos ámbitos, al menos cuatro modelos sucesivos, cuya tensión recorre todavía la discusión contemporánea: la doctrina de la inmunidad de jurisdicción, según la cual el Estado sencillamente no es responsable, hoy inaplicable por ser contraria a las normas constitucionales vigentes; la distinción entre actos de autoridad, manifestación del poder soberano, no generadores de responsabilidad según la doctrina anterior, y actos de gestión, sujetos al derecho común; un tercer modelo que hace responsable al Estado por los actos de sus órganos o funcionarios, a condición de que estos hayan infringido un deber de cuidado o hayan incurrido en una falta de servicio; y un cuarto modelo, de responsabilidad estricta pura, fundado exclusivamente en la relación causal entre la acción u omisión del órgano y el daño causado.

1. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LAS MUNICIPALIDADES

El fundamento normativo de esta responsabilidad se encuentra en los **artículos 6, 7, 38** inciso segundo y 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política; en los **artículos 4 y 44** del D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y en el **artículo 141** del D.F.L. N° 1 de 2006, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

De este conjunto normativo se desprenden varias conclusiones. En primer término, queda descartado el sistema de inmunidad de jurisdicción: el Estado y las municipalidades son, sin discusión, patrimonialmente responsables. En segundo término, y de manera particularmente relevante, estos entes están sujetos a un régimen que hace responder al Estado por los hechos de sus órganos y funcionarios cometidos en el ejercicio de sus funciones, como si fueran hechos propios, con independencia del cuidado empleado respecto de la actuación de esos funcionarios: se trata, en este sentido, de una especie de responsabilidad vicaria, en la que el Estado responde personal y directamente, sin que quepa exonerarse acreditando diligencia en la vigilancia o selección de sus agentes, a diferencia de lo que ocurre en el régimen general de responsabilidad por el hecho ajeno examinado en el Eje 14.

En tercer término, el Estado responde por la culpa infraccional de sus órganos, cuando estos actúan en contravención de la ley o de la Constitución, aplicando aquí el mismo principio general ya exa-

minado en el Eje 8 a propósito de la culpa infraccional entre particulares: la infracción de una norma obligatoria genera responsabilidad cuando el daño es objetivamente atribuible a esa infracción. Y, en cuarto término, el Estado responde por la falta de servicio en que incurran los órganos de la Administración, concepto que tiene una connotación marcadamente objetiva, análoga a la que ha adoptado el concepto civil de negligencia: ni en la responsabilidad por culpa entre particulares ni en la falta de servicio administrativa basta la mera causalidad material entre el hecho y el daño, sino que se exige, en ambos casos, un juicio normativo adicional: en la culpa civil, la comparación de la conducta efectiva con el estándar de conducta debida; en la falta de servicio, la comparación con el estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública.

Un caso especialmente ilustrativo de cómo opera esta atribución es el fallado con ocasión de la caída de una persona en una excavación profunda situada a escasos metros de un paradero de buses, sin señalización ni barreras de protección: la Corte de Santiago consideró que la municipalidad demandada no había sido eficiente en el desempeño del servicio de inspección de obras a que estaba legalmente obligada, dando por establecida la falta de servicio, en sentencia confirmada por la Corte Suprema al conocer de la casación en el fondo el 24 de marzo de 1981. El caso muestra un rasgo característico de esta institución: la falta de servicio no exige individualizar al funcionario concreto cuya negligencia la origina, sino que se limita a calificar si, atendidas las circunstancias, el servicio público debió funcionar de manera que evitara el daño; se trata, en este sentido, de una responsabilidad directa y personal de la Administración, atribuible a la organización del servicio en su conjunto y no al hecho ajeno de un dependiente identificable, aunque en la práctica ciertos fallos hayan recurrido, con menor rigor técnico, a la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno de los **artículos 2320 y 2322** para llegar al mismo resultado. Conviene precisar, sin embargo, que esta ausencia de individualización del funcionario responsable no convierte por sí sola a la falta de servicio en una responsabilidad estricta u objetiva en sentido propio: los tribunales siguen exigiendo que se acredite que el servicio, atendidas sus circunstancias concretas, debió funcionar de un modo distinto al que efectivamente tuvo, juicio normativo que es sustancialmente el mismo que se formula al calificar la culpa difusa o la culpa en la organización examinadas en el Eje 15 a propósito del empresario.

Una doctrina minoritaria, apoyándose en el **artículo 38** de la Constitución y en el **artículo 4** de la Ley de Bases, sostiene en cambio que la responsabilidad del Estado sería de carácter estricto en sentido propio: bastaría la existencia de un daño causalmente atribuible a la actividad estatal, exigiéndose como único requisito adicional que se trate de un daño antijurídico, esto es, de aquel que el administrado no tiene obligación jurídica de soportar. Esta doctrina, según se examinará en la sección siguiente, no es compartida por buena parte de la doctrina nacional.

2. RESPONSABILIDAD POR ERROR JUDICIAL

Este ámbito tiene reconocimiento expreso en el **artículo 19** N° 7 letra i) de la Constitución, que concede el derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales sufridos a quien haya sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por una resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria; la indemnización se determina judicialmente en un procedimiento breve y sumario, con apreciación de la prueba en conciencia.

La jurisprudencia ha sido, con todo, extremadamente exigente para dar por establecidos los presupuestos de esta responsabilidad, exigiendo en la práctica, aunque sin decirlo de modo explícito en el propio texto de sus resoluciones, que la resolución cuestionada revele algo asimilable a una culpa grave del órgano jurisdiccional, y no cualquier error de apreciación que, revisado con posterioridad, resulte equivocado.

3. RESPONSABILIDAD POR ACTOS LEGISLATIVOS

Bajo el principio clásico de la soberanía política del legislador, la responsabilidad del Estado por sus actos legislativos resultaba, tradicionalmente, inimaginable. Ese principio entra hoy en colisión, sin embargo, con el principio de la supremacía del derecho propio del constitucionalismo contemporáneo, que la propia Constitución resguarda mediante instrumentos procesales específicos: un control preventivo de carácter general, previo a la entrada en vigencia de la ley, y un control correctivo de carácter particular, ambos a cargo del Tribunal Constitucional.

Fuera de estos instrumentos, que persiguen impedir la vigencia o la aplicación de una ley inconstitucional, la cuestión de la responsabilidad del Estado legislador se presenta considerablemente más imprecisa, y el derecho comparado se muestra, en general, tímido en reconocerla respecto de decisiones legislativas que no adolecen de inconstitucionalidad alguna. Nada obsta, con todo, para que la obligación reparatoria que pesa sobre el Estado administrador por la imposición de cargas graves y especiales, aun cuando esas cargas sean plenamente lícitas desde el punto de vista de la eficacia normativa de la disposición que las impone, se extienda, en casos excepcionales, también a la ley, al menos cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse razonablemente que el legislador no tuvo la intención de privar a los afectados de toda reparación.

DATO DE GRADO**Falta de servicio y responsabilidad estricta pura**

La disputa entre el tercer y el cuarto de los modelos históricos reseñados al plantear este eje, la responsabilidad fundada en la falta de servicio, de un lado, y la responsabilidad estricta pura fundada solo en la causalidad y en la antijuridicidad del daño, del otro, condensa, en el ámbito de la responsabilidad estatal, la misma pregunta que ha recorrido buena parte de este material: cuánto de reproche normativo debe conservar un régimen de responsabilidad para seguir siendo reconocible como tal, y cuánto puede prescindir de él sin transformarse en otra cosa.

El modelo de la falta de servicio, aunque marcadamente objetivo, conserva un elemento de comparación normativa, el estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública, que cumple, dentro de la responsabilidad estatal, la misma función que cumple el estándar del hombre prudente dentro de la responsabilidad civil por culpa examinada en el Eje 8: permite distinguir entre el daño que el servicio público, funcionando conforme a los estándares que razonablemente se le pueden exigir, no pudo evitar, y el daño que revela, en cambio, un funcionamiento deficiente de ese servicio. Esta comparación introduce, inevitablemente, un juicio de grado y de razonabilidad que exige valorar las circunstancias concretas en que el órgano estatal actuó, sus recursos disponibles, la urgencia de la situación, el estado del conocimiento técnico al momento de los hechos.

El modelo de la responsabilidad estricta pura prescinde deliberadamente de esa comparación, y por eso mismo evita las dificultades probatorias y valorativas que ella supone: basta acreditar el daño, su carácter antijurídico, que el administrado no tenía el deber de soportarlo, y la relación causal con la actividad estatal. La ventaja de esta simplificación es evidente desde la perspectiva de la víctima, que se ve liberada de probar un estándar de funcionamiento normal del servicio para luego contrastarlo con lo efectivamente ocurrido. Pero esa misma simplificación es la que explica la objeción más seria que se le formula: si el Estado responde de todo daño causalmente atribuible a su actividad, con la sola condición de que el afectado no tuviera el deber jurídico de soportarlo, condición que, en la práctica, se satisface en la generalidad de los casos, porque rara vez existe un deber de soportar sin compensación un daño personal o patrimonial concreto, el resultado es que el Estado se transforma, en los hechos, en un vasto sistema de seguridad social frente a cualquier actividad administrativa que cause daño, indiferenciado del que correspondería a un seguro universal financiado con fondos públicos. Esa transformación puede ser deseable como política pública, pero constituye una decisión de una envergadura fiscal y distributiva tan considerable que difícilmente puede presentarse como una simple consecuencia interpretativa de dos artículos generales de la Constitución y de la Ley de Bases, y no como lo que en realidad sería: una redefinición completa del papel del Estado frente al riesgo de la vida social, equivalente en su alcance a extender a toda la actividad administrativa el mismo argumento que, según se examinó en el Eje 17, justifica los regímenes legales de responsabilidad estricta solo para actividades específicas y cuidadosamente delimitadas por el legislador.

4. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con los cuatro modelos históricos de responsabilidad patrimonial del Estado, inmunidad de jurisdicción, distinción entre actos de autoridad y de gestión, responsabilidad por culpa o falta de servicio, responsabilidad estricta pura, y su fundamento constitucional y legal actual, que descarta expresamente la inmunidad de jurisdicción.

En segundo lugar, exponer el régimen vigente de responsabilidad de la Administración: responsabilidad vicaria por el hecho de los órganos y funcionarios, sin exigencia de cuidado en su selección o vigilancia; culpa infraccional por contravención de la ley o la Constitución; falta de servicio, con su connotación objetiva análoga a la negligencia civil; y la doctrina minoritaria de la responsabilidad estricta pura fundada solo en la causalidad y en la antijuridicidad del daño.

En tercer lugar, tratar la responsabilidad por error judicial, fundamento constitucional del **artículo 19** N° 7 letra i), y la exigencia jurisprudencial, no explicitada pero real, de algo asimilable a la culpa grave, y la responsabilidad por actos legislativos (tensión entre la soberanía del legislador y la supremacía constitucional, control preventivo y correctivo del Tribunal Constitucional, y la posibilidad excepcional de extender la responsabilidad del Estado administrador a la ley misma cuando impone cargas graves y especiales).

Cerrar con la tensión de fondo: la disputa entre la falta de servicio, que conserva un juicio normativo de comparación con el estándar razonable de la función pública, y la responsabilidad estricta pura, que prescinde de esa comparación exigiendo solo causalidad y daño antijurídico, con la advertencia de que esta última doctrina, llevada a sus últimas consecuencias, transformaría al Estado en un sistema de seguridad social frente a toda su actividad dañosa, consecuencia de una magnitud que excede lo que puede razonablemente derivarse de la sola interpretación de las normas constitucionales y legales generales que la sustentan.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 18. Responsabilidad del Estado**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

S. LA ACCIÓN POR DAÑO CONTINGENTE (ART. 2333)

El sistema prototípico de responsabilidad civil, examinado en todos los ejes anteriores, tiene por finalidad y fundamento la reparación de daños que ya han ocurrido: es el daño ya causado el que debe repararse o compensarse, y para ello surge la responsabilidad civil como mecanismo de transferencia de su costo. Se trata, en este sentido, de una institución que mira siempre al pasado, el hecho del autor, la relación de causalidad, el daño producido.

Frente a este sistema surge, sin embargo, una pregunta evidente: si la víctima y la sociedad en su conjunto habrían preferido, en la inmensa mayoría de los casos, que el daño simplemente no se hubiera producido, ¿puede la responsabilidad civil servir no solo para reparar, sino también para prevenir? La pregunta no es ajena a la tradición jurídica chilena, que reconoce desde los orígenes mismos del Código Civil la posibilidad de articular medidas, sobre la base de la responsabilidad, para evitar daños que amenazan con cierta certidumbre de ocurrencia. El Código regula expresamente el supuesto de responsabilidad por un daño contingente, esto es, aún no ocurrido, que amenaza a personas determinadas o indeterminadas por la imprudencia o negligencia de alguien, en los **artículos 2333 y 2334**, y establece además como caso especial la amenaza de caída de una cosa desde la parte superior de un edificio, ya examinada en el Eje 16. Cumplen, además, un papel análogo los interdictos de obra nueva y de obra ruinosa, tratados como acciones posesorias, y las medidas que el juez puede adoptar, de oficio o a petición de cualquiera, para proteger la existencia del que está por nacer cuando crea que de algún modo peligr.

1. EL DAÑO CONTINGENTE COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA

1.1. Amenaza y contingencia del daño

El **artículo 2333** habla, en términos generales, de "daño contingente", esto es, de un daño que puede llegar a suceder o no, sin efectuar distinción alguna sobre su naturaleza. No basta, sin embargo, que el daño sea meramente hipotético o posible: es necesario que su ocurrencia sea más que probable, sin que baste tampoco la existencia de un mero riesgo o de una situación de peligro general y abstracto. La amenaza puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión, en los mismos términos ya reconocidos para la acción constitucional de protección. Aunque el concepto de daño contingente suele asociarse, en el imaginario común, a consecuencias materiales, la caída de un edificio que amenaza ruina, la de un árbol mal arraigado, el Código no distingue según la naturaleza del perjuicio amenazado, de manera que cualquier clase de daño puede ser objeto de esta responsabilidad preventiva.

1.2. Relación de causalidad

La amenaza del daño debe tener como causa un comportamiento descuidado del demandado. Esta exigencia presenta una particularidad conceptual que conviene destacar: puesto que el daño amenazado todavía no se ha producido, la relación de causalidad debe establecerse en términos hipotéticos, preguntándose si, de llegar a producirse el daño, este coincidiría con la relación causal que

existiría entre esa conducta negligente y el resultado dañoso. Si esa relación hipotética puede afirmarse, debe darse por establecida la causalidad entre la amenaza actual y el hecho activo u omisivo del demandado.

1.3. Culpabilidad

El **artículo 2333** exige expresamente que de parte del agente exista negligencia, esto es, culpa: la amenaza debe corresponder a una conducta, normalmente una omisión, que le sea imputable por haber incumplido un deber de cuidado que lo obligaba a eliminar la amenaza o la inminencia del daño. Lo que se exige respecto de la culpa se aplica con mayor razón si el demandado no adopta las precauciones necesarias con la intención misma de que el daño llegue a producirse, esto es, si actúa con dolo.

2. LEGITIMACIÓN PASIVA

Está pasivamente legitimada toda persona, natural o jurídica, a quien corresponda el deber de suprimir una situación de amenaza o de riesgo inminente de daño a otro. Por aplicación de las reglas generales ya examinadas en el Eje 5, el demandado debe tener capacidad delictual; pero, según las reglas del **artículo 2319**, también examinadas en ese eje y retomadas en el Eje 14 a propósito del hecho ajeno, pueden responder por él las personas a cuyo cargo se encuentre.

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA

Corresponde distinguir, en esta materia, entre dos formas de acción. Si el daño contingente amenaza únicamente a personas determinadas, la acción compete solo a estas: así lo dispone expresamente el **artículo 2333**, según el cual, si el daño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de ellas podrá intentar la acción. Si, en cambio, no es posible identificar con precisión a los afectados por la amenaza, porque esta se cierne, más bien, sobre cualquier persona que se exponga a la situación amenazante, la ley concede una acción popular, extendida por regla general a todos los casos de daño contingente que, por imprudencia o negligencia de alguien, amenace a personas indeterminadas.

El ejercicio de la acción popular trae consigo una consecuencia económica particular: quien la ejerce debe ser indemnizado de todas las costas de la acción, además del valor del tiempo y la diligencia empleados en ella, sumas que el juez aprecia discrecionalmente y que debe solventar el demandado, todo ello sin perjuicio de la remuneración específica que la ley pueda conceder en casos determinados. Esta regla se conecta con la que rige, en materia posesoria, la querrela de acción popular, que establece asimismo una recompensa en favor de quien la ejerce, dentro de los límites que la propia norma fija.

4. PRESCRIPCIÓN

No resulta aplicable a la responsabilidad preventiva la regla general de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, que ordena computar el plazo desde la perpetración del acto, porque esa norma presupone, precisamente, que el daño ya se ha producido, hipótesis ajena, por definición, a la responsabilidad por daño contingente. Debe aplicarse, en cambio, la regla que declara imprescriptible la acción dirigida a precaver un daño mientras exista justo motivo para temerlo: en consecuencia, mientras subsista la amenaza de un daño, con los requisitos ya examinados, permanece abierta la posibilidad de accionar para evitarlo, sea mediante el juicio civil ordinario, sea mediante la acción posesoria correspondiente, sea mediante la acción constitucional de protección.

DATO DE GRADO

Causalidad retrospectiva y causalidad hipotética

Todo el sistema de responsabilidad civil examinado en los ejes anteriores está construido sobre un ejercicio esencialmente retrospectivo: se pregunta qué causó un daño que ya ocurrió, comparando lo efectivamente sucedido con lo que habría sucedido de no mediar el hecho del demandado, según el método de la supresión mental hipotética examinado en el Eje 13. La responsabilidad por daño contingente exige, en cambio, un ejercicio de naturaleza inversa: puesto que el daño no se ha producido todavía, la causalidad no puede establecerse comparando dos estados de cosas efectivamente verificados, sino que debe proyectarse hacia un resultado que, por definición, es todavía incierto.

Esta inversión plantea una dificultad conceptual que merece destacarse. La exigencia de que la amenaza sea "más que probable", y no meramente posible o hipotética, cumple, en este contexto, una función equivalente a la que cumple la exigencia de certidumbre del daño examinada en el Eje 10 a propósito del daño futuro: así como no todo daño posible pero incierto es indemnizable una vez ocurrido, tampoco toda amenaza posible pero incierta habilita la acción preventiva. La diferencia decisiva es que, en la responsabilidad ordinaria, la certidumbre se predica de un daño que en algún momento se hará irreversible, ya ha ocurrido, o se sabe con certeza que ocurrirá, mientras que en la responsabilidad preventiva la certidumbre exigida es, precisamente, la de una amenaza que la acción judicial pretende impedir que se materialice. Existe, en este sentido, una paradoja estructural en el fundamento mismo de esta institución: cuanto más exitosa sea la acción preventiva, menos evidencia quedará jamás de que la amenaza era, en efecto, seria y no meramente especulativa, porque el daño que habría permitido verificarla ex post nunca llegará a producirse. Esto exige a los tribunales un ejercicio de calificación necesariamente más especulativo que el que realizan en sede de responsabilidad ordinaria, y explica por qué la ley exige, como contrapartida, una amenaza calificada, más que probable, y fundada en una negligencia o un dolo actuales y verificables, y no cualquier situación de riesgo abstracto, para no convertir la acción preventiva en una vía para intervenir judicialmente cualquier actividad que alguien considere, de buena fe pero sin fundamento suficiente, potencialmente riesgosa.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir explicando la naturaleza preventiva, y no reparatoria, de esta institución, y su fundamento en los **artículos 2333 y 2334** del Código Civil, junto con las instituciones análogas del sistema (amenaza de caída de cosas del **artículo 2328** inciso segundo, interdictos posesorios de obra nueva y ruinosas, medidas de protección del que está por nacer del **artículo 75**).

En segundo lugar, exponer los tres requisitos del daño contingente: la amenaza, que debe ser más que probable y puede recaer en cualquier clase de daño; la relación de causalidad, que debe establecerse hipotéticamente, proyectando el resultado que se seguiría de no mediar la intervención judicial; y la culpabilidad, exigida expresamente por el **artículo 2333**, con mayor razón si media dolo.

En tercer lugar, tratar la legitimación pasiva, quien tiene el deber de suprimir la amenaza, con la posibilidad de que respondan por él quienes lo tienen a su cargo conforme al **artículo 2319**, y la legitimación activa, distinguiendo la acción individual, cuando la amenaza recae sobre personas determinadas, de la acción popular, cuando recae sobre personas indeterminadas, con su particular consecuencia económica de reembolso de costas y remuneración del tiempo empleado. Debe mencionarse también la regla especial de imprescriptibilidad mientras subsista justo motivo para temer el daño.

Cerrar con la tensión de fondo: la responsabilidad por daño contingente invierte el ejercicio retrospectivo propio de la causalidad ordinaria, exigiendo una proyección hipotética hacia un resultado todavía incierto, lo que plantea la paradoja de que el éxito mismo de la acción preventiva impide verificar, con posterioridad, si la amenaza que la motivó era realmente seria, razón por la cual la ley exige una amenaza calificada de probabilidad y una negligencia o dolo actuales, para no convertir esta institución en una vía de intervención judicial sobre cualquier riesgo meramente especulativo.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 19. La acción por daño contingente (art. 2333)**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

T. OBJETO Y EXTENSIÓN DE LA REPARACIÓN

Concurriendo los requisitos de la responsabilidad extracontractual ya estudiados a lo largo de este material, nace para el autor del hecho ilícito la obligación de reparar el daño ocasionado, cuyo instrumento procesal es la acción de responsabilidad. Esta acción presenta tres características que conviene fijar desde el inicio: es una acción personal, porque corresponde ejercerla contra el responsable del daño; es siempre mueble, porque persigue normalmente el pago de una suma de dinero y, en ciertos casos, la ejecución de un hecho, que la ley reputa mueble; y es una acción netamente patrimonial, de lo cual se sigue que es renunciable, transigible, cedible y prescriptible, aspectos que se examinan en el Eje 22.

Definidas estas características, este eje examina el objeto mismo de la acción, qué formas puede adoptar la reparación, y su extensión, cuánto debe comprender esa reparación, y cómo se actualiza en el tiempo hasta el momento del pago efectivo.

1. FORMAS DE REPARACIÓN

La reparación puede ser en especie o in natura, o en equivalente. La reparación en especie consiste en la ejecución de actos o la adopción de medidas que hagan desaparecer el daño, buscando restituir al demandante a la situación anterior al hecho ilícito: si una cosa fue deteriorada, repararla; si fue destruida, reemplazarla por otra equivalente; si la víctima sufrió lesiones corporales, cubrir los costos médicos y de hospitalización; si se deterioró el medio ambiente, restituirlo. Pero la reparación en especie también puede consistir en conductas que, sin restituir propiamente, producen un resultado equivalente: la publicación de la sentencia que declara incorrecta una información difamatoria opera como una suerte de restitución moral del ofendido, y en el extremo, cuando el daño moral puede repararse mediante la publicidad del ilícito que lo provocó, esta forma de reparación puede asumir el carácter de una indemnización simbólica.

La reparación en equivalente, en cambio, tiene por objeto que el daño sea compensado por un sustituto, generalmente una suma de dinero, y es la forma de reparación que se ejerce con mayor frecuencia en la práctica. La doctrina reconoce a la víctima la facultad de elegir la forma de reparación que prefiera, sin que el derecho chileno establezca un orden de precedencia entre ambas; la reparación en especie solo puede exigirse cuando es materialmente posible y siempre que no imponga al demandado un gravamen desproporcionado. Ambas formas de reparación, con todo, no son necesariamente indiferentes entre sí en sus resultados: en el caso de una cosa deteriorada, la acción en naturaleza persigue que el responsable la repare por sí mismo o indemnice el costo de la reparación, en clara analogía con las obligaciones contractuales de hacer, mientras que la indemnización compensatoria del perjuicio patrimonial neto persigue, en cambio, la diferencia de valor de la cosa entre antes y después del daño, lo que puede conducir a montos distintos según el método de cálculo empleado. La restitución en naturaleza produce, en todo caso, un efecto reflejo sobre la acción indemnizatoria: en la medida en que corrige o disminuye el daño, disminuye correlativamente el monto de la indemnización debida, al punto de que ejercer la acción indemnizatoria sin considerar que la corrección en naturaleza ya realizada disminuyó significativamente el perjuicio puede constituir un ejercicio abusivo de esa acción.

2. EXTENSIÓN DE LA REPARACIÓN

2.1. El principio de la reparación integral

La jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que la ley obliga a reparar el perjuicio causado por el hecho ilícito de manera completa, esto es, en una medida igual al daño producido, de modo que permita a la víctima reponer las cosas al estado en que se encontraban antes del ilícito. De este principio se siguen, según **ALESSANDRI**, tres consecuencias: que el monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho que lo causó; que la reparación comprende todo el perjuicio sufrido por la víctima que sea consecuencia necesaria y directa del delito o cuasidelito, según los criterios de causalidad examinados en el Eje 13; y que el monto de la reparación no puede ser superior ni inferior al daño efectivamente sufrido. La doctrina y la jurisprudencia coinciden, además, en que la indemnización debe comprender tanto el daño material como el daño moral, examinados respectivamente en los Ejes 11 y 12.

2.2. Reducción de la reparación

La reparación puede verse reducida en dos supuestos ya examinados en ejes anteriores, que aquí basta con recordar en su función de límites a la extensión de la reparación. El primero es la disposición especial del **artículo 2331**, que condiciona la indemnización pecuniaria por imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito a la prueba de un daño emergente o lucro cesante apreciable en dinero, norma cuya interpretación tradicional, y la controversia jurisprudencial abierta sobre su alcance respecto del daño moral, se examinaron con detalle en el Eje 12. El segundo es la concurrencia de culpa de la víctima del **artículo 2330**, que establece una suerte de compensación de culpas, examinada en el Eje 13 a propósito de la causalidad.

2.3. Reajustabilidad de la indemnización

La doctrina y la jurisprudencia contemporáneas coinciden en que el valor del daño debe reajustarse para que la indemnización repare completamente el menoscabo sufrido, por dos razones: porque el propio **artículo 2329** exige que la reparación sea integral, lo que no ocurriría si el acreedor la recibiera desvalorizada por el transcurso del tiempo; y porque, desde la dictación de la legislación que sustituyó al antiguo régimen sobre reajustabilidad de deudas de dinero, la regla general en el derecho chileno es precisamente esa reajustabilidad. No existe, con todo, un índice de reajuste de aplicación obligatoria para el juez, aunque en la práctica se recurre habitualmente al Índice de Precios al Consumidor.

2.4. Procedencia del pago de intereses

Se sostiene que la única manera de que la reparación sea cabal es que considere también las variaciones ocurridas durante la tramitación del pleito, lo que se logra mediante el pago de intereses desde la fecha en que estos hayan sido solicitados, atendida la relativa libertad de que dispone el juez en materia extracontractual. La determinación del momento exacto desde el cual deben computarse esos reajustes e intereses ha sido, sin embargo, objeto de discusión jurisprudencial persistente: algunas sentencias los aplican desde la fecha del ilícito; otras aplican las normas sobre la

mora, haciéndolos correr solo desde la presentación o la notificación de la demanda; y otras, finalmente, solo desde la dictación de la sentencia que impone la obligación de indemnizar, o incluso desde que esta queda ejecutoriada.

DATO DE GRADO**Desde cuándo corre el tiempo de la reparación integral**

La disputa sobre el momento desde el cual deben computarse los reajustes e intereses no es una cuestión puramente práctica de liquidación, sino que pone a prueba, en un terreno muy concreto, el verdadero alcance del principio de reparación integral examinado en la sección anterior: si la reparación debe ser exactamente igual al daño, ni más ni menos, entonces debe preguntarse en qué momento exacto ese daño quedó fijado en su magnitud, porque es desde ese momento, y no desde uno posterior, que su valor comienza a erosionarse por el transcurso del tiempo y que su titular se ve privado del goce del bien que perdió.

La tesis que sostiene que reajustes e intereses deben correr desde la producción misma del daño se apoya precisamente en esta lógica: si el daño se fija, en su entidad, al momento de producirse, cualquier cómputo posterior, desde la notificación de la demanda, desde la sentencia, deja sin reparar la sola pérdida de valor y de goce ocurrida en el intervalo, contradiciendo la exigencia de que la reparación sea exactamente igual al daño. Esta tesis rechaza, además, la aplicación de las normas sobre la mora como fundamento para postergar el cómputo, porque esas normas presuponen una obligación previa cuyo incumplimiento es necesario constituir en mora, la lógica propia de la responsabilidad contractual, mientras que la obligación indemnizatoria extracontractual nace directamente, sin obligación previa alguna, del hecho ilícito que causa el daño: aplicar aquí una institución pensada para un problema estructuralmente distinto, el contraste entre lo debido desde el contrato y lo efectivamente cumplido, importaría trasladar mecánicamente una solución contractual a un terreno que no la necesita ni la justifica.

Sin embargo, la práctica jurisprudencial dominante no ha seguido esta tesis en toda su extensión, y prefiere, tratándose del daño material, computar reajustes e intereses desde la notificación de la demanda o desde la sentencia. La explicación de esta preferencia no es meramente técnica: hacer correr los reajustes desde la fecha exacta del hecho ilícito exige poder fijar, ya en ese momento, un valor determinado del daño sobre el cual aplicar el reajuste, lo que en muchos casos solo se logra con la prueba rendida durante el juicio, de manera que retrotraer el cómputo al momento del hecho supone, en la práctica, proyectar hacia atrás un valor que solo se conoce con certeza al final del proceso. Tratándose del daño moral, esta dificultad se vuelve, además, conceptualmente insalvable: su valoración, a diferencia de la del daño material, que en principio existe como magnitud objetiva desde el momento del hecho, aunque solo se pruebe después, no existe como cifra determinada sino hasta el momento mismo en que el juez la fija en la sentencia, ponderando las circunstancias del caso; no hay, en rigor, un daño moral ya cuantificado en el pasado cuyo valor se trate de actualizar, sino una suma que nace, como tal, recién con el fallo. Por eso, tratándose de este daño, el argumento que exige retrotraer el cómputo al momento del hecho pierde por completo su fuerza, y se impone sin mayor discusión el criterio de aplicar reajustes e intereses solo desde la dictación de la sentencia.

Lo que revela esta disputa, en definitiva, es que el ideal de una reparación exactamente igual al daño, examinado ya, en su vertiente patrimonial, en el Eje 11, se enfrenta, también en materia de reajustes e intereses, a la misma tensión entre precisión teórica y viabilidad práctica:

la solución que mejor satisface el principio en abstracto, retrotraer siempre el cómputo al momento del hecho, cede terreno, en la práctica judicial, ante consideraciones probatorias y conceptuales que varían según la naturaleza del daño de que se trate.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con las características generales de la acción de responsabilidad, personal, mueble, patrimonial, y por tanto renunciable, transigible, cedible y prescriptible, y su objeto general: la reparación del daño causado.

En segundo lugar, exponer las formas de reparación, en especie y en equivalente, la facultad de elección de la víctima sin orden de precedencia legal, y el efecto reflejo de la reparación en especie sobre el monto de la indemnización en equivalente.

En tercer lugar, desarrollar la extensión de la reparación: el principio de reparación integral con sus tres consecuencias según **ALESSANDRI**; los dos supuestos de reducción ya examinados, **artículo 2331** y **artículo 2330**; y la reajustabilidad de la indemnización.

Cerrar con la tensión de fondo: la disputa sobre el momento desde el cual deben computarse los reajustes e intereses pone a prueba el verdadero alcance del principio de reparación integral, porque exige precisar cuándo quedó fijada la magnitud del daño cuyo valor se trata de actualizar. Debe exponerse la tesis que exige retrotraer el cómputo al momento del hecho ilícito, fundada en que las normas sobre la mora son de naturaleza contractual y ajenas a esta materia, frente a la práctica jurisprudencial de computarlos desde la demanda o la sentencia, y explicar por qué, tratándose del daño moral, esta segunda solución se impone sin mayor discusión: a diferencia del daño material, que existe como magnitud objetiva desde el hecho aunque solo se pruebe después, el daño moral no existe como cifra determinada sino desde que el juez la fija en la sentencia misma.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 20. Objeto y extensión de la reparación**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

U. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

Definido el objeto y la extensión de la reparación en el Eje 20, corresponde examinar quién puede ejercer la acción de responsabilidad y contra quién puede dirigirse. La legitimación procesal activa es la titularidad que el ordenamiento reconoce para ejercer una acción judicial, y en materia de responsabilidad extracontractual admite una distinción básica entre titulares por derecho propio y titulares por derecho derivado. La legitimación pasiva, por su parte, se dirige en términos generales contra todo aquel que responde del daño, categoría que, como se verá, no se agota en el autor material del hecho ilícito.

Este eje debe, además, cerrar un hilo anunciado desde el Eje 3: la distinción entre la acción indemnizatoria, propia de la responsabilidad extracontractual, y la acción restitutoria, propia del enriquecimiento sin causa, reaparece aquí con toda su fuerza práctica a propósito de uno de los legitimados pasivos menos estudiados de este estatuto: quien recibe provecho del dolo ajeno sin ser cómplice de él.

1. LEGITIMACIÓN ACTIVA

1.1. Titulares por derecho propio: lesionados directos

Tratándose de daños causados a las cosas, están legitimados el dueño y el poseedor, y también quienes detentan otros derechos reales sobre ellas, el usufructuario, el habitador, el usuario, si el daño perjudica sus respectivos derechos. El mero tenedor, en cambio, carece de derechos sobre la cosa y no puede, en consecuencia, reclamar su valor mediante acción directa en caso de pérdida o deterioro; solo puede accionar en ausencia del dueño, entendiéndose entonces que lo hace en su nombre y no a título personal. Con todo, el mero tenedor sí está legitimado para reclamar, a título personal, el perjuicio que el daño irroga a un derecho personal propio que se ejerce sobre la cosa, como ocurre con el arrendatario respecto del perjuicio que sufre su crédito. Tratándose de daños a las personas, están legitimados quienes sufren una lesión directa en intereses o derechos no susceptibles de valuación económica, concurra o no con un daño material, para reclamar la reparación del daño moral examinada en el Eje 12.

1.2. Titulares por derecho propio: lesionados indirectos o víctimas por repercusión

Se reconoce también legitimación a la víctima indirecta, esto es, a quien sufre un daño patrimonial o moral a consecuencia del daño experimentado por la víctima directa, el dolor causado por la muerte de un ser querido, ya examinado en el Eje 10 a propósito del daño por rebote. Tratándose de daños patrimoniales, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido legitimación a todo aquel que recibía ayuda económica de la víctima directa, aun sin tener derecho a exigirla, y que resulta privado de ella a consecuencia del accidente. Tratándose de daño moral, la regla general restringe la acción a los casos de muerte, exigiendo un parentesco cercano con la víctima directa; excepcionalmente se concede acción por daño moral en casos de lesiones, cuando estas son de tal entidad que imponen, en los hechos, una obligación de cuidado que afecta la calidad de vida de la víctima

indirecta, como ocurre con el pariente que debe hacerse cargo de la invalidez sobreviniente de la víctima directa.

1.3. Titulares por derecho derivado

Pueden interponer la acción los sucesores a título universal de los legitimados por derecho propio, esto es, sus herederos; el Código lo señala expresamente respecto del daño en las cosas, pero el mismo principio se extiende a los daños personales por aplicación de las reglas generales sobre transmisibilidad de los derechos. El derecho a pedir la indemnización de perjuicios ya devengados puede, además, ser objeto de cesión entre vivos, incluso tratándose de daño moral, porque la indemnización tiene siempre un carácter patrimonial y no existe norma que prohíba su transferencia.

1.4. Titularidad de las clases de perjudicados y acción popular

El derecho chileno no reconoce, a diferencia del common law, una institución general equivalente a las acciones de clase, debiendo recurrirse, en su defecto, a la acumulación de acciones que emanen directa e inmediatamente de un mismo hecho, siempre que sus titulares las interpongan expresamente por sí o por mandatario común. Existe, con todo, una excepción sectorial en la legislación de protección al consumidor, que admite el ejercicio de acciones en beneficio del interés colectivo, de un conjunto determinado o determinable de consumidores ligados a un proveedor por vínculo contractual, o difuso, en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados.

Por último, y como ya se examinó en el Eje 19 a propósito del daño contingente, la ley concede acción popular para la prevención de ese daño cuando amenaza a personas indeterminadas, reservando la acción individual para el caso en que la amenaza recaiga sobre personas determinadas.

2. LEGITIMACIÓN PASIVA

2.1. El autor del hecho ilícito

Es en primer término legitimado pasivo el autor del daño. La jurisprudencia comprende dentro de esta categoría al cómplice, pero no al encubridor, distinción que no ha estado exenta de críticas. Cuando son varios los autores, el Código establece entre ellos responsabilidad solidaria, salvo las excepciones ya examinadas en el Eje 16 respecto de la ruina de un edificio perteneciente a una comunidad y de las cosas que caen o se arrojan desde lo alto de un edificio sin que pueda individualizarse su origen. Para que proceda esta solidaridad es necesario que dos o más personas hayan participado, como autores o cómplices, en un mismo delito o cuasidelito; si se trata de hechos ilícitos distintos, aunque afecten a la misma víctima, como el peatón atropellado sucesivamente por dos vehículos distintos, no hay solidaridad, sino la división proporcional ya examinada en el Eje 13 a propósito de la pluralidad de agentes.

2.2. El responsable del hecho ajeno

La acción puede dirigirse también contra quien responde del hecho ajeno conforme al régimen general examinado en los Ejes 14 y 15, como el padre por los hechos ilícitos de su hijo menor que vive con él, quien comparece en el proceso penal, si es este el que conoce de la demanda civil, en calidad de tercero civilmente responsable, sin que ello le acarree responsabilidad penal alguna.

2.3. El que recibe provecho del dolo ajeno

Conforme al **artículo 2316** inciso segundo, quien recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, solo está obligado hasta la concurrencia de lo que valga ese provecho. La circunstancia de que la norma excluya expresamente al cómplice, cuya responsabilidad es la misma del autor, confirma que esta obligación más limitada está reservada para quien, sin haber participado en el ilícito, se benefició de sus efectos; el encubridor, en cambio, queda sujeto a esta misma obligación acotada al monto del provecho recibido, salvo que su reticencia a advertir de la existencia del dolo, conociéndolo, buscara precisamente aprovecharse de sus efectos, caso en el cual pasa a responder como autor por el total de los perjuicios. Esta responsabilidad se limita, además, a los casos de dolo, y no se extiende a la culpa: opera únicamente en los delitos civiles y no en los cuasidelitos, en una solución idéntica a la que el **artículo 1458** inciso segundo da al dolo incidental en materia de formación del consentimiento, que no vicia el acto pero da acción contra quienes lo fraguaron o se aprovecharon de él, hasta la concurrencia del provecho reportado.

Esta acción del **artículo 2316** inciso segundo es, precisamente, la acción restitutoria de un enriquecimiento sin causa cuyo fundamento se anticipó en el Eje 3, al distinguir la acción indemnizatoria propia de la responsabilidad extracontractual de la acción restitutoria propia del cuasicontrato y del enriquecimiento sin causa en general. Conviene ahora completar esa distinción con la precisión que corresponde a este eje. La acción indemnizatoria del **artículo 2314**, que constituye la regla general de este estatuto, se mide por el daño efectivamente sufrido por la víctima, sin límite cuantitativo alguno vinculado al beneficio que el responsable haya podido obtener del ilícito. La acción del **artículo 2316** inciso segundo, en cambio, se mide exclusivamente por el provecho recibido por el tercero, y no por el daño sufrido por la víctima: de ahí que quien recibió un provecho modesto de un dolo ajeno que causó un daño cuantioso solo deba restituir ese provecho modesto, y nunca el daño íntegro, precisamente porque lo que se le reclama no es la reparación de un perjuicio que él no causó, sino la restitución de un enriquecimiento que carece de causa jurídica que lo justifique. Esta es la razón estructural por la cual el **artículo 2316** inciso segundo tiene un límite cuantitativo del que carece el **artículo 2314**: uno y otro precepto no son dos grados de la misma responsabilidad, sino dos instituciones de lógica diversa, indemnizatoria la una, restitutoria la otra, que coexisten dentro de un mismo título del Código.

2.4. Los herederos

Finalmente, la obligación de indemnizar es transmisible conforme a las reglas generales, de manera que los herederos del responsable quedan obligados a satisfacerla dentro de los límites de su responsabilidad sucesoria.

DATO DE GRADO

Por qué la acción restitutoria no puede medirse como la indemnizatoria

Conviene detenerse en la pregunta que la distinción anterior deja abierta: ¿por qué el legislador optó, respecto de quien se beneficia del dolo ajeno sin haber participado en él, por una medida de responsabilidad tan distinta, y tan considerablemente más benigna, que la que rige para el autor y el cómplice del ilícito?

La respuesta se encuentra en la diferencia de fundamento entre ambas acciones, ya anticipada en el Eje 3 a propósito de la agencia oficiosa: la acción indemnizatoria repara un daño causado por la conducta culpable o dolosa de quien responde, y por eso se mide por la extensión de ese daño, con independencia de cuánto se haya beneficiado el responsable de su propio ilícito. La acción restitutoria, en cambio, no supone ningún reproche a la conducta de quien la soporta, el tercero beneficiado no cometió el dolo, ni fue cómplice de él, sino que corrige un desplazamiento patrimonial injustificado: alguien obtuvo un provecho que, de conocerse el origen doloso del acto que lo generó, el derecho no puede permitir que conserve. Medir esta obligación por el daño sufrido por la víctima, y no por el provecho efectivamente recibido, sería incoherente con ese fundamento, porque obligaría a quien nada hizo culpablemente a responder de un perjuicio que puede exceder, largamente, el beneficio que él mismo obtuvo (una consecuencia que sí se justifica, en cambio, respecto de quien cometió el ilícito o fue su cómplice, porque a su respecto el fundamento de la obligación es precisamente el reproche a su propia conducta).

Esta distinción tiene, además, una proyección práctica que conviene explicitar: si se exigiera al tercero beneficiado responder del daño íntegro, se estaría, en los hechos, extendiendo los efectos del dolo ajeno a quien no incurrió en él, borrando la diferencia entre ser autor de un ilícito y beneficiarse pasivamente de sus efectos. El límite cuantitativo del **artículo 2316** inciso segundo preserva, en consecuencia, la coherencia interna del sistema: asegura que nadie responda, a título de mero beneficiario, más allá de lo que efectivamente recibió, reservando la responsabilidad íntegra por el daño para quienes tuvieron parte directa en su causación.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con la legitimación activa: titulares por derecho propio, lesionados directos, distinguiendo daño en las cosas y daño en las personas, y lesionados indirectos o víctimas por repercusión, con sus reglas distintas para daño patrimonial y daño moral; titulares por derecho derivado, sucesores y cesionarios; y la ausencia de una institución general de acciones de clase en el derecho chileno, salvo la excepción sectorial del derecho del consumidor, junto con la acción popular por daño contingente ya examinada en el Eje 19.

En segundo lugar, exponer la legitimación pasiva: el autor del hecho ilícito y la solidaridad del **artículo 2317** con sus excepciones; el responsable del hecho ajeno; y, con especial detenimiento, quien recibe provecho del dolo ajeno conforme al **artículo 2316** inciso segundo, explicando su fundamento restitutorio y su limitación exclusiva al dolo, con exclusión de la culpa.

Cerrar con la tensión de fondo: por qué la acción contra el beneficiario del dolo ajeno se mide por el provecho recibido y no por el daño sufrido por la víctima, a diferencia de la acción indemnizatoria general, explicando que esa diferencia de medida responde a una diferencia de fundamento, reproche a la conducta propia en un caso, corrección de un enriquecimiento injustificado en el otro, que preserva la coherencia del sistema al no extender a quien no participó en el ilícito las consecuencias plenas de la responsabilidad de quien sí lo cometió.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 21. Legitimación activa y pasiva**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

V. TRIBUNAL, PROCEDIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN (ART. 2332).

Definidos el objeto y la extensión de la reparación en el Eje 20, y la legitimación activa y pasiva en el Eje 21, restan por examinar dos cuestiones de cierre: ante qué tribunal y conforme a qué procedimiento se hace valer la acción de responsabilidad, y de qué manera se extingue. Este último punto permite, además, cerrar un hilo anunciado desde el Eje 7 a propósito del consentimiento de la víctima como causal de justificación: la distinción entre la renuncia anticipada al ejercicio de la acción, que el ordenamiento no tolera, y la renuncia posterior al daño ya producido, que es plenamente eficaz precisamente porque recae sobre un objeto de naturaleza distinta.

1. TRIBUNAL COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO

La regla general es que, si el hecho ilícito reviste a la vez carácter civil y penal, la competencia para conocer de la indemnización pertenece indistintamente al juzgado civil o al penal, a elección de la víctima: si el hecho tiene sanción penal, puede conocer de la indemnización el mismo tribunal que juzga el delito o cuasidelito, o el juez civil competente según las reglas generales; si el hecho ilícito carece de sanción criminal, como ocurre, por ejemplo, con un cuasidelito de daños puramente civil, es competente únicamente el juez civil. Si, tratándose de un delito de acción penal privada, se ejerce solamente la acción civil, se entiende por ello renunciada la acción penal.

El juicio indemnizatorio seguido ante los juzgados con competencia penal se sujeta, en cuanto a su procedimiento, a las reglas que señala el Código Procesal Penal, sin que por ello pierda su naturaleza civil. Ante los juzgados civiles, en cambio, sigue las reglas del juicio ordinario sin variantes especiales, salvo la posibilidad de que quede en suspenso hasta la terminación del juicio criminal conexo, siempre que en este se haya dado lugar al plenario. Conviene tener presente que, en materia extracontractual, la jurisprudencia ha entendido que no resulta aplicable la norma que permite reservar para la ejecución del fallo, o para un juicio diverso, lo relativo a la especie y monto de los perjuicios: en los delitos y cuasidelitos civiles, todos estos factores deben quedar establecidos dentro de un solo juicio. La prueba de cada uno de los elementos cuya concurrencia conjunta configura el hecho ilícito corresponde, por regla general, a la víctima, sin limitación alguna en cuanto a los medios probatorios admisibles, tratándose como se trata de acreditar hechos.

2. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La acción de responsabilidad se extingue, en general, por los mismos medios de extinguir las obligaciones, puesto que su objeto es hacer valer una pretensión indemnizatoria de naturaleza patrimonial. Conviene, con todo, detenerse en tres de esos modos: la renuncia, la transacción y la prescripción.

2.1. Renuncia

De acuerdo con la regla general sobre renunciabilidad de los derechos, no cabe duda de que puede renunciarse a la reparación del daño una vez que este se ha producido: la renuncia es, en tal caso,

un acto de disposición que extingue la acción cuando se efectúa con posterioridad al hecho que genera la responsabilidad.

Enteramente distinta es la autorización que la víctima presta antes de la ocurrencia del hecho dañoso. Esa autorización anticipada no constituye una renuncia a una acción todavía inexistente, porque mal podría renunciarse a algo que aún no ha nacido, sino que constituye técnicamente, según ya se examinó en el Eje 7, una causal de justificación que opera como eximente de responsabilidad: el consentimiento de la víctima, prestado antes del daño, impide que la conducta del demandado sea calificada de ilícita, y por eso mismo excluye que llegue siquiera a nacer una acción que renunciar. La distinción entre una y otra hipótesis no es una sutileza terminológica, sino que refleja una diferencia sustancial en el objeto sobre el que recae cada acto: la autorización anticipada compromete la disposición de bienes de la personalidad, la vida, la integridad física, cuya indisponibilidad limita severamente los efectos que el ordenamiento está dispuesto a reconocerle, mientras que la renuncia posterior al daño recae exclusivamente sobre un crédito de contenido patrimonial, la indemnización ya devengada, plenamente disponible por su titular conforme a las reglas generales. Por eso la renuncia anticipada al ejercicio de la acción, entendida como una condonación del dolo o de la culpa grave futuros, no es más eficaz que la condonación del dolo futuro que el **artículo 1465** del Código Civil declara sin valor en materia contractual: en ambos casos se trataría de autorizar de antemano la comisión de un ilícito, lo que el orden público no tolera; la renuncia posterior, en cambio, no condona nada futuro, sino que dispone de un efecto meramente pecuniario ya nacido, y es, por eso, plenamente válida.

2.2. Transacción

El Código Civil admite expresamente este modo de extinguir la responsabilidad extracontractual, al disponer que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, sin perjuicio de la acción criminal. Las partes pueden, en consecuencia, componer libremente la indemnización ya devengada, en el mismo sentido y con el mismo fundamento que hace válida la renuncia posterior al daño examinada en la sección anterior: el objeto sobre el que recae la transacción es, también aquí, un crédito patrimonial y no un bien de la personalidad.

2.3. Prescripción

El **artículo 2332** establece un plazo especial de prescripción de cuatro años, contado desde la perpetración del acto, para las acciones que concede el título de los delitos y cuasidelitos por daño o dolo. Este plazo se refiere exclusivamente a la acción indemnizatoria que nace del delito o cuasidelito civil, y no a otras acciones de que pueda disponer la víctima, como la reivindicatoria, si ha sido objeto de robo, hurto o usurpación, que se rige por su propio término; y es sin perjuicio de los plazos especiales que contemplan leyes particulares y el propio Código, como el de cinco años para la responsabilidad del constructor por la ruina de un edificio, o el de un año para los daños que esa ruina cause a los vecinos, ya examinados en el Eje 16.

El cómputo de este plazo ha generado un debate persistente. Como la norma habla de la "perpetración del acto" como momento inicial, la jurisprudencia y la doctrina entendieron tradicionalmente que el plazo corría desde la acción u omisión imputable al hechor, aunque el daño se produjera con posterioridad, momentos que de ordinario coinciden, pero no siempre. Así se resolvió reiterada-

mente, por ejemplo, en materia de responsabilidad de los conservadores de bienes raíces por certificados de gravámenes y prohibiciones que omitían una hipoteca debidamente inscrita: computándose el plazo desde el otorgamiento del certificado erróneo, y no desde el momento en que el daño efectivamente se manifestó al no poder pagarse el acreedor de la hipoteca omitida al rematarse la propiedad.

Esta interpretación ha sido criticada por conducir a un resultado absurdo: si la existencia del daño es requisito de la indemnización, la acción podría llegar a prescribir antes incluso de nacer, porque antes de que el daño se produzca la víctima nada tiene que reclamar, al no haber sufrido perjuicio alguno. Puesto que el hecho ilícito se define precisamente como la acción u omisión culpable o dolosa que causa daño, la expresión "perpetración del acto" del **artículo 2332** debería entenderse referida a ese concepto completo, que incluye el daño, y no a la sola conducta del agente considerada aisladamente. La jurisprudencia, con todo, ha resuelto la cuestión en uno y otro sentido, sin que pueda darse por zanjada.

En cuanto a la suspensión de este plazo, se ha sostenido tradicionalmente que, tratándose de una prescripción de corto tiempo de carácter especial, no se suspende en favor de las personas enumeradas en las reglas generales sobre prescripción; en cuanto a la interrupción, rigen en cambio las reglas generales, debiendo considerarse especialmente la posibilidad de que se haya iniciado un proceso criminal por un hecho del que emanen conjuntamente una acción penal y una civil.

DATO DE GRADO**Qué momento marca el nacimiento de la acción prescriptible**

La disputa sobre el cómputo del plazo del **artículo 2332** no es una cuestión menor de técnica procesal, porque de ella depende, en los casos de daños diferidos, si la víctima llega siquiera a tener la oportunidad real de accionar antes de que su pretensión se extinga.

La lectura literal de la norma, que hace correr el plazo desde la conducta del hechor, con independencia de cuándo se manifieste el daño, tiene a su favor la letra misma de la disposición, que habla de la "perpetración del acto" y no de la "producción del daño". Pero esta lectura, llevada a sus consecuencias extremas, permite que transcurran los cuatro años completos entre la conducta negligente y la manifestación del perjuicio, dejando a la víctima sin acción alguna que ejercer en el mismo momento en que recién podría advertir que sufrió un daño. El resultado no es solamente inconveniente en la práctica: es lógicamente incoherente con la propia estructura de la institución que se pretende hacer prescribir, porque no puede prescribir una acción que, a falta de daño, todavía no ha nacido; y una acción no puede haber nacido y haber prescrito en el mismo instante sin haber existido nunca en el intervalo.

La lectura que identifica la "perpetración del acto" con el hecho ilícito completo, esto es, con la conducta culpable sumada al daño que ella causa, resuelve esta incoherencia lógica, pero al precio de apartarse de la letra estricta de la norma, que distingue expresamente entre el "acto" y el "daño" en otras disposiciones del mismo título. Esta tensión entre la letra de la ley y la coherencia sistemática del instituto de la prescripción, que exige, por definición, que exista ya una acción viva cuyo no ejercicio se sanciona con el transcurso del tiempo, es la que explica que la jurisprudencia no haya logrado uniformar un criterio único, y por qué el problema reaparece cada vez que el daño se manifiesta con un desfase temporal significativo respecto de la conducta que lo originó, situación que no es infrecuente en materias como la responsabilidad profesional, los daños ambientales o los daños derivados de productos defectuosos, donde el perjuicio puede tardar años en hacerse evidente.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con la competencia y el procedimiento: elección de la víctima entre el tribunal civil y el penal cuando el hecho reviste ambos caracteres, competencia exclusivamente civil cuando carece de sanción penal, y la exigencia de que todos los elementos de la responsabilidad se establezcan en un solo juicio, sin reserva para la ejecución del fallo.

En segundo lugar, exponer los modos de extinción: la renuncia, distinguiendo con precisión la renuncia posterior al daño, válida, porque recae sobre un crédito patrimonial, de la autorización anticipada (que no es propiamente una renuncia, sino una causal de justificación ya examinada en el Eje 7, cuya ineficacia si pretende condonar el dolo o la culpa grave futuros se explica por la misma razón que informa el **artículo 1465** en materia contractual); la transacción, fundada en la misma lógica; y la prescripción de cuatro años del **artículo 2332**, con sus plazos especiales y sus reglas de suspensión e interrupción.

Cerrar con la tensión de fondo: la disputa sobre si la "perpetración del acto" que da inicio al plazo de prescripción se refiere a la sola conducta del hechor o al hecho ilícito completo, incluido el daño, explicando por qué la lectura literal conduce a la posibilidad lógicamente incoherente de que una acción prescriba antes de nacer, y por qué esa incoherencia no ha bastado, sin embargo, para que la jurisprudencia adopte de manera uniforme la lectura que la evita.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 22. Tribunal, procedimiento y extinción de la acción (art. 2332)**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

W. DUALIDAD O UNIDAD DE RÉGIMENES; DIFERENCIAS ENTRE ESTATUTOS

Sobre la base de la distinción romana de las fuentes de las obligaciones, recogida en el **artículo 1437** del Código Civil, el estudio de la responsabilidad civil se ha dividido históricamente en dos grandes estatutos: la responsabilidad contractual, que se origina en el incumplimiento de un contrato, y la responsabilidad extracontractual, que tiene su fuente en un hecho que ocasiona un daño sin que exista un vínculo previo entre su autor y la víctima. Ambos estatutos comparten, sin embargo, un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios que persigue la reparación pecuniaria del daño sufrido por el hecho de un tercero.

Esta coincidencia de finalidad ha llevado a una parte de la doctrina comparada a sostener que la responsabilidad civil debería tratarse bajo un estatuto único, tesis que este eje debe examinar críticamente, junto con las diferencias concretas que, en el derecho chileno vigente, separan a ambos regímenes y que justifican, en definitiva, su tratamiento dual.

1. LA DISCUSIÓN ACERCA DE LA DUALIDAD O UNIDAD DE RÉGIMENES

La teoría de la unidad de la responsabilidad civil tiende a equiparar ambas categorías, sobre la base de que tanto el hecho ilícito como el incumplimiento contractual son manifestaciones de una actuación contraria a derecho, sancionada civilmente con el resarcimiento del daño causado; la obligación de indemnizar nacería, en ambos casos, del hecho ilícito o de la infracción contractual, sustituyendo en este último caso a la obligación original. Esta construcción ha sido replicada en dos puntos: la indemnización moratoria no sustituye a la obligación original, sino que coexiste con ella; y el incumplimiento no siempre da lugar a esa transformación, sino solo cuando el cumplimiento en naturaleza deja de ser posible, mientras pueda obtenerse el cumplimiento forzado, este procede, además de la indemnización moratoria, de manera que el incumplimiento no genera necesariamente una obligación nueva, como sí ocurre, en cambio, con el hecho ilícito. La teoría unitaria invoca, además, una identidad de elementos fundamentales entre ambos estatutos, una acción u omisión imputable, la existencia de un daño, y la relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio, pero esta identidad estructural convive, como se examinará en la sección siguiente, con diferencias de detalle demasiado numerosas y sistemáticas como para explicarse por mera contingencia histórica.

La doctrina predominante en Chile sostiene, en consecuencia, la dualidad de regímenes: la responsabilidad contractual supone una obligación anterior y se genera entre personas ya ligadas por un vínculo jurídico preexistente, mientras que la responsabilidad aquiliana supone precisamente la ausencia de esa obligación previa, se produce entre personas hasta entonces jurídicamente extrañas, y es ella misma la que crea la obligación de reparar. Esta tesis encuentra, además, respaldo textual expreso en el Código: el **artículo 1437** opone como fuentes distintas de las obligaciones el contrato y el hecho que ha inferido injuria o daño; el **artículo 2284** distingue igualmente, entre las fuentes de las obligaciones, la convención de los hechos ilícitos; y la responsabilidad extracontractual cuenta, en los **artículos 2314** y siguientes, con un régimen legal propio y especial, estructuralmente distinto del que regula los efectos de las obligaciones contractuales.

2. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS ESTATUTOS

Conviene enumerar, a continuación, las principales diferencias que separan en el derecho chileno a la responsabilidad contractual de la extracontractual, muchas de las cuales ya se examinaron, desde la perspectiva propia de esta última, en ejes anteriores.

En materia de prueba de la culpa, el incumplimiento contractual hace presumir la culpa del deudor (**artículo 1547** inciso tercero del Código Civil), correspondiéndole a este acreditar que actuó con la diligencia debida; en la responsabilidad extracontractual, en cambio, corresponde en principio a la víctima probar la culpa del demandado, aunque este principio no es absoluto, según se examinó en el Eje 9 a propósito de las presunciones de culpabilidad. En materia de graduación de la culpa, el régimen contractual admite los tres grados del **artículo 44**, grave, leve y levísima, aplicables según a cuál de las partes beneficie el contrato, mientras que en materia extracontractual se discute, según se examinó en el Eje 8, si se responde de toda culpa, incluida la levísima, o únicamente de la culpa leve. En cuanto a la necesidad de la mora, la responsabilidad contractual la exige como presupuesto (**artículos 1551 y 1557** del Código Civil), mientras que la obligación extracontractual de indemnizar nace directamente con el hecho ilícito dañoso, sin que sea necesario constituir en mora a nadie, diferencia que, como se explicó en el Eje 20, es la que justifica que las reglas sobre reajustes e intereses no puedan trasladarse sin más de un estatuto al otro.

En materia de capacidad o imputabilidad, son incapaces de delito o cuasidelito civil únicamente los dementes, los menores de siete años, y los mayores de esa edad pero menores de dieciséis que hayan obrado sin discernimiento, según se examinó en el Eje 5; las incapacidades contractuales son sensiblemente más amplias, comenzando por la mayoría de edad a los dieciocho años y comprendiendo, además, otras causales ajenas a la edad o a la privación de razón, como la interdicción del disipador. Esta diferencia se explica porque resulta más sencillo distinguir lo lícito de lo ilícito que responder correctamente en el cumplimiento de un contrato. En materia de solidaridad, la obligación contractual de varios deudores es, por regla general, simplemente conjunta, salvo que exista una fuente expresa de solidaridad, la ley, el testamento, la convención; en la responsabilidad extracontractual, en cambio, existe solidaridad en todo caso en que un delito o cuasidelito sea cometido por dos o más personas, salvo las excepciones ya examinadas en el Eje 16, y la doctrina extiende esta solidaridad, incluso, a los casos de incumplimiento contractual ejecutado con dolo o culpa grave por dos o más deudores.

En cuanto a la extensión de la obligación de reparar, se afirma habitualmente que la indemnización extracontractual es más completa, y que la facultad de los jueces es, en esa sede, más amplia. En ambos estatutos se responde de los perjuicios previstos (el **artículo 1556** del Código Civil se aplica por analogía como regla general del daño patrimonial, y el **artículo 1558**, en su parte final, exige un nexo causal directo entre el hecho y el daño); los perjuicios imprevistos, en cambio, solo se indemnizan en materia contractual cuando media convención expresa, dolo o culpa grave (**artículo 1558** del Código Civil, en lo relativo a la previsibilidad del daño), mientras que en materia extracontractual no se responde de ellos, sin perjuicio de la posición minoritaria, examinada en el Eje 10 a propósito de la previsibilidad del daño, que sostiene que en esta sede siempre se responde de los perjuicios imprevistos, posición que la doctrina moderna considera errada. Del daño moral se responde incuestionablemente en sede extracontractual desde que un hecho ilícito lo causa; en materia contractual el punto fue tradicionalmente discutido, aunque hoy se acepta también su reparación. En materia de evaluación de perjuicios, el régimen contractual permite la evaluación

anticipada mediante una cláusula penal, exigible por el solo incumplimiento sin necesidad de probar los daños efectivamente sufridos; esto no es admisible en la responsabilidad extracontractual, que no es concebible sin la prueba del monto de los daños, porque estos constituyen tanto la justificación como la medida del deber de reparar.

En cuanto a los efectos del dolo, aunque su concepción es la misma en ambos estatutos conforme a la teoría unitaria examinada en el Eje 8, sus efectos difieren: en materia extracontractual el dolo no produce, por regla general, efectos distintos de los de la culpa, salvo la hipótesis especial del **artículo 2316** examinada en el Eje 21, mientras que en materia contractual el dolo constituye una agravante expresa de la responsabilidad del deudor. Finalmente, en materia de prescripción, la acción de indemnización por incumplimiento contractual prescribe en el plazo general de largo tiempo, contado desde que la obligación se hizo exigible, mientras que la acción extracontractual prescribe en el plazo especial de corto tiempo ya examinado en el Eje 22, contado desde la perpetración del hecho ilícito, sin perjuicio de las excepciones que rigen en uno y otro sentido.

DATO DE GRADO**¿Nueve diferencias o una sola?**

La enumeración anterior podría sugerir, a primera vista, que la dualidad de regímenes descansa en una acumulación más bien contingente de reglas técnicas dispersas, de prueba, de graduación, de prescripción, de solidaridad, que el sistema fue decantando históricamente sin un criterio unificador, lo que daría cierta razón a la crítica unitaria: si las diferencias son solo de detalle técnico, ¿por qué no adoptar un estatuto único y resolver esas cuestiones técnicas caso a caso, sin necesidad de mantener dos regímenes completos?

Examinadas con atención, sin embargo, la mayoría de estas nueve diferencias no son sino manifestaciones distintas de una misma distinción estructural, ya señalada al final de la sección 2: la presencia o ausencia de una obligación previa entre las partes. La exigencia de mora en materia contractual, y su ausencia en materia extracontractual, es la consecuencia más directa de esa distinción: solo puede constituirse en mora a quien debía cumplir una prestación determinada y no lo hizo; quien jamás debió nada a la víctima, porque no existía vínculo previo alguno entre ambos, no puede estar en mora de nada, y por eso su obligación de indemnizar nace directamente del hecho dañoso. La graduación de la culpa según a quién beneficia el contrato es, igualmente, un reflejo de la existencia de una relación previa cuyos términos las partes pudieron negociar y cuyo contenido determina cuánto cuidado es razonable exigir a cada una; en ausencia de esa relación previa, no hay parámetro contractual alguno al cual referir la graduación, y por eso la responsabilidad extracontractual debe apoyarse en un estándar general y abstracto, el hombre prudente, antes que en la distribución de riesgos propia de un contrato específico. La procedencia de la cláusula penal responde a la misma lógica: solo puede evaluarse anticipadamente un perjuicio cuya fuente, el incumplimiento de una obligación ya determinada, las partes conocen de antemano; nadie puede pactar de antemano la evaluación de un daño causado por un hecho ilícito futuro e indeterminado, porque ese pacto anticipado, tratándose de daño extracontractual, se asimilaría a la condonación del dolo o la culpa grave futuros, ya examinada en el Eje 22 como inadmisibles. Y la diferencia en los plazos de prescripción, aunque menos evidente, también se explica por esta misma distinción: la obligación contractual existe desde antes de su incumplimiento, y por eso su plazo corre desde que se hizo exigible; la obligación extracontractual no existe hasta que el hecho ilícito la genera, y por eso su plazo solo puede correr desde ese mismo hecho, con la dificultad, ya examinada en el Eje 22, de precisar si ese momento incluye o no la producción del daño.

Quedan, ciertamente, algunas diferencias, la extensión de las incapacidades, el tratamiento de los perjuicios imprevistos, los efectos agravados del dolo contractual, que no se derivan con la misma nitidez de esa distinción única, y que sí podrían calificarse de decisiones legislativas más autónomas, menos necesariamente conectadas con la presencia o ausencia de un vínculo previo. Pero el hecho de que la mayoría de las diferencias examinadas, prueba de la culpa, graduación de la culpa, mora, evaluación anticipada, prescripción, puedan reconducirse a esa única distinción estructural es, precisamente, el mejor argumento en contra de la tesis unitaria: no se trata de nueve reglas dispersas, sino de las consecuencias sistemáticas de una única diferencia de fondo entre responder por incumplir lo que se prometió y responder por dañar a quien nada se debía. Esa diferencia de fondo, y no la mera acumulación histórica

de soluciones técnicas, es la que justifica, en definitiva, que el derecho chileno mantenga dos estatutos distintos y no uno solo.

3. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir con la distinción romana de las fuentes de las obligaciones del **artículo 1437** y el objetivo común de ambos estatutos, dar lugar a una acción indemnizatoria, exponiendo después la teoría unitaria y sus dos críticas, la indemnización moratoria coexiste con la obligación en vez de sustituirla, y esa sustitución solo opera cuando el cumplimiento forzado deja de ser posible, y la posición dualista predominante en Chile, con su fundamento textual en los **artículos 1437, 2284 y 2314** y siguientes.

En segundo lugar, enumerar las nueve diferencias entre ambos estatutos: prueba de la culpa, graduación de la culpa, necesidad de la mora, capacidad, solidaridad, extensión de la reparación, con la previsibilidad de los perjuicios y el daño moral, evaluación anticipada mediante cláusula penal, efectos agravados del dolo, y plazos de prescripción.

Cerrar con la tensión de fondo: aunque la enumeración de diferencias podría sugerir una acumulación contingente de reglas técnicas, la mayoría de ellas, mora, graduación de la culpa, cláusula penal, prescripción, se reconducen a una única distinción estructural, la presencia o ausencia de una obligación previa entre las partes, lo que constituye el argumento más sólido a favor de mantener dos estatutos diferenciados y no uno solo, frente a la tesis de la unidad de la responsabilidad civil.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 23. Dualidad o unidad de regímenes; diferencias entre estatutos**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

X. CÚMULO O CONCURSO DE RESPONSABILIDADES

Establecida en el Eje 23 la dualidad de regímenes que separa a la responsabilidad contractual de la extracontractual, surge un problema práctico de primera importancia cuando un mismo hecho reúne, simultáneamente, los caracteres de un incumplimiento contractual y de un delito o cuasidelito civil: ¿qué régimen se aplica en ese caso, y puede la víctima elegir entre uno y otro? Bajo el nombre tradicional de cúmulo de responsabilidad, la doctrina agrupa, en realidad, dos cuestiones de naturaleza distinta, que conviene separar desde el inicio para no confundirlas.

1. DOS PREGUNTAS DISTINTAS BAJO UN MISMO NOMBRE

La primera cuestión consiste en determinar si las acciones que emanan de ambos estatutos son acumulables, esto es, si la víctima podría exigir una doble indemnización, una conforme a las reglas contractuales y otra conforme a las extracontractuales, por el mismo daño. Esta primera pregunta, pese a ser la que da nombre a la institución, plantea en realidad pocas dificultades: la responsabilidad contractual no puede acumularse a la extracontractual, porque ello se traduciría en un enriquecimiento sin causa de la víctima, que resultaría indemnizada dos veces por un mismo perjuicio.

La segunda cuestión, que es la verdaderamente controvertida y a la que en la práctica se refiere la discusión sobre el cúmulo, consiste en determinar si la víctima puede optar por el estatuto de responsabilidad que le resulte más provechoso, cuando ambos resultan en principio aplicables de manera alternativa a un mismo hecho. Así planteado, el problema se concibe como una opción de la víctima: si el incumplimiento de un contrato reviste a la vez el carácter de un hecho ilícito, por concurrir en él los requisitos propios de este, ¿puede la víctima cobrar los perjuicios conforme a las reglas de uno u otro estatuto, según le sea más conveniente? El ejemplo constante en la doctrina es el del pasajero transportado por una empresa, que podría cobrar conforme a la responsabilidad contractual, beneficiándose de la presunción de culpa del transportista por su obligación de seguridad, o conforme a los **artículos 2314** y siguientes, para cobrar, por ejemplo, el daño moral sin la discusión que históricamente ha acompañado a su procedencia en sede contractual.

2. LA POSICIÓN DOMINANTE: RECHAZO DE LA OPCIÓN

La doctrina y la jurisprudencia nacionales se han manifestado tradicionalmente en contra de reconocer a la víctima esta opción entre estatutos. El argumento central es que permitirle desconocería la fuerza obligatoria del contrato, que conforme al **artículo 1545** del Código Civil vincula a las partes con la misma intensidad que la ley: si el contrato regula específicamente los términos en que una parte responde ante la otra, permitir que esta prescinda de esas reglas y se acoja en cambio al estatuto extracontractual equivaldría a dejar sin efecto práctico la reglamentación que las propias partes, o la ley aplicable al contrato, acordaron para su relación. A ello se agrega que la doctrina mayoritaria atribuye a la responsabilidad contractual un carácter de especialidad frente a la extracontractual, a la que asigna en cambio un carácter residual: donde existe un vínculo contractual específico, sus reglas propias deben primar sobre los deberes generales de no dañar a los demás, precisamente porque las partes sustituyeron voluntariamente esos deberes generales por una relación obligatoria específica y consentida.

3. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL

Frente a esta posición dominante, la doctrina y cierta jurisprudencia reconocen, sin embargo, casos excepcionales en que la opción resulta procedente. **ALESSANDRI** identifica dos hipótesis de esta naturaleza. La primera se presenta cuando las propias partes han convenido la opción: nada hay de excepcional en ello, porque si las partes pueden modificar a su arbitrio las normas legales meramente supletorias que rigen su contrato, con mayor razón pueden convenir la aplicación de una u otra solución extracontractual en particular, o conceder derechamente al acreedor la posibilidad de optar entre ambos estatutos. La segunda se presenta cuando la infracción contractual constituye, a la vez, un delito o cuasidelito penal típico: de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también una acción civil para obtener la indemnización que la ley concede al perjudicado, aunque esta segunda conclusión ha sido calificada de dudosa, en cuanto la norma que la sustentaría no establece que de todo delito nazca siempre acción civil, sino que se remite, en definitiva, a lo que dispongan las normas de derecho civil aplicables al caso.

CORRAL propone, por su parte, un criterio más amplio: el concurso de responsabilidades procedería cada vez que, prescindiendo por completo del contrato, el daño causado sería igualmente indemnizable por generar responsabilidad extracontractual, sea porque el hecho es penalmente sancionable, sea porque el ilícito se encuentra sancionado por normas civiles o contravencionales, o por la sola violación del deber general de no dañar a otro. Con todo, este mismo autor reconoce un límite a esta amplitud: el cúmulo no será admisible, y deberá aplicarse íntegramente el régimen contractual, cuando las partes lo hayan pactado expresamente en el contrato, o cuando, a falta de pacto expreso, el sometimiento a la distribución de riesgos prevista en el contrato emane de la naturaleza misma de esa relación contractual, o resulte impuesto por el principio de la buena fe.

4. EJERCICIO CONJUNTO DE ACCIONES

En los casos en que se admite el cúmulo, cabe preguntarse si la víctima puede ejercer simultáneamente, en un mismo proceso, tanto la acción de responsabilidad contractual como la de responsabilidad extracontractual. En la medida en que se acepte, para ciertos casos, la opción entre ambos estatutos, el demandante puede deducir ambas acciones, pero siempre una en subsidio de la otra, porque ambas deben entenderse incompatibles entre sí, conforme a las reglas procesales generales sobre acciones incompatibles.

Distinto es el caso en que un mismo hecho genera responsabilidad contractual respecto de las partes de un contrato, y responsabilidad extracontractual respecto de un tercero ajeno a él. En esta hipótesis no existe inconveniente alguno para admitir la acumulación procesal de ambas acciones en un mismo juicio, porque unas y otras emanan directa e inmediatamente de un mismo hecho, cumpliéndose así el requisito general que la ley procesal exige para la acumulación de acciones.

DATO DE GRADO**Especialidad del contrato frente a generalidad del deber de no dañar**

La disputa sobre la procedencia del cúmulo expresa, en el fondo, una tensión entre dos principios que el propio derecho civil reconoce como igualmente legítimos, y que este eje permite ver enfrentados en un mismo problema concreto: la fuerza obligatoria del contrato, que vincula a las partes con la intensidad de la ley y que estas emplearon precisamente para sustituir, dentro de su relación recíproca, los deberes generales de cuidado por una distribución específica de riesgos y obligaciones; y el deber general de no dañar a los demás, que subsiste como trasfondo de cualquier relación humana, incluida la contractual, y que no desaparece por el solo hecho de que las partes hayan, además, celebrado un contrato entre sí.

La posición que rechaza la opción privilegia decididamente el primero de estos principios: si las partes pactaron una distribución específica de riesgos, incluyendo, eventualmente, límites a la responsabilidad, plazos de prescripción distintos, o estándares de diligencia particulares, permitir que una de ellas eluda esa distribución acogiéndose al estatuto extracontractual, más favorable en el caso concreto, vaciaría de contenido práctico lo pactado, porque cualquier incumplimiento contractual que a la vez dañe un interés protegido por el estatuto general terminaría rigiéndose, en los hechos, por las reglas que las partes precisamente quisieron sustituir. La posición que admite el concurso en ciertos casos, cuando el hecho sería independientemente ilícito con prescindencia del contrato, o cuando así lo pactaron las partes, reconoce, en cambio, que no todo lo que ocurre entre partes contratantes queda necesariamente absorbido por el contrato: si el hecho dañoso reviste una gravedad o una naturaleza tal que sería sancionado igualmente entre personas sin vínculo contractual alguno, el delito penal, la lesión grave a la integridad física con ocasión del transporte, no parece razonable que la sola circunstancia de que las partes tuvieran, además, una relación contractual, prive a la víctima de la protección que el ordenamiento dispensaría a cualquier otra persona en su misma situación.

El criterio de **CORRAL**, que subordina la procedencia del cúmulo a la ausencia de un sometimiento, expreso o derivado de la naturaleza del contrato o de la buena fe, a la distribución contractual de riesgos, ofrece en este sentido una vía de conciliación más que una tercera posición autónoma: reconoce la primacía del contrato allí donde este efectivamente distribuyó el riesgo del daño de que se trata, pero no extiende esa primacía a daños que exceden por completo lo que las partes pudieron razonablemente entender comprendido en esa distribución. La pregunta que este criterio obliga a formular, caso a caso, no es entonces si existe o no un contrato entre las partes, sino si el contrato que existe entre ellas efectivamente regula, expresa o tácitamente, el riesgo del daño concreto que se reclama, o si ese daño queda, por su naturaleza, fuera del ámbito que las partes pudieron considerar al contratar.

5. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir distinguiendo las dos cuestiones que se agrupan bajo el nombre de cúmulo de responsabilidad: la acumulación de ambas acciones, rechazada sin mayor controversia por importar

un enriquecimiento sin causa, y la opción entre ambos estatutos, que es la verdaderamente discutida.

En segundo lugar, exponer la posición dominante que rechaza la opción, fundada en la fuerza obligatoria del contrato del **artículo 1545** y en el carácter especial de la responsabilidad contractual frente al carácter residual de la extracontractual, y las excepciones que **ALESSANDRI** reconoce, pacto expreso de las partes, e infracción contractual que constituye a la vez delito penal típico, junto con el criterio más amplio de **CORRAL**, que subordina la procedencia del cúmulo a que el hecho no quede sometido, expresa o tácitamente, a la distribución contractual de riesgos.

En tercer lugar, tratar el ejercicio conjunto de acciones: subsidiariedad obligatoria cuando ambas acciones corresponden al mismo demandante por el mismo hecho, y plena acumulación procesal cuando un mismo hecho genera responsabilidad contractual para las partes y extracontractual para un tercero.

Cerrar con la tensión de fondo: la disputa sobre el cúmulo expresa el conflicto entre la fuerza obligatoria del contrato, que sustituye los deberes generales por una distribución específica de riesgos, y la persistencia del deber general de no dañar a los demás aun dentro de una relación contractual, resuelto por la doctrina más matizada no preguntando si existe un contrato, sino si ese contrato efectivamente regula el riesgo concreto del daño que se reclama.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 24. Cúmulo o concurso de responsabilidades**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.

Y. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL, POR NUL- DAD Y POSTCONTRACTUAL

La dualidad de regímenes examinada en el Eje 23 presupone un contrato válido y vigente, cuyo incumplimiento genera responsabilidad contractual, frente a un hecho dañoso entre extraños, que genera responsabilidad extracontractual. Existen, sin embargo, tres situaciones que no encajan cómodamente en ninguno de los dos extremos de esa distinción, porque en ellas las partes no son exactamente extrañas entre sí, pero tampoco están ligadas por un contrato válido y vigente en el momento en que el daño se produce: el daño causado durante las tratativas previas a la celebración de un contrato que todavía no existe; el daño conectado con un contrato que, celebrado, es luego declarado nulo, de manera que se le priva retroactivamente de existencia jurídica; y el daño causado después de que un contrato válidamente celebrado ha expirado. Este eje examina cada una de estas tres situaciones, que la doctrina agrupa bajo los nombres de responsabilidad precontractual, responsabilidad por la nulidad del contrato y responsabilidad postcontractual.

1. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

1.1. La etapa de negociación preliminar

La regulación legal de la formación del consentimiento no recoge adecuadamente una realidad práctica constante: antes de que exista una oferta propiamente tal, suele existir un período de negociación o tratativas preliminares, en el que las partes desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus respectivos puntos de vista sobre un negocio que se proyecta, sin entender por ello quedar obligadas. La pregunta que ha ocupado a la doctrina es si, durante esta etapa previa a la formación del contrato, puede surgir responsabilidad para alguno de los partícipes de la negociación.

Durante esta etapa impera, en principio, la libertad de contratar: las partes son libres para negociar, debatir posturas distintas y explorar si conviene o no contratar, intercambiando información sin comprometerse todavía a nada. La doctrina tradicional sostiene que, en consecuencia, no existe responsabilidad por el desistimiento unilateral de la negociación, porque este constituye el ejercicio legítimo del derecho a desistirse de un contrato eventual, aunque de ese desistimiento se sigan daños para la otra parte. La doctrina moderna, en cambio, admite que sí puede haber responsabilidad en ciertos casos.

1.2. Las construcciones doctrinales sobre su fundamento

FAGUELLA sostiene que existe responsabilidad cuando una de las partes se retira arbitrariamente de las negociaciones, y que ese retiro es arbitrario cuando viola la confianza generada al negociar o el llamado pacto de garantía implícito en toda negociación, que tiende a asegurar que esta seguirá su curso normal hasta la celebración del contrato o hasta el fracaso de las tratativas por existir intereses económicos irreconciliables. Esta construcción ha sido criticada por su rigidez: llevada a sus últimas consecuencias, nadie estaría dispuesto a negociar bajo esas condiciones. Saleilles pro-

pone, en cambio, un criterio distinto: no puede haber responsabilidad sin culpa, y existe culpa cuando se infringen los usos comerciales impuestos por la práctica y la equidad comercial.

En el sistema chileno, Rosende sintetiza los requisitos para que nazca responsabilidad precontractual en tres elementos. El primero es que exista consentimiento en entrar en las tratativas preliminares, esto es, un acuerdo en negociar: rige siempre el principio de libertad para decidir si se contrata o no, pero esa libertad debe ejercerse dentro del marco que impone la buena fe, cuidando de respetar el patrimonio ajeno; si se viola la buena fe negociando y con ello se causa un daño culpable, procede la indemnización, sea porque se ha cometido un delito civil, si el hecho es ilícito, sea porque, aun siendo lícito el hecho, puede configurarse un caso de enriquecimiento sin causa. El segundo requisito es que se hayan efectuado gastos por alguna de las partes en vías del contrato proyectado: si las partes estipularon la forma en que se solventarían esos gastos, la responsabilidad que de ellos se siga será contractual, por regir el acuerdo entre las partes; si nada estipularon, hay que distinguir según el momento en que los gastos se realizaron y quién se benefició de ellos: los gastos anteriores a la negociación misma, como los de publicidad, son de cargo de quien los hizo, por ceder en su propio beneficio, salvo que otro se haya aprovechado también de ellos, caso en que puede haber enriquecimiento sin causa; los gastos incurridos durante las tratativas por iniciativa propia y en beneficio propio no dan derecho a reembolso, mientras que los realizados por iniciativa propia pero en beneficio de ambas partes sí lo dan, en la medida en que exista enriquecimiento sin causa. El tercer requisito es que exista un retiro unilateral de las negociaciones contrario a la buena fe: el solo hecho del retiro no genera responsabilidad, porque de lo contrario nadie negociaría, y es necesario encontrar un equilibrio entre la libertad para negociar y el respeto al patrimonio ajeno, equilibrio que precisamente aporta el estándar de la buena fe.

1.3. La naturaleza de esta responsabilidad

Se ha discutido extensamente si la responsabilidad que puede surgir de la ruptura de las negociaciones preliminares es de naturaleza contractual o extracontractual. La opinión más generalizada se inclina por la segunda, porque la responsabilidad contractual supone, precisamente, un contrato, y este todavía no se ha formado durante la etapa de negociación. Ihering, sin embargo, sostuvo tempranamente que en esta hipótesis existe una culpa in contrahendo de naturaleza contractual, asimilable a la del acto jurídico que se proyectaba celebrar. **ALESSANDRI** distingue, por su parte, entre las responsabilidades expresamente previstas por la ley en materia comercial, que, por tener fuente legal, califica como contractuales, constituyendo para él la regla general en esta materia, y toda otra responsabilidad precontractual derivada de la sola ruptura de las negociaciones, que califica de extracontractual, porque tales negociaciones no crean entre las partes vínculo jurídico alguno. Con todo, buena parte de la doctrina sostiene, con razón, que las normas comunes en materia de responsabilidad por hechos ilícitos son las de la responsabilidad extracontractual, y que la responsabilidad precontractual, incluida la relativa a obligaciones legales conectadas con la oferta, se rige, en consecuencia, por ese marco normativo general.

Distinto es el caso del contrato de promesa: al ser este mismo un contrato, según sus propios requisitos legales, la responsabilidad que se sigue de su incumplimiento es netamente contractual, y no se rige por las reglas de la responsabilidad precontractual recién examinadas, que presuponen precisamente la ausencia de todo vínculo contractual entre las partes.

2. RESPONSABILIDAD DE QUIEN CAUSA LA NULIDAD DEL CONTRATO

La doctrina ha discutido arduamente la naturaleza de la responsabilidad que puede seguirse para quien causa la nulidad de un contrato, esto es, si es contractual, extracontractual, legal, o incluso de una naturaleza propia y distinta de todas las anteriores. La dificultad de fondo radica en que, en esta materia, existe entre las partes una relación, un contacto social calificado, que impone ciertos deberes de lealtad distintos tanto de los que nacen de un contrato ya celebrado y válido, que dan lugar a responsabilidad contractual, como de los que impone el mero contacto social general, limitado al deber de no dañar a la persona o propiedad ajena, que dan lugar a responsabilidad extracontractual.

Buena parte de la doctrina descarta, en todo caso, la aplicación de las reglas de la responsabilidad contractual, porque esta emana, por definición, de la infracción de un contrato, y la imputación que aquí se formula al responsable recae sobre hechos anteriores al contrato, aunque conectados con las circunstancias de su celebración; y precisamente la nulidad judicialmente declarada pulveriza, con efecto retroactivo, la existencia misma de ese contrato. **RODRÍGUEZ GREZ** sostiene, en cambio, que se trata de una responsabilidad legal: la obligación de indemnizar los perjuicios que se siguen de la declaración de nulidad nace de la ley, aunque supone culpa o dolo de quien causa el daño, sin que las reglas de la responsabilidad extracontractual resulten aplicables íntegramente a esta hipótesis, en la medida en que solo en algunos casos es posible concebir el derecho indemnizatorio que emana de la nulidad judicialmente declarada. Finalmente, varios autores nacionales, entre ellos **BARAONA**, sostienen que esta responsabilidad es de naturaleza extracontractual, aunque los elementos que configuran la culpa deban analizarse en cada caso considerando criterios de buena o mala fe y de expectativas de confianza que se configuran de manera peculiar, distinta de la noción general y abstracta de culpa examinada en el Eje 8; salvo por esta peculiaridad en la determinación de la culpa, la calificación de esta responsabilidad debe ser, en lo demás, extracontractual.

3. RESPONSABILIDAD POSTCONTRACTUAL

La doctrina se ha planteado, finalmente, cuál de los dos estatutos debe regir la reparación de los daños que una de las partes causa a la otra con motivo de la celebración de un contrato, pero por hechos posteriores a su expiración: así ocurre, por ejemplo, si el trabajador, una vez terminado su contrato de trabajo, transfiere a empresas de la competencia información reservada de su antiguo empleador.

Una posición sostiene que en estos casos existe una proyección de la responsabilidad contractual, fundada en la existencia de acuerdos tácitos, de secreto, de no concurrencia, que pueden sobrevivir a la extinción del contrato mismo que les dio origen. Otra posición considera que esta construcción elude la realidad de que el contrato ya ha expirado y no puede, en consecuencia, seguir rigiendo una responsabilidad que se genera con posterioridad a su término, postulando en cambio la aplicación del régimen extracontractual. **CORRAL** se inclina por esta segunda postura, aunque con una salvedad importante: si la ley sanciona el ejercicio abusivo de la facultad de poner término a un contrato disponiendo, como consecuencia de esa sanción, la conservación del contrato mismo, la responsabilidad que de ello se siga será, en cambio, contractual, precisamente porque en tal caso el

contrato no ha llegado a extinguirse en los términos que la parte que lo dio por terminado pretendía.

DATO DE GRADO

Las zonas grises entre el contrato y la ausencia de contrato

Las tres situaciones examinadas en este eje comparten una misma estructura, que conviene explicitar como cierre de todo este material: en cada una de ellas existe entre las partes una proximidad relacional calificada, negociaciones avanzadas, un contrato que existió aunque haya sido invalidado, un vínculo que existió aunque haya terminado, que las distingue de los extraños que se cruzan ocasionalmente en la vida social, pero que no alcanza a constituir, en el momento relevante para juzgar el daño, un contrato válido y vigente capaz de generar responsabilidad contractual en sentido estricto. Frente a esta proximidad calificada pero no contractual, la doctrina chilena tiende a preferir, en los tres casos examinados, la calificación extracontractual como solución residual: extracontractual es, según la posición mayoritaria, la responsabilidad precontractual; extracontractual, según **BARAONA** y otros, la responsabilidad por la nulidad del contrato; extracontractual, según **CORRAL**, la responsabilidad postcontractual, salvo el caso especial de la conservación forzada del contrato.

Esta preferencia uniforme por la calificación extracontractual, sin embargo, no resuelve por sí sola el problema de fondo, porque el régimen extracontractual está construido, en su formulación general, sobre el supuesto de que las partes son enteramente extrañas entre sí antes del hecho dañoso, el supuesto mismo que estas tres situaciones ponen en entredicho. De ahí que, en los tres casos, la doctrina se vea obligada a introducir correctivos al estándar general y abstracto de culpa que rige entre extraños: en la responsabilidad precontractual, el criterio no es la sola causación de un daño, sino la violación de la buena fe en el curso de una negociación que las propias partes decidieron entablar; en la responsabilidad por nulidad, **BARAONA** exige valorar la culpa considerando la buena o mala fe y las expectativas de confianza generadas por la relación previa, y no según el estándar abstracto ordinario; y en la responsabilidad postcontractual, el fundamento de la reserva sigue siendo, aun calificado de extracontractual, un deber de lealtad que solo tiene sentido por haber existido antes un vínculo contractual entre las partes, ya extinguido. En los tres casos, entonces, la etiqueta extracontractual convive con una modulación del estándar de conducta exigible que reconoce, implícitamente, que estas partes no son del todo extrañas entre sí, aunque no lleguen a estar ligadas por un contrato vigente: la proximidad relacional previa, aunque insuficiente para generar responsabilidad contractual propiamente dicha, no desaparece sin dejar rastro en la manera en que se juzga la conducta de quien causó el daño.

4. SÍNTESIS PARA ESTRUCTURAR LA RESPUESTA DE EXAMEN

Conviene abrir explicando por qué estas tres situaciones no encajan en la dualidad ordinaria de estatutos: existe entre las partes una proximidad relacional que no llega a ser un contrato válido y vigente en el momento relevante.

En segundo lugar, exponer la responsabilidad precontractual: la etapa de negociación preliminar, la evolución de la doctrina tradicional a la moderna, las construcciones de **FAGUELLA** y Saleilles, los tres requisitos de Rosende para el derecho chileno, y la discusión sobre su naturaleza, contractual para Ihering y, en los casos legales, para **ALESSANDRI**; extracontractual como regla general para la doctrina mayoritaria, cerrando con la precisión de que el contrato de promesa, por ser ya un contrato, genera responsabilidad contractual y no precontractual.

En tercer lugar, tratar la responsabilidad de quien causa la nulidad del contrato (descartada su naturaleza contractual por la retroactividad de la nulidad, con las posiciones de **RODRÍGUEZ GREZ**, responsabilidad legal, y de **BARAONA**, extracontractual, con una valoración especial de la culpa) y la responsabilidad postcontractual, con la posición de **CORRAL** y su excepción para la conservación forzada del contrato.

Cerrar con la tensión de fondo: las tres situaciones comparten la misma estructura de una proximidad relacional calificada pero no contractual, resuelta uniformemente mediante la calificación extracontractual, pero acompañada en los tres casos de una modulación del estándar ordinario de culpa, buena fe en la negociación, valoración especial de la confianza en la nulidad, deberes de lealtad postcontractuales, que reconoce, aun bajo el nombre de responsabilidad extracontractual, que estas partes no son del todo extrañas entre sí.

PAUSA: COMPRENSIÓN LECTORA

Has terminado el **Eje 25. Responsabilidad precontractual, por nulidad y postcontractual**. Antes de avanzar, entra a la plataforma **Digesto** y responde las preguntas de **comprensión lectora** de esta sección: te servirán de *check-in* de lo leído hasta aquí. Si alguna se te resiste, vuelve sobre el apartado antes de seguir.